

체불 해결을 위한 책임 강화 방안 및 임금채권보장기금의 사업주 부담금 경감기준 등에 관한 연구

연구기관 한국노동연구원

2023. 12.



고용노동부

연 구 진

연구책임자 : 양승엽(한국노동연구원 부연구위원)

참여연구자 : 장우찬(국립경상대학교 법학과 교수)

김 린(인하대학교 법학전문대학원 교수)

이준범(인하대학교 법학전문대학원 교수)

박수경(강원대학교 비교법학연구소 연구교수)

조재호(법무법인 민 변호사)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁연구과제 『체불 해결을 위한 책임 강화 방안 및 임금 채권보장기금의 사업주 부담금 경감기준 등에 관한 연구』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 12.

한국노동연구원

원장 허재준

목 차

제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 내용	4
제2장 임금체불 시 사업주 책임에 관한 해외 법제 비교	7
제1절 미국의 임금체불 구제 수단과 억제제도	7
1. 개 관	7
2. 임금체불에 대한 연방과 각 주의 제재 수단	8
3. 각 수단의 적용	28
4. 소결 및 시사점	41
제2절 캐나다의 임금체불 제도와 그 대응	48
1. 개 관	48
2. 임금체불의 형사적 책임	53
3. 캐나다 연방노동법 제3장의 규율	54
4. 소 결	70
제3절 일본의 임금체불 구제 절차와 사업주의 책임	72
1. 개 관	72
2. 임금채권 이행 확보 방안	73
3. 소송 등의 구제제도	84
4. 임금체불 및 관련 처리 관련 통계	88
5. 소결 및 시사점	91
제3장 임금채권보장법상 사업주 부담금 경감기준 개선 방안	94
제1절 사업주 부담금 경감의 필요성 검토	94
1. 임금채권보장기금의 의의	94
2. 임금채권보장제도 변천에 따른 부담금 분담 방식의 점검 필요	94
3. 법정 경감 대상 개선 필요성	95

4. 부담금 부과의 차등화 여부	98
5. 부담금 경감 조정시 고려할 사항	100
제2절 사업주 부담금 경감 기준 개선 방안	102
1. 부담금 및 경감에 관한 규정 형식	102
2. 부담금 부과 및 경감의 고려 요소	104
3. 부담금 경감 비율의 적정성	110
4. 부담금 경감의 개선 방식	113
5. 소 결	119
제4장 기타 임금채권보장을 위한 제도 방안	120
제1절 도산대지급금의 연령별 차등 지급 적정성	120
제2절 사업주응자제도 확대 필요성	123
1. 한도의 확대	123
2. 사전 응자제도의 도입	124
제3절 간이대지급금 제도 보완 필요성	125
1. 제도의 현황	125
2. 제도적 보완의 내용	126
제5장 결 론	128
제1절 사업주 책임을 강화하기 위한 비교법 연구의 시사점	128
1. 임금채불 시 형사처벌 제도의 의의	128
2. 새로운 경제 제재(과징금·법정배상배액제도)의 도입 여부	129
제2절 현행 사업주 부담금 경감제도의 실효성	131
1. 현행 사업주 부담금 제도의 검토와 보완점	131
2. 현행 사업주 부담금 경감 산식의 개선 여부	132
제3절 기타 현행 임금채권보장제도의 쟁점과 보완	133
1. 도산대지급금의 연령별 차등 지급 여부	133
2. 사업주응자제도의 개선 방안	133
3. 간이대지급금 제도 확대에 대한 보완 방안	134
참고문헌	135

표 목 차

〈표 1- 1〉 연도별 임금체불액 및 인원 현황	1
〈표 1- 2〉 대지급금 지급액 및 항목별 비율	3
〈표 2- 1〉 징벌적 손해배상과 법정배액배상의 비교	10
〈표 2- 2〉 2021년도 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 내용	35
〈표 2- 3〉 2020년도 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 내용	36
〈표 2- 4〉 입법자의 소송을 통한 기대이익 조정 예시	42
〈표 2- 5〉 캐나다 연방노동법의 장별 개요 및 적용 대상	50
〈표 2- 6〉 연방 근로자의 구분과 총인원	55
〈표 2- 7〉 산업별 연방 근로자 구성 비율	56
〈표 2- 8〉 근로기준 위반에 대한 노동 프로그램 신고 4가지 형태	56
〈표 2- 9〉 사용자가 연방관할권의 적용을 받는 경우	57
〈표 2-10〉 미지급 임금 등에 포함되는 사항	58
〈표 2-11〉 임금체불 개선을 위한 2019년 개정 사항	59
〈표 2-12〉 해결 절차에 따른 신고 제기 기간	60
〈표 2-13〉 각 지역 노동 프로그램 사무소	62
〈표 2-14〉 위반 횟수에 따른 벌금 산정 공식	65
〈표 2-15〉 위반 여부에 따른 서면 통보 내용	65
〈표 2-16〉 연방법원에 제출된 지급 명령을 받은 사용자들에 대한 게시 예	66
〈표 2-17〉 미지급 임금에 대한 이사의 책임(연방 및 각 주별 구분)	68
〈표 2-18〉 연방 노동기준 위반의 경우 형사처벌	70
〈표 2-19〉 퇴직일의 연령에 따른 체불임금 총액 한도액 및 대지급금의 상한액	78
〈표 2-20〉 체불임금 대지급금 사업 실시 상황	89
〈표 2-21〉 2022년 전국 노동기준감독서에서 취급한 임금체불 사안의 건수, 대상근로자 및 금액	89
〈표 2-22〉 2022년 전국 노동기준감독서에서 취급한 임금체불 사안 중, 노동기준감독서의 지도로 해결된 상황	90
〈표 2-23〉 노동심판사건 수 - 사건의 종류 및 신규수리, 기처리, 미처리(전국 지방법원) ...	90

〈표 2-24〉 노동심판사건 기처리 수 - 사건의 종류 및 종국 구분 별(전국 지방법원)	91
〈표 3- 1〉 도산대지급금의 연령별 상한액	96
〈표 3- 2〉 간이대지급금의 항목별 상한액	97
〈표 3- 3〉 항목별 대지급금 지급 현황	98
〈표 3- 4〉 사업장 규모별 대지급금 지급 현황	99
〈표 3- 5〉 사회보험료의 정의와 부담금과의 차이	102
〈표 3- 6〉 연도별 사업주 부담금 부담 비율	103
〈표 3- 7〉 종사자 규모별 퇴직연금 도입 현황	111
〈표 3- 8〉 재직자 및 퇴직자에 대한 대지급금 지급 비율	112
〈표 4- 1〉 체불임금 등 대지급금 상한액 고시	120
〈표 4- 2〉 2022년 전체 근로자 연령별 월 임금총액	122

그림목차

[그림 2-1] 연도별 연방법원 임금 관련 집단소송 사건 접수 건	33
[그림 2-2] 연도별 중재신청 건	33
[그림 2-3] 연도별 단체소송 허가/불허 비율 및 단체허가 신청 허가/불허 비율	34
[그림 2-4] 연도별 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 총액	34
[그림 2-5] 연도별 미국 연방노동부 회수 임금 총액 및 근로자당 임금액	38
[그림 2-6] 캐나다 연방의 구성	49
[그림 2-7] 노동 프로그램 신고 제기 양식-금전적 신고 부분 발췌	61
[그림 2-8] 체불임금의 대지급금 추이	88

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

임금체불은 근로자와 그 가족의 생존에 직결되는 문제이다. 그렇기에 국가는 임금체불에서 근로자를 보호하기 위한 민·형사 및 행정적인 대책을 마련한다. 민사적으로 일반채권보다 임금채권의 (최)우선변제를 보장하고(근로기준법 제38조 제1·2항), 형사적으로는 임금체불 사업주에 대하여 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다(동법 제109조 제1항).¹⁾ 그리고 행정적으로는 첫째, 체불임금에 대한 구제 절차를 마련하고(동법 제104조), 둘째, 상습적인 임금체불 사업주인 경우 그 명단을 공개하며(동법 제43조의2), 셋째, 역시 상습적인 임금체불 사업주의 체불 자료를 신용정보기관에 제공하여 신용도에 영향을 미치는 것이다(동법 제43조의3). 그리고 마지막으로 넷째, 체불임금의 일정 부분을 국가가 미리 사업주로부터 각출한 임금채권보장기금에서 대지급금으로 지불하는 것이다(임금채권보장법 제7조 및 제7조의2).

이러한 수단과 정부의 적극적인 근로감독의 영향으로 2018년 이후 임금체불 현황은 나아지고 있다.

〈표 1-1〉 연도별 임금체불액 및 인원 현황

	2018	2019	2020	2021	2022
체불액(천억)	16.5	17.2	15.8	13.5	13.5
체불인원(만명)	35	34.5	29.5	25	24

출처: 고용노동부 제공 자료(2023. 5.)

그러나 해외의 임금체불 현황과 비교했을 때 여전히 높은 수치를 보이고 있고, 상습적이고 고의적인 임금체불이 많다는 지적이 있어 개선의 여지가 있다. 일본의 임금체불 현황과 비교하여 보면, 2022년 전국 노동기준감독서에서 취급한 임금체불의 건수는 20,531건이고, 대상 근로자 수는 179,643명, 그리고 체불금액은 121억 2,316만 엔이었다.²⁾ 우리보다 전반적으

1) 다만, 이는 반의사불벌죄이다(근로기준법 제109조 제2항).

2) 厚生労働省, “賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します(別紙)” <https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001126169.pdf>

로 낮으며 특히 체불금액이 10분의 1 수준도 안 되는 것을 알 수 있다. 또한 우리의 경우 2회 이상 체불을 반복한 사업주는 전체의 30%이지만, 그 사업주들의 체불액이 전체의 80%를 차지하고 있는 실정이다.

임금체불이 발생할 경우 근로자들의 생계를 임시방편으로나마 보장해주는 것이 임금채권보장법의 대지급금 제도이다. 그런데 대지급금의 개선이 이루어진바, 2021. 10. 임금채권보장법 개정으로 간이대지급금의 지급을 간소화하고, 그 대상을 재직 중인 근로자에게도 확대하였다. 이러한 간이대지급금의 적용 확대는 대지급금 지급액을 증가시킬 것으로 예상된다. 그렇다면 한도가 있는 임금채권보장기금의 재정 상태가 악화될 우려가 있다.

따라서 임금체불을 현행보다 낮추는 방법이 절실히 모색되어야 하며 그 방법에는 새로운 경제적인 제재 등 여러 가지를 연구할 필요가 있다. 즉, 사업주의 임금체불에 관한 사전·사후 책임의 강화 방안이 본 연구의 목적 중 첫 번째이다. 이를 위해 비교법 연구를 시행한다.

또 다른 내용으로 임금채권보장법 제10조는 다음과 같은 사업주에게 임금채권보장기금 조성을 위한 부담금을 경감할 수 있다고 규정한다.

- ① 근로기준법 또는 근로자퇴직급여 보장법에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주
- ② 근로자퇴직급여 보장법에 따라 퇴직보험 등에 가입하거나 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도, 개인형퇴직연금제도를 설정한 사업주

모두 넓은 의미의 퇴직금 제도를 설정한 사업주에게 부담금을 경감해 주는 것인데 그 이유는 ①과 ②의 경우는 퇴직금 체불이 일어날 수 없기 때문이다. 부담금을 감경하여 주는 공식은 다음과 같다.

- ①의 경우: 개산부담금 또는 월별부담금 산정년도의 직전년도 말을 기준으로 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금에 대하여 미리 정산하여 지급한 비율

②의 경우

- ㉠ 확정기여형퇴직연금제도를 설정한 경우: 직전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정기여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여의 지급이 보장되는 비율
 - ㉡ 확정급여형퇴직연금제도를 설정한 경우: 직전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정급여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여부담금을 적립한 비율
- 다만, 전체 가입근로자의 평균가입기간이 3년을 초과하고 소급 적용하지 아니한 경우에는 다음 산식에 따른다.

$$\frac{3\text{년} - [\text{평균근속연수} \times (1 - \text{퇴직금 적립비율})]}{3\text{년}}$$

3년

부담금의 경감은 최대 50%까지인데 그 이유는 1998년 7월부터 2001년 10월까지 지급된 대지급금 중 임금·휴업수당은 50.4%이고, 퇴직금은 49.6%임을 감안한 것이다.

그러나 대지급금 중 임금 대비 퇴직급여의 지급 비율은 감소하는 추세이기 때문에 이러한 추세를 반영할 필요도 있다.

〈표 1-2〉 대지급금 지급액 및 항목별 비율

(단위: 억원)

연도	임금	퇴직급여	임금비율	합계	퇴직급여비율	휴업수당	휴업수당비율
2017	2,167.14	1,539	58.2%	3,724.21	41.3%	18.07	0.5%
2018	2,151.41	1,581.51	57.5%	3,739.98	42.3%	7.06	0.2%
2019	2,681.18	1,907.12	58.3%	4,598.8	41.5%	10.5	0.2%
2020	3,467.98	2,302	59.8%	5,796.9	39.7%	26.92	0.5%
2021	3,272.03	2,127.54	59.9%	5,465.71	38.9%	66.14	1.2%

출처: 고용노동부 제공 자료(2023. 5.)

따라서 본 연구의 두 번째 목적은 이러한 대지급금의 부담금 감경 비율을 현실적으로 맞추고 어려운 부담금 감경 산식을 보다 쉽게 개정하여 현장에서 바로 활용할 수 있는 방안은 없는지, 있다면 어떤 방안이 있으며, 없다면 그 이유는 무엇인지 살펴보는 것이다.

마지막 세 번째 목적은 대지급금제도에 있어서의 여러 쟁점을 총괄적으로 검토하는 것이다. 먼저 현재 도산대지급금은 연령별로 30세 미만에서 60세 이상까지 5등분하여 각각 상한액을 차등 두고 있다. 이는 임금채권보장법 제7조 제2항 단서가 “대지급금의 상한액은 근로자의 퇴직 당시의 연령 등을 고려하여 따로 정할 수 있”다고 규정하기 때문이다. 그러나 주의해야 할 점은 법조문은 연령별 상한액을 고려 사항으로 예시하고 있어 입법자가 반드시 연령별 상한액을 규정해야 하는 것은 아니다. 그렇다면 이것이 연령차별은 아닌지 검토할 필요가 있다.

그리고 사업주용자제도의 확대 가능성도 제도적으로 검토가 되어야 한다. 임금채권보장법은 제7조의3 제1항에서 “고용노동부장관은 사업주가 일시적인 경영상 어려움 등 고용노동부령으로 정하는 사유로 근로자에게 임금 등을 지급하지 못한 경우에 사업주의 신청에 따라 체불임금 등을 지급하는 데 필요한 비용을 융자할 수 있다”고 규정하고 있다. 그 한도 역시 동법 시행규칙으로 설정되어 있는데 사업주당 총 1억 5천만 원의 범위에서 횟수의 제한이 없고 체불임금 대상 근로자 1명당의 상한은 1천 5백만 원으로 한다(시행규칙 제8조의9 제2항). 그

려나 사용자용자의 한도가 적어 제도를 활성화하는데 애로가 있다는 의견이 있다. 사용자가 자발적으로 임금체불 해결 수단을 강구하고 기업에게 회생 기회를 줄 수 있다는 장점이 있지만, 기업의 남용 또한 있을 수 있기 때문에 상한액의 증액이 타당한지 검토할 필요가 있다.

마지막으로 간이대지급금 제도의 보완을 고민해야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 2021년 임금채권보장법 개정으로 간이대지급금 제도가 간소화되고 지급 대상이 확대되었다. 2022년 기준으로 간이대지급금이 전체 대지급금의 94%를 차지하고, 그중 2021년 신설된 요건인 체불확인서를 통한 대지급금 지급액이 전체의 85%를 차지하고 있다는 통계를 보면, 엄격한 요건의 도산대지급금 제도보다 요건이 간소해진 간이대지급금 제도로의 유인이 더 큰 것을 알 수 있다. 그러나 간이대지급금 제도의 확대가 형사상 임금체불죄를 무용지물로 만드는 것이 아니냐는 우려 또한 나오고 있다. 체불확인서 발급 과정에서 사업주가 근로자에게 임금체불죄에 대한 반의사불벌을 표시해 주면 임금체불 사실을 시인하겠다는 거래가 있을 수 있다는 것이다. 따라서 이러한 부작용을 최소화하면서 간이대지급금의 남용을 막을 수 있고, 아울러 대지급금 회수까지도 쉽게 할 방법을 모색하여야 한다.

제2절 연구의 내용

본 연구의 첫 번째 목적인 임금체불 사업주에 대한 책임 강화 방안을 모색하는 데 있어 중심이 되는 것은 물리적인 형사처벌과 경제적인 부담 가중이라고 할 수 있다. 이중 경제적인 제재로는 여러 가지가 있을 수 있지만 여기서는 행정제도로 임금체불에 대한 과징금제도와 사법제도로 임금체불근로자에 대한 징벌적 손해배상(또는 법정배액배상)제도를 중점으로 살펴볼 것이다. 이 중 과징금제도와 징벌적 손해배상(또는 법정배액배상)제도는 우리나라에 도입되지 않았기 때문에 비교법적 연구가 필요하다. 이 비교법적 연구에 각국의 형사처벌 제도의 특징도 아울러 살펴보고자 한다. 비교 대상 국가로는 법정배액배상제도를 채택하고 있는 미국, ‘노동 프로그램(labor program)’이라는 행정구제 절차를 갖고 있는 캐나다, 그리고 우리의 임금채권보장제도와 유사한 제도를 두고 있으며 부가금 제도를 가지는 일본, 3개국을 조사할 것이다.

미국의 경우 임금체불 제재 수단으로서 주(州)별로 체불임금의 2~3배를 지급하는 법정배액 배상제도를 두고 있는데, 법정배액배상제도를 징벌적 손해배상이라 할 수 있는지는 회의적이라 한다. 그리고 몇몇 주에서는 민사별로 과징금을 부과하기도 한다. 또한 미국 역시 임금체불에 대한 형사처벌 규정이 있으나 실제로는 기소까지 잘 이루어지지 -전혀 없는 편은 아니

지만- 않는다는 점을 살펴볼 것이다. 만일 징벌적 손해배상제도가 도입된다면 그 효과를 배가시키는 것이 ‘집단소송제도’이다. 미국의 징벌적 손해배상 소송은 집단소송으로 이루어지는 경우가 많아 그 특징과 현황을 알아보아, 집단소송제도가 없는 우리에게도 적합한지를 고민해 본다.

캐나다의 경우 임금체불에 형사처벌보다는 행정적 구제를 통하여 근로자의 생계를 보장하는 쪽으로 제도가 발전되어 있다. 형사처벌 자체는 연방노동법에 규정되어 있지만, 실제로는 잘 활용되지 않는 점을 지적한다. 주요한 것은 노동 프로그램(labor program)이라 알려진 권리구제 절차로서 이중 체불임금에 대한 회수 제도가 특징이다. 이는 먼저 국가가 일정 임금액을 선지급하는 대지급금제도와는 다른 것으로 노동 프로그램이라 불리는 국가 행정 절차가 체불임금의 24개월분까지를 회수하는 것을 의미한다. 만일 임금체불 사업주가 끝까지 체불임금을 지급하지 않는다면 노동 프로그램은 행정벌금을 부과할 수 있다.

일본의 경우 우리와 유사한 형사처벌 제도가 존재한다. 임금 지급과 임금 지급 방법의 원칙을 준수하지 않을 경우 “6개월 이하의 징역 또는 30만 엔 이하의 벌금”에 처해지게 된다(노동기준법 제119조 제1호). 그리고 임금체불 사업주에는 부가금을 부과하는데(노동기준법 제114조), 부가금은 해고예고수당, 휴업수당, 할증임금, 연차유급휴가에 한정하지만, 체불된 이 임금과 동일한 금액을 상한으로 근로자가 추가로 받을 수 있게 한다. 또한 일본은 우리와 유사한 대지급금(입체불)제도를 갖고 있어 그 요건을 우리와 비교하여 살펴볼 수 있다. 일본은 강력한 행정국가로서 행정기관의 지도 권한이 강한 나라인데, 임금체불 예방과 체불임금의 지급에 관하여 노동기준감독서의 감독행정 또한 어떻게 이루어지는지 알아볼 필요가 있다.

두 번째 목표로서 대지급금의 부담금 감경 비율의 조정과 복잡한 부담금 감경 산식을 조정하는 것이다. 일단 사업주의 임금채권보장기금 부담금의 감경이 제도적으로 필요한지부터 살펴본다. 만일 부담금 감경이 필요하다면 퇴직급여에만 경감을 인정하는 것이 타당하지도 검토해 본다. 그리고 부담금 감경과는 조금 다른 문제지만 부담금에 관한 쟁점으로서 현재 업종구분 없이 일률적으로 부과하고 있는 부담 비율(보수총액의 0.06%)을 업종별 또는 규모별로 차등화하는 것에 관한 장단점을 분석해 보고자 한다. 그 후 부담금 감경 공식이 개선 가능한지 그렇다면 어떻게 개선해야 할지, 만일 불가능하다면 그 이유는 무엇이고, 어떻게 접근해야 좀 더 이해도를 높일 수 있을지를 제안해 본다.

세 번째 목표는 기타 임금채권보장을 위한 쟁점들을 검토하는 것으로 도산대지급금의 상한액을 연령별로 차등 규정하는데 그 이유와 연혁은 어떠했는지, 상한액을 연령별로 규정하지 않는다면 발생하는 문제로 채권자로서 임금체불근로자의 권리는 어떻게 훼손될 수 있는지를 중심으로 살펴보고자 한다. 그리고 사업주용자제도의 한도 확대한다면 일종의 도덕적 해이(moral hazard)는 발생하지 않을지 고민되는데, 이러한 우려를 막기 위한 제도로써 새롭게

‘사전 용자제도’를 도입하되 역시 남용을 막기 위한 제도적 장치는 어떤 것이 있을지 탐구해 본다. 또한, 간이대지급금 제도가 확산됨에 따라 근로자들이 그것을 수월하게 받기 위해 사업주와의 ‘합의’를 우선하여 형사처벌제도가 형해화되고 있는데 근로자의 합의가 진정성을 띠고 사업주가 간이대지급금을 믿고 의도적으로 임금체불을 하는 것을 방지하기 위하여 필요한 대안은 무엇인지 모색해 본다.

제2장 임금체불 시 사업주 책임에 관한 해외 법제 비교

제1절 미국의 임금체불 구제 수단과 억제제도

1. 개 관

미국에서도 임금체불은 중요한 사회문제이며, 이를 임금절도(Wage Theft)라 칭하기도 한다.³⁾ 다만, 미국에서 임금절도는 계산 착오 등으로 임금을 체불하는 것, 최저임금을 위반한 금액을 지급하는 것, 약정된 임금보다 적은 금액을 지급하는 것, 임금에서 법적으로 허용되지 않은 공제를 한 것, 근로자가 일한 시간 전부에 대한 임금을 지급하지 않는 것 등을 모두 포함하는 개념으로 사용된다.⁴⁾ 즉, 미국에서는 임금의 일부나 전부가 체불되는 상황을 임금절도로 통칭하며, 그중 근로자가 일한 시간(이나 기간) 전부에 대한 임금을 지급하지 않는 것이 한국에서 통상 임금체불이라 하는 상황에 해당한다.⁵⁾

미국의 임금절도 관련 연구는 여러 가지 이유로 임금의 일부나 전부가 지급되지 않은 임금절도 상황을 통합적으로 검토하고 있고, 근로자가 일한 기간 전부에 대한 임금을 체불당한 경우만을 체계적으로 연구한 자료를 찾기는 어렵다. 우선, 미국은 50개 주로 이루어진 연방제 국가로, 임금체불에 대한 주정부의 통계를 체계적으로 정리한 자료를 찾기 어렵다.⁶⁾ 아래에서 보는 바와 같이 미국에서는 역사적으로 임금체불을 형사처벌하는 경우가 많지 않아 형사사건을 통해 공식적으로 드러나는 임금체불 통계가 있기 어렵다. 민사사건의 경우 아래에서 보는 바와 같이 주로 연방법원에 집단소송으로 제기되는 사건들 중심으로 연구가 이루어지므로, 집단소송으로 진행되기 좋은 최저임금위반 사건, 연장근로수당 청구 사건 등에 대한 자료가 존재할 뿐, 전통적인 임금체불 사건은 잘 제기되지 않는 것 같다. 이러한 이유로 미국

3) 예를 들어, Kim Bobo, Wage Theft in America: Why Millions of Working Americans are not Getting Paid – And What we can do About it(2014); Benjamin Levin, Wage Theft Criminalization, 54 U.C. Davis L. Rev. 1429(2021) 등.

4) Anthony Damelio, Making Wage Theft Costly: District Attorneys and Attorneys General Enforcing Wage and Hour Law, 49 Fordham Urb. L.J. 113-14(2021).

5) 건설업 근로자에게 업무가 끝난 후 임금을 지급하겠다고 약속한 후, 업무가 끝나자 사용자가 사라지는 경우를 예로 든다. César F. Rosado Marzán, Wage Theft as Crime: An Institutional View, 20 J. Law in Society 300, 302(2020).

6) 연구 과정에서 확인한 임금절도를 다룬 최신 2차 문헌들도 이러한 통계를 소개하지 않았다.

의 최저임금 위반 등을 제외한 임금 전체를 체불당하는 사건만 별도로 구별하여 한 연구는 찾지 못하였다. 이하에서는 부득이하게 미국의 연구에 따라 검토하되, 가급적 최저임금에 대한 논의보다는 임금 전부에 대한 체불에 도움이 되는 내용을 검토하겠다.

미국 주 차원에서는 임금절도를 억제하기 위한 다양한 입법안이 2004년부터 2012년 사이에 약 250건이 제출되어 검토되었다.⁷⁾ 이러한 개정안들은 크게 (1) 임금을 체불한 사용자에 대한 제재를 강화하는 것과 (2) 체불한 사업자로부터 임금채권을 받을 방안을 개선하는 것으로 분류되기도 하고,⁸⁾ (1) ‘근로자’ 개념을 확장하는 것, (2) 민형사상 제재를 강화하는 것, (3) 청구권과 구제방안을 확장하는 것, 그리고 (4) 기록 보관의무를 강화하는 것으로 분류되기도 한다.⁹⁾

미국 관련 제도를 보면, 연방법이 근로시간과 임금에 관한 하한을 정하면서 각 주나 시가 정책적 판단에 따라 주법이나 시법으로 근로자의 근로시간이나 임금 등에 관한 더 강한 규제를 할 수 있게 한다.¹⁰⁾ 따라서 이하에서는 미국의 임금체불에 대한 연방과 각 주의 제재수단을 소개하고, 그 외 체불임금 확보 방안을 살핀 후, 이에 관한 미국의 평가를 검토한다.¹¹⁾

2. 임금체불에 대한 연방과 각 주의 제재 수단

미국 연방과 각 주는 사용자의 임금체불을 억제하기 위하여 임금을 체불할 경우 민사벌 등으로 추가적인 제재를 하는 제도를 두고 있다. 이와 같은 제도를 두는 이유는 임금을 체불할 경우 사후적으로(ex post) 체불임금에 더하여 추가 제재가 있을 것임을 아는 사업자들이 사전적으로(ex ante) 임금을 체불하지 않기 위해 행동할 유인이 더 생길 것이라는 기대에 의한 것 같다.

다만, 미국 연방과 각 주는 미국 연방 헌법에 따라 별도의 입법권이 있고, 연방과 각 주는 그 입법자의 정책적 판단에 따라 다양한 임금절도 유형 중 어떠한 유형에 대해 어떠한 제재를 어느 정도로 가할 지를 달리한다. 즉, 미국은 한국과 달리 하나의 법률이 적용되는 국가가 아니며, 미국 연방 법률과 각 주의 - 서로 내용이 다른 - 법률이 중첩적으로 적용된다. 그러

7) Marc Doussard & Ahmad Gamal, The Rise of Wage Theft Laws: Can Community-Labor Coalitions win Victories in State Houses?, 52 Urb. Aff. Rev. 780, 781(2015).

8) Nicole Hallett, The Problem of Wage Theft, 37 Yale L. & Pol’y Rev. 93, 114(2018).

9) Matthew Fritz-Mauer, The Ragged Edge of Rugged Individualism: Wage Theft and the Personalization of Social Harm, 54 U. Mich. J. L. Reform 735, 757(2021).

10) National Employment Law Project, Winning Wage Justice: An Advocate’s Guide to State and City Policies to Fight Wage Theft 9(2011).

11) 미국은 50개 주로 이루어진 연방국가이므로, 이 보고서에서 50개 주의 모든 관련 법률과 실무를 검토하는 것은 이 보고서 범위를 벗어난다고 본다. 따라서, 이하에서는 보고서의 목적 범위 내에서 조사가 가능한 주의 법률과 실무를 소개하고자 한다. 또한, 각 시의 법률과 실무는 원칙적으로 연구 범위에서 제외한다.

므로 이하의 미국에 대한 검토는 미국 영토 내에서 동일한 법이 적용되는 것이 아님을 전제로 미국 입법자에 의해 다양한 임금절도 유형에 대응하기 위해 활용되는 다양한 입법기술을 비교법적으로 검토하여 참고할 수 있게 하고자 한다.

구체적인 방법은 여러 가지가 있겠으나, 크게 (1) 법정배액배상제, (2) 민사벌, (3) 형사벌로 분류할 수 있다. 그중 법정배액배상제는 그 법률의 집행을 주로 임금을 체불 당한 당사자나 그 소송대리인이 하는 반면, 민사벌과 형사벌은 정부기관이 그 법률의 집행을 한다. 또한, 민사벌은 대체로 주 노동부 등이 집행하지만, 형사벌은 검사에 의해 집행한다. 이하에서 차례로 살펴되, 다만 먼저 법정배액배상제와 구별되는 개념인 징벌적 손해배상에 대해 간단히 설명한다.

한국에서는 통상 성문법으로 배액배상을 허용하는 법률 조항에 대하여 징벌적 손해배상이라는 용어를 사용하지만,¹²⁾ 미국법 체계상 징벌적 손해배상은 통상 보통법(common law)¹³⁾ 상 법리를 말하고, 성문법에 규정되어 있으면 통상 법정배액배상으로 구별한다.¹⁴⁾ 징벌적 손해배상은 미국에서 역사적으로 보통법상 인정되었으나, 캘리포니아(California)주처럼 보통법상 인정되는 법리를 성문법으로 정한 주도 있다.¹⁵⁾ 즉, 미국법상 각 주는 보통법상 징벌적 손해배상 법리¹⁶⁾에 더하여 입법정책 목적에 따라 징벌적 손해배상이나 배액배상제도를 입법하므로, 더 이상 징벌적 손해배상과 법정배액배상 제도는 완전히 구별되는 개념이 아니다. 그 래도 - 예외가 있음을 인정함을 전제로 - 이를 구별하여 표로 정리하면 다음과 같다.

12) 고형석, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구 - 소비자권익침해를 중심으로 -”, 비교사법 제29권 1호, 2022, 308면 등.

13) 보통법(Common law)은 헌법이나 법률이 아닌 사법부의 재판들에 의하여 형성되는 법리이다. Common Law, Black's Law Dictionary(11th ed. 2019).

14) 박지원, “민사소송에서 법정배액배상 조항의 심리에 관한 소고”, 민사소송 제27권 2호, 2022, 29면.

15) 다만, 미국에서 역사적으로 징벌적 손해배상이 보통법상 인정되었다는 것을 의미하는 것이고, 캘리포니아 주처럼 성문법으로 정한 주도 있다. California Code, Civil Code - CIV § 3294.

(a) In an action for the breach of an obligation not arising from contract, where it is proven by clear and convincing evidence that the defendant has been guilty of oppression, fraud, or malice, the plaintiff, in addition to the actual damages, may recover damages for the sake of example and by way of punishing the defendant.

16) 반면, 보통법상 징벌적 손해배상을 인정하지 않는 주도 있다. 예를 들어, 1981년 기준 루이지애나(Louisiana)주, 매사추세츠(Massachusetts)주, 네브라스카(Nebraska)주, 워싱턴(Washington)주는 징벌적 손해배상을 인정하지 않았다. Tom Riley, Proving Punitive Damages: The Complete Handbook, 1981, 29면.

〈표 2-1〉 징벌적 손해배상과 법정배액배상의 비교¹⁷⁾

	(보통법상) 징벌적 손해배상	법정배액배상
목적 및 기능	처벌을 통한 억제	(1) 처벌을 통한 억제, 또는 (2) 배상을 통한 억제
대상 사건	모든 종류의 불법행위 사건	법정되어 있는 경우에 한정(법정되어 있다면 계약책임도 포함한다)
청구권자	원고(피해자)는 징벌적 손해배상의 수여를 권리로서 주장할 수 없다	원고(피해자)는 배액배상을 주장할 수 있는 권리가 있다
요건	(처벌을 전제로 하므로) 가해행위의 악성 또는 행위자의 고의 요구	(1) 처벌목적의 경우: 행위자의 고의를 요구한다 (2) 전보목적의 경우: 행위자의 고의를 요구하지 않는다
총배상액	(1) 전보배상액 외에 징벌적 손해배상액(행위의 악성, 가해자의 부의 정도를 주로 고려하여 징벌적 손해배상액을 정함)을 사실인정자의 재량으로 정한다 (2) 제한 없으나, 과도한 경우 위헌 가능성이 있다.	(1) 전보배상액의 2배 또는 3배로 법정되어 있다 (2) 필수적 증액과 재량적 증액 구별

이하 미국 부분에서는 그 목적이 - 법률상 또는 해석상 - 전보적이든 징벌적이든 불문하고 성문법에 의하여 2배 이상의 배액배상을 정한 경우 배액배상제 내지 법정배액배상제라 하고, 보통법상 징벌적 손해배상에 대하여 논의를 할 경우 이를 구별하여 징벌적 손해배상이라 한다.¹⁸⁾ 미국의 경우 여러 주들이 임금체불에 대하여 징벌적 성격이 있는 법정배액배상제를 두므로 이러한 의미에서는 징벌적 손해배상 제도를 채택하고 있다고 평가할 수 있다.

17) 박지원, 앞의 글, 31-32면.

18) 징벌적 손해배상제도는 사법(私法)에서 ‘처벌’에 의미를 두지 않고 ‘전보’를 중시하는 대륙법 계열인 프랑스와 독일에서는 존재하지 않는다. 참고로 프랑스의 경우 사업주가 악의적으로 임금체불을 할 경우, 사업주는 프랑스 민법전 L.1153조의 불법행위책임에 따라 근로자에게 손해배상을 해야 한다. 그 외 프랑스의 임금채권보장제도에 관한 자세한 내용은 한국노동연구원의 연구보고서, 김근주·김명수·오승규·황수옥, 「체불임금해결시스템의 국제비교 연구: 임금채권보장제도를 중심으로」, 2016. 12.를 참조할 수 있다.

징벌적 손해배상제도는 전형적인 영미법 계열의 제도로서 영국의 징벌적 손해배상제도를 개략하면 다음과 같다. 영국의 징벌적 손해배상은 법원이 불법행위를 처벌하고 억제하는 것을 목적으로 한다. 징벌적 손해배상이 모든 경우에 인정되는 것은 아니며, 공무원의 억압적·자의적·위험적 행위 또는 대기업의 계산적이고 냉소적인 행위와 같이 피고의 행위가 특히 터무니없는 예외적인 경우에만 인정된다. 영국 법원은 *Rookes v. Bernard* 사건에서 징벌적 손해배상이 인정될 수 있는 세 가지 범주를 제시하였다.

첫째, 피고의 행위가 억압적이거나 자의적이거나 위험적이어서 원고가 권력 남용의 영향을 받은 경우,

둘째, 피고의 행위가 원고에게 지급해야 할 보상금을 초과하는 이익을 얻기 위해 계산된 경우

셋째, 2013년 명예훼손법(Defamation Act) 또는 1997년 괴롭힘 방지법(Protection from Harassment Act)과 같이 법률에서 징벌적 손해배상을 명시적으로 허용하는 경우이다.

주의해야 할 점은 영국 법원은 징벌적 손해배상이 보상적 손해배상에 비해 과도하거나 불균형하여서는 안 된다는 비례 원칙을 고려하며, 이중처벌금지 원칙에 따라서 징벌적 손해배상이 동일한 행위에 대해 피고에게 부과된 형사 또는 규제적 제재와 중복되어서는 안 된다는 점도 고려한다. 사실상 형사처벌과 병행하지는 않는 것이다.

가. 법정배액배상제

임금을 체불한 사용자에게 대한 제재 강화 방안의 예로 성문법상 배액배상제를 들 수 있다. 성문법상 배액배상의 성격이 징벌적(punitive)인지, 전보적(compensatory)인지는 그 성문법의 규정 내용에 따라 다르다.¹⁹⁾ 단순히 법에 배액배상이 규정되어 있다는 이유로 그 조항의 법적 성격을 징벌적이라 단정할 수 없고, 전보를 포함한 다른 목적으로 제정되었을 수 있다.²⁰⁾ 어떤 법은 오로지 전보만 목적으로 할 수도 있고, 전보와 징벌을 둘 다 목적으로 할 수도 있다.²¹⁾

예를 들어, 미국연방 법률은 연방 최저임금을 위반하여 급여를 지급하지 않거나 연장근로수당을 지급하지 않은 사용자는 지급받지 못한 근로자에게 미지급액에 더하여 같은 금액을 손해배상액의 예정으로 지급할 의무가 있다고 정한다.²²⁾ 이러한 법정 손해배상액은 법원이 재량에 의해 체불임금의 2배까지 지급을 명할 수 있는 것이 아니라, 법률로 2배 지급이 강제되는 것이다.²³⁾ 위 손해배상액 예정 조항은 손해를 추정하는 것이지 간주하는 것은 아니지만, 보통 위 추정을 깨기는 어렵다.²⁴⁾

그러나 위 미국연방 법률은 사용자에게 근로자가 일한 모든 시간에 대한 임금을 지급할 것을 요하지는 않는다.²⁵⁾ 위 법률은 근로자에게 법정 주 40시간을 초과하는 시간에 대하여는 통상 시간당 임금의 1.5배가 지급될 것과 40시간에 달할 때까지는 최저임금 이상이 지급될 것만 정한다.²⁶⁾ 따라서, 이론적으로는 근로자에게 40시간에 달할 때까지 시간당 임금을 지급받고, 40시간이 초과하는 시간에 대한 통상 시간당 임금의 1.5배가 지급되었다면 사용자는

19) 박지원, 앞의 글, 27-28면.

20) 박지원, 위의 글, 28면.

21) 박지원, 위의 글, 28-29면.

22) 29 U.S.C. §216. Penalties(b) Damages; right of action; attorney's fees and costs; termination of right of action

Any employer who violates the provisions of section 206 or section 207 of this title shall be liable to the employee or employees affected in the amount of their unpaid minimum wages, or their unpaid overtime compensation, as the case may be, and in an additional equal amount as liquidated damages.

즉, 위 연방 법률 조항에 따라 최저임금을 위반한 미지급 임금과 연장근로수당 미지급에 대하여 법정배액배상제를 두고 있다. 아래에서 보는 바와 같이 연방대법원은 이를 징벌적 성격이 아니라 증명이 어려운 손해를 배상하는 성격을 갖는다고 해석한다. Brooklyn Savings Bank v. O'Neil, 324 U.S. 697, 707(1945)(“We have previously held that the liquidated damage provision is not penal in its nature, but constitutes compensation for the retention of a workman's pay which might result in damages too obscure and difficult of proof for estimate other than by liquidated damages.”)

23) Llezlie L. Green, Wage Theft in Lawless Courts, 107 Cal. L. Rev. 1303, 1312(2019).

24) Ibid.

25) James M. Nicholas, Defending Wage and Hour Class Action Cases: Winning Strategies, in Strategies for Employment Class and Collective Actions,(2012), 8면.

26) Ibid.

위 미국연방 법률의 요건을 충족한 것이다.²⁷⁾ 이는 결과적으로 근로자가 임금을 모두 지급받지 않았어도 충족한다.²⁸⁾ 그러나 많은 주는 연방법률보다 더 근로자를 강하게 보호한다.²⁹⁾ 즉, 미국 연방법률은 최저 보호정도를 정하고, 각 주는 근로자를 보호하기 위한 더 강한 법률을 둘 수 있다.³⁰⁾

미국 연방대법원은 이러한 미국연방 법률의 손해배상액 예정 조항은 그 성격이 징벌(penal)적이지 않으며, 이는 임금체불로 인하여 발생하는 손해가 너무 불명확하고 계산할 증거를 수집하기 어려운 경우에도 이를 배상하게 하기 위한 것이라 해석하였다.³¹⁾ 즉, 이는 미국 연방의회가 법정 최저임금을 지급하지 않는 것은 근로자가 건강을 포함한 일반복리를 유지하기 위한 최소한의 생활수준과 자유로운 상거래에 해악을 가져오므로 급여 지급이 지연될 경우 2배의 배상은 이루어져야 그 근로자가 최소한의 복리 수준으로 회복될 수 있을 것이라는 것을 인정했기 때문이라고 보았다.³²⁾

워싱턴 DC는 근로관계가 종료하는 일정한 경우 사용자가 근로자에게 기한 내에 급여를 지급하지 않으면 (1) 손해배상액의 예정으로 지급일로부터 지급할 때까지 매 영업일마다 미지급 급여의 10% 또는 (2) 미지급 급여의 3배 중 더 적은 금액을 추가로 지급하게 하였다.³³⁾ 이는 미국 연방 중 최초 사례에 해당한다.³⁴⁾

2012년 기준 미국 주 중 21개 주는 최저임금 위반 등 일정한 방법으로 임금을 체불한 사용자에게 체불임금의 2배를, 7개 주는 체불임금의 3배를 배상하게 하는 방안을 택한다.³⁵⁾ 각주가 정하는 법률은 약간씩 다르므로, 이하에서는 주별로 간단히 소개한다.³⁶⁾

27) Ibid

28) Ibid. at 8-9면.

29) Ibid. at 9면.

30) Ibid.

31) Brooklyn Savings Bank v. O'Neil, 324 U.S. 697, 707(1945)("We have previously held that the liquidated damage provision is not penal in its nature, but constitutes compensation for the retention of a workman's pay which might result in damages too obscure and difficult of proof for estimate other than by liquidated damages.").

32) Ibid.

33) D.C. Code § 32-1303 - Payment of wages upon discharge or resignation of employee and upon suspension of work; employer's liability for failure to make such payment

(4) If an employer fails to pay an employee wages earned as required under paragraphs (1), (2), and (3) of this section, such employer shall pay, or be additionally liable to, the employee, as liquidated damages, 10 per centum of the unpaid wages for each working day during which such failure shall continue after the day upon which payment is hereunder required, or an amount equal to treble the unpaid wages, whichever is smaller.

34) Hallett, 앞의 글, 115면.

35) Lauren K. Dasse, Wage Theft in New York: The Wage Theft Prevention Act as a Counter to an Endemic Problem, 16 CUNY L. Rev. 97, 114(2012). 최근 조사 결과, 2012년 이후 일부 주의 법률 개정으로 위 통계는 정확하지는 않다. 위에서 본 바와 같이 미국 연방법률은 최저 보호정도를 정하고, 각 주는 근로자를 보호하기 위한 더 강한 법률을 둘 수 있다. 각주 29 참조.

1) 알래스카(Alaska)주

연장근로수당,³⁷⁾ 최저임금³⁸⁾보다 적게 지급하여 해당 법률을 위반한 사용자는 미지급 금액을 지급하여야 하고, (d)항에서 정한 경우에 해당하지 않는 한 추가로 같은 미지급 금액을 손해배상액의 예정으로 지급하여야 한다.³⁹⁾ (d)항은 미지급 연장근로수당 청구 또는 미지급 연장근로수당 상당액 손해배상 청구 소송에서 피고가 명백하고 믿을 수 있는 증거로 이러한 미지급행위가 신의성실에 의하여 이루어진 것으로 사용자가 위법행위를 할 당시 그 행위가 위법하지 않았다고 믿을 합리적인 이유가 있었다면, 법원은 미지급 연장근로수당 상당액 부분은 기각하거나 감액할 수 있다고 정한다.⁴⁰⁾ 즉, 알래스카주는 원칙적으로 미지급액의 2배를 배상하여야 하고, 예외적으로 피고가 엄격한 요건을 증명하면 미지급액보다 같거나 많지만, 2배보다는 적게 배상하게 할 수 도록 한다.

2) 아리조나(Arizona)주

만약 사용자가 이 장(chapter)에 반하여 근로자에게 기한이 도래한 급여를 지급하지 않으면, 그 근로자는 사용자 또는 전 사용자(former employer)에 대한 민사소송을 제기하여 미지급 급여의 3배에 해당하는 금액을 받을 수 있다.⁴¹⁾

36) 미국은 50개 주가 있고, 주마다 입법 내용이 다를 수 있어 이를 모두 검토하는 것은 효율적이지 않다. 이하에서는 한국에서 참고할 수 있도록 가급적 많은 주 법률을 소개하였다. 다만, 본 연구는 최저임금에 대한 검토는 제외되므로 최저임금에 대한 법정배상을 정하는 것으로 보이는 주는 제외하였다.

37) Alaska Stat. § 23.10.060 - Payment for overtime

(a) An employer who employs employees engaged in commerce or other business, or in the production of goods or materials in the state, may not employ an employee for a workweek longer than 40 hours or for more than eight hours a day.

(b) If an employer finds it necessary to employ an employee for hours in excess of the limits set in this subsection, overtime compensation for the overtime at the rate of one and one-half times the regular rate of pay shall be paid. An employee is entitled to overtime compensation for hours worked in excess of eight hours a day.(이하 생략).

38) Alaska Stat. § 23.10.065 - Minimum Wages.(이하 생략)

39) Alaska Stat. Section 23.10.110 - Remedies of employee; attorney fees; offers of judgment; settlement; waiver

(a) An employer who violates a provision of AS 23.10.060 or 23.10.065 is liable to an employee affected in the amount of unpaid minimum wages, or unpaid overtime compensation, as the case may be, and, except as provided in(d) of this section, in an additional equal amount as liquidated damages.

40) Alaska Stat. Section 23.10.110 - Remedies of employee; attorney fees; offers of judgment; settlement; waiver

(a) An employer who violates a provision of AS 23.10.060 or 23.10.065 is liable to an employee affected in the amount of unpaid minimum wages, or unpaid overtime compensation, as the case may be, and, except as provided in(d) of this section, in an additional equal amount as liquidated damages.

41) Ariz. Rev. Stat. § 23-355 - Action by employee to recover wages; amount of recovery.

A. Except as provided in subsection B of this section, if an employer, in violation of this chapter,

3) 알칸소(Arkansas)주

연장근로수당, 최저임금보다 적게 근로자에게 지급한 사용자는 근로자에게 실제지급한 금액을 제한 총액과 법원이 허용하는 변호사 보수를 포함한 소송비용을 지급할 책임이 있다고 정한다.⁴²⁾ 만약 사용자의 위반행위가 고의로 인한 것임을 근로자가 증명하면 체불된 임금의 액수를 초과하지 않는 범위 내의 금액을 사용자로부터 추가로 받을 수 있다고 정한다.⁴³⁾ 즉, 알칸소주의 경우 근로자가 받는 미지급 임금에 더한 추가 금액은 미지급 액의 2배가 아니라 2배까지이다.

4) 콜로라도(Colorado)주

만약 사용자에게 의하여 근로관계가 단절될 경우 미지급된 급여는 원칙적으로 즉시 지급되어야 한다.⁴⁴⁾ 만약, 근로자가 사직하거나 그만둘 경우, 미지급 급여는 통상적인 그 다음 급여 지급일에 지급되어야 한다.⁴⁵⁾ 만약, 사용자가 지급기한이 도래한 위 미지급 급여 지급을 구하는 서면 요청이 있는 후 14일 이내 또는 지급기한이 도래한 미지급 급여에 관한 민사 또는 행정 사건에 기한 청구를 받은 후 14일 이내에 급여를 지급하지 않으면 그 사용자는 해당 근

fails to pay wages due any employee, the employee may recover in a civil action against an employer or former employer an amount that is treble the amount of the unpaid wages.

42) Ark. Code Section 11-4-218(a)

(1) Any employer who pays any employee less than the minimum wages, including overtime compensation or compensatory time off as provided by this subchapter, to which the employee is entitled under or by virtue of this subchapter shall:

(A) Pay any applicable civil penalties; and

(B) Be liable to the employee affected for:

(i) The full amount of the wages, less any amount actually paid to the employee by the employer; and

(ii) Costs and such reasonable attorney's fees as may be allowed by the court.

(2) The employee may be awarded an additional amount up to, but not greater than, the amount under subdivision (a)(1)(B)(i) of this section to be paid as liquidated damages if the employee proves the violation was willful.

43) Ark. Code Section 11-4-218(a)

(2) The employee may be awarded an additional amount up to, but not greater than, the amount under subdivision (a)(1)(B)(i) of this section to be paid as liquidated damages if the employee proves the violation was willful.

44) Colo. Rev. Stat. § 8-4-109 - Termination of employment - payments required - civil penalties - payments to surviving spouse or heir

(1) (b) When an employee quits or resigns such employee's employment, the wages or compensation shall become due and payable upon the next regular payday.(이하 생략)

45) Colo. Rev. Stat. § 8-4-109 - Termination of employment - payments required - civil penalties - payments to surviving spouse or heir

(1) (a) When an interruption in the employer-employee relationship by volition of the employer occurs, the wages or compensation for labor or service earned, vested, determinable, and unpaid at the time of such discharge is due and payable immediately.(이하 생략)

로자 또는 해당 근로자와 같은 상황인 근로자들에 대하여 미지급 급여에 더하여 자동적인 제재로 (1) 미지급 급여 2배와 1,000미국 달러 중 더 큰 금액 또는 (2) 만약, 근로자가 사용자가 급여를 지급하지 않은 것이 고의(willful)로 인한 것임을 보일 경우 미지급 급여 3배와 3,000달러 중 더 큰 금액을 지급하여야 한다.⁴⁶⁾ 최근 5년 이내에 사용자가 임금을 체불하였다는 판결이 있었다는 증거는 사용자의 고의를 증명하기 위한 증거로 제출가능하다. 만약, 근로자가 이 사건 소가 제기되기 5년 이내에 사용자가 같거나 비슷한 종류의 급여를 체불하였다는 것을 보이면 사용자가 고의로 체불하였다는 사실이 간주된다.⁴⁷⁾

5) 코네티컷(Connecticut)주

만약 근로자가 사용자로부터 최저공정임금 또는 연장근로임금을 전액 지급받지 못하였다면 그 근로자는 (1) 최저공정임금 또는 연장근로임금의 2배에서 실제 지급된 금액을 제한 금액(과 합리적인 변호사 보수를 포함한 소송비용)을 사용자로부터 지급받거나, (2) 만약 사용자가 이와 같이 적게 지급한 것이 법에 따른 것이라고 선의로 믿었다(good faith belief)는 것을 보이면 최저공정임금 또는 연장근로임금에서 실제 지급된 금액을 제한 금액(과 합리적인 변호사 보수를 포함한 소송비용)을 사용자로부터 지급받을 수 있다.⁴⁸⁾

46) Colo. Rev. Stat. § 8-4-109 - Termination of employment - payments required - civil penalties - payments to surviving spouse or heir

(3) (b) On or after January 1, 2023, if an employer fails or refuses to pay, in the manner specified in subsection (3)(d) of this section, all earned, vested, and determinable wages or compensation within fourteen days after the written demand is sent or within fourteen days after a civil action or administrative claim for the wages or compensation is sent to or served on the employer, the employer is liable to the employee or group of similarly situated employees for the amount of the earned, vested, determinable, and unpaid wages or compensation plus an automatic penalty of:

(I) The greater of two times the amount of the unpaid wages or compensation or one thousand dollars; or

(II) If the employee can show that the employer's failure or refusal to pay wages or compensation was willful, the greater of three times the amount of the unpaid wages or compensation or three thousand dollars.

47) Colo. Rev. Stat. § 8-4-109 - Termination of employment - payments required - civil penalties - payments to surviving spouse or heir

(3) (c) Evidence that a judgment or wage determination of the division has, within the previous five years, been entered against the employer for failure to pay wages or compensation is admissible as evidence of willful conduct. An employer's failure or refusal to pay wages or compensation is per se willful if the employee can show that the claim for which a penalty under subsection (3)(b) of this section is assessed is the employer's second or subsequent failure or refusal to pay to employees wages or compensation of the same or similar type within the five years immediately preceding the claim. 증거관련 법칙은 한국과 미국이 달라 자세히 설명하는 것은 이 보고서 범위를 넘어선다.

48) Conn. Gen. Stat. § 31-68 - Collection of minimum or overtime wage. Class action certifications. Collection of wages for employee whose whereabouts are unknown

(a) (1) If any employee is paid by his or her employer less than the minimum fair wage or overtime

6) 하와이(Hawaii)주

사용자가 근로자의 최저임금이나 연장근로수당을 지급하지 않으면 그 미지급액을 지급할 의무가 있고, 만약 고의로 이를 위배한 경우(wilful viation) 같은 금액을 손해배상액의 예정으로 추가로 지급하여야 한다.⁴⁹⁾

7) 아이다호(Idaho)주

근로관계가 종료한 경우 사용자는 원칙적으로 다음 급여지급일 또는 근로관계 종료일로부터 10일 이내(주말과 휴일 제외) 중 먼저 도래하는 날까지 급여를 지급하거나 지급할 준비를 하여야 한다.⁵⁰⁾ 만약, 사용자가 위 조항이 정한 지급일에 급여를 모두 지급하지 못한다면 사용자는 그 미지급 급여가 모두 지급된 일자나 15일 중 더 적은 일수에 이를 때까지 같은 비율에 의하여 계산한 급여를 더 지급하여야 한다. 어느 경우도 이러한 벌(penalty)의 상한은 750미국 달러(\$750)를 초과할 수 없고, 일정한 관련 법률이 정한 경우에는 500미국 달러(\$500)를 초과할 수 없다.⁵¹⁾ 단, 근로자가 급여를 지급받기를 피하거나 급여 지급을 거절한다면 이러한 벌은 적용되지 않는다.⁵²⁾ 미지급 급여를 구하는 소를 제기한 원고는 피고로부터

wage to which he or she is entitled under sections 31-58, 31-59 and 31-60 or by virtue of a minimum fair wage order he or she shall recover, in a civil action, (A) twice the full amount of such minimum wage or overtime wage less any amount actually paid to him or her by the employer, with costs and such reasonable attorney's fees as may be allowed by the court, or (B) if the employer establishes that the employer had a good faith belief that the underpayment of such wages was in compliance with the law, the full amount of such minimum wage or overtime wage less any amount actually paid to him or her by the employer, with costs and such reasonable attorney's fees as may be allowed by the court.

49) Haw. Rev. Stat. § 387-12(b) Liability to employee.

Any employer who violates any provision of sections 387-2 and 387-3 shall be liable to the employee or employees affected in the amount of their unpaid minimum wages or unpaid overtime compensation, and in case of wilful violation in an additional equal amount as liquidated damages.

50) Idaho Code § 45-606 - PAYMENT OF WAGES UPON SEPARATION FROM EMPLOYMENT

(1) Upon layoff, or upon termination of employment by either the employer or employee, the employer shall pay or make available at the usual place of payment all wages then due the employee by the earlier of the next regularly scheduled payday or within ten(10) days of such layoff or termination, weekends and holidays excluded.(이하 생략)

51) Idaho Code § 45-607 - PENALTY FOR FAILURE TO PAY

Whenever an employer fails to pay all wages then due an employee at the times due under section 45-606, Idaho Code, then the employee's wages shall continue at the same rate as if services had been rendered in the manner as last employed until paid in full or for fifteen(15) days, whichever is less. However, in no event can the maximum penalty exceed seven hundred fifty dollars(\$750), and if the full amount of the wages are paid prior to the filing of a lien pursuant to section 45-620, Idaho Code, the maximum penalty shall not exceed five hundred dollars(\$500).

52) Idaho Code § 45-607 - PENALTY FOR FAILURE TO PAY

Any employee who secretes or absents himself to avoid payment, or refuses to receive payment when made available as provided for in section 45-606, Idaho Code, shall not be entitled to any penalty under this chapter.

미지급 급여에 더하여 위 벌금을 받거나, 미지급 급여의 3배에 달하는 손해배상액 중 더 큰 금액을 받을 수 있다(합리적인 범위 내의 변호사 보수를 포함한 소송비용도 받을 수 있다).⁵³⁾

8) 캔사스(Kansas)주

만약 사용자가 근로자에게 고의적으로 근로자가 만약 계속 일을 하였다면 급여를 지급받았을 급여를 그때 지급하지 않을 경우를 포함한 몇 가지 경우 그러한 사용자는 근로자에게 미지급 급여에 더하여 (1) 벌(penalty)로 지급일로부터 8일이 지난 후 하루당(일요일과 법정공휴일을 제외한다) 미지급 급여의 1%에 해당하는 금액을 더한 금액⁵⁴⁾ 또는 (2) 미지급 급여 100%에 해당하는 금액 중 더 적은 금액을 지급하여야 한다.⁵⁵⁾

9) 켄터키(Kentucky)주

사용자가 근로자에게 최저임금이나 연장근로수당을 모두 지급하지 않은 경우 그 근로자는 (법원이 허용하는 합리적인 변호사 보수를 포함한 소송비용에 더하여) 사용자가 실제 지급한 금액을 제외한 최저임금이나 연장근로수당 전액을 손해배상액 예정으로 추가로 지급받을 수 있다.⁵⁶⁾ 만약, 사용자가 그 미지급 행위가 신의성실(good faith)로 이루어졌고, 그의 행위가

53) Idaho Code § 45-615 - COLLECTION OF WAGE CLAIMS BY SUIT - ATTORNEY'S FEES AND COSTS

(2) Any judgment rendered by a court of competent jurisdiction for the plaintiff in a suit filed pursuant to this section may include all costs and attorney's fees reasonably incurred in connection with the proceedings and the plaintiff shall be entitled to recover from the defendant either the unpaid wages plus the penalties provided for in section 45-607, Idaho Code; or damages in the amount of three(3) times the unpaid wages found due and owing, whichever is greater.

54) 예를 들어, 지급일로부터 8일이 지난 후 일요일과 법정공휴일을 제외한 5일이 지나면 미지급 급여의 5%에 해당하는 금액이 될 것이다.

55) Kan. Stat. § 44-315 - Separation prior to payday; damages for willful non-payment

(b) If an employer willfully fails to pay an employee wages as required by K.S.A. 44-314, and amendments thereto, or as required under subsection (a) of this section, such employer shall be liable to the employee for the wages due and also shall be liable to the employee for a penalty in the fixed amount of 1% of the unpaid wages for each day, except Sunday and legal holidays, upon which such failure continues after the eighth day after the day upon which payment is required or in an amount equal to 100% of the unpaid wages, whichever is less. For the purpose of such additional damages, the failure to pay shall not be deemed to continue after the date of the filing of a petition in bankruptcy with respect to the employer if he or she is adjudicated bankrupt upon such petition nor shall it be deemed to continue after an appeal is filed under K.S.A. 44-322a, and amendments thereto, until the decision on appeal becomes final.

56) Ky. Rev. Stat. § 337.385 - Employer's liability - Unpaid wages and liquidated damages - Punitive damages for forced labor or services

(1) Except as provided in subsection (3) of this section, any employer who pays any employee less than wages and overtime compensation to which such employee is entitled under or by virtue of KRS 337.020 to 337.285 shall be liable to such employee affected for the full amount of such wages and overtime compensation, less any amount actually paid to such employee by the employer,

관련 법률을 위반하지 않는다고 믿을 합리적인 근거들(reasonable grounds)이 있었음을 보이면, 법원은 그 재량으로 손해배상액의 예정을 인정하지 않거나 법이 정한 손해배상액의 예정액보다 적은 금액을 지급할 것을 선고할 수 있다.⁵⁷⁾ 만약, 사용자가 근로자를 관련 법률이 정의하는 강제노동을 시켰다고 판단하면, 법원은 (그 사용자가) 근로자에게 징벌적 배상(punitive damages)으로 미지급한 금액의 3배를 초과하는 금액(법원이 허용하는 변호사 보수를 포함한 소송비용도 포함한다)과 그에 대한 이자를 지급하게 하여야 한다.⁵⁸⁾

10) 메인(Maine)주

사용자는 미지급 급여 상당액에 대하여 근로자에게 책임이 있다. 근로자에 대한 이 절에 의한 미지급 급여 청구 사건에 관한 승소 판결이 있으면 그 판결은 미지급 급여에 더하여 합리적인 비율에 의한 이자, 합리적인 변호사 보수뿐 아니라 손해배상액의 예정으로 미지급 급여의 2배에 달하는 금액을 포함한다.⁵⁹⁾

11) 매사추세츠(Massachusetts)주

만약 사용자로부터 연장근로에 대한 비율에 의한 금원보다 적게 받은 자는 본인과 본인과 같은 상황에 있는 자를 위하여 연장근로수당 전액에서 사용자가 실제 지급한 금액을 제한 금

for an additional equal amount as liquidated damages, and for costs and such reasonable attorney's fees as may be allowed by the court.

57) Ky. Rev. Stat. § 337.385 - Employer's liability - Unpaid wages and liquidated damages - Punitive damages for forced labor or services

(2) If, in any action commenced to recover such unpaid wages or liquidated damages, the employer shows to the satisfaction of the court that the act or omission giving rise to such action was in good faith and that he or she had reasonable grounds for believing that his or her act or omission was not a violation of KRS 337.020 to 337.285, the court may, in its sound discretion, award no liquidated damages, or award any amount thereof not to exceed the amount specified in this section.(이하 생략)

58) Ky. Rev. Stat. § 337.385 - Employer's liability - Unpaid wages and liquidated damages - Punitive damages for forced labor or services

(3) If the court finds that the employer has subjected the employee to forced labor or services as defined in KRS 529.010, the court shall award the employee punitive damages not less than three(3) times the full amount of the wages and overtime compensation due, less any amount actually paid to such employee by the employer, and for costs and such reasonable attorney's fees as may be allowed by the court, including interest thereon.

59) Me. Stat. tit. 26 § 626-A - Penalties

Any employer is liable to the employee or employees for the amount of unpaid wages and health benefits. Upon a judgment being rendered in favor of any employee or employees, in any action brought to recover unpaid wages or health benefits under this subchapter, such judgment includes, in addition to the unpaid wages or health benefits adjudged to be due, a reasonable rate of interest, costs of suit including a reasonable attorney's fee, and an additional amount equal to twice the amount of unpaid wages as liquidated damages.

액을 소구할 수 있다.⁶⁰⁾ 만약, 근로자가 이러한 소를 승소하면 받지 못한 연장근로수당의 3배를 손해배상액의 예정으로 받을 수 있고, 합리적인 변호사 보수를 포함한 소송비용도 받을 수 있다.⁶¹⁾

12) 미네소타(Minnesota)주

근로자에게 법이 정한 임금이나 연장근로수당을 모두 지급하지 않은 사용자는 그 근로자에게 임금 또는 연장근로수당 총액에서 사용자가 실제 지급하였음을 보일 수 있는 금액을 제한 금액과 이에 더하여 같은 금액을 손해배상액의 예정으로 지급하여야 한다.⁶²⁾

13) 미주리(Missouri)주

근로자에게 법이 정하는 급여보다 적게 급여를 지급한 사용자는 그 근로자에게 급여액에 더하여 그 2배에 달하는 금액을 손해배상액의 예정으로 지급하여야 하되 실제 지급한 금액을 제한다(또한, 법원이나 배심이 정한 합리적인 변호사 보수를 포함한 소송비용을 지급하여야 한다).⁶³⁾ 연장근로수당은 원칙적으로 위 법률에 적용을 받는다.⁶⁴⁾

60) Mass. Gen. Laws ch. 151 § 1B - Overtime compensation; failure to pay; penalties; collection proceedings; unclaimed awards; deposit of funds

In addition, if a person is paid by an employer less than such overtime rate of compensation, the person may institute and prosecute in his own name and on his own behalf, or for himself and for others similarly situated, a civil action for injunctive relief, for any damages incurred, and for the full amount of the overtime rate of compensation less any amount actually paid to him by the employer.

61) Mass. Gen. Laws ch. 151 § 1B - Overtime compensation; failure to pay; penalties; collection proceedings; unclaimed awards; deposit of funds

An employee so aggrieved who prevails in such an action shall be awarded treble damages, as liquidated damages, for lost overtime compensation and shall also be awarded the costs of the litigation and reasonable attorneys fees.

62) Minnesota Statutes 2022 Section 177.27.

(8) employer who pays an employee less than the wages and overtime compensation to which the employee is entitled under sections 177.21 to 177.44 or a contractor that has assumed a subcontractor's liability as required by section 181.165, is liable to the employee for the full amount of the wages, gratuities, and overtime compensation, less any amount the employer or contractor is able to establish was actually paid to the employee and for an additional equal amount as liquidated damages.

63) Mo. Rev. Stat. § 290.527 - Action for underpayment of wages, employee may bring - limitation
Any employer who pays any employee less wages than the wages to which the employee is entitled under or by virtue of sections 290.500 to 290.530 shall be liable to the employee affected for the full amount of the wage rate and an additional amount equal to twice the unpaid wages as liquidated damages, less any amount actually paid to the employee by the employer and for costs and such reasonable attorney fees as may be allowed by the court or jury. The employee may bring any legal action necessary to collect the claim. Any agreement between the employee and the employer to work for less than the wage rate shall be no defense to the action. All actions

14) 몬타나(Montana)주

기한이 도래한 급여를 지급하지 않은 사용자는 근로자에게 벌(penalty)로 미지급 급여의 110%를 넘지 않는 금액을 지급하여야 한다.⁶⁵⁾

15) 노스캐롤라이나(North Carolina)주

최저임금 조항, 연장근로 조항, 급여지급 관련 조항을 위반한 사용자는 미지급한 급여나 연장근로수당 및 그에 대한 이자를 지급하여야 하고, 이에 더하여 법원은 손해배상액의 예정으로 위와 같은 금액을 지급하게 하여야 하되, 다만 사용자가 그 미지급 행위가 신의성실(good faith)에 의한 것이고 사용자가 관련 법률을 위반하지 않았다고 믿을 합리적인 근거들(reasonable grounds)이 있었음을 보일 경우 손해배상액의 예정을 인정하지 않거나 감액할 수 있다.⁶⁶⁾

16) 노스다코다(North Dakota)주

이 장(chapter)이 정한 미지급 급여를 받을 근로자의 권리에 더하여 근로자는 사용자로부터

for the collection of any deficiency in wages shall be commenced within three years of the accrual of the cause of action.

64) Mo. Rev. Stat. § 290.505 - Overtime compensation, applicable number of hours, exceptions

1. No employer shall employ any of his employees for a workweek longer than forty hours unless such employee receives compensation for his employment in excess of the hours above specified at a rate not less than one and one-half times the regular rate at which he is employed.(이하 생략)

65) Mont. Code § 39-3-206 - Penalty for failure to pay wages at times specified in law

(1) An employer who fails to pay an employee as provided in this part or who violates any other provision of this part is guilty of a misdemeanor. A penalty must also be assessed against and paid by the employer to the employee in an amount not to exceed 110% of the wages due and unpaid.

66) N.C. Gen. Stat. §95-25.22 - Recovery of unpaid wages

(a) Any employer who violates the provisions of G.S. 95-25.3(Minimum Wage), G.S. 95-25.4(Overtime), or G.S. 95-25.6 through 95-25.12(Wage Payment) shall be liable to the employee or employees affected in the amount of their unpaid minimum wages, their unpaid overtime compensation, or their unpaid amounts due under G.S. 95-25.6 through 95-25.12, as the case may be, plus interest at the legal rate set forth in G.S. 24-1, from the date each amount first came due.

(a1) In addition to the amounts awarded pursuant to subsection (a) of this section, the court shall award liquidated damages in an amount equal to the amount found to be due as provided in subsection (a) of this section, provided that if the employer shows to the satisfaction of the court that the act or omission constituting the violation was in good faith and that the employer had reasonable grounds for believing that the act or omission was not a violation of this Article, the court may, in its discretion, award no liquidated damages or may award any amount of liquidated damages not exceeding the amount found due as provided in subsection (a) of this section.

터 (1) 미지급 급여에 대한 이자를 받을 수 있고, (2) (a) 만약 급여지급기한이 도래한 날로부터 1년 전 이내에 그 사용자가 다른 일로 이 장(chapter)에 의한 2번의 임금청구에 대해 책임이 있다고 인정된 사실이 있으면 미지급 급여의 2배에 해당하는 금액을, (b) 만약 급여지급 기한이 도래한 날로부터 1년 전 이내에 그 사용자가 다른 일로 이 장(chapter)에 의한 3번 이상의 임금청구에 대해 책임이 있다고 인정된 사실이 있으면 미지급 급여의 3배에 해당하는 금액을 지급받을 수 있다.⁶⁷⁾

17) 오레곤(Oregon)주

성별에 따라 급여를 차등하는 것은 원칙적으로 위법하다.⁶⁸⁾ 위 법률에 반하는 급여를 받은 근로자는 사용자에게 (a) 소 제기 전 1년동안 그 근로자가 받았어야 할 미지급 급여에 더하여 (b) 손해배상액의 예정으로 위 (a)에 정한 금액과 같은 금액을 청구할 권리가 있다.⁶⁹⁾

67) N.D. Cent. Code § 34-14-09.1 - Interest on unpaid wages - Amount of recovery - Exception
In addition to the employee's right to recover unpaid wages as provided in this chapter, every employee is entitled to recover from the employer's employer:

1. Interest on the unpaid wages from the date the wages are due until payment is made in full at the rate as established by section 47-14-09; and
2. An amount equal to:
 - a. Double the employee's unpaid wages, if, within one year preceding the date such wages are due, the employer has, on separate occasions, been subject to, and found liable for, two previous wage claims under the provisions of this chapter; or
 - b. Treble the employee's unpaid wages, if, within one year preceding the date such wages are due, the employer has, on separate occasions, been subject to, and found liable for, three or more previous wage claims under the provisions of this chapter.(이하 생략)

68) ORS §652.220 - Prohibition of discriminatory wage rates based on sex; exceptions; employer not to discriminate against employee who is complainant

- (1) It is an unlawful employment practice under ORS chapter 659A for an employer to:
 - (a) In any manner discriminate between employees on the basis of a protected class in the payment of wages or other compensation for work of comparable character.
 - (b) Pay wages or other compensation to any employee at a rate greater than that at which the employer pays wages or other compensation to employees of a protected class for work of comparable character.(이하 생략)

69) ORS 652.230 - Employee right of action against employer for unpaid wages and damages; statute of limitations; notice requirement

- (1) Any employee whose compensation is at a rate that is in violation of ORS 652.220 shall have a right of action against the employer for the recovery of:
 - (a) The amount of the unpaid wages to which the employee is entitled for the one year period preceding the commencement of the action; and
 - (b) An additional amount as liquidated damages equal to the amount referred to in paragraph (a) of this subsection.

18) 사우스데코다(South Dakota)주

미지급 급여 청구 소송에서, 만약 사용자가 근로자에게 기한이 도래한 급여 지급을 억압적(oppressive)이거나, 기망(fraudulent)에 의하거나, 또는 해의(malicious)에 의해 거절한 것이라면, 그 손해배상액은 사용자에게 책임이 있는 미지급 급여의 2배이다.⁷⁰⁾

19) 위스콘신(Wisconsin)주

담당 부서가 조사와 화해 시도를 하기 전에 제기된 임금청구 사건에서 법원은 사용자가 근로자에게 미지급 급여에 더하여 그 미지급 급여의 50%를 넘지 않는 금액을 지급할 것을 명할 수 있고, 담당 부서가 조사와 화해 시도를 종결한 후에 제기된 임금청구 사건에서 법원은 사용자가 근로자에게 미지급 급여에 더하여 그 미지급 급여의 100%를 넘지 않는 금액을 지급할 것을 명할 수 있다.⁷¹⁾

나. 민사벌(과징금)

몇 주는 사용자에게 민사벌(civil fines)을 주정부에게 지급하게 하는 방법으로 제재를 하기도 한다.⁷²⁾

70) S.D. Codified Laws §60-11-7 - Liability of employer for double damages for breach of obligation to pay wages

In any action for the breach of an obligation to pay wages, if a private employer has been oppressive, fraudulent, or malicious, in the employer's refusal to pay wages due to the employee, the measure of damages is double the amount of wages for which the employer is liable.

71) Wis. Stat. §109.11 - Penalties

(2) CIVIL PENALTIES.

(a) In a wage claim action that is commenced by an employee before the department has completed its investigation under s. 109.09(1) and its attempts to compromise and settle the wage claim under sub. (1), a circuit court may order the employer to pay to the employee, in addition to the amount of wages due and unpaid and in addition to or in lieu of the criminal penalties specified in sub. (3), increased wages of not more than 50 percent of the amount of wages due and unpaid.

(b) In a wage claim action that is commenced after the department has completed its investigation under s. 109.09(1) and its attempts to settle and compromise the wage claim under sub. (1), a circuit court may order the employer to pay to the employee, in addition to the amount of wages due and unpaid to an employee and in addition to or in lieu of the criminal penalties specified in sub. (3), increased wages of not more than 100 percent of the amount of those wages due and unpaid.

72) Nicole Hallett, 앞의 글, 115면.

1) 아이오와(Iowa)주

사용자가 임금 지급에 관한 일정한 법률을 위반한 경우 각 급여지급 기간(per pay period) 당 위반행위별로(for each violation) 각 500미국 달러 이하의 민사벌에 처해진다. 민사벌은 주에 귀속된다.⁷³⁾

2) 뉴욕(New York)주

사용자가 근로자에게 급여를 지급하지 못하면 각 행위별로 500달러를 주에 납부하여야 한다.⁷⁴⁾ 만약, 사용자가 전에 급여지급에 관한 법령을 위반한 사실이 있거나, 사용자의 미지급 행위가 고의(willful)에 의한 것이거나 악하다고(egregious)로 판단되면 추가적인 민사별로 급여 등의 2배를 넘지 않는 돈을 납부하게 하여야 한다.⁷⁵⁾

3) 워싱턴(Washington)주

근로자가 노동산업부(department of labor and industries)⁷⁶⁾에 임금을 지급받지 못하였다고 신고 하면 노동산업부는 그에 관해 조사하여야 한다.⁷⁷⁾ 만약, 노동산업부가 급여를

73) Iowa Code § 91A.12 - Civil penalties

1. Any employer who violates the provisions of this chapter or the rules promulgated under it shall be subject to a civil money penalty of not more than five hundred dollars per pay period for each violation. The director may recover such civil money penalty according to the provisions of subsections 2 through 5. Any civil money penalty recovered shall be deposited in the general fund of the state.

74) N.Y. Lab. Law § 197 - Civil penalty

Any employer who fails to pay the wages of his employees or shall differentiate in rate of pay because of protected class status, as provided in this article, shall forfeit to the people of the state the sum of five hundred dollars for each such failure, to be recovered by the commissioner in any legal action necessary, including administrative action or a civil action.

75) N.Y. Lab. Law § 218 - Violations of certain provisions; civil penalties

1. In addition to directing payment of wages, benefits or wage supplements found to be due, and liquidated damages in the amount of one hundred percent of unpaid wages, such order, if issued to an employer who previously has been found in violation of those provisions, rules or regulations, or to an employer whose violation is willful or egregious, shall direct payment to the commissioner of an additional sum as a civil penalty in an amount not to exceed double the total amount of wages, benefits, or wage supplements found to be due.

76) Wash. Rev. Code § 49.48.082 - Wage complaints-Definitions

The definitions in this section apply throughout this section and RCW 49.48.083 through 49.48.086:

(2) "Department" means the department of labor and industries.

77) Wash. Rev. Code § 49.48.083 - Wage complaints-Duty of department to investigate-Citations and notices of assessment-Civil penalties

(1) If an employee files a wage complaint with the department, the department shall investigate the wage complaint.(이하 생략)

지급하지 않은 것이 고의적인 위반행위(willful violation)이라고 판단하면, 법률이 정한 일정한 예외에 해당하지 않는 한,⁷⁸⁾ 노동산업부는 적어도 (가) 1,000미국 달러와 (나) 미지급임금 총액의 10% 중 더 큰 금액(상한은 20,000미국 달러이다)을 민사별로 노동부에게 지급할 것으로 사용자에게 명할 수 있다.⁷⁹⁾ 단, 노동산업부는 사용자가 반복적 고의 위반자(repeat willful violator)⁸⁰⁾에 해당하지 않고, 사용자가 근로자에게 노동산업부가 미지급하였다고 인정한 임금 전액과 그에 대한 이자를 노동산업부의 통지 후 10일 이내에 지급하였다고 판단한 경우 민사벌을 면제하여야 한다.⁸¹⁾ 노동산업부의 장이 사용자가 모든 임금과 이자를 지급하였다고 판단하면 민사벌을 감경하거나 면제할 수 있다.⁸²⁾

78) Wash. Rev. Code § 49.48.083 - Wage complaints-Duty of department to investigate-Citations and notices of assessment-Civil penalties

(3) (b) The department may not assess a civil penalty if the employer reasonably relied on:

(i) A rule related to any wage payment requirement;

(ii) a written order, ruling, approval, opinion, advice, determination, or interpretation of the director; or

(iii) an interpretive or administrative policy issued by the department and filed with the office of the code reviser. In accordance with the department's retention schedule obligations under chapter 40.14 RCW, the department shall maintain a complete and accurate record of all written orders, rulings, approvals, opinions, advice, determinations, and interpretations for purposes of determining whether an employer is immune from civil penalties under (b)(ii) of this subsection.

79) Wash. Rev. Code § 49.48.083 - Wage complaints-Duty of department to investigate-Citations and notices of assessment-Civil penalties

(3) If the department determines that the violation of the wage payment requirement was a willful violation, the department also may order the employer to pay the department a civil penalty as specified in (a) of this subsection.

(a) A civil penalty for a willful violation of a wage payment requirement shall be not less than one thousand dollars or an amount equal to ten percent of the total amount of unpaid wages, whichever is greater. The maximum civil penalty for a willful violation of a wage payment requirement shall be twenty thousand dollars.

80) 반복적 고의 위반자는 가장 최근 위반 사실 통지가 있는 날 이전 3년 내에 고의로 임금을 체불하였다는 통지가 확정된 사실이 있는 사용자를 의미한다.

Wash. Rev. Code § 49.48.082 - Wage complaints-Definitions

The definitions in this section apply throughout this section and RCW 49.48.083 through 49.48.086:

(8) "Repeat willful violator" means any employer that has been the subject of a final and binding citation and notice of assessment for a willful violation of a wage payment requirement within three years of the date of issue of the most recent citation and notice of assessment for a willful violation of a wage payment requirement.

81) Wash. Rev. Code § 49.48.083 - Wage complaints-Duty of department to investigate-Citations and notices of assessment-Civil penalties

(3) (c) The department shall waive any civil penalty assessed against an employer under this section if the employer is not a repeat willful violator, and the director determines that the employer has provided payment to the employee of all wages that the department determined that the employer owed to the employee, including interest, within ten business days of the employer's receipt of the citation and notice of assessment from the department.

82) Wash. Rev. Code § 49.48.083 - Wage complaints-Duty of department to investigate-Citations and notices of assessment-Civil penalties

4) 캘리포니아(California)주

근로자에게 임금을 지급하지 못한 자는 (1) 최초로 위반한 경우 임금을 지급하지 못한 근로자 1인당 100미국 달러, (2) 최초가 아닌 위반 행위 또는 고의나 의도적으로 위반한 경우 임금을 지급하지 못한 근로자 1인당 200미국 달러에 위법하게 지급하지 않은 금액의 25%를 더한 금액을 민사별로 한다.⁸³⁾ 이 조항은 급여, 연장근로수당 및 다른 근로자에게 지급하기로 한 혜택을 포함한다.⁸⁴⁾

다. 형사벌

2011년 기준 미국의 30개주와 컬럼비아구(District of Columbia)에 임금절도에 대한 형사벌이 정해져 있다.⁸⁵⁾ 그러나 미국에서는 역사적으로 임금절도 등 근로자에 대한 범죄에 대한 공소제기가 되지 않았다고 평가받는다.⁸⁶⁾ 예를 들어, 한 연구는 로드아일랜드주 검찰총장(attorney general)은 2020년 임금절도 사건 3건에 대한 공소를 제기하였다고 소개하면서, 이 공소제기가 그 주에서 아마도 최초일 것이라고 평가하였다.⁸⁷⁾ 그러나 미국 각 주 검찰총장이나 주 검사들은 점점 적극적으로 임금절도를 포함한 사용자의 근로자에 대한 범죄행위에 대한 공소를 제기하고 있다.⁸⁸⁾ 한 언론은 미네소나 주는 2019년 처음으로 임금절도를 중범

(3) (d) The department may waive or reduce at any time a civil penalty assessed under this section if the director determines that the employer paid all wages and interest owed to an employee.

83) CA Lab Code Section 210

(a) In addition to, and entirely independent and apart from, any other penalty provided in this article, every person who fails to pay the wages of each employee as provided in Sections 201.3, 204, 204b, 204.1, 204.2, 205, 205.5, and 1197.5, shall be subject to a civil penalty as follows:

(1) For any initial violation, one hundred dollars(\$100) for each failure to pay each employee.

(2) For each subsequent violation, or any willful or intentional violation, two hundred dollars(\$200) for each failure to pay each employee, plus 25 percent of the amount unlawfully withheld.

84) Sirmabekian, Understanding the California Labor Code 210, Sirmabekian Law Firm,(2023), [https://www.slawla.com/understanding-the-california-labor-code-210/#:~:text=What%20Is%20The%20California%20Labor%20Code%2010%20According,if%20they%20don%E2%80%99t%20pay%20their%20employees%20on%20time.\(2023. 9. 28. 최종방문\).](https://www.slawla.com/understanding-the-california-labor-code-210/#:~:text=What%20Is%20The%20California%20Labor%20Code%2010%20According,if%20they%20don%E2%80%99t%20pay%20their%20employees%20on%20time.(2023. 9. 28. 최종방문).)

85) National Employment Law Project, 앞의 글, 35면. 알래스카주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 컬럼비아구, 조지아주, 하와이주, 일리노이주, 인디애나주, 메릴랜드주, 미시시피주, 미네소타주, 미주리주, 네브라스카주, 네바다주, 뉴햄프셔주, 뉴저지주, 뉴멕시코주, 뉴욕주, 노스캐로라이나주, 노스데코다주, 오하이오주, 로드아일랜드주, 사우스데코다주, 텍사스주, 유타주, 버지니아주, 워싱턴주, 웨스트버지니아주, 위스콘신주이다. National Employment Law Project, 위의 글, 35면.

86) Terri Gersten, How district attorneys and state attorneys general are fighting workplace abuses: An introduction to criminal prosecutions of wage theft and other employer crimes against workers, 1(Economic Policy Institute May 17, 2021).

87) Ibid. at 5면.

88) Ibid. at 3면. 다만, 이 보고서는 몇몇 주에 임금절도 등 사용자의 범죄행위에 대하여 공소가 제기된 사례들을 소개할 뿐이다. Ibid. at 3-5면. 그 외 체계적인 주별 통계는 찾을 수 없었다.

죄(felony)로 정의하였다면서, 최근까지 이를 전문으로 수사하는 전담 수사관이 2명 뿐이라고 보도하였다.⁸⁹⁾

다른 기사도 여러 주가 임금절도를 법률상 범죄로 취급하지만, 그에 대한 공소제기는 거의 이루어지지 않는다고 지적하였다.⁹⁰⁾ 한 기사는 일리노이주는 임금을 고의로 지급을 거절하는 것은 범죄로 정하고 있음에도 불구하고, 그 언론사가 시카고 지역 검찰청 데이터를 조사한 바에 2010년 이후 위 법률에 의한 공소제기는 단 한 건만 있었다고 보도하였다.⁹¹⁾ 또한, 뉴저지주는 2019년 근로자에게 임금을 지급하지 않는 사용자를 10일에서 100일의 징역형에 처할 수 있게 하는 법률을 입법하였으나, 뉴저지 노동부 대변인은 대부분의 사용자가 공소제기를 피하기 위하여 자발적으로 사건을 종결하였으므로 위 법률에 의한 공소제기를 한 사례가 없다고 하였다고 보도하였다.⁹²⁾

미국 주 중에는 임금절도를 범죄로 명시한 주들도 있지만, 어떤 주에서는 검사가 일반 절도죄에 관한 조항 등을 임금절도에 적용하여 공소를 제기한 경우도 있다.⁹³⁾ 이하에서는 명시적으로 임금에 관한 절도죄를 입법한 몇 개 주만 대표적으로 살핀다.

1) 알래스카주

연장근로수당⁹⁴⁾을 포함한 알래스카주 임금과 근로시간 법(Alaska Wage and Hour Act)의 각 조항과 그에 따른 시행령 등을 위반하여 유죄 판결을 받은 자는 100미국 달러 이상 2,000미국 달러 이하의 벌금형 또는 10일 이상 90일 이하의 구금형에 처하고, 위 형은 병과될 수 있다. 하루 위반할 때마다 별개의 1죄를 구성한다.⁹⁵⁾

89) Jonah Kaplan, "I was scared." How wage theft drains millions of dollars from Minnesota families ? and what's being done to stop it., CBS News Minnesota, (Jan. 24, 2023 6:00pm), [https://www.cbsnews.com/minnesota/news/i-was-scared-how-wage-theft-drains-millions-of-dollars-from-minnesota-families-and-whats-being-done-to-stop-it/\(2023. 9. 4. 최종방문\).](https://www.cbsnews.com/minnesota/news/i-was-scared-how-wage-theft-drains-millions-of-dollars-from-minnesota-families-and-whats-being-done-to-stop-it/(2023. 9. 4. 최종방문).)

90) Chris Hacker, Ash-har Quraishi, Amy Corral, & Ryan Beard, Wage theft often goes unpunished despite state systems meant to combat it, CBS News, (June 30, 2023 8:00AM), [https://www.cbsnews.com/news/owed-employers-face-little-accountability-for-wage-theft/\(2023. 9. 4. 최종방문\).](https://www.cbsnews.com/news/owed-employers-face-little-accountability-for-wage-theft/(2023. 9. 4. 최종방문).)

91) Ibid.

92) Ibid.

93) Gersten, 앞의 글, 14면.

94) Alaska Stat. § 23.10.060 - Payment for overtime

(a) An employer who employs employees engaged in commerce or other business, or in the production of goods or materials in the state, may not employ an employee for a workweek longer than 40 hours or for more than eight hours a day.

(b) If an employer finds it necessary to employ an employee for hours in excess of the limits set in this subsection, overtime compensation for the overtime at the rate of one and one-half times the regular rate of pay shall be paid. An employee is entitled to overtime compensation for hours worked in excess of eight hours a day.(이하 생략).

95) Alaska Stat. § 23.10.140 - Penalty

2) 캘리포니아주

고의로 급여명세를 제공에 관한 조항⁹⁶⁾을 위반한 사용자, 근로자에 대한 기한이 도래한 급여를 지급하거나 통제하거나 영수하거나 보관할 수 있는 임원, 대리인, 직원 등, 고의로 급여명세를 제공에 관한 조항을 위반하는 데 방조하는 자는 경범죄(misdemeanor)에 처하고, 유죄 판결이 선고될 경우 법원의 재량에 따라 1,000 미화 달러 이하의 벌금형 또는 1년을 넘지 않는 징역형에 처하고, 위 형은 병과될 수 있다. 위 벌금형, 징역형, 또는 벌금형과 징역형의 병과는 법이 정한 다른 형이 있다면 그에 병과된다.⁹⁷⁾

3) 콜로라도주

사용자나 사용자의 대리인이 본인 또는 다른 사람을 위해 그 채무를 줄이거나, 그 채무를 적게 지불하거나, 그 임금채권자를 성가시게 하거나, 괴롭히거나, 억압하거나, 방해하거나, 강요하거나, 임금 지급을 지연시키거나, 사기를 치려는 의도로 이 조 4항에 규정된 임금이나 보상의 지급을 고의로 거부하거나, 임금 청구 금액 또는 그 채권의 효력을 허위로 부인하거나, 그 기한의 도래를 부인하면 별도로 법이 정한 절도로 의율한다.⁹⁸⁾

4) 매사추세츠주

검찰총장은 임금 관련 법 위반에 대하여 형사소추를 할 수 있다.⁹⁹⁾ 형사 법정에서 임금 관

An employer who violates a provision of AS 23.10.050 - 23.10.150, or of any regulation or order of the commissioner issued under it, upon conviction is punishable by a fine of not less than \$100 nor more than \$2,000, or by imprisonment for not less than 10 nor more than 90 days, or by both. Each day a violation occurs constitutes a separate offense.

96) Cal. Lab. Code § 226 - Itemized statement of wages(이하 생략)

97) Cal. Lab. Code § 226.6 - Criminal penalty

Any employer who knowingly and intentionally violates the provisions of Section 226, or any officer, agent, employee, fiduciary, or other person who has the control, receipt, custody, or disposal of, or pays, the wages due any employee, and who knowingly and intentionally participates or aids in the violation of any provision of Section 226 is guilty of a misdemeanor and, upon conviction thereof, shall be fined not more than one thousand dollars(\$1,000) or be imprisoned not to exceed one year, or both, at the discretion of the court. That fine or imprisonment, or both, shall be in addition to any other penalty provided by law.

98) C.R.S. 8-4-114 - Criminal penalties.

(2) In addition to any other penalty imposed by this article 4, any employer or agent of an employer who willfully refuses to pay wages or compensation as provided in this article 4, or falsely denies the amount of a wage claim, or the validity thereof, or that the same is due, with intent to secure for himself, herself, or another person any discount upon such indebtedness or any underpayment of such indebtedness or with intent to annoy, harass, oppress, hinder, coerce, delay, or defraud the person to whom such indebtedness is due, commits theft as defined in section 18-4-401.

런 법을 위반하였다고 인정될 경우 각 건당 50,000미국 달러 상당의 벌금과 2년까지의 구금 형에 처해질 수 있다.¹⁰⁰⁾

5) 미네소타주

미네소타주는 관련 법을 개정하여 2019년부터 새로운 임금절도 법을 도입하였다.¹⁰¹⁾ 위 법은 특히 임금절도를 절도의 일종으로 정의하였고,¹⁰²⁾ 그 절도 금액이 35,000미국 달러를 초과할 경우 최대 20년 이하의 징역에 처할 수 있도록 하였다.¹⁰³⁾

3. 각 수단의 적용

가. 사적 집행(Private Enforcement) – 집단소송¹⁰⁴⁾을 중심으로

미국 연방법원에는 이미 10년 전부터 임금 관련 집단소송이 점점 많이 제기되는 경향이 있었고, 이는 법정 배상배액 제도가 있기 때문이라고 평가하기도 한다.¹⁰⁵⁾ 또 다른 실무가(임금

99) Mass.gov, Office of the Attorney General, The Attorney General's Fair Labor Division, Enforcement Authority, The Attorney General's Office Enforces Workplace Laws Both Civilly and Criminally, [https://www.mass.gov/info-details/enforcement-authority#:~:text=A%20civil%20citation%20orders%20an%20employer%20to%20pay,a%20violation%20and%20whether%20the%20offense%20is%20intentional.\(2023. 9. 28. 최종방문\).](https://www.mass.gov/info-details/enforcement-authority#:~:text=A%20civil%20citation%20orders%20an%20employer%20to%20pay,a%20violation%20and%20whether%20the%20offense%20is%20intentional.(2023. 9. 28. 최종방문).)

100) Ibid.

101) Department of Labor and Industry, Summary of Minnesota's new Wage Theft Law, https://www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/wage_theft_law_summary.pdf(2024. 1. 18. 최종방문).

102) Minnesota Legislature, Office of the Revisor of Statutes, Minnesota Session Laws - 2019, 1st Special Session, [https://www.revisor.mn.gov/laws/2019/1/Session+Law/Chapter/7/\(2024. 1. 18. 최종방문\).](https://www.revisor.mn.gov/laws/2019/1/Session+Law/Chapter/7/(2024. 1. 18. 최종방문).)

(13) "Wage theft" occurs when an employer with intent to defraud:

- (i) fails to pay an employee all wages, salary, gratuities, earnings, or commissions at the employee's rate or rates of pay or at the rate or rates required by law, including any applicable statute, regulation, rule, ordinance, government resolution or policy, contract, or other legal authority, whichever rate of pay is greater;
- (ii) directly or indirectly causes any employee to give a receipt for wages for a greater amount than that actually paid to the employee for services rendered;
- (iii) directly or indirectly demands or receives from any employee any rebate or refund from the wages owed the employee under contract of employment with the employer; or
- (iv) makes or attempts to make it appear in any manner that the wages paid to any employee were greater than the amount actually paid to the employee.

103) Department of Labor and Industry, Summary of Minnesota's new Wage Theft Law, https://www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/wage_theft_law_summary.pdf(2024. 1. 18. 최종방문).

104) 연방 민사소송규칙 제23조에 의한 Class Action을 집단소송으로 번역하기도 하나, 여기서는 연방 민사소송규칙 제23조에 의한 Class Action을 대표당사자소송으로 번역하고, 29 U.S.C. Section 216(b)에 의한 소송을 집합소송으로 번역하며, 집단소송은 이 둘을 포함하는 개념으로 사용한다.

사건을 주로 대리하는 로펌 변호사)는 대기업들이 전국적으로 사내 회사 경영을 표준화면서 전국적인 근로시간 기록 등 노무관리 방법이 연방 법률을 위반하였다고 주장하기 쉬워진 면도 있다고 한다.¹⁰⁶⁾ 즉, 과거에는 같은 기업 내라도 지역 별로 노무관리를 달리 하여 지역 별 근로자들을 하나의 집단으로 구성하기 어려웠으나, 원고 측이 전국적으로 노무관리가 표준화 되면서 기업 내 여러 지역에서 일하는 근로자들을 하나의 집단으로 하여 집단소송을 제기하기 쉬워졌다는 것이다.¹⁰⁷⁾

다른 실무가는 미지급 근로시간을 증명하는 방법에 관한 법리가 임금 청구를 하는 근로자에게 유리하다고 평가한다.¹⁰⁸⁾ 임금청구의 손해액은 미지급 근로시간과 시간당 급여액에 의하여 산정되고, 이 중 시간당 급여액에 대해서는 보통 다툼이 없다.¹⁰⁹⁾ 그런데, 미국 연방대 법원은 1946년 *Anderson v. Mt. Clemes Potter Co.* 사건에서 사용자가 근로시간에 대한 기록을 부정확하고 부적절하게 관리하였고, 이를 대체할 설득력이 있는 다른 자료도 제시하지 못하는 경우(“where the employer's records are inaccurate or inadequate and the employee cannot offer convincing substitutes”)에 근로자는 임금을 적절히 받지 못한 업무를 사실상 하였다는 것과 근로의 양과 정도를 적정하고 합리적인 추론이 가능한 정도로만 보일 수 있는 충분한 증거를 제시하면 근로자의 책임을 한 것이라 판시하였다.¹¹⁰⁾ 이때 사용자는 정확한 근로시간의 양을 증명할 증거를 제시하거나, 근로시간의 양을 합리적으로 추론할만한 근로자의 증거를 부정적으로 탄핵할 증거를 제출할 의무가 있게 된다.¹¹¹⁾ 만약, 사용자가 이러한 증거를 제출하지 못할 경우 법원은 대략적으로 산정한 손해배상액을 근로자에게 지급하게 할 수 있다.¹¹²⁾ 이 법리는 근로자가 일을 한 사실과 법률에 의한 급여를 지급받지 못한 사실은 인정될 것을 전제로 한다.¹¹³⁾ 즉, 손해가 있음은 확실하나, 사용자가 법률

105) Nicholas, 앞의 글, 9면.

106) William C. Martucci, Katherine R. Sinatra, & Gregory K. Wu, Understanding and Preparing for Today's Employment Class Action Environment, in *Strategies for Employment Class and Collective Actions*,(2012), 31면.

107) Ibid. at 31-32면.

108) William F. Allen, Defending Employers in Complex Wage and Hour Litigation, in *Strategies for Employment Class and Collective Actions*,(2012), 78면.

109) Ibid.

110) *Anderson v. Mt. Clemes Potter Co.*, 328 U.S. 680, 687(1946)(“In such a situation we hold that an employee has carried out his burden if he proves that he has in fact performed work for which he was improperly compensated and if he produces sufficient evidence to show the amount and extent of that work as a matter of just and reasonable inference.”).

111) Ibid. at 687-688면(“The burden then shifts to the employer to come forward with evidence of the precise amount of work performed or with evidence to negative the reasonableness of the inference to be drawn from the employee's evidence.”).

112) Ibid. at 688면(“If the employer fails to produce such evidence, the court may then award damages to the employee, even though the result be only approximate.”).

113) Ibid.(“But here we are assuming that the employee has proved that he has performed work and

을 위반하여 발생한 손해액이 불확실할 경우 적용된다.¹¹⁴⁾ 단, 임금 청구 집단소송은 어느 단계에 이르면 대체로 화해로 종결되므로,¹¹⁵⁾ 위 법리에 따라 원고가 승소 판결을 받을 수 있다는 의미라기보다는, 위 법리로 인하여 원고가 더 유리한 내용의 화해를 이끌어낼 수 있을 것이라는 의미인 것 같다.

근로자가 미지급 임금을 받기 위하여 집단소송을 제기하려면 연방 민사소송규칙 제23조이나 연방 법률 29 U.S.C. Section 216(b) 중 어느 하나 이상을 충족하여야 한다.¹¹⁶⁾ 원고는 하나의 사건에서 이 두 절차를 모두 사용하려 하기도 한다.¹¹⁷⁾ 각 절차에 대하여 하나씩 간단히 본다.

연방 민사소송규칙 제23조에 의한 대표당사자소송의 주요한 특징은 구성원이 집단의 일부가 되기 위한 별다른 행위를 하지 않아도 된다는 것이다.¹¹⁸⁾ 판사가 집단소송을 허가하면 구성원들은 그 사건의 존재를 알지 못하여도 그 집단의 구성원이 된다.¹¹⁹⁾

연방 민사소송규칙 제23조(a)는 모든 유형의 대표당사자소송이 집단소송 허가를 받기 위한 공통 요건을 정한다.¹²⁰⁾ 연방 민사소송규칙 제23조(a)는 집단의 구성원이 너무 많아 모든 구성원들의 공동소송이 실용적이지 않을 것, 집단의 구성원들에게 공통되는 법률상 쟁점들 또는 사실인정에 관한 쟁점들이 있을 것, 대표당사자들의 주장이나 방어방법이 그 집단의 구성원의 주장이나 방어방법으로 전형적일 것, 대표당사자들이 집단의 구성원들의 이익을 공정하고 적절하게 방어할 수 있을 것이라는 각 요건을 모두 갖추어야 대표당사자소송을 제기할 수 있다고 규정한다.¹²¹⁾

위 각 요건을 모두 충족하는 것은 대표당사자소송을 유지할 필요조건이지만 충분조건은 아니다.¹²²⁾ 미국 연방대법원은 금전 청구를 구하는 대표당사자소송은 제23조(b)(3)의 적용을 받아야 한다고 판시하였으므로,¹²³⁾ 금전적 청구를 주된 청구로 하는 대표당사자소송을 수행

has not been paid in accordance with the statute.”).

114) Ibid. (“The damage is therefore certain. The uncertainty lies only in the amount of damages arising from the statutory violation by the employer.”).

115) Amy K. Jensen, Effective Counseling and Defending Employers in Increasing Wage and Hour Class Action, in Strategies for Employment Class and Collective Actions, (2012), 112면.

116) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, iii면.

117) Jill S. Kirila, Defense Strategies in Hybrid Wage and Hour Class Action Litigation, in Strategies for Employment Class and Collective Actions, (2012), 61면.

118) Jay Tidmarsh & Roger H. Trangsrud, Complex Litigation and Its Alternatives 139(2018).

119) Ibid.

120) Ibid. at 144면.

121) 이준범, 증권관련집단소송 사건 중 집단소송허가절차에 관한 한국과 미국 법리 비교연구 - 사건연구를 중심으로 -, 민사소송 제26권 2호, 2022, 327면.

122) 이준범, 위의 글, 327-328면.

123) Wal-Mart v. Dukes, 564 U.S. 338, 362(2011).

하기 위해서는 연방 민사소송규칙 제23조(b)(3)도 충족할 것을 요한다.¹²⁴⁾ 연방 민사소송규칙 제23조(b)(3)는 법원이 집단의 구성원들에게 공통되는 법률상 쟁점들이나 사실인정에 관한 쟁점들이 개별 구성원들에게만 영향을 주는 쟁점들을 압도하고, 집단소송이 다른 방법에 비하여 사건을 공정하고 효율적으로 해결하는 데 우월하다고 판단할 것을 요한다.¹²⁵⁾ 제23조(b)(3)가 이러한 요건을 두는 이유는 각 사건을 수행하기 위하여 발생하는 거래비용(transactions costs)만 없었다면 개별적으로 진행할 수도 있는 사건을 보다 효율적으로 해결하고자 하기 때문이다.¹²⁶⁾

29 U.S.C. Section 216(b)에 의하면 연방 근로기준법(Federal Labor Standard Act)이 정한 최저임금 위반이나 연장근로수당 미지급으로 인한 미지급 임금 청구를 하는 근로자는 본인과 같은 처지에 있는 근로자들을 위하여 소송을 제기할 수 있으나, 이 경우 그 같은 처지에 있는 근로자들의 서면에 의한 동의가 소송이 계속 중인 법원에 접수되어야 그 근로자들이 당사자 원고가 될 수 있다.¹²⁷⁾ 연방대법원은 1989년 Hoffmann-La Roche v. Sperling 사건에서 집합소송에 관한 적절한 사건에서 법원이 잠재적 원고에게 통지를 하는 것을 촉진할 재량이 있다고 하였다.¹²⁸⁾ 실무상 법원은 피고로부터 관련된 근로자들의 명단을 받아 집합소송에 가담할 것인지 연락할 수 있게 원고에게 줄 권한이 있다는 것으로 해석한다.¹²⁹⁾

법원은 같은 처지에 있는지 여부를 판단하는 기준으로 보통 조건부 허가 단계(conditioned certification process)와 (잠재적인) 불허 단계(potential decertification process)로 이루어진 2단계로 운영한다.¹³⁰⁾ 법원은 디스커버리(discovery)¹³¹⁾를 하기도 전에 단체소송으

124) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, iv면.

125) 이준범, 앞의 글, 328면.

126) Samuel Issacharoff, Civil Procedure 98(2022).

127) 29 U.S. Code § 216 – Penalties

(b) Damages; right of action; attorney's fees and costs; termination of right of action

.... An action to recover the liability prescribed in the preceding sentences may be maintained against any employer(including a public agency) in any Federal or State court of competent jurisdiction by any one or more employees for and in behalf of himself or themselves and other employees similarly situated. No employee shall be a party plaintiff to any such action unless he gives his consent in writing to become such a party and such consent is filed in the court in which such action is brought.

128) Hoffmann-La Roche v. Sperling, 493 U.S. 165, 169(1989)(“We hold that district courts have discretion, in appropriate cases, to implement 29 U.S.C. § 216(b)(1982 ed.), as incorporated by 29 U.S.C. § 626(b)(1982 ed.), in ADEA actions by facilitating notice to potential plaintiffs.”).

129) Alisha Jarwala, Collective Action Notice Requirements: The Next Hurdle in the Arbitration Fight, Onlabor,(2020. 4. 30.), <https://onlabor.org/collective-action-notice-requirements-the-next-hurdle-in-the-arbitration-fight/>(2023. 9. 9 최종방문).

130) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, v면.

131) 디스커버리는 미국 연방 민사소송규칙에 의한 증거를 포함한 자료 수집 및 조사 절차를 말한다. 미국 증권소송 관련 분야에 대한 집단소송에서의 디스커버리 법리 및 실무에 관한 설명으로, 이준범, 증권관련 집단소송에서 디스커버리의 인적 적용 범위에 관한 연구, 저스티스 통권 제197호, 2023, 125-137면.

로 진행하는 것을 조건부로 허가한 후 잠재적 원고들에게 통지를 하는 것을 허가하곤 한다.¹³²⁾ 이에 따라 조건부 허가를 하는 법원의 기준이 상대적으로 낮다는 평가를 받는다.¹³³⁾

두 번째 단계는 피고 측이 집단을 불허해 달라는 신청에 대하여 판단하는 것이다.¹³⁴⁾ 피고 측은 디스커버리 절차가 끝나기 전에 불허 신청을 할 수 있다.¹³⁵⁾ 통상 피고 측은 디스커버리가 거의 끝나갈 때 또는 끝난 후 불허 신청을 한다.¹³⁶⁾ 법원은 그 후 디스커버리를 진행한 후 그 결과를 토대로 근로자들이 같은 처지에 있었는지 심사하여 그렇지 않다고 판단되면 허가를 취소하고 단체소송을 불허한다.¹³⁷⁾ 이때 법원은 상대적으로 더 엄격한 심사기준에 의하여 판단한다고 평가된다.¹³⁸⁾ 만약, 법원이 불허신청을 기각하면 사건은 집단소송이 허가된 상태로 계속 진행되고, 인용하면 집단이 아닌 원고 개인의 사건으로 진행할 수 있다.¹³⁹⁾

대표당사자소송과 집합소송의 큰 차이는 대표당사자소송은 허가가 있으면 구성원이 적극적으로 가입하지 않아도 효력이 미치고, 그 효력을 벗어나고자 하는 구성원은 적극적으로 제외신고(opt-out)를 하여야 하지만, 집합소송의 경우 집합소송 허가의 효력을 받고자 하는 자는 적극적으로 적용신고(opt-in)를 하여야 한다는 것이다.¹⁴⁰⁾ 이에 따라 대표당사자소송의 경우 허가가 있으면 구성원의 거의 100%에게 그 효력이 미치지만, 집합소송이 허가되어도 적용신고를 하는 근로자 비율은 대체로 5%에서 40% 정도라고 한다.¹⁴¹⁾

집합소송에서 피고 측 소송대리인은 적용신고를 한 근로자들에 소송에 관한 연락을 하면 안된다.¹⁴²⁾ 왜냐하면 그들은 원고 측 소송대리인에 의한 대리를 받기 때문이다.¹⁴³⁾ 그러나 대표당사자소송의 구성원 중 적용신고나 제외신고를 하지 않은 구성원은 통상 집단소송허가가 있을 때까지는 원고 측 소송대리인의 대리를 받는 것으로 인정되지 않는다.¹⁴⁴⁾

위에서 본 바와 같은 절차에 따라 근로자들은 미국 연방법원에 미국 연방 근로기준법에 의한 최저급 급여를 구하는 집단소송을 다수 제기한다. 아래 [그림 2-1]은 2015년부터 2021년까지 사이 연방법원에 제기된 임금 관련 집단소송 사건 수를 나타낸다. 2015년 8,954건으로

132) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, v면.

133) Martucci, Sinatra, & Wu, 앞의 글, 31면.

134) Ibid. at 37면.

135) Ibid.

136) Ibid.

137) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, v면. 단체소송에 관한 더 자세한 법리에 대한 설명은 이 연구의 범위를 벗어난다.

138) Martucci, Sinatra, & Wu, 앞의 글, 37면.

139) Ibid.

140) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, vi면.

141) Ibid.

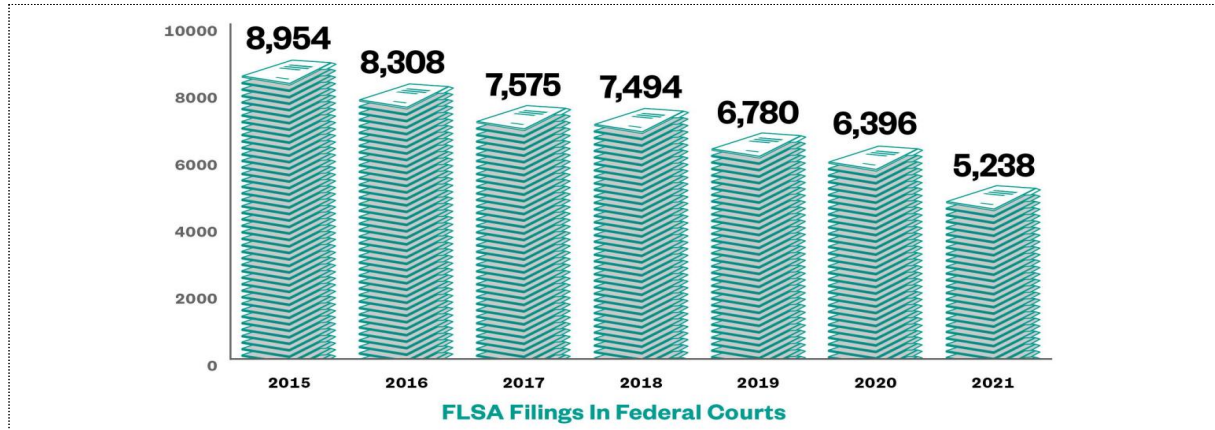
142) Kirila, 앞의 글, 61면.

143) Ibid.

144) Ibid. at 61-62면.

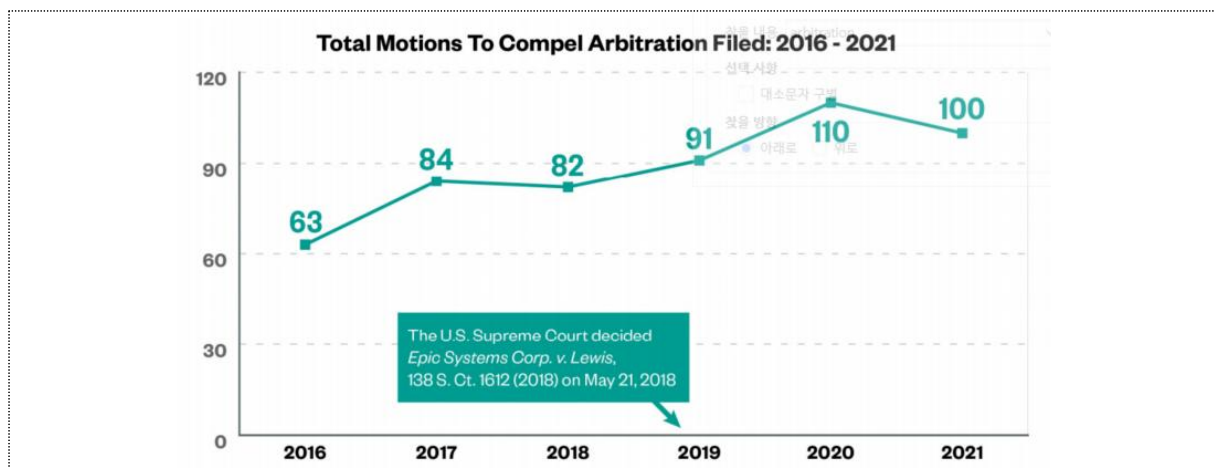
부터 2021년 5,238건까지 매년 줄어드는 추세를 보이고 있으나 그래도 매년 수천 건이 제기되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-1] 연도별 연방법원 임금 관련 집단소송 사건 접수 건



집단소송 제기 건수가 줄어드는 이유는 아마도 최근 미국 연방대법원이 근로자와 사용자 사이에 중재 합의를 하는 것을 허용하는 내용의 결정을 선고한 후 사용자들이 근로계약 중에 위와 같은 중재 합의를 넣어 집단소송을 제기하는 것을 제한하려 하기 때문인 것 같다. 미국 연방대법원이 2018년 EPIC Sys. Corp. v. Lewis 사건에서 집단소송이나 집단중재(class arbitration)를 못하게 하는 효과를 가져오는 개별적 중재를 강제하는 중재 조항의 효력을 재확인한 후,¹⁴⁵⁾ 많은 사용자들이 근로계약 등 근로자 측과의 계약에 강제적 중재조항을 포함하였다.¹⁴⁶⁾ 이에 따라 사용자들은 아래 [그림 2-2]에서 나타나는 바와 같이 점점 적극적으로 집단소송이 제기된 사건에 대하여 중재로 진행할 것을 신청하고 있다.

[그림 2-2] 연도별 중재신청 건

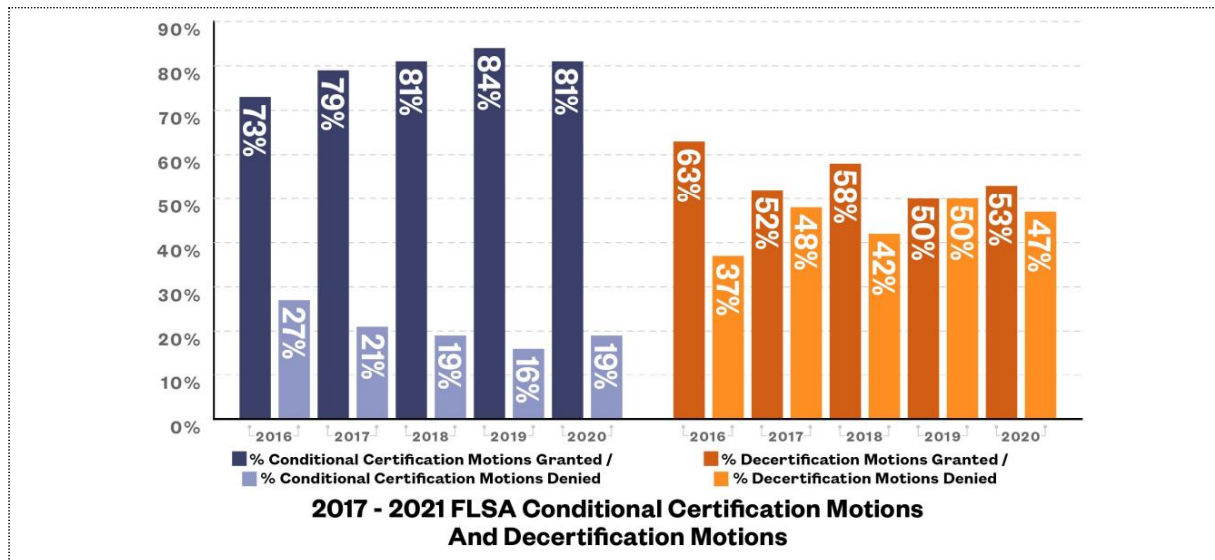


145) EPIC Sys. Corp. v. Lewis, 138 S.Ct. 1612, 1632(2018).

146) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, 3면.

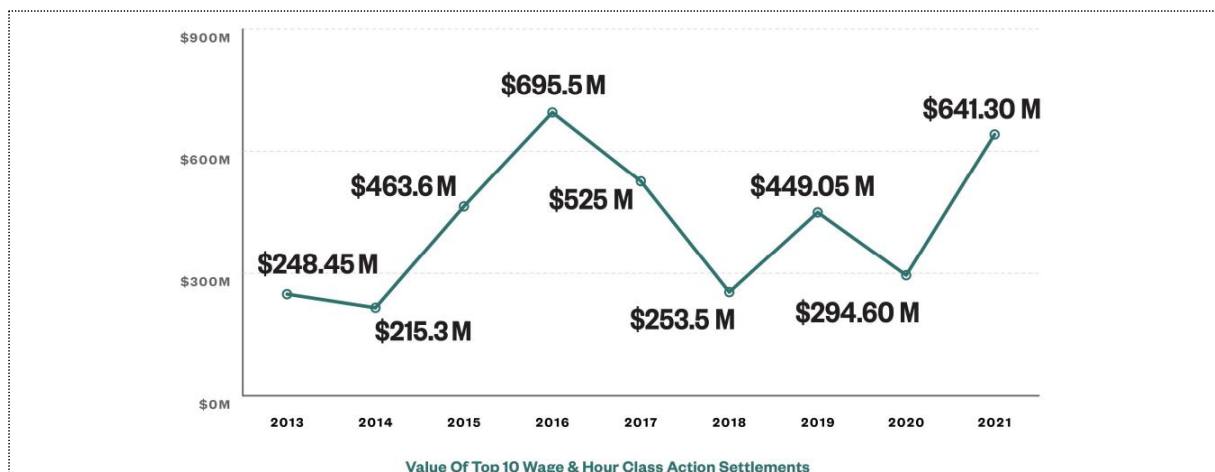
근로자가 제기하는 집단소송 사건에 대하여 연방법원은 높은 비율로 집단소송을 허가하고 있다. 아래 [그림 2-3]은 2016년부터 2020년까지 사이 연방법원에 제기된 임금 관련 집단소송 중 집단소송 허가 여부 비율을 나타낸다. 아래에서 보는 바와 같이 매년 70% 이상의 사건에 대하여 집단소송 허가가 이루어지고 있다. 집단소송 허가 비율이 높다는 것을 아는 원고 내지 원고 측 변호사는 적극적으로 소를 제기할 유인이 있을 것이다.

[그림 2-3] 연도별 단체소송 허가/불허 비율 및 단체허가 신청 허가/불허 비율



또한, 근로자들은 집단소송을 통하여 상당한 금원을 받고 있다. 허가가 된 집단소송은 대체로 화해로 종결되는 경우가 많은데, 그 금액은 상당하다. 아래 [그림 2-4]는 2013년부터 2021년까지 사이 연방법원에 제기된 임금 관련 집단소송 중 화해로 종결된 화해금이 높은 10건의 화해금 합계를 나타낸 것이다. 적게는 2014년 미화 215.3백만 달러, 많게는 2016년 미화 695.5백만 달러에 달한다.

[그림 2-4] 연도별 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 총액



위와 같이 화해에 이른 임금 관련 집단소송 사건들의 내용을 이해하기 위하여 2020, 2021년 화해에 이른 화해금액 기준 상위 10건의 주장 내용을 정리하면 아래 <표 2-2>, <표 2-3>과 같다. 각 사건은 연장근로수당을 지급하지 않았다는 주장, 근로시간 중 일부를 인정하지 않아 임금을 일부 미지급하였다는 주장, 근로자를 개인사업자로 분류하는 방법으로 급여 일부를 지급하지 않았다는 주장 등 다양하다.

<표 2-2> 2021년도 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 내용¹⁴⁷⁾

순번	사건명	금액	원고 측 주장 내용
1	Mercier, et al. v. United States, Case No. 12-CV-920(Fed. Cl. Nov. 3, 2021)	\$160 million	간호사들에 대한 연장근로수당을 미지급하였다는 주장
2	ABM Industries Overtime Cases, Case No. CJC-07-004502(Cal. Super. Ct. July 9, 2021)	\$140 million	회사가 근로시간을 적절히 관리하지 않아 근로자들에 대한 임금을 일부 지급하지 않았다는 주장
3	Marko, et al. v. DoorDash, Case No. BC659841(Cal. Super. Ct. Dec. 22, 2021)	\$100 million	운전 근로자들을 개인사업자로 오분류하여 급여를 일부 미지급하였다는 주장
4	Kang, et al. v. Wells Fargo Bank, N.A., Case No. 17-CV-6220(N.D. Cal. Dec. 8, 2021)	\$95 million	회사가 근로자들에 대하여 시간당 급여, 휴가수당, 판매 수수료 등을 적절히 지급하지 않았다는 주장
5	Roberts, et al. v. The TJX Co., Inc., Case No. 13-CV-13142(D. Mass. Jan. 5, 2021)	\$31.5 million	매니저보들을 잘못 분류하여 연장근로수당을 미지급하였다는 주장
6	Alvarez, et al. v. XPO Logistics Cartage, LLC, Case No. 18-CV-3736(N.D. Cal. Oct. 8, 2021)	\$30 million	운전 근로자들을 개인사업자로 오분류하여 급여를 일부 미지급하였다는 주장
7	Frelkein, et al. v. Apple Inc., Case No. 13-CV-3451(N.D. Cal. Dec. 17, 2021)	\$30 million	근로자들이 근로시간이 끝난 후 가방 확인을 하기 위해 기다린 시간에 대한 대가를 지급하지 않았다는 주장
8	In Re JCK Legacy Co., Bankr. Case No. 20-BK-10418(S.D.N.Y. April 7, 2021)	\$22 million	신문 배달 근로자를 개인사업자로 오분류하여 급여를 일부 미지급하였다는 주장
9	Kinthead, et al. v. Humana, Inc., Case No. 15-CV-1637(D. Conn. March 26, 2021)	\$17 million	출장 건강 관련 근로자들(home healthcare workers)에 대하여 연장근로수당을 미지급하였다는 주장
10	Fleming, et al. v. Matco Tools Corp., Case No. 19-CV-463(N.D. Cal. Dec. 13, 2021)	\$15.8 million	근로자를 개인사업자로 오분류하여 급여를 일부 미지급하였다는 주장

147) Ibid. at 35-36.

〈표 2-3〉 2020년도 임금 관련 집단소송 사건 최다 화해금액 10건 내용¹⁴⁸⁾

순번	사건명	금액	원고 주장 내용
1	Helmick, et al. v. Air Methods Corp., Case No. RG-13665373(Cal. Super. Ct. July 1, 2020)	\$78 million	연장근로수당 등 미지급하였다는 주장
2	Merino, et al. v. Wells Fargo & Co., Case No. 16-CV-7840(D.N.J. Jan. 15, 2020)	\$35 million	38,000여 은행 소속 근로자들에 대한 연장근로수당 미지급하였다는 주장
3	Roberts, et al. v. The TJX Companies Inc., Case No. 13-CV-13142(D. Mass. July 27, 2020)	\$31.5 million	1,911명의 전·현직 상점 관리자보 (assistant store manager)들에 대한 연장근로수당을 미지급하였다는 주장
4	Oliveira, et al. v. New Prime Inc., Case No. 15-CV-10603(D. Mass. July 23, 2020)	\$28 million	수 천 명의 운전 근로자들의 근로시간 중 일부에 대한 급여를 미지급하였다는 주장
5	Worley, et al. v. City of New York, Case No. 17-CV-4337(S.D.N.Y. June 8, 2020)	\$28 million	안전관리자(safety agent)들이 임금과 연장근로수당을 일부 미지급 받았다는 주장
6	Lacher, et al. v. Aramack Corp., Case No. 19-CV-687(E.D. Pa. June 10, 2020)	\$21 million	매니저들에게 보장한 보너스 미지급하였다는 주장
7	Goodman, et al. v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., Case No. 11-CV-4395(D.N.J. Aug. 26, 2020)	\$20 million	상점 관리자보(assistant store manager)에 대한 연장근로수당 미지급하였다는 주장
8	Gradie, et al. v. C.R. England, Inc., Case No. 16-CV-0768(D. Utah Nov. 20, 2020)	\$18.6 million	운전 노동자들에 대해 음식료 및 휴게 시간에 관한 수당 등 미지급하였다는 주장
9	Negrete, et al. v. Conagra Foods, Inc., Case No. 16-CV-631(C.D. Cal. Nov. 16, 2020)	\$18 million	전·현직 근로자들의 휴게 시간에 대한 수당과 연장근로수당 미지급하였다는 주장
10	Browne, et al. v. PAM Transport Inc., Case No. 16-CV-5366(W.D. Ark. July 31, 2020)	\$16.5 million	트럭 운전 근로자들에 대한 일부 임금 미지급하였다는 주장

그러나 이러한 집단소송의 경우 원고 측 변호사가 성공보수를 목적으로 제기하는 사건이 대부분으로 이러한 사건은 피고가 충분한 자산이 있는 경우에 근로자에 대한 실질적 배상을 하는 효과와 피고의 임금체불을 억제하는 효과가 있을 것이다. 이와 달리 원고 측 변호사가 집단소송을 통해 성공보수를 받을 것을 기대하기 어려운 사용자들—소규모의 적용 인원을 고용한 사용자들이 대체로 여기에 해당할 것 같은데—에 대해서는 정부의 집행 노력을 주로 검토해야 한다.

148) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2021 Edition, 34-35면.

나. 연방 정부

미국 연방노동부(U.S. Department of Labor)의 임금 및 근로시간국(Wage and Hour Division)은 연방 근로기준법을 집행하는 역할을 한다.¹⁴⁹⁾ 근로자가 미지급 임금 신고를 하면 임금 및 근로시간국은 이에 대하여 조사하여 만약 위반 사실을 증명할 증거가 충분하다고 판단하면 사용자와 미지급 급여를 지급할 것을 협의한다.¹⁵⁰⁾ 만약, 사용자가 이에 따르겠다고 하면 임금 및 근로시간국은 그 지급을 감독한다.¹⁵¹⁾ 그러나 사용자가 이를 따르는 것을 거부하면 미국 연방노동부는 사용자를 상대로 소를 제기할 수 있다.¹⁵²⁾ 미국 연방노동부가 소를 제기하면 근로자는 같은 소를 제기할 수 없으나, 미국 연방노동부는 소를 제기하지 않는 대신 근로자에게 그 조사 결과와 근로자가 사적으로 소를 제기할 수 있음을 안내할 수 있다.¹⁵³⁾

미국 연방노동부는 2005년부터 2023년 현재까지 약 18년 동안의 연방 근로기준법 위반 등 임금 및 근로시간 관련 연방법 위반이 문제된 사건들 중 종결된 사건들에 관한 데이터를 웹사이트에 공개하고 있다.¹⁵⁴⁾ 사건번호 기준으로 그 사건 수는 약 34만 건에 달한다. 그러나 그 원자료는 어떤 법률 위반인지를 표할 뿐 그 구체적인 체불 유형을 정확히 구별해주지 않고 있어 위 사건들 중 어느 정도가 임금을 전액 체불한 것인지 파악하기는 어렵다.

한 연구는 2020년 미국 연방노동부가 2017년부터 2020년 사이에 회수한 미지급 임금을 조사하였다. 이를 표로 나타낸 [그림 2-5]에 의하면 미국 연방노동부는 회계 연도 기준 2017년에¹⁵⁵⁾ 미화 270,403,906달러, 2018년에 미화 304,914,114달러, 2019년에 미화 322,490,774달러, 2020년에 257,829,604달러 합계 미화 1,155,638,398달러를 회수하였다고 보고하였다. 이는 근로자당 평균 2017년 미화 1,124달러, 2018년 미화 1,151달러, 2019년 미화 1,027달러, 2020년 미화 1,121달러를 회수한 것에 해당한다.

149) Elizabeth Ford, Wage Recovery Funds, 110 Cal. L. Rev. 1503, 1512(2022).

150) Ibid.

151) Ibid.

152) Ibid.

153) Ibid.

154) U.S. Department of Labor, Data Enforcement, Data Catalog, Wage and Hour Compliance Action Data, https://enforcedata.dol.gov/views/data_summary.php(2023. 9. 4. 최종방문).

155) 미국 연방 정부의 회계 연도는 10월 1일부터 9월 30일까지이다.

[그림 2-5] 연도별 미국 연방노동부 회수 임금 총액 및 근로자당 임금액

Back wages recovered by the U.S. Department of Labor, fiscal years 2017–2020					
	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	Total
Back wages	\$270,403,906	\$304,914,114	\$322,490,774	\$257,829,604	\$1,155,638,398
Employees receiving back wages	240,608	265,027	313,941	229,934	1,049,510
Average amount recovered per worker	\$1,124	\$1,151	\$1,027	\$1,121	\$1,101

Source: EPI analysis of U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division (WHD) enforcement database, 2021.

Economic Policy Institute

그러나 이 연구는 위 금액이 미국 연방의 모든 미지급 임금을 회수한 것이 아님을 강조하면서 많은 근로자들 다수는 미지급 임금 회수 신청을 하지 않는다고 하였다.¹⁵⁶⁾ 미국 연방노동부는 2019년에 비하여 20% 정도 적은 임금을 회수하였다고 보고하였다.¹⁵⁷⁾

미국 연방노동부는 미지급 임금에 대한 이자에 해당하는 손해배상액의 예정과 민사벌을 구할 수 있으나 이를 잘 하지 않는다.¹⁵⁸⁾ 한 연구는 임금 및 근로시간국이 2003년부터 2008년까지 사이에 손해배상액 예정을 구한 사건이 없다고 보고하였고,¹⁵⁹⁾ 1998년부터 2008년 사이에 민사벌이 검토된 것이 3% 미만이라고 하였다.¹⁶⁰⁾ 그러나 반복적으로 법을 위반한 사용자에 대하여도 약 43%에 대해서만 민사벌이 검토되었고, 그중에서도 61%만 부과되었다.¹⁶¹⁾

미국 연방노동부는 2013년경 손해배상 예정액을 보다 적극적으로 집행하기 시작하였으나, 2020년 트럼프 대통령 행정부는 손해배상 예정액을 구하는 사건이 원금만 구하는 사건보다 약 28% 시간이 더 걸린다는 이유 등을 근거로 손해배상 예정액 상당을 구하지 않기로 하였다.¹⁶²⁾ 이후 바이든 행정부는 다시 손해배상 예정액 상당을 일정한 경우 구하기로 하였다.¹⁶³⁾

156) Ibid. at 4면.

157) Ibid.

158) Ford, 앞의 글, 1513면.

159) David Weil, Improving Workplace Conditions Through Strategic Enforcement: A Report to the Wage and Hour Division 13(2010).

160) Ibid. at 14면. 다만, 그 이유는 민사벌은 사용자가 반복적이거나 고의로 법을 위반하였을 경우에 부과될 수 있는데, 위 기간 중 조사된 사건 중 다수 사건에서 사용자는 최초로 법을 위반한 사실을 고려하여야 한다. Ibid.

161) Ibid.

162) Ford, 앞의 글, 1513면.

163) Ibid.

한편, 미국 연방노동부는 사용자에게 감사(audit)을 하기도 하였다.¹⁶⁴⁾ 감사를 시작하면 미국 연방노동부는 과거 3년치 급여기록, 근로시간기록부(timesheets)를 포함하여 임금 관련 법률을 지키고 있음을 확인할 수 있는 자료를 조사한다.¹⁶⁵⁾ 이러한 감사는 오바마 정부 당시에 더 많아졌다는 평가가 있다.¹⁶⁶⁾

다. 주 정부

주 정부는 각 임금절도에 관한 데이터를 수집하는 방식이 다르기 때문에 주 사이의 비교를 목적으로 한 연구나, 주들의 데이터를 단순 합산한 통계를 목적으로 한 연구는 유의미하게 수행되기 어렵다.¹⁶⁷⁾ 한 언론사는 미국 대부분의 주 노동부(state labor department)에 정보 공개 청구를 하여 약 650,000건의 임금체불 신청 사건의 데이터베이스를 만들었다.¹⁶⁸⁾ 그중 약 절반 정도의 사건에서 주 정부는 근로자의 체불 사실을 인정하였다.¹⁶⁹⁾ 위와 같이 수집한 데이터에 의하면 체불임금액의 평균은 약 1,000 미화 달러(\$ 1,000)에 미달한다고 보도하였다.¹⁷⁰⁾ 그리고 근로자가 이긴 사건 중 약 1/3에 대해서는 실제 돈을 받았다는 정보가 존재하지 않았다고 보도하였다.¹⁷¹⁾

164) Nicholas, 앞의 글, 17면.

165) Ibid.

166) Ibid.

167) 각 주의 임금절도 통계를 비교하기 어렵다는 언론의 지적으로, Max Siegelbaum, 127,000 New York Workers Have Been Victims of Wage Theft, Documented, (Aug 22, 2023), <https://documentedny.com/2023/08/22/wage-theft-restaurants-new-york-nyc/> (2023. 9. 4. 최종방문). 또한, 플로리다 주 등 어떤 주 정부 차원의 미지급 임금을 담당하는 부서가 없고, 카운티 차원에 있는 경우도 있다. Joan Murray, Are you getting paid? Wage theft not uncommon in South Florida, CBS News Miami, (2023. 1. 24. 11:18 PM), <https://www.cbsnews.com/miami/news/are-you-getting-paid-wage-theft-not-uncommon-in-south-florida/> (2023. 9. 4. 최종방문). 위 언론은 플로리다 주 마이마이-데이드(Miami-Dade) 카운티의 경우 2018년부터 2019년 사이에 1,503건의 미지급 임금 청구 사건이 있었고, 브로워드(Broward) 카운티의 경우 2020년부터 2022년 사이에 179명의 근로자가 미지급 임금 청구를 하였다고 보도하였다. Joan Murray, Are you getting paid? Wage theft not uncommon in South Florida, CBS News Miami, (2023. 1. 24. 11:18 PM), <https://www.cbsnews.com/miami/news/are-you-getting-paid-wage-theft-not-uncommon-in-south-florida/> (2023. 9. 4. 최종방문).

168) Chris Hacker, Ash-har Quraishi, Amy Corral, & Ryan Beard, Wage theft often goes unpunished despite state systems meant to combat it, CBS News, (June 30, 2023 8:00AM), <https://www.cbsnews.com/news/owed-employers-face-little-accountability-for-wage-theft/> (2023. 9. 4. 최종방문).

169) Ibid.

170) Ibid.

171) Ibid.

1) 캘리포니아주

한 보도에 의하면 2017년 캘리포니아주에서 임금 청구 사건에 대하여 법원의 판결이 선고된 사건들에 대하여 5년 후 약 1/7에서만 근로자에게 임금이 전액 지급되었다고 캘리포니아주 담당 부서가 밝혔다고 한다.¹⁷²⁾ 또한, 임금 청구 사건은 너무 적체되어 임금체불 신고가 화해에 이르지 못한 때로부터 판결 선고시까지 2017년부터 2021년 평균 505일이 걸려, 120일 내에 변론기일을 열어야 하고, 그 기일로부터 15일 이내에 판결을 하여야 한다는 법정 기한을 위반하고 있다고 하였다.¹⁷³⁾ 후속 보도에서는 이러한 캘리포니아주의 상황은 다른 주 평균에 비하여 약 2배 정도 오래 걸리는 것이라고 하였다.¹⁷⁴⁾

2) 뉴욕주

뉴욕주 노동부에 대한 정보공개청구를 통해 입수한 데이터와 연방 데이터베이스 중 뉴욕 지역에 대한 데이터를 분석한 기사는 2017년부터 2021년 사이에 뉴욕주 기준 연방노동부와 뉴욕주 노동부는 합산하여 13,000건의 임금절도 사건을 적발하였다고 보고하였다.¹⁷⁵⁾ 해당 기사는 위 연방 정부와 주 정부는 해당 기간 동안 127,000명의 근로자로부터 합계 203,000,000미국 달러(\$203 million)이 체불되었다고 판단하였다고 보도하였다.¹⁷⁶⁾ 그러면 서도 위 기사는 연방노동부에 의하면 위 건 수와 금액은 체불 건수와 체불 금액이 상당히 많 이 누락된 것이라고 하였다고 보도하였다.¹⁷⁷⁾

3) 매사추세츠주

매사추세츠주는 사용자의 근로기준 관련 법령 위반을 이유로 민사적인 공적 집행을 한 사건들에 관한 자료를 웹사이트를 통하여 공개한다.¹⁷⁸⁾ 2022년 임금을 제 때 지급하지 않았음을

172) Jeanne Kuang & Alejandro Lazo, Wage Theft Whack-a-mole: California Workers Win Judgments Against Bosses but Still Don't Get Paid, (Sept. 15, 2022, updated May 2, 2023), <https://calmatters.org/california-divide/2022/09/california-wage-theft-cases/?series=unpaid-wages-california-workers> (2023. 9. 28. 최종방문).

173) Ibid.

174) CBS News Sacramento, National Wage Theft Investigation Reveals California Victims Wait Twice As Long For Resolution, (Jan. 26, 2023), <https://www.cbsnews.com/sacramento/video/national-wage-theft-investigation-reveals-california-victims-wait-twice-as-long-for-resolution/> (2023. 9. 28. 최종방문).

175) Max Siegelbaum, 127,000 New York Workers Have Been Victims of Wage Theft, Documented, (Aug 22, 2023), <https://documentedny.com/2023/08/22/wage-theft-restaurants-new-york-nyc/> (2023. 9. 4. 최종방문).

176) Ibid.

177) Ibid.

178) <https://www.mass.gov/info-details/fair-labor-division-data> (2023. 9. 28. 최종방문).

이유로 민사별로 나아간 사건은 92건으로, 그중 36건에 대하여 임금이 전부 지급되었다.¹⁷⁹⁾

한 보도는 2015년 검찰총장이 2,419건의 임금절도 사건에 대한 공적 집행을 하여 4,800만 미국 달러를 근로자를 위하여 회수하였다고 하였다.¹⁸⁰⁾ 그러나 위 보도는 이조차 실제 매사추세츠주의 임금절도 건이나 금액에 비하면 매우 적은 것으로 추측한다고 하였다.¹⁸¹⁾

4. 소결 및 시사점

가. 제재 정도

한 연구는 제재적 효과가 있는 배상액을 예정하는 입법을 한 주들에서, 정책 구조와 법의 집행 정도에 따라 다르나, 최저임금을 위반하는 사례가 줄어드는 결과가 있었다고 보고하였다.¹⁸²⁾ 그러나 제재를 강화하는 것은 강화된 법을 실제로 집행하지 않는 한 영향이 크지 않을 수 있다.¹⁸³⁾

미국 실무상 관련 행정청은 사용자가 체불된 임금을 즉시 지급하면 체불된 임금에 대한 이자나 법정 손해액을 면제해주는 관행이 있다고 한다.¹⁸⁴⁾ 또한, 민사사건은 그 사건이 판결까지 갔다면 사용자가 근로자에게 지급하였어야 할 금액에 비하여 훨씬 적은 금액으로 합의되는 경우가 대부분이다.¹⁸⁵⁾ 이러한 관행에 대하여 행정청이 근로자가 사용자에게 체불임금 상당액을 이자 없이 대여해주게 하는 것과 같다는 비판이 있다.¹⁸⁶⁾

민사별 등 추가 제재를 더함으로 인한 추가 임금체불 억제 효과가 이론적으로 인정되더라도, 그 효과가 실제 있기 위해서는 그 제도가 실효성이 있어야 할 것이다. 그러나 위에서 본 바와 같이 미국 학자들 중에서는 집행기관인 행정청이 원금만으로 조정하여 사건을 종결하면 실효성이 떨어지게 된다는 주장이 있다. 나아가 이와 같은 집행 관행에 의하여 결국 행정청이 집행 과정에서 근로자가 사용자에게 체불임금 상당액을 이자 없이 빌려주게 하는 결과를 가져오는 것이라는 비판도 있다.¹⁸⁷⁾

179) Ibid.(제공된 자료를 엑셀로 받아 “2022년”, “Failure to make timely payment”로 필터).

180) Cheryl Fiandaca, I-Team: Wage Theft in Massachusetts is Widespread in Some Industries, CBS News Boston, (Jan. 24, 2023, 11:28 PM), [https://www.cbsnews.com/boston/news/i-team-wage-theft-massachusetts-investigation/\(2023. 9. 28. 최종방문\)](https://www.cbsnews.com/boston/news/i-team-wage-theft-massachusetts-investigation/(2023. 9. 28. 최종방문)).

181) Ibid.

182) Daniel J. Galvin, Deterring Wage Theft: Alt-Labor, State Politics, and the Policy Determinants of Minimum Wage Compliance, 14 Perspective on Politics 324, 326(2016).

183) Jennifer J. Lee & Annie Smith, Regulating Wage Theft, 94 Wash. L. Rev. 759, 794(2019).

184) 예를 들어, Ford, 앞의 글, 1511-12면.

185) Hallett, 앞의 글, 109면.

186) Ford, 앞의 글, 1538면.

나. 제재 주체

사인에 의한 민사소송을 통하여 법률이 의도한 정책이 실현되게 할 것인지, 즉 사적 집행(private enforcement)을 허용할 것인지는 입법자의 선택으로,¹⁸⁸⁾ 입법자는 민사소송을 어느 정도 제기되게 할지를 유도하기 위한 수단으로 소송비용을 누가 부담하게 할 것인지, 손해배상액을 어느 정도 인정할 수 있게 할 것인지, 증거에 관한 법리를 어떻게 정할 것인지를 촉진할 것인지 등을 정할 수 있다.¹⁸⁹⁾ 예를 들어, 입법자가 몇 가지 소송절차를 조정하여 원고 측이 소송으로 얻을 수 있는 기대이익을 바꿀 수 있는 경우를 아래 표와 같이 나타낼 수 있다.

〈표 2-4〉 입법자의 소송을 통한 기대이익 조정 예시¹⁹⁰⁾

순번	기대편익	성공가능성	기대비용	기대값
1	실손해 \$10,000	중립적 증거법칙 0.6	소송비용 각자부담 \$10,000	-\$4,000 ¹⁹¹⁾
2	3배 배상 \$30,000	중립적 증거법칙 0.6	소송비용 각자부담 \$10,000	\$8,000 ¹⁹²⁾
3	3배 배상 \$30,000	원고 측 유리한 증거법 0.8	소송비용 각자부담 \$10,000	\$14,000 ¹⁹³⁾
4	3배 배상 \$30,000	원고 측 유리한 증거법 0.8	소송비용 패소자부담 \$2,000 ¹⁹⁴⁾	\$22,000 ¹⁹⁵⁾

이론적으로 사적 집행이 행정기관에 의한 공적 집행에 비하여 갖는 잠재적 장점으로 (1) 법을 집행하기 위한 비용을 정부로부터 사인에게로 이전할 수 있고, (2) 법 위반 사실을 사적 정보를 통하여 얻을 수 있고, (3) 법정정책 개혁을 시도할 유인을 제공하고, (4) 법 정책이 일관되게 집행될 것이라는 신호를 줄 수 있으며, (5) 시장에 국가기관이 직접적으로 개입하는

187) Ibid. at 1503면.

188) 미국에서는 이같이 의도적으로 사인이 소를 제기할 수 있게 하는 제도를 도입하여 의회의 정책 목표를 성취하려 하였고, 이러한 사인을 사적 검찰총장(private attorney general)이라고 한다. Pamel S. Karlan, Diarming the Private Attorney General, 2003 U. Illinois L. Rev. 183, 186(2003). 사적 검찰총장이라는 용어는 1943년 처음 사용되었다고 한다. Ibid. at 188면.

189) Sean Farhang, The Litigation State 3-4(2010).

190) Ibid. at 29면.

191) $\$10,000 \times 6/10 - \$10,000 = -\$4,000$.

192) $\$30,000 \times 6/10 - \$10,000 = \$8,000$.

193) $\$30,000 \times 8/10 - \$10,000 = \$14,000$.

194) $\$10,000 \times 2/10 = \$2,000$. 편면적 소송비용부담제도에 따라 원고 패소시 소송비용 각자부담, 원고 승소시 피고가 원고 소송비용 부담하는 것으로 계산하였다. 미국 개별 연방 법률 및 주 개별 법률들 중에는 편면적 소송비용 부담제도를 둔 경우가 많다. 편면적 소송비용 부담제도에 관한 논문으로, 이준범, 장애인차별금지법 사건의 활성화와 편면적 소송비용 부담제도, 비교사법 제27권 제2호, 2020, 315면; 이준범, 정보공개청구거부처분취소 사건 결과와 원고 소송대리인 선임의 관계, 저스티스 통권 177호, 2020, 194면 등.

195) $\$30,000 \times 8/10 - \$2,000 = \$22,000$.

것을 제한하며, (6) 참여적이고 민주적인 통치를 촉진한다는 점을 든다.¹⁹⁶⁾ 또한, 공적 집행을 하는 행정기관이 있어도 그 예산이 한정될 수 있으므로, 사적 집행을 함께 두면 그 집행을 강화하는 기능도 있다.¹⁹⁷⁾

반면, 잠재적 단점으로, (1) 사적 집행을 하면 정책에 대한 전문성이 없는 법관에게 정책적 판단을 하게 하고, (2) 법원으로부터 일관되지 않고 때로는 상충하는 법리를 생성하게 하는 경우가 있으며, (3) 담당 행정기관의 행정입법 권한을 사전에 배제하여 행정기관이 판단한 적절한 규제전략을 세우는 것을 약화시키고, (4) 행정기관의 재량을 빼앗고, (5) 행정기관에 협조할 유인을 약화시키고, (6) 입법부와 행정부가 행정기관의 정책 집행을 감독할 권한을 약화시키고, (7) 그 집행 자체가 민주적 정당성도 책임도지지 않는다는 점을 든다.¹⁹⁸⁾

위와 같은 잠재적 장단점에 대한 이론을 논외로 하고, 미국에서는 역사적으로 많은 정책 영역에서 입법자가 사적 집행을 하게 하는 제도를 도입하였다.¹⁹⁹⁾ 입법자가 사인의 민사소송을 통하여 사적 집행이 이루어지게 하는 제도를 도입하는 이유에 대하여, 만약 어떤 정책 영역에 대하여 의회가 집행이 이루어지기를 바라는 정도와 대통령이 집행이 이루어지기를 바라는 정도가 다르다고 우려할 때, 의회는 그 집행을 행정기관이 원하는 만큼을 충분히 하지 않아도 사적 집행에 의하여 이루어질 수 있도록 민사소송을 제기할 유인을 제공한다고 평가하기도 한다.²⁰⁰⁾ 또한, 특정 시점에 대통령과 의회가 같은 정도로 집행이 이루어지기를 바라더라도, 그 후 선거에 의하여 대통령이나 의회 다수 세력이 바뀌는 상황이 발생하는 것을 걱정할 수도 있다.²⁰¹⁾ 이때 입법자는 나중에 권력을 잡은 세력이 집행 정도에 대한 선호가 다르더라도 그 세력이 그 집행을 하는 ‘기관’을 통제하기 어렵게 하고자 할 수 있다.²⁰²⁾ 이때 행정기관에 의한 공적 집행보다는 사적 집행을 활성화하는 것이 나중에 권력을 잡은 세력을 집행 정도를 조정하는 것을 더 어렵게 할 것이라는 판단 하에 권력기관이 통제하기 상대적으로 더 어려운 사적 집행을 활성화할 유인을 제도화하는 방안을 택하는 경우가 있는 것이다.²⁰³⁾ 즉, 입법자가 사적 집행을 활성화할 유인을 두는 것은 대통령이 행정기관을 통하여 의회의 의지를 실행하지 않을 경우를 대비한 보험과 같은 기능을 한다.²⁰⁴⁾

196) Stephen B. Burbank, Sean Farhang & Herbert M. Kritzer, Private Enforcement, 17 Lewis & Clark L. Rev. 637, 662(2013).

197) Ibid.

198) Ibid. at 667.

199) Ibid. at 4-5면.

200) Farhang, 앞의 책, 36면.

201) Ibid. at 37면.

202) Ibid.

203) Ibid. at 38면.

204) Stephen B. Burbank & Sean Farhang, A New(Republican) Litigation State?, 11 UC Irvine L. Rev. 657, 661(2021).

예를 들어, 위에서 본 것처럼, 미국 연방노동부는 민주당의 오바마 대통령 시절인 2013년 경 손해배상 예정액을 보다 적극적으로 집행하기 시작하였으나, 2020년 공화당 대통령인 트럼프 대통령의 행정부는 손해배상 예정액을 구하는 사건이 원금만 구하는 사건보다 약 28% 시간이 더 걸린다는 이유 등을 근거로 손해배상 예정액 상당을 구하지 않기로 하였다.²⁰⁵⁾ 이후 민주당인 바이든 대통령의 행정부는 다시 손해배상 예정액 상당을 일정한 경우 구하기로 하였다.²⁰⁶⁾ 이같이 공적 집행을 대통령이 어떠한 정책을 선호하는지에 따라 집행 정도가 달라질 수 있다.

그러나 사적 집행을 활성화시키는 정책을 도입할 경우, 대통령이나 의회권력이 바뀌더라도 바뀐 권력자가 원고 또는 원고 측 변호사²⁰⁷⁾의 집행 정도를, 즉, 얼마나 적극적으로 소를 제기할지를 통제하기 어려우므로, 입법자가 나중에 권력을 잃더라도 집행이 약화되는 것을 막을 수 있다.²⁰⁸⁾ 이러한 판단 때문인지 사적 집행을 활성화시키는 제도는 미국의 양대 정당이 모두 활용하고 있다.²⁰⁹⁾

다. 제재 주체의 변화

위에서 본 바와 같이 미국에서는 임금절도에 관하여 사적 집행이 중재계약에 의하여 배제될 상황에 처하여 있다. 한 연구는 2000년 초반 이후 중재 조항의 적용을 받는 근로자의 수는 2배가 되어 55%가 넘는다고 보고하였다.²¹⁰⁾ 그런데, 위에서 본 바와 같이 미국 연방대법원이 2018년 EPIC Sys. Corp. v. Lewis 사건에서 집단소송이나 집단중재(class arbitration)를 못하게 하는 효과를 가져오는 개별적 중재를 강제하는 중재 조항의 효력을 재확인한 후,²¹¹⁾ 더 많은 사용자들이 근로계약 등 근로자 측과의 계약에 강제적 중재조항을 포함시키고 있다.²¹²⁾

이러한 상황이 발생하자 크게 두 가지 경향이 나타나고 있다. 첫째, 원고 측 변호사는 사용

205) Ford, 앞의 글, 1513면.

206) Ibid.

207) 미국 학자들은 사적 검찰총장의 역할은 원고보다는 이윤을 목적으로 하는 원고 측 변호사가 한다고 평가한다. 예를 들어, John C. Coffee, Jr., Rescuing the Private Attorney General: Why the Model of the Lawyer as Bounty Hunter is not Working, 42 Md. L. Rev. 215, 218-220(1983) 등.

208) Farhang, 앞의 책, 38면.

209) 한 연구는 2010년 이후에는 미국 공화당 연방 의원과 민주당 연방 의원이 사적 집행 제도를 두는 법안 발의에 참여한 정도가 비슷하다고 보고하였다. Burbank & Farhang, 앞의 글, 686면.

210) Alexander J.S. Colvin, The Growing use of Mandatory Arbitration 1(Economic Policy Institute Apr. 6, 2018).

211) EPIC Sys. Corp. v. Lewis, 138 S.Ct. 1612, 1632(2018).

212) Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition, 3.

자를 상대로 수 백 내지 수 천 개의 개별적 중재 신청을 하기 시작하였다.²¹³⁾ 이는 회사로 하여금 수 많은 개별 중재 사건에 대응하는 비용이 너무 커지게 하여서 결국 회사들이 근로자와 중재 계약을 체결하지 않게 만들고자 하는 것이다.²¹⁴⁾ 그러나 이 방법을 쓰려면 원고 측 변호사는 우선 집합소송을 제기하여 법원으로 하여금 피고인 회사로부터 잠재적 원고들의 명단을 원고 측에게 넘기도록 하여야 한다.²¹⁵⁾ 원고 측은 이렇게 받은 근로자들 명단을 이용하여 개별 근로자들을 설득하여 개별적 중재 신청을 하게 하는 것이다.²¹⁶⁾ 이 방법은 법원이 결국 중재 합의가 있기 때문에 집합소송이 유지될 수 없는 상황임에도 불구하고 피고인 회사로부터 잠재적 원고들의 명단을 받아 원고 측에게 넘겨주어야 가능할 것인데, 법원이 계속 이와 같이 할 것인지 불투명하다.²¹⁷⁾

둘째, 임금절도에 대한 공적 집행, 특히 형사 처벌의 필요성이 제기되고 있다.²¹⁸⁾ 본 바와 같이 미국에서는 역사적으로 임금절도가 형사상 죄로 입법이 되어 있더라도, 그 행위에 대한 공소제기가 거의 이루어지지 않았다.²¹⁹⁾ 그러나 중재 조항을 포함한 근로계약이 점점 많아지면서 사적 집행이 어려워지자 형사 처벌을 포함한 공적 집행의 필요성이 강조되고 있고, 일부 주 검찰총장들이 이에 대응하여 적극적으로 임금절도에 대한 공소제기를 시도하고 있다.²²⁰⁾

라. 법정배액배상제도와 민법상 특별손해배상의 차이점 및 존재 의의

한국에서는 미국을 포함한 외국 법리를 참고하여 임금체불을 줄이기 위해 민사적 제재를 더하는 방안을 고려 중인 것 같다.²²¹⁾ 이론적으로는 제재를 더하는 방안으로 미국처럼 배액 배상제를 입법하는 것을 고려할 수 있다.

물론, 민법 제763조에 민법 제393조가 준용되어, 불법행위에 대하여도 특별손해를 인정할 수 있고, 그 효과는 징벌적 손해배상나 배액배상제와 유사하므로, 징벌적 손해배상 제도를 굳이 법률을 개정하여 도입할 필요가 없다는 견해도 있을 수 있다.²²²⁾ 그러나 우선, 민법 제

213) Alisha Jarwala, Collective Action Notice Requirements: The Next Hurdle in the Arbitration Fight, Onlabor, (2020. 4. 30.), <https://onlabor.org/collective-action-notice-requirements-the-next-hurdle-in-the-arbitration-fight/> (2023. 9. 9 최종방문).

214) Ibid.

215) Ibid.

216) Ibid.

217) Ibid.

218) Marzán, 앞의 글, 304면.

219) Ibid.

220) Gerstein, 앞의 글, 1면.

221) 예를 들어, 임이자 의원이 2023. 6. 22. 대표발의하여 국회에 계류 중인 근로기준법 일부개정법률안은 체불사업주에 대한 경제적 제재를 강화하는 내용을 담고 있다. 근로기준법 일부개정법률안, 임이자의원 대표발의, 의안번호 22815, 발의연월일: 2023. 6. 22.

763조에 의하여 민법 제393조가 준용되는 특별손해도 피해자가 입은 실제 손해를 기준으로 하므로,²²³⁾ 만약, 배액배상이 실제 손해를 초과하는 금액을 가해자가 피해자에게 지급하게 하여 가해자가 불법행위를 하는 것을 억제하는 것을 목적으로 하는 것으로 이해한다면, 특별 손해는 배액배상 제도와 완전히 같은 효과가 있다고 하기 어렵다. 이를 가해자 입장과 피해자 입장으로 간단한 예를 들어 설명한다.

가해자의 입장에서 보면, 예를 들어, 가해자의 불법행위로 인하여 가해자에게는 100원의 이익이 발생하고, 피해자에게는 통상손해 70원, 특별손해 50원 합계 120원의 손해가 발생한다고 한다.²²⁴⁾ 만약, 피해자에게 통상손해만 인정된다면 가해자는 피해자에게 70원만 지급하면 되므로 가해자에게는 30원의 이익이 있을 것이므로 불법행위를 할 것이다. 이때 가해자에게는 100원의 이익이 있으나 피해자에게는 120원의 손해가 있으므로 가해자의 불법행위는 피해자 개인뿐만 아니라 사회적으로 볼 때도 20원 손해이다.

그러나 특별손해가 인정됨으로 인하여 가해자는 피해자에게 120원(= 통상손해 70원 + 특별손해 50원)을 지급할 의무가 있고, 이 경우 가해자가 불법행위를 하여 얻는 이익보다 손해가 20원(왜냐하면 이익은 100원, 손해는 120원(통상손해 70원 + 특별손해 50원)이기 때문이다)이 크므로, 이 경우 특별손해가 인정되면 합리적인 가해자가 불법행위를 하지 않게 하는 효과가 있는 것은 맞다.

사례를 바꾸어 본다. 가해자의 불법행위로 인하여 가해자에게는 100원의 이익이 발생하고, 피해자에게는 통상손해 70원, 특별손해 50원 합계 120원의 손해가 발생한다고 한다. 그런데, 피해자가 어떤 이유로든 가해자에게 손해배상을 청구할 확률이 1/2이라 가정한다.²²⁵⁾ 이때 가해자가 불법행위를 함으로 얻을 수 있는 기대이익은 40원(= 100원 - (50원 + 70원)/2)이 되어 피해자에게 특별손해가 인정되어도 가해자는 여전히 불법행위를 하는 것이 이익이 된다.

다시 사례를 바꾸어 본다. 가해자의 불법행위로 인하여 가해자에게는 100원의 이익이 발생하고, 피해자에게는 통상손해 70원, 특별손해 50원 합계 120원의 손해가 발생한다고 한다. 그리고 피해자가 어떤 이유로든 가해자에게 손해배상을 청구할 확률이 1/2이라 가정한다. 다만, 여기서는 법률이 손해배상액에 대한 2배에 달하는 금액을 배상할 것을, 배액배상을 입법

222) 윤정환, “징벌적 손해배상에 관한 연구”, 재산법연구 제9권 제1호, 1992, 146면(김정환, 징벌적 손해배상의 적절한 운영방안에 관한 연구, 사법정책연구원, 2019, 18면에서 재인용). 위에서 본 바와 같이 한국에서는 배액배상을 징벌적 손해배상과 혼용하여 사용하고 있으나, 논의의 편의상 여기서는 배액배상이라 한다.

223) 김정환, 징벌적 손해배상의 적절한 운영방안에 관한 연구, 사법정책연구원, 2019, 19면.

224) 논의의 편의상 피해자에게는 불법행위로 인한 손해배상청구권만 있다고 가정한다. 또한, 가해자에게 형사상 책임 등 다른 제재가 가해질 수 있음은 논외로 한다. 또한, 피해자가 가해자를 상대로 소를 제기하면 손해배상금을 모두 받을 수 있다고 가정하고, 소송으로 인해 발생하는 비용은 무시한다.

225) 피해자가 피해 사실을 모를 수도 있고, 가해자가 사회적 권력이 있어 피해자 중 일부가 감히 가해자를 상대로 제소하지 못할 수도 있다.

하였다고 가정한다. 이때는 가해자가 불법행위를 함으로 얻는 이익보다 손해가 20원이 커진다. 왜냐하면 이익은 100원이지만, 손해는 120원(= (통상손해 50원 + 특별손해 70원)×소제기 확률 1/2×배액배상 2)이 되기 때문이다.

물론, 위의 간단한 예에서 몇 가지 숫자를 조정하면 특별손해를 인정하는 것만으로 가해자의 불법행위를 억제할 수 있게 할 수 있다. 그러나 위 예에 의하면 특별손해만 있는 경우와 배액배상제도가 추가되는 경우가 서로 다른 효과를 가져오는 상황이 있을 수 있으므로, 특별손해가 인정된다는 것만으로 반드시 배액배상 제도와 유사한 효과가 있다고 할 수 없다.

피해자의 입장에서 보면, 합리적인 피해자가 가해자를 상대로 소를 제기하는 것은 소송으로부터 얻게 될 이익이 이를 위해 사용해야 하는 비용에 비하여 크거나 같을 때이다.²²⁶⁾ 만약, 피해자에게는 통상손해 70원, 특별손해 30원 합계 100원의 손해를 입었으나, 소송을 하면 소송비용 120원이 발생한다면, 피해자는 소를 제기하지 않을 것이다.²²⁷⁾

다시, 배액배상이 입법되어 소송을 하면 손해액 100원의 2배인 200원을 배상받을 수 있다고 가정한다. 그렇다면 피해자는 소송을 하면 80원(= 200원 - 120원) 이익이므로 소송을 할 유인이 있다.²²⁸⁾

역시, 위의 간단한 예에서 몇 가지 숫자를 조정하면 특별손해를 인정하는 것만으로 피해자가 소송을 하는 상황을 만들 수 있다. 그러나 위 예를 통해 보이려는 것은 특별손해만 있는 경우와 배액배상 제도가 추가되는 경우가 다른 효과를 가져오는 상황이 있을 수 있으므로, 특별손해가 인정되는 것만으로 반드시 배액배상 제도와 같은 효과가 있다고 할 수 없다는 것이다.

마. 시사점

위와 같이 특별손해가 인정되더라도, 상황에 따라 배액배상이 인정되는지 여부에 따라 다른 결과를 가져오는 경우가 있을 수 있으므로, 특별손해배상이 있으므로 당연히 배액배상이 없어도 된다고 말하기는 어렵다. 구체적인 상황에 따라 특정한 영역에 배액배상을 도입하는 것이 입법정책적으로 바람직한지 판단하는 것이 바람직하다.

226) 김두열, 소송 및 분쟁해결제도의 법경제학, 법경제학 이론과 응용, 김일중·김두열 편, 2011, 267면.

227) 논의의 편의상 피해자가 가해자를 상대로 소를 제기하면 손해배상금을 모두 받을 수 있다고 가정한다. 소송제기의 결정요인에 관한 더 자세한 법경제학적 설명으로 김두열, 위의 책, 267-273면; Robert Cooter & Thomas Ulen, Law and Economics, 2016, 386-391면; Robert G. Bone, Civil Procedure: The Economics of Civil Procedure, 2003, 29-36면 등.

228) 소의 제기가 사회적으로 바람직한지는 논외로 한다. 소의 제기가 사회적으로 바람직하지 않음에도 원고에게 소송을 할 유인이 있는 경우에 대한 예와 소의 제기가 사회적으로 바람직하고 원고에게 소송을 할 유인이 있는 예로, 송옥렬, 민사소송의 법경제학 - 기초이론 -, 서울대학교 법학 제46권 제2호, 2005, 142-43면.

미국은 임금절도를 억제하기 위하여 공적 집행과 사적 집행을 모두 활용하는 전략을 취하고 있으나, 역사적으로 사적 집행에 주로 의존하였고, 특히 공적 집행 중 형사 처벌을 이용하는 전략을 거의 사용하지 않았다. 이에 대한 학자들이나 언론 보도에 의하면 미국이 한국에 비하여 임금절도를 성공적이고 효율적으로 억제하고 있다고 평가하기는 어렵다.

이러한 미국 현황에 비추어 볼 때 임금체불에 대하여 형사 처벌을 적극적으로 활용하는 것은 유효할 것 같다.²²⁹⁾ 다만, 한국은 신용제재, 입찰제한, 정부지원금 제한 등의 제재가 있어, 형사 처벌을 보완한다.²³⁰⁾ 이러한 제재들에 더하여 사적 집행을 더 할 유인을 추가하는 것이 바람직한지 고려를 요한다.

제2절 캐나다의 임금체불 제도와 그 대응

1. 개 관

가. 캐나다의 노동법제

캐나다는 10개의 주와 3개의 준주로 이루어져 있는 연방국가이다.²³¹⁾ 노동관계를 규율하는 법의 명칭과 관련하여 캐나다에서는 고용법(Employment Law)과 협의의 의미의 노동법(Labour Law)으로 구별할 수 있다. 고용법은 일반적으로 개별적 근로계약을 다루고 있으며, 근로자는 노동조합의 조합원이 아닐 뿐 아니라 단체협약에 의해서 구속받지 않는 경우이다. 노동법은 일반적으로 단체교섭에 따르며 노동조합의 조합원인 근로자들에게 적용된다.²³²⁾

229) 나상현, 임금체불 벌써 1조 넘겼다... “악덕 업주 구속수사” 칼 빼든 정부, 중앙일보, (2023. 9. 25. 18:48, 업데이트 2023. 9. 25. 18:53), <https://www.joongang.co.kr/article/25195350>(2023. 9. 28. 최종방문).

230) 위에서 본 것처럼 임이자 의원이 2023. 6. 22. 대표발의하여 국회에 계류 중인 근로기준법 일부개정법률안은 체불사업주에 대한 경제적 제재를 강화하는 내용을 담고 있다. 근로기준법 일부개정법률안, 임이자의원 대표발의, 의안번호 22815, 발의연월일: 2023. 6. 22.

231) 캐나다 연방은 10개의 주와 3개의 준주로 구성되어 있다. 10개의 주는 노바스코샤(주도 핼리팩스), 뉴브런즈윅(주도 프레더릭턴), 뉴파운드랜드레브라도(주도 세인트존스), 매니토바(주도 위니펙), 브리티시 컬럼비아(주도 빅토리아), 서스캐처원(주도 리자이나), 알버타(주도 에드먼턴), 온타리오(주도 토론토), 퀘벡(주도 퀘벡 시), 프린스 에드워드아일랜드(주도 샬럿타운)이다. 3개의 준주는 노스웨스트 준주(주도 옐로나이프), 누나부트 준주(주도 이칼루이트), 유콘 준주(주도 화이트호스)이다.

232) <https://www.minkenemploymentlawyers.com/employment-law-issues/employment-law-and-labour-law-whats-the-difference/>(2023-08-22 검색)

[그림 2-6] 캐나다 연방의 구성



연방제 국가인 캐나다는 연방정부의 관할과 주정부 관할 대상이 구별이 엄격하며, 주민의 일상생활과 밀접한 관계가 있는 권리의 대부분은 주정부 관할에 있다.²³³⁾ 따라서 연방 차원의 법률이 적용될 수 있는 범위와 주정부 차원의 법률이 적용될 수 있는 범위는 구별될 수밖에 없다.

고용과 관련한 사항에 대해서 규율하는 캐나다의 법들은 연방과 주의 수준에서 둘 다 존재한다. 예를 들면 캐나다 연방노동법(Canada Labour Code)과 온타리오주의 고용기준법(2000)이 그것이다. 온타리오 고용기준법은 주의 입법으로서 연방 규제의 회사에서 일하지 않으면서 온타리오 주의 관할 하에서 일하는 근로자들에게 적용된다. 반면 연방노동법은 연방 규제의 회사에서 고용되어 있는 근로자에 적용된다.²³⁴⁾

임금 체불과 관련하여서는 행정적 구제방식이 주가 된다는 점에 있어서 연방 노동법과 퀘벡을 같이 한다.²³⁵⁾ 온타리오주의 고용기준법 제103조가 임금지불명령(Order to pay wages)을 규정하고 있는 것이 그 예이다.²³⁶⁾

여기서는 캐나다의 연방노동법을 전체적으로 개관하고 이를 중심으로 하여 임금체불을 어떻게 규율하며, 그 구제 방안은 어떠한지 구체적으로 살펴보도록 한다.²³⁷⁾

233) 구미영, “캐나다의 임금차별 판단 법리에 관한 비교법적 검토”, 노동법학 제40호, 한국노동법학회, 170면.

234) <https://www.minkenemploymentlawyers.com/employment-law-issues/employment-standards-act-2000-vs-canadian-labour-code/>(2023.08.22자 검색)

235) Eric Tucker, “When Wage Theft Was a Crime in Canada, 1935-1955: The Challenge of Using the Master’s Tools Against the Master”, OSGOODE HALL LAW JOURNAL(54), YORK UNIVERSITY, 2017, p.933.에서는 행정적 규율방식이 위주가 된다고 평가하고 있다.

236) 온타리오주에서는 임금 체불시 고용기준담당관(employment standards officer)이 사용자가 직접 근로자에게 지불하도록 조정하거나, 사용자가 근로자에게 임금을 지불할 것을 명령하거나, 사용자가 임금의 액수를 법인의 이사에 지급할 것을 명령할 수 있다고 규정하고 있다.

나. 캐나다 연방노동법 개관

캐나다 연방노동법(the Canada Labour Code)은 캐나다 의회에서 제정한 법률로서 연방 규율 사업장의 근로자와 사용자의 권리와 의무를 규정하고 있다. 연방노동법은 4개의 장(Part)으로 구분되어 있다.

〈표 2-5〉 캐나다 연방노동법의 장별 개요 및 적용 대상

구분	개요	적용 대상
제1장 노사관계 (Part I: Industrial relations)	- 제1장은 노동조합과 사용자 사이의 사업장 관계와 단체교섭을 규율 - 이 장에서는 분쟁해결, 파업과 직장폐쇄를 관련된 규정을 담고 있음 - 사용자, 노동조합과 근로자들이 가지는 노동 관계에 관한 권리와 의무를 담고 있음	- 항공 운수 - 은행 - 곡물 관련 - 원주민단 평의회 - 대부분의 연방 왕실 법인 - 우편 - 라디오 및 텔레비전 방송 - 철도 - 도로 운송 - 통신 - 우라늄 광산 - 위의 활동 중 하나의 운영에 필수적인 모든 사업 - 유콘, 노스웨스트, 누나부트 준주의 사적 부분 회사와 자치단체
제2장 산업 보건 및 안전 (Part II: Occupational health and safety)	- 제2장에서는 업무상 질병을 포함하여 산업 재해를 방지하기 위한 규정을 설정 - 제2장 하에서 사용자는 작업하는 동안 근로자들의 건강과 안전을 보호할 일반적인 의무를 가짐. 또한 작업장에 접근하도록 허락된 비근로자(도급인, 일반 대중)를 포함 - 업무상 재해를 방지하기 위하여 근로자들, 보건/안전위원회 또는 보건/안전대표에 대한 의무 부과	- 항공 운수 - 은행 - 곡물 관련 - 원주민단 평의회 - 대부분의 연방 왕실 법인 - 우편 - 라디오 및 텔레비전 방송 - 철도 - 도로 운송 - 통신 - 우라늄 광산 - 위의 활동 중 하나의 운영에 필수적인 모든 사업 - 연방 공공 서비스 - 의회

(계속)

237) 캐나다는 연방제 국가로서 10개 주와 3개의 준주로 구성되어 있는데, 이에 대해 모두 조사, 검토하기 어렵다는 현실적 문제점이 상존한다는 점에 대해서는 구미영, 앞의 논문, 171면.

구분	개요	적용 대상
제3장 기준 근로시간, 임금, 휴가와 휴일 (Part III: Standard hours, wages, vacations and holidays)	- 제3장에서는 공정하고 형평성 있는 고용조건에 대한 근로자의 권리를 확립하고 보호 - 당해 규정들은 고용 조건에 대한 노동 기준을 규정 - 이러한 노동 기준은 연방 규율 사적 부문에서 근로시간, 최저임금, 법정휴일, 연차휴가와 다양한 형태의 휴가와 같은 최저 근로 기준을 설정 - 당해 규정들은 사용자들이 이러한 최소한의 권리를 충족하도록 요구함으로써 사용자들 간의 공정한 경쟁의 장을 조성	- 항공 운수 - 은행 - 곡물 관련 - 원주민단 평의회 - 대부분의 연방 왕실 법인 - 우편 - 라디오 및 텔레비전 방송 - 철도 - 도로 운송 - 통신 - 우라늄 광산 - 위의 활동 중 하나의 운영에 필수적인 모든 사업
제4장 행정 벌금 (Part IV: Administrative Monetary Penalties)	- 제4장은 새로운 행정 벌금 시스템을 규정 - 이 법의 제2장, 제3장 또는 관련 지침에 대한 위반을 한 사용자에 대한 명단 공개를 규정	- 항공 운수 - 은행 - 곡물 관련 - 원주민단 평의회 - 대부분의 연방 왕실 법인 - 우편 - 라디오 및 텔레비전 방송 - 철도 - 도로 운송 - 통신 - 우라늄 광산 - 위의 활동 중 하나의 운영에 필수적인 모든 사업 - 연방 공공 서비스 - 의회

다. 캐나다 연방노동법의 임금체불 규율 개관

캐나다 연방노동법상의 임금체불 해결 시스템을 중심으로 그 규율 내용을 개관하면 다음과 같다. 캐나다 연방노동법은 연방 노동기준을 정립하고 있고, 이에 대한 위반이 있는 경우 구제 시스템으로 일명 ‘노동 프로그램’이라는 지칭하는 일종의 행정 절차를 두고 있다.²³⁸⁾

연방 노동기준의 위반에 대해서는 4가지 형태의 신고(Complaints)를 준법집행책임자(The Head of Compliance and Enforcement)²³⁹⁾에게 할 수 있다. 4가지 중 하나의 형태가

238) 노동 프로그램(labor program)은 연방정부 차원에서 사회 프로그램과 노동시장을 담당하는 캐나다 연방정부 부서인 ESDC(Employment and Social Development Canada)의 일부 기관이며, 여기서 운영하는 제도라고 할 수 있다.

239) 캐나다 연방노동법은 “Head means the Head of Compliance and Enforcement designated under subsection 122.21(1)”로 정의하고 있는데, 여기서는 준법집행책임자로 번역하였다. 기존의 문헌에서는 ‘근로감독관’으로 번역하기도 하는데(김소영 외 4인, 『우리나라·미국·캐나다의 노동법제 비교연구』, 노동부, 2007, 209면 참조), 우리나라의 근로감독관과 비교하면 유사한 점도 있으나 차이점도 있다. 유사한 점으로 임금, 근로시간 또는 연방 근로

바로 임금체불에 해당하는 경우이다. 임금체불이 발생한 경우 연방노동법의 적용을 받는 연방 근로자는 6개월 내에 신고를 제기하여야 한다. 일정한 서식을 갖추어 관련 증거서류의 사본을 첨부하여 지역 노동 프로그램 사무소에 이메일, 우편으로 제출한다. 이에 대해 노동 프로그램에서 근거가 있는지를 검토하여 결정을 내리게 된다.²⁴⁰⁾ 신고가 근거가 있고 체불액 등이 결정되면, 먼저 사용자의 자발적 이행을 유도한다. 그러나 자발적으로 체불임금의 지급을 완료하지 않는 경우 노동 프로그램은 지급 명령(payment order)를 사용자에게 부과할 수 있다. 만약에 지급 명령도 이행하지 않는 경우라면 노동 프로그램은 연방법원에 지급 명령을 제출하고 이를 인정받게 되면 이 지급 명령은 판결과 동일한 효력을 갖게 된다. 또한 자발적 이행을 하지 않는 경우 행정 벌금을 부과할 수도 있다.

캐나다에서는 임금체불에 대해서 임금절도라는 표현으로 일상적으로 사용하기는 하지만 법적인 표현은 아니다. 과거 임금절도를 형법전에 규정하기는 하였지만 실제로 이를 적용하지는 않았었다. 이러한 측면에서 임금체불 자체를 형사처벌 대상으로 하고 있지는 않다고 할 수 있다. 다만, 캐나다 연방노동법상 규정하고 있는 노동기준을 위반하는 경우 사용자가 회사 인지 여부, 위반 횟수 등의 기준에 따라 일률적으로 벌금의 형사처벌을 규정하고 있다. 연방 노동기준과 관련하여서는 임금의 구성이나 지급과 관련한 사항이 포함된다는 점에서 임금체불의 경우 형사처벌을 한다고 할 수 있다.

라. 캐나다 연방노동법에서의 임금체불 구제 시스템의 특징

캐나다 연방 차원에서는 임금체불에 대해 형사적 처벌 보다는 행정적 구제제도를 통하여 임금체불을 구제하려는데 초점을 맞추고 있다고 할 수 있다. 따라서 ‘노동 프로그램(Labour Program)’이라는 일종의 행정적 구제 제도를 활용한다. 이러한 노동 프로그램의 실효성을 보장하기 위한 장치가 지급 명령과 행정 벌금이다. 또한 연방 근로기준을 위반한 사용자의 정보 게시 제도를 시행하고 있다.

또 한 가지 특징적인 것이 있다면 회사의 이사 내지 임원에 대하여 임금체불에 대한 일정한 책임을 지도록 규정하고 있다는 것이다. 회사가 도산하거나 지불능력이 없을 경우가 아니더라도 이사의 책임을 인정하고 있다.

자에게 영향을 주는 고용조건에 대하여 사용자의 모든 자료와 기록을 조사할 수 있으며, 이를 위해 관련된 장소에 들어갈 수 있다는 것이다. 구별되는 차이점의 예로는 캐나다 연방노동법의 경우 근로시간의 변경이나 연장이 이루어진 경우 이에 대한 불복절차를 규정하고 있는데, 이때 근로자는 그 찬성 비율의 확인을 위하여 근로감독관에게 투표 실시를 요청할 수 있다(Canada Labour Code Subsection 172.1(1) 참조).

240) 캐나다 연방노동법은 노동 프로그램이라는 용어를 사용하지 않고 준법집행책임자인 ‘The Head’로 표현하고 있지만, 관련 제도를 설명하고 있는 캐나다 정부 홈페이지에서는 The Head라는 법률용어 대신에 노동 프로그램이라는 용어를 사용하고 있다. 이하에서는 노동 프로그램과 준법집행책임자를 혼용하여 사용한다.

2. 임금체불의 형사적 책임

가. 임금체불과 임금절도

캐나다와 미국에서는 일반적으로 근로자들에게 마땅히 주어야 할 임금을 주지 않는 경우, 임금절도(wage theft)라는 표현을 사용하기도 한다. 즉 임금체불은 캐나다에서는 임금절도라는 용어에 포함될 수 있다. 실제 1935년 캐나다는 임금절도를 명문화하고 형법적으로 규율하려고 하기도 하였다. 이 법은 1955년까지 명문화되어 있었으나 실제 활용되는 일은 거의 없었으며, 이 법은 명목적이며 상징적인 입법에 불과하였다고 평가받는다.²⁴¹⁾

캐나다에서의 임금절도의 액수는 점차 늘어나서 이에 대한 사회적 문제가 되고 있는데, 형법적 제재를 부가하는 방식보다는 온타리오주의 고용기준법과 같이 행정적 규율을 통한 수단이 더 강조되고 있다.²⁴²⁾

여기서는 캐나다에서 과거 임금절도를 규정하고 형법적 대응을 시도한 적이 있으므로 이에 대해 간략하게 살펴보기로 한다.²⁴³⁾

나. 캐나다에서의 임금체불과 형법적 대응: 1935~1955년

미국과 캐나다의 노동 활동가들은 임금체불 문제를 제기할 때 지속적으로 근로자들에 대한 임금절도라고 표현하여 왔다. 이들이 주장하는 임금절도는 사용자들이 근로자에게 지불해야 마땅할 임금 및 혜택을 지불하는 데 실패하는 것을 의미한다.

이러한 임금절도라는 언어적 표현은 형법의 언어를 환기시키지만, 정작 캐나다에서 임금체불을 규율하는 방향은 형사적이라기 보다 행정적 규율을 강화하는 방식을 택하고 있다. 노동계에서는 사용자들에게 형법적 제재를 부과하라는 요구도 있지만 이를 거부하고 행정적 규율을 강화하는 방향을 선호하고 있는 것이다.

그럼에도 불구하고 이러한 용어가 사용되고 있는 것은 과거 캐나다가 형법적으로 임금절도를 법률화한 적이 있기 때문이라고 할 수 있다. 1935년에 캐나다는 임금절도법을 법률화하였고, 1955년까지도 명문으로 이러한 규정이 남아 있었다. 1935년부터 1955년까지 캐나다의 형법전은 의도적으로 캐나다 법에서 규정한 최저임금보다 적게 근로자들에게 임금을 주는

241) Eric Tucker, "When Wage Theft Was a Crime in Canada, 1935-1955: The Challenge of Using the Master's Tools Against the Master", OSGOODE HALL LAW JOURNAL(54), YORK UNIVERSITY, 2017, p.933.

242) *Ibid.*, p.934.

243) 참고로 캐나다의 경우 임금체불에 대해서는 징벌적 손해배상제도를 취하고 있지는 아니하다.

경우 그것을 범죄로 규정하였다. 그러나 실제로 이 법이 작동하지는 못하였다. 당해 법은 근로자들의 불만에 대한 상징적인 제스처에 불과하였다고 평가받는다. 이러한 예는 형법을 통하여 사용자의 잘못된 행위를 처벌하는 것을 꺼려하는 것을 방증한다.

다. 캐나다 연방노동법상의 형사처벌

임금체불 자체의 불법성을 강조하고 이를 형사적으로 규율하려고 하였던 시도는 있었지만 실제로 적용되지는 않았었다. 그러나 현재 캐나다 연방노동법에서는 각종 노동기준을 제3장(Part III)에서 규정하고 있고, 제3장의 규정을 위반한 경우에 사용자가 회사인지 여부와 위반 횟수에 따라 차등적으로 벌금을 규정하고 있다.

이러한 측면에서 임금에 대한 노동기준을 위반하는 임금체불에 대해서 캐나다 연방노동법은 형사처벌을 하고 있다고 볼 수도 있다. 그러나 이러한 형사처벌 규정의 존재는 임금체불 행위 자체의 위법성과 불법성에 대한 고려를 통하여 형사처벌 규정을 두었다기 보다, 캐나다 연방노동법이 규정하고 있는 각종의 노동 기준의 준법을 강제하기 위한 수단적 성격이 강하다고 볼 수 있다.

그렇기 때문에 임금에 관한 노동기준 위반을 별도로 규정하여 처벌규정을 두기 보다는 전반적인 노동 기준 위반 행위의 경우에 있어 그 위반 횟수 등을 고려하여 차등적으로 벌금 액수를 규정하고 있는 것이라고 평가할 수 있다.

3. 캐나다 연방노동법 제3장의 규율

가. 캐나다 연방노동법 제3장 개관

캐나다 연방노동법의 제3장(Part III of the Canada Labour Code)은 1965년에 처음 제정되었다. 제3장에서는 연방 관할하의 사용자와 근로자에 대한 최저 근로조건을 확립하고 있다. 이러한 고용 기준에는 근로시간, 최저임금, 휴일, 연차 휴가, 해고 통지, 해고 수당 그리고 법정 휴가 등이 포함된다. 여기에는 또한 체불임금 회수에 있어 근로자들을 돕기 위해 고안된 규정을 담고 있다.

나. 근로 기준 위반에 대한 노동 프로그램 신고 제도²⁴⁴⁾

캐나다 연방노동법의 3장(part III)은 공정하고 형평성있는 근로 조건을 위하여 연방에 의해 규율되는 산업과 작업장에서 일하는 근로자들(이하 ‘연방 근로자’이라고 표현)의 권리를 규정하고 이를 보호하고 있다.²⁴⁵⁾

〈표 2-6〉 연방 근로자의 구분과 총인원²⁴⁶⁾

구분			인원(명)		
연방 공공 서비스 (Federal Public Service)	연방 공공 부문 (Federal Public Sector)	핵심 공공 행정(Core Public Administration, including the Royal Canadian Mounted Police)	267,000	575,900	1,400,000
		각 정부기관(Separate Agencies)	73,900		
		정규군(Canadian Armed Forces, Regular Force)	65,200		
		예비군(Canadian Armed Forces, Reservists)	37,500		
		왕실 법인 등(Crown Corporations and Other)	131,700		
	연방 규율 사적 부문 (Federally Regulated Private Sector)	운송(Transportation, including Road, Air, Rail, Maritime)	310,400	828,200	
		은행(Banks)	260,400		
		통신 및 방송(Telecom and broadcasting)	138,400		
		우편 및 파이프라인(Postal and pipelines)	58,200		
		곡물(Feed, flour, seed, grain)	18,000		
		기타(Miscellaneous for example uranium mining, oil and gas exploration in the territories)	7,800		
		원주민 정부(Indigenous government on First Nations reserves)	35,000		

244) <https://www.canada.ca/en/services/jobs/workplace/federal-labour-standards/filing-complaint.html> (2023. 8. 2. 검색)

245) 앞서 언급한 바와 같이 고용과 관련한 사항에 대해서 규율하는 캐나다의 법들은 연방과 주의 수준에서 둘 다 존재한다. 따라서 연방 근로자가 아닌 경우에는 각 주법의 적용을 받게 된다. 예를 들어 연방 근로자가 아니면서 온타리오 주의 관할하에서 근로하는 근로자는 온타리오주의 고용기준법이 적용되게 된다. 임금 체불과 관련하여서 행정적 구제방식이 추가 된다는 점에 있어서 각 주의 고용관련법은 연방 노동법과 그 틀을 같이 한다. 따라서 여기서는 연방노동법을 중심으로 서술하였다.

246) <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/reports/labour-transition-binders/minister-labour-2021/employee-distribution-infographic.html>(2023. 10. 15. 검색)

〈표 2-7〉 산업별 연방 근로자 구성 비율²⁴⁷⁾

구분	비율
은행(Banks)	28%
도로 운송(Road transportation)	16%
통신 및 방송(Telecommunications and broadcasting, including CBC)	16%
우편 및 택배 서비스 (Postal and Courier services, including Canada Post, and pipelines)	14%
항공 운송(Air transportation, including airport authorities)	12%
철도 운송(Rail transportation, including VIA Rail)	7%
곡물 관련(Grain handling)	2%
해상 운송(Maritime transportation, including ports)	2%
기타(Miscellaneous industries such as uranium mining, federal government museums, oil and gas exploration in the territories)	3%

연방노동법의 규정은 연방법에 의해 규율받는 작업장에서의 기본적인 고용 조건을 정립하고 있다. 캐나다 연방노동법은 연방 근로자들의 미지급 임금 회수를 위한 방법을 제공하고 있고 그 외에 다른 근로 기준들이 사업장에서 지켜지고 있는지를 확인한다. 즉, 근로 기준 위반에 대해 노동 프로그램에 신고(filing a labour standards complaint with the Labour Program)하고 이에 대해서 구제받을 수 있도록 하는 제도이다. 연방 근로자들은 근로 기준 위반에 대해 4가지 형태의 신고를 할 수 있다.

〈표 2-8〉 근로기준 위반에 대한 노동 프로그램 신고 4가지 형태

	구분	내용
1	Monetary complaints Monetary complaints for unpaid wages or other amounts owed	임금 (위반) 사항 신고 미지급 임금 등에 대한 금전적 신고
2	Non-monetary complaints	비임금 (위반) 사항 신고
3	Unjust dismissal complaints	부당해고 신고
4	Genetic testing ²⁴⁸⁾ complaints	유전자 검사 신고

이렇게 캐나다 연방노동법은 연방 근로자들을 위하여 연방 근로 기준의 확립과 보호를 위한 방법으로 4가지 형태의 노동 프로그램에 신고할 수 있는 행정적 구제제도를 두고 있다.

247) <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/reports/labour-transition-binders/minister-labour-2021/industries-infographic.html>(2023-10-15 검색)

248) 캐나다 연방노동법에서 규정하고 있는 유전자 검사란 “근로자와 관련하여, 질병 예측 또는 수직 감염 위험 또는 모니터링, 진단 또는 예후와 같은 목적을 위하여 근로자의 DNA, RNA 또는 염색체를 분석하는 시험”을 의미한다.

연방 근로자 중 임금체불을 당한 경우에 임금 위반 신고로서 노동 프로그램(준법집행책임자)에 신고할 수 있다. 이를 통해 노동 프로그램(the Labour Program)에서 체불 근로자가 받아야 할 임금 액수를 산정할 수 있도록 하고 있다.

또한 이러한 제도를 활용한 것에 대해서 사용자 측의 불이익 취급과 같은 보복(reprisals)으로부터도 보호받을 수 있다. 연방 근로자로서, 연방법하에서의 권리 행사에 대한 사용자의 불이익취급이 있었을 때에는 보호(recourse) 매커니즘을 이용할 권리가 있다. 불이익 취급을 당한 연방 근로자는 캐나다 산업 관계 위원회(the Canada Industrial Relations Board)에 서면으로 신고(complaint)할 수 있다. 사용자의 불이익 취급의 예로서는 부당해고(dismissing), 정직(suspending), 정리해고 내지 강등(laying off or demoting), 재정적 불이익(imposing a financial or other penalty), 징계(discipline) 등을 들 수 있다.

여기서는 노동 프로그램에 대한 연방 근로 기준 위반 사항 신고 형태 중 임금체불의 경우를 중심으로 살펴보도록 한다. 노동 프로그램 신고 제도 중 체불임금 회수 제도는 다음의 두 가지 사항이 먼저 전제된다. 첫째는 이 제도를 이용하기 위해서는 연방 근로자일 것이 요구된다는 것이다. 둘째는 체불임금의 대상 범위가 정해져 있다는 것이다. 이에 대해 먼저 살펴보도록 한다.

첫째, 이러한 규정의 적용을 받는 근로자들은 연방법에 의하여 규율되는 사용자를 위하여 근로하는 이른바 연방 근로자들이어야 한다. 연방 근로자들은 사용자가 연방 관할권의 적용을 받는 경우로서 캐나다 연방노동법에서 규정하고 있는 내용은 다음과 같다.

〈표 2-9〉 사용자가 연방관할권의 적용을 받는 경우

The Canada Labour Code (the Code) regulates the following industries and workplaces: Federally regulated private sectors (parts I, II, III and IV of the Code): air transportation, including airlines, airports, aerodromes and aircraft operations banks, including authorized foreign banks grain elevators, feed and seed mills, feed warehouses and grain-seed cleaning plants First Nations band councils and Indigenous self-governments(certain activities). most federal Crown corporations, for example, Canada Post Corporation port services, marine shipping, ferries, tunnels, canals, bridges and pipelines(oil and gas) that cross international or provincial borders postal and courier services	캐나다 연방노동법은 다음의 산업들과 사업장들에 적용된다; - 연방 규제 민간 부분(법의 I, II, III and IV 장) 항공사, 공항, 비행장 및 항공기 운영을 포함한 항공 운송 공인된 외국 은행을 포함한 은행 곡물 엘리베이터, 사료 및 종자 공장, 사료 창고 및 곡물 종자 세척 공장 First Nations band councils과 원주민 자치 정부(특정 활동) 대부분의 연방 직할 기업(예: Canada Post Corporation) 국제 또는 지방 국경을 가로지르는 항만 서비스, 해상 운송, 페리, 터널, 운하, 교량 및 파이프라인(석유 및 가스) 우편 및 택배 서비스 라디오 및 텔레비전 방송
--	--

(계속)

radio and television broadcasting railways that cross provincial or international borders and some short-line railways road transportation services, including trucks and buses, that cross provincial or international borders telecommunications, such as, telephone, Internet, telegraph and cable systems uranium mining and processing and atomic energy any business that is vital, essential or integral to the operation of one of the above activities Federally regulated public sector (parts II and IV of the Code only): the federal public service Parliament(such as, the Senate, the House of Commons and the Library of Parliament) Private-sector firms and municipalities in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut (part I of the Code only)	지방 또는 국제 국경을 가로지르는 철도 및 일부 단거리 철도 주 또는 국경을 넘는 트럭 및 버스를 포함한 도로 운송 서비스 전화, 인터넷, 전신 및 케이블 시스템과 같은 통신 우라늄 채굴 및 가공 및 원자력 위의 활동 중 하나의 운영에 중요하거나 필수적이거나 필수적인 모든 사업 연방 규제 공공 부문(법의 II 및 IV장만 해당): 연방 공공 서비스 의회(예: 상원, 하원, 의회 도서관) 유콘(Yukon), 노스웨스트 준주(Northwest Territories) 및 누나부트(Nunavut)의 민간 부문 기업 및 지방 자치 단체(법의 I장만 해당)
---	--

다만, 연방 근로자일지라도 제3자 해결 조항을 포함하고 있는 단체협약의 적용을 받는 노동조합에 가입한 조합원은 먼저 노동조합 대표자에게 연락하여 문제 및 그 해결방법에 대해 논의하여야 한다.

둘째, 노동 프로그램에서 산정할 수 있는 임금 액수에 포함되는 것으로는 다음의 사항이 있다.

〈표 2-10〉 미지급 임금 등에 포함되는 사항

wages ²⁴⁹⁾ for hours worked including overtime ²⁵⁰⁾	시간외근로를 포함한 근로시간에 대한 임금
vacation pay	휴가 수당
general holiday pay ²⁵¹⁾	(일반)공휴일 수당
severance pay	해고 수당
pay in lieu of notice of termination of employment	해고 예고 수당

249) 임금은 수행된 근로에 대한 모든 형태의 보수를 포함하지만 팁과 기타사례는 포함하지 않는다.

250) 시간외근무는 기준근로시간을 초과하는 근로시간을 의미한다.

251) 일반 공휴일은 새해 첫날, 성금요일, 빅토리아 데이, 캐나다 데이, 노동절, 추수감사절, 현충일, 크리스마스 및 박싱데이 그리고 제195조에 따라 이러한 공휴일을 대체하는 모든 날을 포함한다.

노동 프로그램은 미지급 임금의 24개월 분까지 회수할 수 있다.²⁵²⁾ 사용자가 임금 기록을 제공하지 않는 경우, 노동 프로그램은 활용 가능한 최선의 증거들을 활용하여 임금의 액수를 정할 수 있다.

체불 근로자는 과거 내지 현재 사용자에게 받아야 할 미지급 임금 등에 관하여 신고할 수 있으며, 노동 프로그램에 이에 대해 그 신고가 근거가 있는지, 사용자가 임금 등을 지급해야 하는지에 대해서 조사를 하게 된다.

다. 노동 프로그램의 미지급 임금 회수 지원 제도

앞서 살펴 본 연방 근로기준 위반에 대한 노동 프로그램 신고 제도 중 임금 위반 사항에 대한 신고 제도를 살펴 보기로 한다. 이 경우가 노동 프로그램의 체불임금 회수 지원 제도라고 할 수 있다.

1) 제도의 특징

2019년 개정에서 미지급 임금의 회수를 위한 다음의 사항에 대한 개선을 하였다. 이른바 임금 회수 지원 제도로써 노동프로그램(the Labour Program)이라고 부르고 있고, 이를 지역적으로 관장하는 기관으로 노동 프로그램 사무소(Labour Program Office)를 두고 있다.

〈표 2-11〉 임금체불 개선을 위한 2019년 개정 사항²⁵³⁾

순번	구분	내용	장점
1	체불 액수 결정 개선	고용 또는 임금 기록이 제공되지 않는 경우, 노동 프로그램(The Labour Program)에서 임금 액수 결정	문제 해결 시간 단축
2	임금 회수 기간 연장	노동 프로그램이 체불임금의 24개월분까지 회수(12개월 이상)	근로자의 회수되는 임금액 증가
3	행정적 비용 포함	노동 프로그램은 행정 비용(총 액수의 15% 또는 200\$)을 지급 명령 액수에 추가	사용자의 자발적인 이행을 촉진시키고 문제 해결 시간 감소
4	이사(Director)의 책임 규정 강화	사용자 또는 이사가 지불 명령에 따른 지불을 하지 않는 경우 노동 프로그램은 이사의 채무자 또는 재정기관으로부터 부담	근로자들이 회복할 수 있는 임금(액) 증가
5	재심의(review)를 구하는 사용자 내지 이사에 대한 지급 선택권 추가	지불 명령에 대한 재심의 요청이 행하여졌을 때, 노동 프로그램은 금전적 지급 대신에 신용장을 받을 수 있음	심사 요청하는 사용자를 위하여 유연성 증가

252) 대륙법계 국가에서는 소멸시효제도를 규정하고 있는 반면, 영미법계 국가에서는 제소기간의 형태로 규정하고 있는데, 캐나다의 경우는 각 주의 규정에 따라 다르지만 상사채권의 경우 2년의 제소기간을 두고 있다. 따라서 미지급임금의 24개월까지로 범위를 규정한 것은 이러한 제소기간과도 관계가 있을 것이라 추측할 수 있다.

253) Employment and Social Development Canada, "Recovering Unpaid Wages - Know that Facts", 2019.

노동 프로그램을 통한 미지급 임금에 대한 회수 제도는 다음의 방향성을 염두에 두고 있다.
첫째, 신속성의 확보이다. 임금 지급의 신속성은 근로자의 생계와 직결되므로 체불 액수 결정에 있어서 종전보다 문제 해결을 단축하는 방식을 취하였다.

둘째, 사용자의 자발적 이행 촉진이다. 지급 명령 액수에 행정비용을 추가하여 부담시킴으로써 사용자가 지급 명령 전에 임의적으로 이행할 수 있도록 유도한다.

셋째, 근로자들의 보호 강화이다. 임금 회수 기간을 24개월까지로 연장하고 이사의 책임 규정을 강화하여 근로자들이 체불임금을 받을 가능성을 더 높이고 있다.²⁵⁴⁾

넷째, 사용자 측면에 있어서도 제도적 유연성이 강화되었다. 사용자가 재심의 요청시 유연성의 폭이 증가하였다.

2) 신고 제기 기간

캐나다 연방노동법은 연방 근로기준 위반 사항의 해결을 위해 절차를 제공하는 데, 이때 그 유형에 따라 별도의 신고 제기 기간이 부여된다.

〈표 2-12〉 해결 절차에 따른 신고 제기 기간

구 분	신고 제기 기간
임금 위반 사항 신고	사용자가 급여를 지급해야 하는 마지막 날로부터 6개월 이내에 신고를 제기해야 함 ²⁵⁵⁾
비임금 위반 사항 신고 예) 유연 근무제 요청에 대한 사용자의 미응답 승인된 휴식 시간의 미부여	문제를 인지한 날로부터 6개월 이내에 신고를 제기해야 함
부당 해고 신고	해고일로부터 90일 이내 제출 - 동일한 사용자와 최소 12개월 연속 고용 - 단체협약의 적용을 받지 않을 것 - 관리자가 아닐 것
유전자 검사 신고	유전자 검사 결과에 근거 내지 거부, 결과 공개 거부와 관련된 조치 또는 상황을 알게 된 날로부터 90일 이내

다만, 연방 정부 관할 사항을 지방 정부 등 다른 부서나 기관에 신고하였을 경우에는 기간이 연장될 수 있다. 이 경우에는 신고 제기시에 “신고 제기 기간 연장 자격”을 작성하여 그 사본을 동봉하여야 한다. 또한 신고에 불완전성이 있거나 오류가 있는 경우에는 기한 연장을

254) 종전에는 휴가 수당(vacation pay)은 24개월분까지 회수할 수 있었고, 다른 미지급 임금에 대해서는 최대 12개월분까지 회수할 수 있었다.(<https://kentemploymentlaw.com/recent-changes-canada-labour-code-mean/2023-10-15> 검색)

255) Canada Labour Code Subsection 250.01(2)

요청할 수 있는데, 먼저 노동 프로그램에 제출된 종전 신고를 철회하고 다시 신고를 제기하면서 신고 제기 기간 연장 자격을 작성하여야 한다.²⁵⁶⁾

3) 신고서의 작성

관련 웹사이트에서 신고 제기 양식을 다운로드하여 작성한다. 신고 양식에는 다음과 같은 정보가 포함된다. 연방 근로자의 성명, 주소 및 연락처 정보 및 사용자의 성명, 주소 및 세부 정보, 사용자와의 근무 이력, 신고 사항에 대한 세부 정보 등이다. 이를 노동 프로그램에 제출하기 전에는 반드시 신고 양식에 서명을 하여야 한다. 이러한 서명은 신고자가 제공한 정보가 정확하고 개인정보 처리방침을 읽고 이해했다는 것을 확인한다.

[그림 2-7] 노동 프로그램 신고 제기 양식 - 금전적 신고 부분 발췌

The image shows two pages of a complaint form. The first page is titled 'COMPLAINT FORM - MONETARY AND NON-MONETARY' and includes sections for 'BEFORE FILING A COMPLAINT' and 'SECTION A - YOUR PERSONAL AND WORK INFORMATION'. The second page is titled 'SECTION B - EMPLOYER INFORMATION' and includes a table for 'MONETARY COMPLAINT ALLEGATIONS' with columns for 'Standard', 'Periods covered by this complaint', and 'Estimated amount'.

금전적 또는 비금전적 신고 사항을 조사하는 동안 사용자에게 신고자의 신원을 기밀로 유지하도록 요청할 수 있다. 다만, 이 경우 신고 사항 처리를 용이하게 하고 신속하게 처리할 수 있는 가능성을 제한하여 지연을 유발할 수 있다. 더불어 기밀을 유지할 수 없는 경우가 있다.

공개는 기소의 목적을 위해 필요한 경우, 공개가 공익을 위한 경우, 또는 노동 프로그램이 신고 사항에 대한 조사를 수행하기 위해 공개가 필요하다고 결정하고 신고자가 서면으로 공

²⁵⁶⁾ Canada Labour Code Subsection 250.01(3)

개하는 데 동의한 경우 등이다. 서면으로 동의를 요청받은 후 동의를 거부하는 경우 노동 프로그램은 불만 사항을 철회한 것으로 간주할 수 있다.

4) 신고 사항과 관련된 기록 제공

신고 사항을 뒷받침하기 위해 관련 문서 또는 기록이 있는 경우 이를 제출한다. 제출하기 위해서는 관련 문서의 사본을 만들고 신고 사항 양식에 사본을 첨부하여야 한다. 다만 이 때 신고 사항 해결에 필요한 정보만을 제공하고 증인과 같은 제3자의 개인 정보는 제공해서는 안된다. 체불임금과 관련한 신고에서는 급여 명세서, 근로 계약 및 직원 기록 또는 영수증을 첨부한다. Canada Labour Code Subsection 251(1.2)은 만약 사용자가 법률상 작성, 유지 의무가 있는 근로자 관련 기록을 작성, 유지하지 않거나 또는 노동프로그램이 그 기록을 조사하거나 자료를 추출하거나 복사본을 만들지 못하게 한다면, 노동프로그램은 어떠한 다른 증거라도 사용할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 Canada Labour Code Subsection 258(3)은 임금 내지 초과근무시간의 양을 정할 때, 사용자가 요구되는 정확한 기록을 유지하지 못하였다고 판단하면, 관련 근로자는 결국 법상의 허용된 한 주의 최대 시간 동안 일한 것으로 그에 따라 완전한 주급을 받을 권리가 있는 것으로 추정되어야 한다고 규정하고 있다. 임금 또는 기타 미지급 금액과 관련된 신고 사항의 경우 신고 제기 전 24개월의 기간에 해당하는 문서나 기록을 제공한다.

5) 신고서의 제출

작성한 신고 양식과 증빙 서류를 이메일을 보내거나 가장 가까운 노동 프로그램 사무소에 우편으로 제출한다. 각 지역 노동 프로그램 사무소는 다음과 같이 분포되어 있다.

〈표 2-13〉 각 지역 노동 프로그램 사무소

구분	지역 사무소
북서 태평양 지역	캘거리 에드먼턴 밴쿠버
노스웨스트 준주, 누나부트 및 유콘	밴쿠버 주소에 우편으로 보냄
중부 지역(매니토바, 서스캐처원)	위니펙
온타리오	오타와, 토론토, 런던
퀘벡	몬트리올 퀘벡 시티
대서양지역(뉴브런즈윅, 뉴펀들랜드, 노바스코샤, 프린스에드워드아일랜드)	명크턴(Moncton, 뉴브런즈윅)

6) 신고의 처리

노동 프로그램에 신고를 제기하면 확인 편지를 받는다. 신고가 받아들여지는 경우 노동 프로그램에서 조사를 실시하게 된다. 신고 사항 전체 또는 일부에 근거가 있는 경우, 노동 프로그램은 사용자에게 위반 사항을 시정하도록 요청한다.

임금 위반 사항 신고의 경우 신고 제기 기간인 6개월 이내 제출된 신고만을 접수하고 조사하며, 신고가 성립되는지 여부와 사용자가 임금 등을 미지급하고 있는지를 결정한다.

구체적으로 크게 다음의 두 가지로 신고가 처리될 것이다.

첫째, 근로자의 사용자가 임금 등을 지급해야 하는 경우이다. 노동 프로그램은 미지급 임금 등에 대한 근로자의 신고가 근거가 있고 근로자의 사용자는 근로자에게 임금을 지급하여야 한다고 판단할 수 있다. 이러한 경우 노동 프로그램은 먼저 근로자의 사용자에게 자발적으로 미지급 임금 등을 지급할 것을 요청한다. 만약 사용자가 자발적으로 미지급 임금 등을 지급하고 사용자가 지급할 액수에 동의한다면, 노동 프로그램은 당해 신고 사건을 종결하게 된다. 만약, 사용자가 지불할 임금액에 대하여 동의하지 않을 경우, 노동 프로그램은 사용자에게 임의적 준수 통지를 보낼 수 있다. 이것은 사용자에게 재심을 요구할 기회를 부여할 수 있다. 만약 사용자가 자발적으로 따르지 않는다면, 노동 프로그램은 지급 명령²⁵⁷⁾을 사용자 또는 법인 회사의 이사에게 내릴 수 있다.

둘째, 사용자에게 미지급 임금 등이 없는 경우이다. 노동 프로그램은 근로자의 사용자가 근로자에게 지급할 임금 등이 없다는 것을 확인할 수 있다. 이러한 경우 근로자와 사용자는 서면으로 노동 프로그램의 결정서를 받을 것이고, 신고가 근거가 없다는 통지를 받게 된다. 이 경우 통지에서는 근로자에게 사용자는 연방법을 준수하고 있다는 것을 알리고 근로자에게 재심의 요청을 할 수 있다는 내용을 담게 된다.²⁵⁸⁾

만약 노동 프로그램이 조사를 통하여 사용자가 연방노동법을 계속 미준수하고 있다는 것을 알게 되면, 사용자에게 연방노동법상의 사용자 책임을 알릴 것이다. 그럼에도 불구하고 사용자가 연방노동법을 준수하지 않으면, 노동 프로그램은 행정 벌금을 포함하여 강제적 조치를 하게 된다.

257) Canada Labour Code Subsection 251.1(1)

258) Canada Labour Code Subsection 251.1(2)

라. 노동 프로그램의 행정 벌금(Administrative Monetary Penalties/이하‘AMT’)

1) 행정 벌금의 목적

행정 벌금(AMT)은 캐나다 연방노동법 및 관련 규정을 준수하지 않는 것에 대한 금전적 억제책으로 작용한다. 행정 벌금은 관련 법의 준수를 독려하며, 기존의 시행 조치를 보완하는 역할을 하고, 기소에 대한 대안으로 사용되는 것이다.

노동 프로그램은 교육 및 의식 전환을 통해 사용자가 캐나다 연방노동법을 준수하도록 지원하고 장려하는데 중점을 두고 있으며, 행정 벌금은 자율 준수 조치를 다한 후에도 규정 미준수가 지속되는 경우에 부과된다. 그러나 위반의 심각성과 근로자에 대한 영향 또는 위반의 재발로 인해 노동 프로그램이 규정 준수 및 집행 프로세스 초기에 행정 벌금을 부과해야 하는 경우도 있다. 더불어 행정 벌금을 부과했는데도 미준수를 방지하는데 도움이 되지 않고 위반이 지속되는 경우 노동 프로그램은 사용자에게 행정 벌금을 부과할 수 있다.

기소되어 형사적 처벌을 하는 것에 대안으로서 활용된다는 점과 법원이 아니라 행정기관이라고 할 수 있는 노동 프로그램에서 부과한다는 점에 있어서 이를 임금체불에 대한 형사처벌이라고 할 수 없다.

더불어 후술하다시피 행정 벌금은 국가에 납부하는 것으로서 임금체불을 겪고 있는 근로자에게 지불하는 것이 아니다. 이러한 점에서 징벌적 손해배상이라고 볼 수도 없다. 캐나다는 임금체불에 있어 징벌적 손해배상제도를 두고 있지 않다.

앞서 언급한 바와 같이 행정 벌금은 관련 법의 준수를 독려하며, 기존의 시행 조치를 보완하고, 형사처벌(기소)에 대한 대안 역할을 한다는 점에서 똑같지는 않지만, 우리나라의 이행강제금과 유사한 성격을 가지고 있다고 생각한다. 이행강제금 제도는 부당해고에 있어 구제 명령의 실효성을 확보하기 위한 것으로 행정기관인 노동위원회가 부과한다는 점 등에 있어서 유사한 점이 발견된다.

2) 행정 벌금의 대상

캐나다 연방노동법의 조항, 지침, 지급 명령 등을 위반하거나 준수하지 않는 경우 행정 벌금을 부과할 수 있다. 인적 대상으로는 사용자, 직장 내 자신이나 타인의 건강과 안전을 위협하는 무모하거나 고의적 행동에 연루된 직원, 임원, 법인의 이사 또는 대리인, 관리 또는 감독 기능을 수행하는 고위 공무원, 연방 부서 또는 기타 정부 기관 등이다.

3) 행정 벌금의 산정

위반 범주를 구분하고 이에 따라 구분하여 부과되는데, 첫 번째로는 위반 유형과 사업의 규모를 고려하여 계산한다. 이를 기준 금액이라고 하는데 아래의 공식에 따라 계산한다.

두 번째 또는 그 이후의 벌금 금액의 기준 금액에 반복적인 위반에 대한 기준 금액의 200%를 더한다.

〈표 2-14〉 위반 횟수에 따른 벌금 산정 공식

구분	산정 공식
첫 번째 위반	기준 금액 (첫 번째 벌금) = 위반 유형 + 사업 규모
두 번째 또는 후속 벌금	두 번째 (및 후속 벌금) = 기준 금액 + 2 × 기준 금액

4) 행정 벌금에 대한 이의(review) 제기

행정 벌금 통지서가 송달된 날로부터 30일 이내에 벌금액 내지 위반 사실에 대한 검토를 서면으로 요청할 수 있다. 이의를 제기받은 경우 이는 재심의(노동 프로그램이 검토) 또는 항소(위원회 회부)로 처리될 수 있다.

검토에 대한 결정이 내려지면 서면으로 통보되는데, 다음의 두 가지로 결정되게 된다.

〈표 2-15〉 위반 여부에 따른 서면 통보 내용

구분	내용
위반이 없는 경우	노동 프로그램은 위반 통지를 취소 벌금을 지불할 필요 없음
위반이 확인되는 경우(벌금액 유지, 확인, 변경)	벌금 지불 결정에 동의하지 않는 경우 서면으로 이의 제기(15일 이내) 위원회에 항소 요청서를 보내야 하며, 항소 사유에 대한 진술이 포함되어야 함

5) 벌금 미납의 경우

노동 프로그램 웹사이트에 이름이 공개될 수 있다. 또한 벌금은 캐나다의 권리로서 이는 여왕에게 빚을 지는 것이므로, 금액을 지불하지 않으면 캐나다 국세청에서 징수 조치를 취할 수 있다.

6) 위반 사용자의 공개

근로 기준의 경우 일반적으로 근로자의 삶과 생계에 영향을 미치는 근무 조건에 대한 심각성과 영향에 따라 위반 유형을 분류한다. 노동 프로그램은 AMP가 지급되고 AMP를 발생시킨 조항 준수 확인 후 2년이 지나면 사용자의 이름과 관련 정보를 제거한다.

마. 캐나다 연방법원에 제출된 지급 명령과 지급 명령의 게시

지급 명령은 준법집행책임자(노동 프로그램)가 사용자 또는 기업의 이사에게 발행하는 법적 문서 및 집행 도구라 할 수 있다. 임금 및 지급 의무 있는 기타 금액을 회수하기 위해 사용자의 준수를 얻기 위한 자발적인 시도가 실패했을 때 발급된다. 사용자에게 대한 지급 명령이 준수되지 않는 경우, 준법집행책임자는 캐나다 연방법원에 사용자에게 부과한 지급 명령을 제출할 수 있다. 이는 명령이 해당 법원에서 받은 판결과 동일한 효력을 갖는다는 것을 의미한다.

연방법원에 제출된 지급 명령을 받은 사용자의 명단 공개는 다음 세 가지 기준 중 하나가 충족될 때 발생한다. 첫째, 연방법원에 제출된 지급 명령의 액수가 \$5,000 이상인 경우, 둘째, 18개월 동안 총 \$5,000 이상에 대해 연방법원에 제출된 사용자에게 대한 2회 이상의 지급 명령이 있는 경우, 또는 지난 18개월 동안 총액이 \$5,000 미만인 사용자에게 최소 3번의 지급 명령을 제출한 경우.

게시된 정보는 캐나다 정부 웹사이트에서 2년 동안 사용할 수 있으며 그 이후에는 노동 프로그램에 의해 사이트에서 제거된다. 노동 프로그램은 제거된 정보를 보관하며 정보 액세스 요청을 통해 사용할 수 있다.

〈표 2-16〉 연방법원에 제출된 지급 명령을 받은 사용자들에 대한 게시 예

Filter items Showing 1 to 10 of 41 entries | Show entries

Region	Employer Name	Date Payment Order Issued	Date Filed in Federal Court	Violation(s) Section/Subsection
NWP	V Trans Ltd.	April 22, 2021	May 25, 2022	Section 188 - Vacation Pay Section 247 - Payment of Wages
NWP	V Trans Ltd.	April 22, 2021	May 25, 2022	Section 188 - Vacation Pay Section 197 - Additional Pay for Working on a Holiday Section 247 - Payment of Wages
NWPR	Transport Ivan Pascal Inc.	April 16, 2021	May 26, 2022	Section 188 - Vacation Pay Section 196 - General Holiday Pay Section 247 - Payment of Wages Section 254.1 - Unauthorized Deductions
NWPR	Transport Ivan Pascal Inc.	July 9, 2021	May 20, 2022	Section 188 - Vacation Pay Section 196 - General Holiday Pay Section 247 - Payment of Wages Section 254.1 - Unauthorized Deductions

당해 게시에서는 지역, 사용자의 성명, 지급 명령 날짜, 연방법원에 제출된 날짜, 위반 조항이 표시된다.

바. 미지급 임금에 대한 이사의 책임

1) 임금체불과 이사의 책임간의 딜레마

근로계약의 핵심은 임금의 대가로 서비스를 수행하는 것이다. 것처럼 노동은 노동시장에서 사고 팔리는 가능성을 가지는 물건의 형태로 간주된다. 그러나 노동은 그것을 소유하는 자로부터 분리될 수 없고 시장을 위해서 생산되지도 않는다. 그렇기 때문에, 노동은 특별한 가상적 재화로 여겨져 왔다.

이러한 인식을 통한 법적 규율방식은 한 편으로는 사용자들이 근로자들로부터 그들이 구입한 노동의 가치를 추출할 수 있게 만들었다. 반면 다른 한편으로는 근로자들이 받아들일 수 없는 착취로부터 보호할 필요성이 생겨나게 되었다. 이러한 상황에서 법은 일련의 순환적인 딜레마들에 마주하게 되었다. 그것은 구조적으로 노동의 특별한 상품적 지위에서 기인하는 것이고 사회적이고 정치적으로는 노동자와 사용자의 이해 관계의 갈등으로부터 기인하는 것이다.

임금체불 노동자의 임금에 대한 주주와 이사의 책임, 임금 보호에 대한 순환적 딜레마는 노동을 먼저 제공하고 임금을 지불하는 일반적 관행으로부터 발생한다. 이는 결과적으로 노동자들은 그들의 사용자의 채권자들이 되고, 그들은 지불받지 못할 수 있는 위험을 감수할 수밖에 없게 된다. 그러나 노동자들이 그들이 제공하는 노동에 대해서 보수를 지불받지 못하는 것은 용납될 수 없다. 임금체불은 사용자들의 가장 근본적인 계약 의무 위반이다. 그것은 근로자들과 근로자들로부터 생계를 유지하는 가족에게 고통을 주는 원천이 된다. 근로자와 그의 가족의 기본적 필요의 충족은 오로지 임금에 의존할 수밖에 없다. 그 결과, 근로자의 임금이 지불되지 않았을 때, 생계에 주는 타격과 노동의 상품으로서의 가상적 본질에 대한 의문의 제기, 부정의의 발생에 대한 인식이 넓게 퍼졌다. 그러므로 노동자들의 임금의 보호가 고용법의 역사에서 뿌리가 깊다는 것은 놀라운 일이 아니다.

임금 보호는 수많은 형태를 가져왔는데, 임금 회복을 위한 소송에 특별한 절차 부여, 파산 절차에서 몇 가지 우선권 부여, 노동 수행에 따른 가치 증가의 자산에 대한 선취특권들(liens)의 부여; 종속 계약자에 대한 계약자의 책임. 그리고 근로자들에 대하여 회사(corporation-법인 회사)가 지불하여야 할 체불임금에 대한 주주 또는 이사의 책임 등이 그것이다.

특히 그간 상법은 이사의 책임을 제한하는 방향으로 발전해 왔는데, 임금체불에 대한 이사의 책임은 상법과의 충돌과도 문제되는 사항이다. 법원에서도 체불임금의 보호의 이사의 책

임 제한에 있어 균형을 찾기 위해 노력해 왔다.²⁵⁹⁾

2) 이사의 책임

일반적으로 법인의 이사나 임원은 개별적으로 법인의 채무에 대해 책임지지 않는다. 이러한 법인과 개인 책임의 분리는 많은 회사들이 법인으로 설립되는 이유 중 하나이기도 하다. 그러나 캐나다에서는 회사의 고용기준위반 행위에 대해 이사나 임원에 대해서 개인 책임을 묻는 경우도 있다. 따라서 관할에 따라 연방노동법과 각 주의 고용기준법 등을 살펴볼 필요가 있다.

캐나다의 연방노동법은 연방 근로자들이 사용자로부터 임금 회복이 여의치 않고 불가능할 경우에 대해 규정하고 있다. 이 경우 노동 프로그램은 법인의 이사들에게 책임을 지울 수 있다. 그 액수는 회사의 미지급 임금 전액은 아니고, 이사로서 그들이 있었던 기간 동안 사용자가 지불해야 하는 미지급 임금액에 대하여 책임을 지게 된다. 법인 회사의 이사는 공동으로 그리고 개별적으로 근로자들의 임금에 대하여 책임이 있다. 다만 6개월분의 임금에 해당하는 부분까지만 제한된다.

각 지역에 따라 주법이 적용되는 경우는 어떠한 주법이 적용되느냐에 따라서 법인의 이사나 임원의 체불임금에 대한 책임 여부와 범위가 달라지게 된다. 이하에서는 그 내용을 각 지역별로 정리한 것이다.

〈표 2-17〉 미지급 임금에 대한 이사의 책임(연방 및 각 주별 구분)²⁶⁰⁾

구분	내용	근거
연방	법인의 이사는 법인으로부터 금액을 회수할 가능성이 없거나 불가능한 경우 연대하여 재임기간 동안 발생한 임금에 대한 책임을 진다. 그 제한은 6개월(분)까지에 한한다.	Canada Labour Code, Sec. 251.18
알버타	법인의 이사는 연대하여 재임기간 동안 발생한 6개월의 임금에 대한 책임을 가지고 있다. 그러나 다만, 법인이 파산선고를 받은 날로부터 6개월 이내에 청산, 해산 또는 파산선고를 받은 날로부터 6개월 이내에 청구할 수 있는 경우에 한한다.(법인이 채무를 변제할 수 있다고 합리적인 근거에 의하여 판단되는 경우에는 이사의 책임은 없다)	Employment Standards Code, Sec. 119

(계속)

259) Eric Tucker, "Shareholder and Director Liability for Unpaid Workers' Wages in Canada: From Condition of Granting Limited Liability to Exceptional Remedy", OSGOODE HALL LAW JOURNAL(26), YORK UNIVERSITY, 2008 참조.

260) <https://hrinsider.ca/corporate-director-liability-for-unpaid-wages-know-the-laws-of-your-province/?print=print>(2023. 10. 15. 검색)

구분	내용	근거
브리티시 컬럼비아	법인의 이사 및 임원은 재직 중에 받았거나 지급되었어야 할 근로자 1인당 2개월 이내의 임금에 대해 개인적으로 책임을 진다. 다만, 다음의 경우에는 개별 책임을 지지 않는다. (i) 개별 또는 집단적 해고 통지 또는 법인이 관리 중이거나 특정한 파산 조치의 대상이 될 경우 지급해야 할 금전, (ii) 퇴직 후 지급해야 할 휴가 수당 또는 (iii) 퇴직 후 직원의 타임 बैं크(time bank)에 남겨진 돈	Employment Standards Act, Sec. 96
매니토바	이사 또는 종전 이사는 법인의 직원 또는 종전 직원에 대해 다음과 같이 연대 책임을 진다. (i) 재직했던 6개월 이내의 휴가 수당을 제외한 임금, (ii) 재직했던 22개월 이내의 휴가 수당 (제외: 통지에 갈음한 임금 등)	Employment Standards Code, Sec. 90
뉴브런즈윅	이사 또는 종전 이사는 사원 또는 종전 사원에 대해 법인과 연대하여 책임을 진다. (i) 이사 재직시 6개월 이내의 임금, (ii) 이사 재직시 12개월 이내의 휴가 수당 (적용되지 않는 경우로는 (a) 행정 벌금, (b) 비영리 이사 및 (다) 2년 이상 이사로 재직하지 않은 종전 이사. 그리고 이사 또는 종전 이사가 미지급된 금액의 지급을 위해 합리적인 주의를 기울인 경우 책임이 없음)	Employment Standards Act, Sec. 65
뉴파운드리랜드 앤 래브라도	법인의 이사와 임원은 임금체불에 대해 개별 책임이 없음	
노바 스코샤	법인의 이사와 임원은 임금체불에 대해 개별 책임이 없음	
온타리오	이사는 다음과 같은 경우에 연대하여 6개월 이내의 임금에 대한 책임을 진다. (i) 사용자가 파산한 경우, 근로자가 인수자(receiver) 또는 파산관재인에게 미지급 임금 청구를 제기하고 청구액이 지급되지 않은 경우, 또는 (ii) MOL 고용 기준 담당자가 고용주 및/또는 이사에게 임금을 지급할 책임이 있다는 명령을 내린 경우, (b) 이사에게 임금을 지급할 책임이 있는 경우	Employment Standards Act, Sec. 81
프린스 에드워드 아일랜드	법인의 이사는 연대하여 재임시 6개월 이내의 임금에 대하여 책임을 진다. (i) 법인이 파산한 경우, 파용자가 인수인 또는 파산관재인에게 미지급 임금을 청구한 경우, 또는 (ii) (☞)정부가 법인에게 지급을 명하고 법인이 30일 이내에 지급을 하지 않는 경우	Employment Standards Act, Sec. 5.7
퀘벡	법인의 이사와 임원은 임금체불에 대해 개별 책임이 없음	
서스캐처원	법인의 이사는 연대하여 재임시 발생하여 지급되지 않은 최대 6개월 (분)의 임금에 대해 책임을 진다.	Sask Employment Act, Sec. 2-68
노스웨스트 준주	법인의 이사와 임원은 임금체불에 대해 개별 책임이 없음	
누나부트	법인의 임원 및 이사는 각 직원이 임금을 받지 못한 경우에 대하여 2개월 이내의 체불임금에 대해 책임을 진다.	Labour Standards Act, Secs. 61 and 60
유콘	법인의 이사는 이사로 재직하는 동안 행해진 용역(services)에 대한 2개월(분) 이내의 임금을 연대하여 책임진다.	Employment Standards Act, Sec. 86

사. 형사처벌(기소)

캐나다 연방노동법에서 형사처벌(기소)을 규정하고 있는 경우는 중대한 위반(serious offences)이나 사용자의 법준수에 대하여 다른 규율방식이 실패한 경우들 등이다. 주로 건강과 안전에 관하여 규정하고 있는 캐나다 연방노동법 제2장(Part II)과 캐나다의 노동기준을 규정하고 있는 제3장(Part III)과 관련하여 당해 규정과 지침(regulations), 명령(order)을 위반하는 경우이다.

Canada Labour Code Subsection 256(1.1)에서는 사용자가 법인(corporation)인 경우와 그 외의 경우를 구분하여 처벌을 규정하고 있다.

〈표 2-18〉 연방 노동기준 위반의 경우 형사처벌

구분	법인인 사용자	그 외의 경우
첫 번째 위반	\$50,000 이하	\$10,000 이하
두 번째 위반	\$100,000 이하	\$20,000 이하
그 후의 위반	\$250,000 이하	\$50,000 이하

선고가 된 날 이전 5년 동안의 기간 내에서 앞선 위반을 고려하여 두 번째(계속된) 위반 여부 등을 결정한다.

4. 소 결

임금체불과 관련하여 캐나다 연방노동법상의 규정을 중심으로 살펴보면, 임금체불에 대해서 캐나다 노동법은 행정적 절차 및 형사처벌을 병용하고 있다고 할 수 있다. 다만, 임금체불 문제에 있어 가장 중요한 것은 근로자가 체불임금을 사용자로부터 지급받는 것이므로 행정적 절차가 중심이 된다고 할 수 있다. 형사처벌은 임금체불을 포함하여 캐나다 연방노동법상 규정된 노동기준 준수를 위한 것이다.

캐나다 연방노동법상의 임금체불 해결 시스템을 중심으로 그 규율 내용을 살펴보면 다음과 같았다. 캐나다 연방노동법은 연방 노동기준을 정립하고 있고, 이에 대한 위반이 있는 경우 구제 시스템으로 일명 ‘노동 프로그램’이라는 지칭하는 일종의 행정 절차를 두고 있다.

연방 노동기준의 위반에 대해서는 4가지 형태의 신고(Complaints)를 준법집행책임자(The Head of Compliance and Enforcement)²⁶¹⁾에게 할 수 있다. 그 4가지 중 하나의 형태

261) 캐나다 연방노동법은 “Head means the Head of Compliance and Enforcement designated under subsection 122.21(1)”로 정의하고 있는데, 여기서는 준법집행책임자로 번역하였다.

가 바로 임금체불에 해당하는 경우이다.

임금체불이 발생한 경우 연방노동법의 적용을 받는 연방 근로자는 6개월 내에 신고를 제기하여야 한다. 일정한 서식을 갖추어 관련 증거서류의 사본을 첨부하여 지역 노동 프로그램 사무소에 이메일, 우편 등으로 제출한다. 이에 대해 노동 프로그램에서 근거가 있는지를 검토하여 결정을 내리게 된다.²⁶²⁾ 신고가 근거가 있고 체불액 등이 결정되면, 먼저 사용자의 자발적 이행을 유도한다. 그러나 자발적으로 체불임금의 지급을 완료하지 않는 경우 노동 프로그램은 지급 명령(payment order)을 사용자에게 부과할 수 있다. 만약에 지급 명령도 이행하지 않는 경우라면 노동 프로그램은 연방법원에 지급 명령을 제출하고 이를 인정받게 되면 이 지급 명령은 판결과 동일한 효력을 갖게 된다. 또한 자발적 이행을 하지 않는 경우 행정 벌금을 부과할 수도 있다.

캐나다에서는 임금체불에 대해서 임금절도라는 표현을 일상적으로 사용하기는 하지만 법적인 표현은 아니다. 캐나다는 과거 임금절도를 형법전에 규정하기는 하였지만 실제로 이를 적용하지는 않았었다. 이러한 관점에서 보았을 때, 임금체불이 갖는 불법성을 특별히 평가하여 사용자에게 대해서 형사처벌하지는 않는다고 할 수 있다. 다만 캐나다 연방노동법 준수의 강제를 위하여 연방노동법이 규정한 노동기준을 준수하지 않는 경우 사용자가 회사인지 여부와 위반 횟수를 고려하여 일정한 벌금을 부과하는 형사처벌 규정을 가지고 있다.

캐나다 연방 차원에서는 임금체불을 포함하여 일반적인 노동기준의 준수를 위하여 형사처벌 규정을 가지고 있으나 임금체불 구제의 핵심적 절차는 행정적 구제제도가 중심이 된다. 따라서 이른바 ‘노동 프로그램(Labour Program)’이라는 일종의 행정적 구제 제도를 활용한다. 이러한 노동 프로그램의 실효성을 보장하기 위한 장치가 지급 명령과 행정 벌금이다. 또한 연방 근로기준을 위반한 사용자의 정보 게시 제도도 시행하고 있다. 또 한 가지 특징적인 것이 있다면 회사의 이사 내지 임원에 대하여 임금체불에 대한 일정한 책임을 지도록 규정하고 있다는 점이다.

2019년 개정에서 미지급 임금의 회수를 위하여 다음의 사항에 대한 개선을 하였다. 따라서 노동 프로그램을 통한 미지급 임금에 대한 회수 제도는 다음의 방향성을 염두에 두고 개선되게 되었다. 첫째, 신속성의 확보이다. 임금은 근로자의 생계와 직결되므로 신속한 지급의 확보가 관건이 된다. 체불액의 결정에 있어서 종전보다 문제 해결을 단축하는 방식을 취하였다. 둘째, 사용자의 자발적 이행 촉진이다. 지급 명령 액수에 행정비용을 추가하여 부담시킴으로써 사용자가 지급 명령 전에 임의적으로 이행할 수 있도록 유도한다. 셋째, 근로자들의 보호 강화이다. 임금 회수 기간을 24개월까지로 연장하고 이사의 책임 규정을 강화하여 근로자들

262) 캐나다 연방노동법은 노동 프로그램이라는 용어를 사용하지 않고 준법집행책임자인 ‘The Head’로 표현하고 있지만, 관련 제도를 설명하고 있는 캐나다 정부 홈페이지에서는 The Head라는 법률용어 대신에 노동 프로그램이라는 용어를 사용하고 있다. 이하에서는 노동 프로그램과 준법집행책임자를 혼용하여 사용한다.

이 체불임금을 받을 가능성을 더 높일 수 있도록 하였다. 넷째, 사용자 측에도 절차적 유연성을 부여하였다. 사용자가 재심의를 요청하는 경우 보다 유연한 선택이 가능할 수 있도록 하였다.

다만, 이러한 개선이 실제로 미지급 임금의 감소시키거나 사용자의 임의적인 지급을 촉진했는가, 즉 개선이 실효적이었는지 여부에 대해서 평가 내리기에는 현재까지는 조심스러운 면이 있다. 이에 대해서는 이러한 개선책을 시행한 이후 변화에 대한 캐나다의 통계를 살펴볼 필요가 있는데, 연방국가의 특징상 그 통계를 찾기가 어려웠다. 그러나 여러 신문 기사들을 통해 단편적으로 보여지는 점은 여전히 캐나다의 외국인 근로 등 취약 계층의 근로에 대하여 소위 “임금절도”가 지속적으로 문제되고 있는 상황이라는 것이다. 이렇게 본다면, 캐나다의 임금체불에 대한 문제는 여전히 현재진행형이라고 평가할 수 있다.

제3절 일본의 임금체불 구제 절차와 사업주의 책임

1. 개 관

일본에서는 임금은 노동기준법 제11조에 따라 “이 법률에서 임금이란, 임금, 급료, 수당, 상여, 기타 명칭의 여하를 불문하고, 노동의 대상(대가)로서 사용자가 근로자에게 지급하는 모든 것을 말한다”고 정의되어 있다.

일본의 헌법 제27조 제2항에서 “임금, 취업규칙, 휴식, 기타 근로조건에 관한 기준은 법률에서 이를 정한다”고 규정하고 있는데, 이 헌법 제27조 제2항에 근거로 “임금, 취업규칙, 휴식, 기타 근로조건에 관한 기준”을 정한 법률이 노동기준법이다.

노동기준법 제11조에서 말하는 “임금”은 ① “노동의 대상(대가)”로서, ② “사용자가 근로자에게 지급”하는 모든 것을 의미하고, 명칭에 관계없이 실태로서 ①, ② 요건을 충족시키면 금전에 한정되지 않고 물건이나 이익이라고 해도 노동기준법상의 “임금”에 해당되게 된다.

또한 노동기준법상의 “임금”의 정의는 임금지급방법에 관한 제원칙(제24조) 등의 노동기준법상의 임금보호규정에서의 임금의 의미를 명확히 하는 목적과 형벌법규에서의 범죄구성요건의 한 요소로서의 의미를 가지고 있다고 볼 수 있다. 그렇기 때문에, 노동기준법상의 임금은 사용자와 근로자와의 합의내용 여하에 관계없이 노동기준법 제11조에서 규정된 정의에 근거로 하여, 객관적이고 일의적으로 명확하게 되는 것으로, 사용자와 근로자와의 합의에 맡겨지는 민법상의 “보수”와는 반드시 동일한 개념이라고는 할 수 없다.²⁶³⁾

263) 石峯信憲編, 『賃金規制・決定の法律実務』, 中央経済社, 2022, p. 15.

따라서 임금이 지급되지 않으면 근로자의 생활에 중대하고 심각한 영향을 미치게 되고, 그래서 노동기준법, 기타 법률은 사용자가 경영위기에 처하고, 더 나아가 도산한 경우도 포함하여 근로자에 대한 임금 지급을 확보하기 위하여, 사용자에게 대한 임금지급의 강제, 사용자에게 대신하여 임금의 입체불(이하에서는 “대지급금” 이라고 함), 도산시의 임금의 우선적 취급 등을 규정하고 있다.

2. 임금채권 이행 확보 방안

가. 노동기준법에 의한 이행강제 방안

1) 임금체불과 사용자 책임²⁶⁴⁾

노동기준법은 근로자에 대한 임금 지급을 확보하기 위하여, 임금전액불 원칙과 일정기일 지급의 원칙을 규정하고 있으며(노동기준법 제24조), 이러한 준수를 감독행정과 벌금(동법 제120조) 등으로 도모하고 있다.

주로, 일본에서 임금체불과 관련하여, 문제가 되기 쉬운 경우는 다음과 같다.

- (1) 연장근로, 휴일근로, 심야근로의 할증임금체불이 있는 경우,
- (2) 정액잔업비(고정잔업비, 간주잔업비 등 우리나라의 포괄임금제로 볼 수 있음)의 요건을 충족시키고 있지 못한 경우,
- (3) 선택적 근로시간제나 변형근로시간제 하에서의 할증임금체불이 있는 경우,
- (4) 관리직의 할증임금체불이 있는 경우,
- (5) 임금지급 5원칙(노동기준법 제24조: 현물급여의 금지, 직접불 원칙, 전액불 원칙, 매월 1회 이상 원칙, 일정기일지불 원칙)에 반하는 경우 등이 문제가 되고 있음.

즉, 일본에서는 임금지급 5원칙에 위반한 경우에는 “30만엔 이하의 벌금”(노동기준법 제120조 제1호)에 처해지게 된다. 그리고 임금체불에 대한 벌칙 규정으로는 노동기준법상에 규정되어 있는데, 할증임금 등의 임금체불에 대해서는 “6개월 이하 징역 또는 30만엔 이하의 벌금”(노동기준법 제119조 제1호)에 처해진다.

이러한 벌칙의 대상은 각 규정에 위반한 자로, 사업주에 한정되지 않는다. 사업주가 아닌

264) 石寄信憲編, 『賃金規制・決定の法律実務』, 中央経済社, 2022, p. 1008.

사용자(사업주를 위해 행위를 하는 자), 관리직에 의한 위반행위가 있는 경우에는 사업주도 위반자와 마찬가지로 벌금형이 부과된다(징역형은 대상이 아님). 다만 사업주가 위반의 방지에 필요한 조치를 취한 경우에는 이 규정은 적용되지 않는다(노동기준법 제121조 제1항).

2) 부가금 제도²⁶⁵⁾

상기와 같이 임금체불에 대해서는 사용자에게 대한 제재의 취지로 “부가금”이 규정되어 있다. 부가금은 근로자가 체불잔업비와 함께 청구하여 법원이 판결로 사용자에게 명하는 것이다(노동기준법 제114조). 부가금의 금액은 조문상으로는 체불잔업비와 “동일한 금액”으로 규정되어 있는데, 실무에서는 사용자측의 위반 정도나, 근로자 측이 입은 불이익 정도 등 개별 구체적인 사정을 고려하여 “체불액과 동일한 금액을 상한으로” 부가금이 결정되는 경우가 많다.

노동기준법은 사용자가 ① 해고예고수당(제20조), ② 휴업수당(제26조), ③ 시간외·휴일·심야노동을 한 경우의 할증임금(제37조), ④ 연차유급휴가를 취득한 경우의 임금(제39조 제9항)을 지급하지 않은 경우에 법원은 근로자의 청구로 체불액 외에, 이와 동일한 금액의 부가금 지급을 명령할 수 있는 것으로 되어 있다(제114조). 즉, 부가금은 상기의 해고예고수당, 휴업수당, 할증임금, 연차유급휴가에 한정하여 부가금을 청구할 수 있는 것이다.

이 부가금의 청구는 지급의무 위반이 있었던 때로부터 5년 이내에 청구해야 한다(제114조 단서). 법 개정으로 2020년 4월 1일 이후 부가금 청구기간이 5년으로 연장되었는데, 경과조치로 당분간은 3년으로 되어 있다(제143조 제2항).²⁶⁶⁾

한편, 체불임금에 대한 부가금 지급 명령과 관련해서는 앞서 살펴본 것과 같이 노동기준법 제37조는 근로자를 시간외, 휴일, 심야에 노동시킨 경우, 법정 할증률을 계산한 할증임금을 지급해야 한다고 규정되어 있다. 시간외 근로 등에 대한 할증임금의 체불이 있는 경우, 법원은 근로자의 청구로 사용자에게 체불액과 동일한 금액의 부가금 지급을 명령할 수 있다(제114조). 즉 법원으로부터 부가금 지급을 명령받은 경우, 사용자는 체불액의 두 배의 금전적 부담을 가지게 된다.

이에 대해서는 법원은 사용자에게 의한 동법 위반의 정도·양태, 근로자가 입은 불이익의 성질·내용 등 제반 사정을 고려하여 지급의무 존재여부 및 금액을 결정할 수 있다고 해석한다.²⁶⁷⁾

265) 石崎信憲編, 『賃金規制・決定の法律実務』, 中央経済社, 2022, pp. 392~393.

266) 일본에서 상기와 같이 부가금 청구기간이 5년으로 변경된 이유는, 2020년 4월 1일부터 시행중인 민법의 개정에서, 관련 법의 개정이 함께 이루어졌기 때문이다. 일본에서 사회경제정세 변화에 비추어, 민법의 일부를 개정하는 법률(2017년 6월 2일 공포)에 따라, 민법에 대하여 소멸시효의 기간의 통일화 등 시효에 관한 규정을 정비, 법정 이율을 변동시키는 규정의 신설 등이 이루어졌다. 이에 따라 노동기준법 제115조의 임금청구권 소멸시효기간의 연장이 이루어져, 개정전에는 임금청구권의 소멸시효기간이 2년이었는데 5년으로 연장(당분간은 그 기간이 3년)되었으며, 또한 노동기준법 제114조의 부가금의 청구기간이 연장되었는데, 이도 개정전에는 부가금의 청구가능 기간이 2년이었는데 5년으로 연장(당분간은 그 기간이 3년)되게 되었다.

그러나 법원이 부가금의 지급을 명령하는데 있어서 사용자에게 특별한 귀책사유가 있는 것이 요건으로 되어 있는 것은 아니고, 법원에서 시간외 수당의 체불이 있다고 인정된 경우에, 함께 부가금 지급을 명령할 가능성이 상당히 높은 경향이 있다.

3) 지연손해금

할증임금을 포함한 임금전반(상여, 퇴직금 등도 포함)에 체불이 있는 경우, 체불이 지연하고 있는 동안의 이자에 상당하는 지연손해금이 발생한다. 할증임금에 체불이 있는 경우 본래 지급해야 하는 날의 다음날부터 계산하여 체불이 지연되고 있는 기간의 이자에 상당하는 것으로서, 사용자는 지연손해금을 지급해야 할 의무를 가진다. 임금은 채권의 일종이므로, 정해진 기일에 지급되지 않으면 채무불이행으로서 지연손해금이 발생한다.

이율에 대해서는 일본 상법 제514조에서 “상행위로 인해 발생하는 채무에 관해서는 법정 이율은 연 6%로 한다”고 규정되어 있었는데, 상법 제514조가 2020년 4월 민법 개정에 따라 삭제되어, 현재는 민법상의 법정 이율과 같은 3%로 되어 있다.

그리고 지연손해금의 청구기한은 할증임금과 마찬가지로 3년이다. 또한 할증임금청구의 소 멸시효는 과거 2년이었는데, 2020년 4월 민법 개정으로 당분간 3년으로 되었다(향후 시기 미정으로 5년으로 될 예정이다).

나. 임금의 지급확보 등에 관한 법률에 의한 임금채권의 보호²⁶⁸⁾

임금의 지급확보 등에 관한 법률(이하 “임확법”)은 경기변동, 산업구조 변화, 기타 사정으로 기업경영이 불안정하게 된 경우나 근로자가 기업을 퇴직한 경우의 임금 지급 등을 확보하기 위한 근로자에 대한 보호조치를 규정한 법률이다.

임확법이 규정하는 보호정책은 크게, i) 체불임금의 대지급, ii) 저축금의 보전조치, iii) 퇴직수당의 보전조치 등을 들 수 있다.

1) 체불임금의 대지급금 제도

일본에는 “체불임금 입체불제도(未払賃金立替払制度)”가 있어, 기업도산으로 임금을 지급 받지 못한 채 퇴직한 근로자에게 체불임금의 일부를 입체불(대지급)하는 제도가 있다. 이 제

267) 結婚式場運営会社A社事件・東京高判 平31.3.28. 労判 1204, 31頁; 松山石油事件・大阪地判例 平成13.10.19. 労判 820, 15頁.

268) 石寄信憲編, 『賃金規制・決定の法律実務』, 中央経済社, 2022, pp.1008-1019 및 野村剛司, 『未払賃金立替払制度 [第2版]』, 金融財政事業研究会, 2021, pp.8-18; 未払賃金の立替払事業: <https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx>

도는 임확법에 따라 마련된 제도로, 1976년부터 실시되고 있다. 동법에서는 체불임금 대지급금 제도 외에, 사내예금 및 퇴직금에 대하여 사외적립 등의 보전조치를 강구해야 하는 내용 등도 규정되어 있다.

체불임금 대지급금 제도는 사업주(사용자)가 파산절차, 기타 법적 정비 절차의 개시결정을 받은 경우나, 사업활동을 정지한 경우 등에 근로자가 해당 사업주로부터 임금 지급을 받을 수 없는 때에, 정부가 해당 사업주에 대신하여 근로자에게 일정 범위에서 임금을 대지급하는 제도이다.

체불임금 대지급 제도는 정부가(대지급금 실시업무는 독립행정법인 근로자건강복지기구가 실시하고 있음) 근로자에게 임금을 대지급하는 제도이기 때문에, 사업주의 재산상황에 영향 받지 않기 때문에 파산 등으로 사업주의 재산이 고갈된 경우라고 해도, 근로자는 정부로부터 일정한 범위에서 임금 지급을 받을 수 있어 근로자의 입장에서 중요한 의의를 가지는 제도라고 할 수 있다.

사업주가 법적 정리절차, 특히 파산절차 신청을 함에 있어, 근로자에게 임금을 지급할 수 없다는 것이 판명된 경우에는 근로자에게 체불임금의 대지급금 제도 개요를 설명하고 신청용지를 교부하는 등으로 해당 제도를 주지시키는 경우가 종종 이루어지고 있다.

가) 사업주의 요건

체불임금 대지급금 제도가 적용되기 위한 사업주의 요건은 ① 산재보험 적용사업(농림수산업의 일부를 제외하고 근로자를 사용하는 모든 사업을 말함)으로 1년 이상 해당 사업을 실시하고 있는 자(법인, 개인의 유무·산재보험 가입절차 유무·산재보험료의 납부 유무는 불문함)가, ② i) 파산, 민사재생, 회사갱생절차개시의 결정을 받거나 혹은 특별청산개시명령을 받았을 것, ii) 중소기업의 경우에 그 사업활동이 정지되고 재개의 전망이 없고, 또한 임금지급능력이 없는 것이 노동기준감독서장에게 인정받은 것이 필요하다(임확법 제7조, 시행령 제2조, 시행규칙 제7조, 제8조).

나) 근로자의 요건

체불임금의 대지급금 제도가 적용되기 위한 근로자의 요건은 상기의 i) 파산, 민사재생, 회사갱생절차개시의 결정을 받거나 혹은 특별청산개시명령을 받았을 것의 경우에는 법적 정리절차를 신청한 날, 또는 상기 ii) 중소기업의 경우에 그 사업활동이 정지되고 재개의 전망이 없고, 또한 임금지급능력이 없는 것이 노동기준감독서장에게 인정받은 것의 경우(노동기준감독서의 인정 후에 파산절차결정이 이루어지는 등으로 i)에 해당하게 된 경우도 포함)에

는 노동기준감독서장에 대한 인정신청이 이루어진 날의 6개월 전의 날 이후 2년 간에 퇴직한 것이 필요하게 된다(임확법 제7조, 시행령 제3조).

〈대지급금을 받을 수 있는 경우(다음의 요건을 모두 충족시켜야 함)〉

- ① 사업주가 노동자재해보상보험(산재보험)의 적용사업장으로 1년 이상의 사업활동을 하고 있었을 것
- ② 사업주가 도산했을 것
- ③ 청구자가 노동기준법상 근로자일 것
- ④ 청구자가 각 도산절차의 신청 또는 “사실상 도산”의 인정신청이 이루어진 날의 6개월 전의 날부터 2년간 퇴직자일 것
- ⑤ 정기임금, 퇴직금이 체불되어 있을 것(총액 2만엔 미만은 대상외)
- ⑥ 퇴직일의 6개월 전부터 대지급금 청구일 전날까지 지급기일이 도래하고 있을 것
- ⑦ 파산절차개시 결정일(또는 “사실상 도산”의 인정일) 등의 다음 날부터 2년 이내에 대지급금 청구가 이루어질 것

다) 보호의 내용

사업주는 상기 (1)의 요건을, 근로자는 상기 (2)의 요건을 충족시킨 경우에는 근로자는 체불임금의 대지급금 제도에 의한 보호를 받을 수 있지만, 대지급금의 대상이 되는 임금은 다음의 범위에 한정된다.

(1) 대지급금의 대상

대지급금 대상이 되는 체불임금은 퇴직일의 6개월 전의 날부터 대지급금 청구일의 전날까지 동안에 지급일이 도래하고 있는 정기임금 및 퇴직수당에서 체불되어 있는 것에 한정된다.

따라서 상여, 해고예고수당, 경조사비, 기타 은혜적 또는 복리후생상의 급여 등은 포함되지 않고, 미정산 출장교통비 등의 실비가 있다고 해도 이러한 비용은 대지급금의 대상이 아니다.

또한 체불임금의 총액이 2만엔(약 20만원) 미만인 경우에는 대지급금을 받을 수 없다.

(2) 대지급금의 한도액

대지급금이 이루어지는 금액은 대지급금의 대상이 되는 금액의 80%에 상당하는 금액으로 되어 있는데, 급부되는 금액에는 퇴직일의 연령에 따라 한도액이 설정되어 있다. 체불임금의 총액이 그 한도액을 초과하는 때에는 그 한도액의 80%가 된다.

퇴직일의 연령에 따른 체불임금의 총액 한도액 및 대지급금의 상한액은 다음과 같다.

〈표 2-19〉 퇴직일의 연령에 따른 체불임금 총액 한도액 및 대지급금의 상한액

퇴직일의 연령	체불임금 총액의 한도액	대지급금의 상한액
45세 이상	370만엔	296만엔
30세 이상 45세 미만	220만엔	176만엔
30세 미만	110만엔	88만엔

2) 저축금의 보전조치

임확법 제3조는 사업주가 근로자의 저축금을 근로자로부터 위탁을 받아 관리하는 경우에, 저축금의 관리가 근로자의 예금 수입인 때에는 매년 3월 31일의 수입 예금액(해당 사업주가 받아들이고 있는 예금 금액을 말한다)에 대하여 동일 후 1년 간을 통한 저축금의 보전조치를 강구해야 한다고 되어 있다.

여기에서 말하는 보전조치란, 근로자마다의 수입 예금액에 대하여 후불에 관한 채무를 은행 등이 보증하는 것을 내용으로 한 계약 체결 및 근로자를 수익자로 하는 신탁계약을 체결하는 것 등을 말한다(임확법 시행규칙 제2조).

노동기준감독서장은 사업주가 이러한 보전조치를 강구하고 있지 않은 경우에는 그 시정을 명령할 수 있고(임확법 제4조), 이 명령에 위반한 사업주에 대해서는 벌금을 부과함으로써(임확법 제18조) 저축금의 보전조치 준수를 도모하고 있다.

3) 퇴직수당의 보전조치

퇴직수당의 제도가 있는 경우에, 사업주는 퇴직수당의 지급을 확보하기 위해서 일정한 금액(임확법 시행규칙 제5조)에 대하여 상기의 저축금의 보전조치에 준한 조치를 채용하도록 노력해야 한다고 한다(임확법 제5조). 퇴직수당의 보전조치는 노력의무에 불과한 점에 유의할 필요가 있다.

또한 중소기업퇴직금공제계약, 적격퇴직연금계약을 체결한 사업주나 그 근로자가 후생연금 기금에 가입하고 있는 사업주 등에 대해서는 상기의 보전조치의 노력의무는 부과되지 않는다(임확법 제5조, 동법 시행규칙 제4조).

다. 도산절차에서의 임금채권의 보호

1) 파산

파산절차는 법적 정리절차 중에서도 이른바 청산형으로 불리는 절차로, 파산자(사용자)가

행했던 사업의 재건은 예정되어 있지 않고, 파산관재인이 채무자의 재산(파산재산)을 최종적으로는 모두 처분하여 이로써 채권자에 대하여 배당하는 것을 목적으로 하는 절차이다.

파산절차에서 근로자의 임금은 다른 채권에 비하여 우선적인 지위를 부여받게 되어 있는데, 부득이하게 파산절차 신청을 하게 된 채권자는 파산신청시에 현저한 재산이 거의 남아 있지 않은 경우가 많아 근로자의 임금채권에 대하여 충분한 배당을 할 수 없는 경우가 많다.

따라서 이러한 경우에는 근로자는 앞에서 언급한 임금 대지급금 제도를 이용함으로써 임금 지급을 확보하게 된다.

또한 실무상으로는 사용자는 파산절차를 신청함에 있어 파산절차개시 후에 근로자에 대한 임금 등의 지급이 새롭게 발생하는 일이 없도록 근로자 전원을 해고하는 경우가 많다.

가) 재단채권

(1) 파산절차개시 전 3개월간의 급료

사용인(근로자)의 급료 청구권은 파산절차개시 전 3개월에 관한 것에 대해서는 재단채권이 된다(파산법 제149조 제1항).

재단채권이란, 파산절차에 의하지 않고 파산재단으로부터 파산채권에 우선하여 수시로 변제할 수 있는 채권을 말하고(파산법 제2조 제7호, 제151조), 파산자에 대한 채권 중에서도 가장 우선적인 취급이 인정되고 있는 채권을 말한다.

또한 “급료”란 파산자로부터 사용인에 대하여 노동의 대가로서 지급되는 일체의 것을 말하고, 노동기준법 제11조에서 정하는 “임금”과 같은 뜻으로 해석되고 있다.

(2) 퇴직수당의 일부

파산절차의 종료 전에 퇴직한 사용인(근로자)의 퇴직수당 청구권에 대해서는 퇴직전 3개월 간의 급료 총액(그 총액이 파산절차개시 전 3개월간의 급료 총액보다 적은 경우에는 파산절차개시 전 3개월간의 급료 총액이 된다)에 상당하는 금액이 재단채권이 된다(파산법 제149조 제2항).

또한 “파산절차의 종료 전에 퇴직”한 것이 요건이므로, 퇴직 시기가 파산절차의 개시전인지 후인지는 문제가 되지 않고, 또한 퇴직 이유가 해고인지, 자기 상황에 따른 퇴직인지도 불문한다.

그리고 재단파산이 되는 퇴직수당의 범위에 대해서 퇴직전 3개월간의 급료 총액이 파산절차 개시전 3개월 간의 급료 금액보다 적은 경우에는 파산절차 개시전 3개월간의 급료 총액이 되는 것으로 되어 있는 것은 파산절차 개시후에 급료가 인하되는 경우가 많다는 점에 비추어, 근로자의 보호를 도모하는 취지라고 보고 있다.

(3) 파산절차개시 후의 고용관계에서 발생한 급료 등의 채권

파산절차는 파산자의 사업 계속을 예정하고 있지 않고, 사용자는 근로자를 해고하는 것이 통상적인데, 파산절차 개시후에도 파산절차를 종료시키기 위해서 근로자를 계속 고용하는 경우도 있고, 이러한 경우에는 파산절차 개시후에 고용관계에서 발생한 급료 등의 채권이 발생하는 경우가 있다.

이러한 상황으로 발생한 급료 등의 채권에 대해서는 “파산관재의 관리, 환가 및 배당에 관한 비용의 청구권”(파산법 제14조 제1항 제2호) 또는 “파산재단에 관하여 파산관재인이 한 행위로 발생한 청구권”(동항 제4호)에 해당하고, 재단채권이 된다고 해석되는 경우도 있다.

나) 우선적 파산채권

파산절차 개시 전에 고용관계에서 발생한 임금채권, 기타 채권 중에 상가 가.에서 언급한 재단채권이 되는 것을 제외하고는 일반 선취특권(민법 제306조, 제308조)이 있는 채권으로서 우선적 파산채권이 된다(파산법 제98조 제1항).

우선적 파산채권이란, 파산재단에 속하는 재산에 대하여 일반 선취특권, 기타 일반 우선권이 있는 파산채권을 말하고, 다른 파산채권(일반 파산채권 및 열후적 파산채권)에 우선하여 변제를 받을 수 있는 것을 말한다.

우선적 파산채권의 변제원자가 되는 파산재단은 저당권자 등의 별채권자 및 재단채권자에 대하여 변제가 이루어진 후의 잔여 재산으로, 재단채권조차 만족하게 배당할 수 없는 경우에는 우선적 파산채권에는 배당이 돌아오지 않는다.

이 점은 해고예고금에 대해서는 해고로 근로자가 받는 영향을 완화하기 위한 것으로, 근로의 대가 즉 급료가 아니기 때문에 재단채권은 되지 못하고, 우선적 파산채권에 된다고 해석된다(재단채권이 되는 경우도 있을 수 있다).

2) 민사재생

민사재생절차는 법적 정리절차 중에서도 이른바 재건형이라고 불리는 절차로, 재생계획에 따른 재생채무자(사용자)가 행한 사업의 전부 또는 일부의 재건을 목적으로 하는 절차이다.

민사재생절차는 재생채권자의 재건을 전제로 한 절차로, 부득이하게 파산절차의 신청을 하게 된 경우보다는, 근로자의 임금이 확보될 가능성은 상대적으로 높다고 할 수 있다.

이 민사재생절차에서도 근로자의 임금에 대하여 우선적인 지위를 부여하고 있다.

가) 공익채권(절차개시 후에 발생한 임금)

임금(퇴직수당을 포함) 가운데 절차개시 후에 발생한 것은 재생채무자의 업무에 관한 비용의 청구권으로서 공익채권이 된다(민사재생법 제119조 제2호).

이미 언급한 것과 같이, 민사재생절차는 재생채무자의 재건을 목적으로 하는 절차로, 재건을 도모하는데 있어서 그 사업에 종사하는 근로자의 임금 지급은 재생채무자의 재건에 불가결하기 때문에, 공익채권으로 여겨진다.

공익채권은 재생절차에 따르지 않고 수시로 변제되고, 또한 재생채권에 우선하여 변제된다(민사재생법 제121조 제1항, 제2항).

이 점은 민사재생절차를 신청했지만, 재생의 전망이 없어 파산절차로 이행하는 경우도 있지만, 이 경우에는 파산절차에서 앞에서 언급한 재단채권으로 취급되게 된다(민사재생법 제252조 제1항 각호, 제3항, 제6항 전단).

또한 공익채권은 재생채권에 앞서 변제되는 것이므로, 공익채권이 모두 변제할 수 있는 것이 재생계획에 근거로 한 재생채권의 변제의 전제로 되어 있으며, 공익채권의 변제도 되지 못하는 경우에는 재생절차는 폐지되게 된다(민사재생법 제191조 제1호 제2호, 제174조 제2항 제2호, 제194조).

나) 일반 우선채권(절차개시결정 전에 발생한 임금)

임금(퇴직수당을 포함) 중 절차개시결정 전에 발생한 것은 일반 선취특권이 있는 채권으로서 일반 우선채권이 여겨진다(민사재생법 제122조 제1항).

일반 우선채권은 공익채권과 마찬가지로 재생절차에 따르지 않고 수시로 변제된다(동조 제2항).

단, 민사재생절차가 폐지되어 재생절차로 이행한 경우에는 일반 우선채권이 된 임금은 우선적 파산채권으로 취급되는 것에 불과한 점에서, 절차개시 후에 발생한 임금과 다르다.

다) 재생채권(사내예금)

사내예금은 재생계획에 따라야 하는 재생채권으로 취급되고, 앞에서 언급한 임금이나 퇴직수당과 같은 보호는 없다. 이것은 사내예금에는 일반 선취특권이 부여되고 있지 않기 때문이다.

3) 회사갱생

회사갱생절차는 민사재생절차와 마찬가지로, 재건형 절차로 채무자(사용자)의 사업의 재건을 도모하는 것을 목적으로 하고 있는데, 그 대상이 주식회사라는 점, 담보권자도 갱생절차의

대상이 되는 점, 재산의 관리처분 등을 관재인이 행하는 점 등이 민사재생절차와 다르다.

회사갱생절차에서도 채무자의 사업의 재건을 목적으로 하고 있기 때문에, 근로자의 임금에 대하여 우선적인 지위를 인정하고 있다.

가) 공익채권이 되는 것

(1) 갱생절차개시 전 6개월간의 급료 및 갱생절차개시 후의 급료

갱생절차개시 전 6개월 간의 사용인(근로자)의 급료 및 갱생절차개시 후에 발생한 사용인(근로자)의 급료는 공익채권으로 여겨진다(회사갱생법 제130조 제1항, 제127조 제2호).

공익채권은 갱생절차에 따르지 않고 갱생채권, 갱생담보권에 앞서 수시 변제되고 있어(회사갱생법 제132조 제1항, 제2항), 우선적 지위가 인정되고 있다.

(2) 퇴직수당

갱생계획 인가결정 전의 퇴직자의 퇴직수당 중 일시금으로 지급되는 것은 퇴직전 6개월 전의 급료 총액에 상당하는 금액 또는 퇴직금액의 3분의 1에 상당하는 금액 중 어느 한 쪽 많은 금액을 한도로 공익채권으로 여겨진다(회사갱생법 제130조 제2항).

또한 갱생계획 인가결정전의 퇴직자의 퇴직수당 중 정기금 타입의 것은 각 시기의 정기금에 대하여 3분의 1이 공익채권으로 여겨진다(동조 제3항).

그리고 갱생절차 개시결정 후의 회사의 상황(관재인에 의한 해고를 포함)으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직금 금액이 공익채권이 된다(동법 제127조 제2호). 이것은 갱생절차 개시후의 사업의 경영 등에 근거로 하여 발생한 것으로 평가되기 때문이다.

마찬가지로 갱생계획 인가결정 후의 퇴직자(자기상황 퇴직과 회사상황 퇴직을 불문)의 퇴직금은 전액이 공익채권으로 수시 변제된다(동호).

(3) 사내예금

갱생절차 개시전에 맡겨진 사내예금의 반환청구권에 대해서는 갱생절차 개시전 6개월 전의 급료 총액에 상당하는 금액 또는 그 예금 금액의 3분의 1에 상당하는 금액의 어느 한 쪽 많은 금액이 공익채권으로 여겨진다(회사갱생법 제130조 제5항).

나) 우선적 갱생채권이 되는 것

(1) 재생절차개시 전 6개월 이전의 급료

앞의 가.(가)에서 언급한 급료 이외의 급료(갱생절차개시 전 6개월 이전의 급료)는 일반 선취특권이 있는 갱생채권(우선적 갱생채권)으로 취급된다.

우선적 갱생채권은 갱생절차에 편입되어 원칙적으로 갱생계획에 근거로 하여 변제되게 되어 수시 변제되지 않는다(회사갱생법 제47조). 이 우선적 갱생채권은 일반 갱생채권보다도 우대되지만, 갱생담보권에는 열후하다(동법 제168조 제1항 제2호).

(2) 퇴직수당

갱생계획인가 결정전의 퇴직자의 앞의 나.(가)에서 언급한 퇴직수당 이외의 퇴직수당은 우선적 갱생채권으로 취급된다. 또한 해당 퇴직수당에 대해서는 퇴직자를 배려하여 그 채권의 신청은 퇴직후에 하면 되고(회사갱생법 제140조), 또한 그 채권의 확정에 대해서도 관재인의 이의가 없으면 확정되고 있다(동법 제150조).

4) 기타 절차

가) 특별청산

특별청산절차는 파산절차의 간이판과 같은 절차로, 채무초과의 의혹이 있는 주식회사에 대해서 회사의 자산을 환가하고 환가로 얻어진 금원으로 채무를 지급하고 부채를 탕감하는(채무면제 등을 포함) 절차이다. 구체적으로는 채권자 집회에서 채무의 변제방법을 기재한 협정안을 가결함으로써 행해진다.

앞서 언급한 것과 같이 임금이나 퇴직수당은 일반 선취특권이 있는 채권인데, 특별청산절차에서는 일반 선취특권이 있는 채권은 특별청산절차의 효력을 받는 채권에서 제외되고, 특별청산개시의 명령이 있어도 해당 채권에 근거로 한 강제집행을 할 수 있는 것으로 되어 있다(회사법 제515조 제1항 단서).

또한 일반 선취특권이 있는 채권(임금이나 퇴직수당 등)을 가지는 채권자(근로자)는 협정안의 작성시에 담보채권자와 같은 입장에서 참가할 수 있는 채권자로 되어 있다(동법 제566조 제2호).

특별청산절차에서의 임금과 퇴직수당의 취급은 상기와 같은데, 특별청산은 모회사가 자회사를 정리하는 경우(이 경우, 특별청산절차신청 전에 모회사 이외의 다른 채권자에 대한 채무를 모두 변제하고, 모회사를 자회사의 유일한 채권자로 두는 경우가 많다) 등 청산결료까지 매끄럽게 청산할 수 있는 전망이 있는 경우에 이용되는 것이 통상적이고, 이러한 경우에는 근

로자에 대한 임금 및 퇴직수당은 모두 지급되는 경우가 많기 때문에 실무상으로는 특별청산에서 임금 및 퇴직수당의 보호가 결여되는 일은 그다지 없다고 본다.

나) 사적 정리(임의정리)

사적 정리란, 법적 정리절차에 따르지 않고 채권자와의 합의로 회사의 채무를 정리하는 절차의 총칭이다.

사적 정리의 형태로는 사업자의 감독 하에서 행해지는 사업재생ADR절차나 중소기업재생지원협의회 및 주 거래은행의 협력 하에서 행해지는 경우 등의 절차도 있고, 사업재생이나 채권자의 협력 전망이 없는 등 채권자의 공평함을 도모하기 위해서 본래적으로는 파산을 신청해야 하는 상황임에도 불구하고 이를 신청하지 않는 등 무질서인 상태로 행해지는 절차가 있다.

사업재생ADR절차 등의 사적 정리가 행해지는 경우에는 근로자의 임금 및 퇴직수당의 보호가 결여되는 경우는 없지만, 무질서한 사적 질서가 행해지는 경우에는 근로자의 임금이나 퇴직수당 보호를 전혀 받지 못하게 되는 경우가 있다.

이러한 경우에는 근로자의 입장에서는 최종적으로는 앞에서 언급한 체불임금 대지급금 제도로 보호를 받게 된다. 물론 근로자가 채권자로서 해당 회사의 파산 신청을 하는 것도 가능하지만, 예납금의 부담 및 시간이 걸리기 때문에 실무적으로는 없다.

3. 소송 등의 구제제도²⁶⁹⁾

가. 재 판

1) 민사소송

민사소송에서 예를 들어 잔업비 청구를 하는 경우, 근로자측이 실근로시간의 주장 및 입증 책임을 가지게 되므로, 증거자료의 유무가 승부처가 될 수 있다.

그러나 민사소송의 경우, 시간이 걸리는 단점이 있고, 사용자 측의 반론 내용 여하에 따라서는 해결까지 장기화될 가능성도 있다.

2) 노동심판

일본의 노동심판법에 따른 노동심판제도는 개별노동분쟁에 대하여 재판관을 맡는 노동심판관 1명과, 노동관계에 관한 전문적 지식을 가진 자로 근로자측과 사용자측 각 1명이 선출되

269) 旬法法律事務所編, 『未払い残業代請求』, 学陽書房, 2022, p. 182~191 참조하여 정리함.

는 노동심판원 3명으로, 총 3명으로 구성되는 노동심판위원회에서 행해진다.²⁷⁰⁾ 이 노동심판은 원칙 3회로 끝나는 절차이기 때문에, 단기 해결이 기대되는 절차이다. 그러나 이 절차가 도입되기 전에는 노동심판절차는 잔업비 청구사건에는 맞지 않다고 말해지기도 하였다. 이는 사용자가 근로자가 주장하는 근로시간을 부인한 경우, 근로자는 매일의 근로시간을 하나씩 입증해야 했기 때문에, 방대한 입증자료가 필요하게 되고, 또한 그것은 근로자의 근로시간 주장과 정합되어 있는지, 1분단위로 치밀한 조사가 요구되기 때문에 단 3회의 기일 내에 종료되지 못한다고 생각했었기 때문이다.

그러나 노동심판제도가 시작되고 나서 보자, 잔업비 지급을 요구하는 노동심판절차의 신청이 많고, 그중 상당수가 해결되는 등, 지금까지는 잔업비 청구사건이기 때문에 노동심판절차에 적합하지 않다고는 할 수 없게 되었다.

하지만, 원칙 3회로 끝난다는 것으로 인해, 상세한 증거조사는 할 수 없다. 신청시에 방대한 증거자료를 내도 노동심판위원회가 소화할 수 없을 가능성이 있기 때문이다. 노동심판은 원칙 3회로 끝나기 때문에 빨리 해결 될 수 있다.

노동심판절차는 노동심판이 내려져도 당사자가 이의가 있으면 민사소송으로 이행한다(노동심판법 제22조 제1항). 또한 부가금에 대해서는 법원이 지급을 명령하는 것으로 되어 있기 때문에, 민사소송에서의 판결로만 지급명령이 나오므로 주의가 필요하다.

3) 가압류

사용자의 자력이 부족하여 재판 등을 하고 있는 동안에 자산이 없어질 가능성이 있는 경우에는 가압류를 행할 수 있다. 이 절차 자체는 민사소송 및 노동심판절차와 모순되는 것이 아니기 때문에, 선행하거나 병행할 수 있다.

또한 사용자가 가압류 결정에 이의를 제기하여 보전이의 심문 중에 화해가 성립하여 사건이 해결될 수도 있다.

4) 기타 절차

가) 소액소송

소액소송은 60만엔 이하의 금전 지급을 요구하는 청구에 대한 특별 절차이다(민사소송법 제368조 이하). 청구하는 잔업비 등이 60만엔 이하인 경우에 이용가능하다.

270) 이 노동심판위원회가 설치되어 있는 곳은 도쿄지방법원 다치가와지부와 시즈오카지방법원의 하마마츠지부, 나가노지방법원의 마츠모토지부, 히로시마지방법원의 후쿠야마지부, 후쿠오카지방법원의 오구라지부의 5곳 지부를 제외하고, 하코다테시, 아사히카와시 및 쿠시로시와 각 도도부현청 소재지 50개소에 있는 지방법원의 본청에만 설치되어 있다.

소액소송은 원칙적으로 1회 기일에 심리가 종결하고(동법 제370조 제1항), 조사된 증거도 즉시 조사하는 것이 가능한 것에 제한된다(동법 제371조). 판결은 변론종결 후 즉시 이루어 지므로(동법 제374조), 빠른 해결이 기대되지만, 상급심으로 항소는 허용되지 않고(동법 제 377조), 수소법원에 대한 이의만이 인정(동법 제378조)된다는 특칙이 있다.

다만, 피고인 사용자가 통상 절차로의 이행을 신술할 수 있고, 이것이 이루어지면 통상 절차로 심리되게 되어(제373조 제1항), 소액소송의 장점은 없어지게 된다.

나) 독촉절차

독촉절차는 금전 등의 급부를 목적으로 하는 청구권에 대하여 간이신속한 확정을 하기 위한 절차이다(민사소송법 제382조 이하). 당연히 잔업비청구도 이용가능하다. 절차는 채권자가 신청을 하면, 지급독촉이 발행된다. 이 때 심문은 이루어지지 않는다(동법 제386조 제1항).

다만, 지급독촉에 대하여 채무자가 독촉이의를 신청할 수 있고, 적법한 독촉이의 신청이 있는 때에는 통상의 민사소송으로 이행된다(제395조).

다) 민사조정

민사조정은 민사분쟁에 대하여 재판관과 민사조정위원으로 구성된 조정위원회가 당사자의 합의에 근거로 한 분쟁해결을 도모하는 절차이다. 잔업비 청구 사건도 민사조정을 이용하는 것이 가능하다.

다만, 민사소송 및 노동심판과 달리, 당사자의 합의가 기초가 되기 때문에, 첨예하게 대립하고 있는 사안이나 사실관계에 다툼이 있는 경우 등에는 적합하지 않다.

조정절차는 조정위원회(주로 민사조정위원)가 당사자로부터 사정을 청취하고, 당사자의 합의가 성립되도록 조정이 행해진다. 조정이 성립하는 경우에는 조정조서가 작성되고, 이것은 재판상의 화해와 동일한 효력을 가진다(민사조정법 제16조). 조정이 성립하지 않는 경우에는 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 조정에 대신하는 결정을 할 수 있지만(제17조), 실제적인 사례는 거의 없다. 또한 이 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 2주간 이내에 이의를 제기하지 않으면 소송상의 화해와 동일한 효력이 부여된다. 이의를 제기하면 결정의 효력은 잃는다(제18조).

라) 선취특권

민법상 고용관계를 원인으로 하여 발생한 채권을 가지는 자는 채무자의 총재산에 대하여 선취특권이 인정되고 있다(민법 제306조 제2호).

선취특권의 대상이 되는 채권은 “급여, 기타 채무자와 사용인 간의 고용관계에 근거로 발생

한 채권”으로 되어 있다(민법 제308조). 잔업비는 임금이기 때문에 당연히 여기에 포함된다.

행사에 있어서는 선취특권은 담보권이므로, 담보권의 존재를 증명하는 문서가 필요하게 된다(민사집행법 제193조 제1항). 잔업비에 대해서는 근로계약의 존재, 급료의 규정, 노무 제공의 각 사실에 더불어, 소정 근로시간외에 근로한 사실을 증명하는 서증 등이 필요하다.

다만 잔업비에 대해서는 사용자가 항변을 가지고 다툼이 되는 경우도 많기 때문에, 기본임금의 체불의 경우와 비교 하여 선취특권의 행사에 대하여 집행법원은 신중한 자세를 보이는 경향이 있다. 이것은 선취특권의 일반 채권자에게 우선하는 효력을 가지고 있음에도 불구하고, 통상적으로는 다른 일반 채권자가 모르는 사이에 집행을 완료하고, 또한 다른 채권자에게 불복의 기회가 없는 등의 특징이 있기 때문이다.

나. 행정기관

1) 노동기준감독서

노동기준감독서는 노동국의 하부기관으로서 각 도도부현에 복수 설치되어 있는 기관이다. 노동기준감독서는 국민에게 있어 비교적 가까운 노동행정서비스를 제공하는 기관이다.

노동기준감독서는 노동기준행정의 제1기관으로서, 노동기준법을 비롯하여 소관하는 법률에 근거로, 근로조건 확보 및 개선의 지도, 안전위생(산업안전)의 지도, 산재보험의 급여 등의 업무를 수행한다.

그리고 노동기준감독서는 노동기준법 등의 법령위반에 대한 신고를 받고 있으며, 위반이 인정되면 사용자에게 시정권고를 한다(신고감독). 또한 정기적으로 각 노동기준감독서의 관할 내 사업소의 법령 준수상황을 확인하고, 위반이 있으면 시정권고를 하는 경우도 있다(정례감독).

또한 노동기준감독관은 노동기준법 등이 소관하는 법령에 벌칙이 마련되어 있는 사항에 대해서는 특별사법경찰관으로서 범죄수사를 하는 권한을 가지고 있다(노동기준법 제102조). 특히 악질적인 법령위반인 경우 등, 행정지도에 그치지 않고 경찰권을 행사하는 경우도 있다.

잔업비 체불 등의 임금체불 문제는 노동기준법 위반 그 자체의 문제이기 때문에 상기의 권한을 가진 노동기준감독서에 근로자가 노동기준법 위반을 신고하면 시정권고 등이 이루어지고, 이에 따라 사용자가 법령위반상황을 개선하면(체불임금 등을 지급하면) 분쟁은 해결되게 된다.

또한 예를 들면 잔업비 체불에는 형사벌이 있기 때문에(노동기준법 제119조) 고소도 가능하다. 고소한 경우 사용자가 시달 목적으로 잔업비를 지급하는 경우도 있다.

어느 경우든, 노동기준감독서로의 신고는 행정처분을 요구하는 것이고, 고소는 형사처벌을 요구하는 것이기 때문에, 사법상의 분쟁을 해결한다는 목적은 아니다.

2) 노동국의 알선

개별노동분쟁해결촉진법의 제정으로 개별 근로자와 사업주 간의 분쟁(개별노동관계분쟁)에 대하여 분쟁조정위원회가 설치되어 동 기관에 의한 알선이 이루어진다(개별노동분쟁해결촉진법 제6조).

알선은 개별노동관계분쟁의 당사자의 일방 또는 쌍방으로부터 신청이 있는 경우에, 노동국장이 필요하다고 인정한 경우 분쟁조정위원회에 개별노동관계분쟁의 알선을 실시하게 되는 것이다.

분쟁조정위원회는 학식경험자가 임명되고, 3명의 알선위원이 알선을 행한다(동법 제12조). 알선절차는 알선위원이 당사자의 사이에 개입하여 당사자와 참고인으로부터 사정을 청취하고, 당사자 쌍방의 주장을 정리 및 검토하고, 그리고 나서 실정에 입각한 해결을 할 수 있도록 알선을 한다(동법 제12조). 또한 필요가 있으면 알선안을 작성하고, 이를 당사자에게 제시하고, 알선의 성립을 촉구한다(동법 제13조).

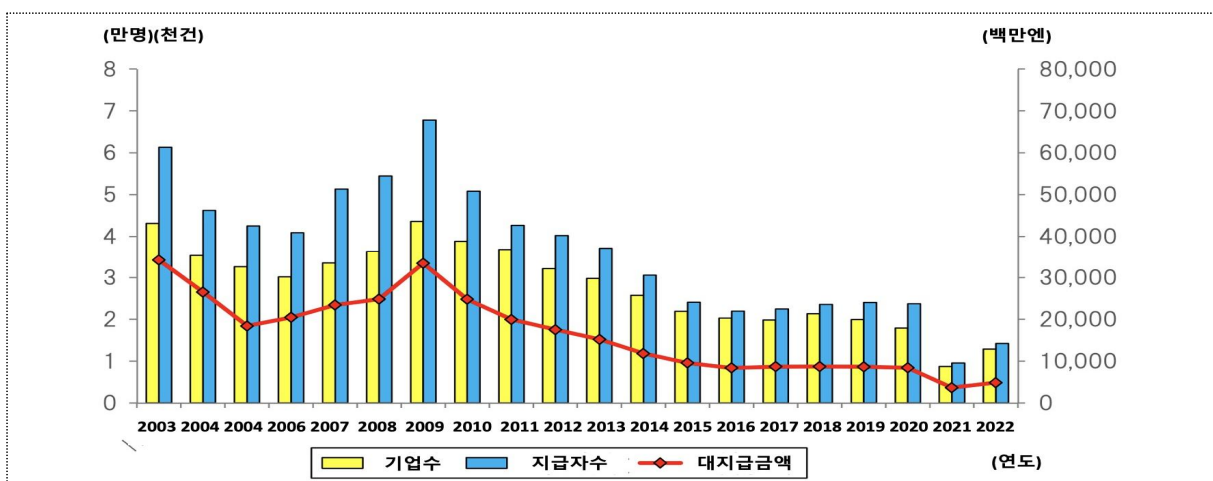
당사자에게 합의가 성립하여 알선이 성립한 경우에는 당사자 쌍방은 그 합의에 사법상 구속된다(화해계약으로서의 구속력이 발생하는 것에 불과하고, 채무명의는 되지 않으므로 이를 가지고 강제집행은 할 수 없다).

분쟁해결의 전망이 있는 경우에는 알선안은 중단되지만, 알선이 중단된 경우라고 해도, 30일 이내에 알선의 대상이 된 청구에 대해서 소송이 제기되면, 알선신청시에 소송의 제기가 있었다고 간주되어 시효의 중단효가 그 시점에서 발생한다(동법 제15조, 제16조). 또한 알선은 상대방에게 출두할 의무가 없기 때문에, 상대방이 응하지 않는 한 중단될 수 있다. 또한 상호 동의할 수 있는 조건이 되지 않으면 중단된다는 한계가 있다.

4. 임금체불 및 관련 처리 관련 통계

가. 체불임금 대지급금 사업 실시 현황

[그림 2-8] 체불임금의 대지급금 추이



〈표 2-20〉 체불임금 대지급금 사업 실시 상황²⁷¹⁾

구분	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도
기업수	1,991건	1,791건	872건	1,285건
지급자수	23,992명	23,684명	9,560명	14,203명
대지급금액	8,638백만엔	8,411백만엔	3,642백만엔	4,856백만엔
회수액	1,806백만엔	2,405백만엔	2,029백만엔	1,327백만엔

일본에서의 체불임금 대지급금의 추이를 보면, 2008년 리먼 브라더스 쇼크로 인한 세계 금융위기가 일본 경제에도 영향을 끼쳤기 때문에 2009년도에 체불임금의 대지급금 기업수와 지급자수, 그리고 대지급금액이 가장 높은 추이를 보인 이후, 매해의 다소의 증감은 있지만 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.

그리고 2022년도의 실시상황을 보면, 대지급을 행한 기업 수, 지급자 수 및 대지급금액은 전년에 비하여, 기업 수는 1,285건으로 전년대비 47.4% 증가, 지급자 수는 14,203명으로 전년대비 48.6% 증가, 대지급금액은 48억 56백만엔으로 전년대비 33.4% 증가하였다. 2021년도에 비하여 큰 폭으로 증가하였지만, 2019년이나 2020년도의 수치에 비하면 감소한 것이다. 이와 같은 증감의 변화에 대해서는 명확한 이유는 확인되지 않지만, 코로나19 등으로 인한 경제 및 노동시장의 상황이 영향을 미쳤기 때문으로 추측된다.

나. 행정의 임금체불이 의심되는 사업장에 대한 감독지도 결과²⁷²⁾

후생노동성은 2022년 1월부터 12월까지, 임금체불이 의심되는 사업장에 대하여 노동기준 감독서가 실시한 감독지도의 결과를 발표하였다. 이번 발표는 그동안 지불액이 1기업당 100만엔 이상의 할증임금체불 사안만 집계하여 발표를 해왔었는데, 이번부터는 그 이외의 사안을 포함한 임금체불 전체를 집제한 것이다.

〈표 2-21〉 2022년 전국 노동기준감독서에서 취급한 임금체불 사안의 건수, 대상근로자 및 금액

건수	20,531건
대상근로자 수	179,643명
금액	121억 2,316만엔

271) 労働者健康安全機構, “未払賃金の立替払事業”: <https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/1021/Default.aspx>

272) 厚生労働省, “賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します”: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.html

〈표 2-22〉 2022년 전국 노동기준감독서에서 취급한 임금체불 사안 중, 노동기준감독서의 지도로 해결된 상황

건수	19,708건(96.0%)
대상근로자 수	175,893명(98.0%)
금액	79억 4,597만엔(65.5%)

상기와 같이, 노동기준감독서에서 임금체불사안에 대하여 감독지도를 한 후, 이러한 감독지도로 대부분의 사건이 해결되고 있음을 알 수 있다. 또한 이러한 감독지도를 통하여, “근로시간의 적정 파악의 저해”, “근로시간기록과 노동실태의 괴리”, “근로시간의 적정파악의 저해” 등의 문제로 임금체불이 이루어지고 있어 감독지도를 통하여 시정한 사례 등도 제시되어 있다. 이에 더불어 “월 20시간을 초과한 시간외 할증임금을 지불하지 않은 혐의”, “시간외 할증임금을 지불하지 않고 감독관에게 허위의 진술을 한 혐의” 등으로 검찰에 송치한 사례 등도 제시되어 있다.²⁷³⁾

다. 법원(전체 지방법원)에서의 노동심판 사건 수²⁷⁴⁾

〈표 2-23〉 노동심판사건 수 - 사건의 종류 및 신규수리, 기처리, 미처리(전국 지방법원)

사건의 종류	신규수리	기처리	미처리
총수	3,208	3,283	742
금전을 목적으로 하는 것 이외			
지위확인(해고 등)	1,641	-	-
기타	45	-	-
금전을 목적으로 하는 것			
임금수당 등(해고예고수당 포함)	1,079	-	-
퇴직금	58	-	-
기타	385	-	-

273) 厚生労働省, “賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します(別紙)” <https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001126169.pdf>

274) 最高裁判所事務総局, “令和4年 司法統計年報 1. 民事・行政編”: <https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/657/012657.pdf>

〈표 2-24〉 노동심판사건 기처리 수 - 사건의 종류 및 종국 구분 별(전국 지방법원)

사건의 종류	노동 심판	조정 성립	결정	노동심판사 건의 종료 (법제24조)	취하	기타
총수	544	2,272	25	160	258	14
금전을 목적으로 하는 것 이외						
지위확인(해고 등)	277	1,183	14	51	109	11
기타	12	30	1	1	10	-
금전을 목적으로 하는 것						
임금수당 등(해고예고수당 포함)	181	786	7	75	94	-
퇴직금	19	30	-	5	6	-
기타	55	243	3	28	39	3

일본의 최고재판소 사무총국에 발표한 “2022년 사법통계연보 1. 민사·행정편”에서 제시된 노동심판사건 수를 보면, 신규 접수된 사건 수는 3,208건인데, 그중 금전을 목적으로 하는 것 중 임금수당 등(해고예고수당 포함)과 관련된 사건의 수는 1,079건으로, 금전을 목적으로 하는 것이 아닌 사건인 지위확인(해고 등)의 1,641건에 이어 두 번째로 많이 다루어지고 있음을 알 수 있다(물론 이 때의 임금수당 등과 관련된 사건에는 임금채불 등의 잔업비 청구 등도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다).

또한 상기의 임금수당 등과 관련된 사건이 어떻게 처리되었는지 살펴 보면, 조정성립(786건), 노동심판(181건), 취하(94건), 노동심판사건의 종료(75건), 결정(7건) 등으로, 대부분의 사건이 조정성립으로 해결되고 있음을 알 수 있다.

5. 소결 및 시사점

가. 요약

일본에서는 우리와 마찬가지로 채불임금 대지급금제도가 있어, 기업도산으로 임금을 지불 받지 못한 채로 퇴직한 근로자 등에 대하여 채불임금의 일부를 대지급하고 있다. 사용자는 1년 이상 사업활동을 하고 있었을 것, 도산(법률상 도산 및 사실상 도산)했을 것, 또는 중소기업의 경우 사업활동을 정지하고 재개할 전망이 없어 임금지불능력이 없는 경우이며, 근로자의 경우에는 기업의 법률상 도산한 경우에는 법원에 신청을 하거나 또는 기업의 사실상 도산의 경우에는 노동기준감독서에 인정신청을 한 근로자는 대지급을 받을 수 있는 요건이 된다.

하지만 상기 통계에서 살펴 본 바와 같이, 일본에서는 임금체불에 대한 대지급금의 실시 현황이 다소의 증감은 있지만 감소하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다.

한편, 체불임금에 대하여 근로자의 청구로 법원에서 사용자에게 부가금을 청구할 수 있다. 법원이 부가금의 지급을 명령하는 판결을 내려 재판이 확정되면 사용자는 체불임금에 더불어, 최대 해당 체불금액과 같은 금액을 근로자에게 지불할 의무가 발생한다.

이 부가금의 대상이 되는 것은 노동기준법 제114조에 따라 해고예고수당(노동기준법 제20조 제1항), 휴업수당(동법 제26조), 시간외 및 휴일근로 등에 대한 할증임금(동법 제37조), 연차유급휴가중의 임금(동법 제39조 제9항)의 네 가지 체불금액이 대상이 된다. 그리고 이 부가금의 청구가능 기간은 체불이 있던 날로부터 2년이었는데, 노동기준법 개정으로 2020년 4월 1일 이후에 지불일이 돌아오는 임금에 대한 부가금은 5년으로 연장되었다(경과조치로서 당분간은 3년).

이와 같은 부가금을 청구하기 위해서는 근로자가 재판을 제기하여 청구하고, 법원이 이를 인정한 경우에 판결로 사용자에게 지불을 명령하는 것이다. 다만, 임의교섭으로 화해가 성립한 경우, 노동심판위원회 관할의 노동심판에서 해결한 경우, 소송상의 화해가 성립한 경우에는 부가금은 지급되지 않는다.

그리고 부가금 금액은 법률상으로는 체불금의 금액과 동일한 금액으로 정의되는데, 실제로는 법원이 사용자에게 의한 법률 위반의 정도 및 양태, 혹은 근로자의 불이익의 성질 및 내용 등 제반 사정을 종합적으로 판단하여 부가금의 지불의 필요여부 및 금액을 결정하기 때문에, 일률적으로 동일한 금액이라고는 할 수 없고 이 동일한 금액은 부가금의 상한이 된다고 볼 수 있다. 이와 같이 결정된 부가금에 대해서는 법원이 사용자에게 체불금과 함께 지불을 명령한다.

나. 시사점

상기의 일본 제도 및 사례를 바탕으로 다음의 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 임금체불에 대하여 형사벌에 더불어 부가금 제도를 통한 경제적 제재의 방법을 마련하여 임금체불 예방을 도모하고 있는 점을 들 수 있다. 일본의 경우에는 임금체불에 대한 형사처벌이 우리나라에 비하여 매우 약하지만, 임금체불을 한 사용자에게 소송을 통해 부가금을 청구하여 경제적 제재를 할 수 있는 제도가 마련되어 있음을 확인할 수 있다.

일본에서는 임금지급 5원칙에 위반한 경우에는 30만엔 이하의 벌금(노동기준법 제120조 제1호)에 처해지고, 임금체불에 대한 벌칙규정으로서 6개월 이하의 징역 또는 30만엔 이하의 벌금(노동기준법 제119조 제1호)이라는 제재방법이 규정되어 있다. 이러한 벌칙의 대상은 각

규정에 위반한 자로, 사업주에 한정되지 않는다. 사업주가 아닌 사용자(사업주를 위해 행위를 하는 자), 관리직에 의한 위반행위가 있는 경우에는 사업주도 위반자와 마찬가지로 벌금형이 부과된다(징역형은 대상이 아님). 다만 사업주가 위반의 방지에 필요한 조치를 취한 경우에는 이 규정은 적용되지 않는다(노동기준법 제121조 제1항).

이에 더불어, 임금체불에 대해서 해고예고수당, 휴업수당, 시간외 할증임금, 연차유급휴가에 한정하여 “부가금”이 규정되어 있는 점이 특징이다. 이 부가금은 근로자가 상기의 임금을 지불하지 않은 사용자에게 근로자의 청구하여 법원이 판결로 사용자에게 명하는 것이다(노동기준법 제114조). 부가금의 금액은 조문상으로는 체불금액과 “동일한 금액”으로 규정되어 있는데, 법원에서는 사용자 측의 위반 정도나, 근로자 측이 입은 불이익 정도 등 개별 구체적인 사정을 고려하여 “체불금액과 동일한 금액을 상한으로” 부가금이 결정되는 경우가 많은데, 이 “동일한 금액”은 실질적으로 부가금의 상한이 된다고 이해할 수 있다.

둘째, 체불임금의 예방과 체불임금 등의 지불청구와 관련해서는 노동기준감독서(행정)의 감독행정과 사법의 역할이 연계하여 기능하고 있으며, 이를 통해 예방과 구제가 적절히 기능하고 있음을 알 수 있다.

임금체불은 노동기준법 제24조에 위반하는 행위이다. 따라서 임금 등의 체불은 노동기준감독서의 감독행정(지도, 시정권고)으로 지급되는 것을 기대할 수 있다. 다만, 노동기준법은 이에 위반한 사용자에게 형벌을 부과함으로써 준수하도록 하는 체계를 취하고 있으며, 노동기준감독서가 근로자를 대신하여 체불임금의 징수 등을 해주는 것은 아니다. 현실에 형벌권이 발동되는 경우는 드물고, 대부분의 사례는 지도나 시정권고 등으로 처리되고 있다.²⁷⁵⁾ 앞선 통계에서 살펴 보았듯이, 노동기준감독서의 행정감독지도로 임금체불 사안은 대부분 해결되고 있음을 알 수 있다.

따라서 사용자가 노동기준감독서의 지도, 시정권고에도 따르지 않고 체불임금 등의 지불을 하지 않는 경우에는 법원에 소송을 제기하여 민사적인 수단을 통하여 법원의 판단을 받아 체불임금과 부가금 등을 징수받을 수 있는 구조로 이해할 수 있다.

275) 鴨田哲郎·君和田伸仁·棗一郎, 『労働審判制度その仕組みと活用の実際(第3訂版)』, 日本法令, 2023, pp. 86~87.

제3장 임금채권보장법상 사업주 부담금 경감기준 개선 방안

제1절 사업주 부담금 경감의 필요성 검토

1. 임금채권보장기금의 의의

임금채권보장법은 경기 변동과 산업구조 변화 등으로 사업을 계속하는 것이 불가능하거나 기업의 경영이 불안정하여, 임금등을 지급받지 못하고 퇴직한 근로자 등에게 그 지급을 보장하는 조치를 마련함으로써 근로자의 생활안정에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 임금채권보장법은 임금채권보장제도를 마련하여 시행하도록 하고 있다.

임금채권보장제도란 기업의 도산 등으로 인하여 근로자가 임금 등을 지급받지 못한 경우 정부가 사업주를 대신하여 일정 범위의 미지급임금(최종 3개월분의 임금·휴업수당, 출산전후 휴가기간 중 급여, 최종 3년간의 퇴직급여) 등을 근로자가 지급받을 수 있도록 보장해주는 제도를 말한다.

임금채권보장제도는 사업주를 대신하여 그의 임금등을 근로자에게 지급하는 것이 본질적 내용이므로 이를 위해서는 상당한 수준의 재원이 필요하다. 임금채권보장제도를 운영하기 위해서 필요한 재정적 원천은 임금채권보장기금이다. 임금채권보장기금은 사업주가 납부하는 부담금과 근로복지공단이 체불 근로자에게 대지급금 지급한 다음 대위권을 행하여 사용자로부터 받는 변제금을 주요 재원으로 조성된다(법 제18조 제1항 참조).

2. 임금채권보장제도 변천에 따른 부담금 분담 방식의 점검 필요

임금채권보장제도는 1998. 2. 20. 제정된 임금채권보장법에 의해 도입되었다. 최초 도입 당시에는 사업주의 파산 등으로 퇴직한 근로자를 보호대상으로 설정하고, 최종 3월분의 임금과 최종 3년간의 퇴직금을 임금채권보장기금에서 사업주를 대신하여 지급하는 도산대지급금 제도만이 시행되었다. 그 후 2015. 7. 1. 개정을 통해 임금채권보장법은 대지급금의 지급사유를 도산하지 아니한 사업장에서 임금을 지급받지 못하고 퇴직한 경우를 포함하도록 확대하여 300만원을 지급 한도로 하는 간이대지급금 제도를 도입한다. 그러나 당시에는 근로자가

간이대지급금을 지급받기 위해서는 해당 사업장에서 퇴직하여야 하며 사업주를 상대로 「민사집행법」에 따른 확정된 종국판결 기타 이에 준하는 집행권원을 확보하여야 했다. 그 이후에는 지급한도를 증액하는 방향으로 제도개선이 이루어지는 데, 간이대지급금의 지급한도는 2019. 7. 1.부터 임금 등, 퇴직급여 각 700만원, 합계 1,000만원으로 증액하였고, 도산대지급금은 2020. 1. 1.부터 1월분 임금(1년분 퇴직급여등) 기준 최대 350만원으로 인상하여 현재에 이르고 있다.

한편, 임금채권보장법은 2021. 4. 13. 다시 한 번 큰 폭의 개정을 맞게 된다. 개정은 두 방향으로 정리할 수 있는데, 먼저, 간이대지급금의 경우 종래 확정판결에 준하는 집행권원을 요구하였는데, 이에 더해 고용노동부장관으로부터 체불임금등과 체불사업주 등을 증명하는 서류(이하 “체불금품 확인서”라 한다)를 발급받으면 간이대지급금을 지급받을 수 있도록 지급요건으로 추가하였다(법 제7조 제1항 5호). 이 개선은 재판이라는 지리한 절차를 근로자가 아닌 근로복지공단에 전가시킨 것으로 근로자 입장에서는 지급절차가 매우 간소화, 신속화된다는 장점이 있다. 다음으로 종래 대지급금제도는 퇴직한 근로자만을 대상으로 하였으나, 이제는 ‘재직중’인 근로자도 대지급금을 지급받을 수 있도록 적용대상자가 확대되었다(제7조의2). 다만 재직중인 근로자는 저임금근로자로서 하나의 사업당 1회에 한해서만 대지급금을 지급받을 수 있다(제7조의2 참조).

이와 같이 임금채권보장법이 개정되어온 과정에서 제도운영에 적지않은 변화가 일어났고, 이러한 변화의 과정에서 부담금제도를 재검토할 필요가 있다는 의견이 대두하고 있다. 그 방향은 부담금 경감제도가 현재의 실질에 부합하도록 수정할 필요가 있는지 여부이고, 다른 하나는 편중된 대지급금 사용 사업주의 비율로 인한 잠재적 불만을 해소할 필요가 있는지 여부이다.

3. 법정 경감 대상 개선 필요성

가. 퇴직급여에만 경감을 인정하는 현재도의 문제점

임금채권보장기금의 재원으로 사업주가 납부하는 부담금은 현행법상 사업주의 업종을 불문하고 일률적으로 보수총액의 0.06%로 산정되고 있다(법 제9조 제2항, 「임금채권보장기금 사업주 부담금비율」 고시). 다만, 고용노동부장관은 다음과 같은 요건에 해당하는 사업주에 대해서는 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준」 고시(이하 ‘경감기준’이라 한다)가 정하는 바에 따라 부담금을 경감할 수 있다(법 제10조).

- ① 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주
- ② 법률 제7379호 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항에 따른 퇴직보험등에 가입한 사업주, 「근로자퇴직급여 보장법」 제3장에 따른 확정급여형퇴직연금제도, 같은 법 제4장에 따른 확정기여형퇴직연금제도 또는 같은 법 제25조에 따른 개인형퇴직연금제도를 설정한 사업주
- ③ 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제13조에 따라 외국인근로자 출국만기보험·신탁에 가입한 사업주

그런데 임금채권보장제도에 의해 지급이 보장되는 근로자의 임금채권은 「근로기준법」 제2조·제34조·제46조 및 제74조 제4항에 따른 임금·퇴직금·휴업수당 및 출산전후휴가기간 중 급여로서(법 제2조 제3호), 구체적으로 대지급금이 보장하는 범위는 법 제7조 제2항에 따르면 다음과 같다.

- ① 「근로기준법」 제38조 제2항 제1호에 따른 임금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제12조 제2항에 따른 최종 3년간의 퇴직급여등
- ② 「근로기준법」 제46조에 따른 휴업수당(최종 3개월분으로 한정한다)
- ③ 「근로기준법」 제74조 제4항에 따른 출산전후휴가기간 중 급여(최종 3개월분으로 한정한다)

임금채권보장법은 이러한 대지급금 지급 범위를 고려하여 임금, 퇴직급여등, 휴업수당, 출산전후휴가기간 중 급여에 대해 상한액을 대지급금의 종류를 고려하여 각 항목별로 다르게 설정하고 있다(법 제7조 제2항, 체불임금 등 대지급금 상한액 고시)

1) 도산대지급금의 상한액

도산대지급금의 연령별 상한액은 다음 표와 같다.

〈표 3-1〉 도산대지급금의 연령별 상한액

(단위: 만원)

항목 \ 퇴직당시 연령	30세 미만	30세 이상 40세 미만	40세 이상 50세 미만	50세 이상 60세 미만	60세 이상
임금	220	310	350	330	230
퇴직급여 등	220	310	350	330	230
휴업수당	154	217	245	231	161
출산전후휴가기간 중 급여	310				

주: 임금, 출산전후휴가기간 중 급여, 휴업수당은 1월분, 퇴직급여 등은 1년분 기준임.

2) 간이대지급금의 상한액

간이대지급금의 항목별 상한액은 다음과 같다.

〈표 3-2〉 간이대지급금의 항목별 상한액

(단위: 만원)

항목	상한액
임금, 출산전후휴가기간 중 급여, 휴업수당	700
퇴직급여 등	700

주: 1) 총 상한액은 1,000만원

2) 퇴직급여 등은 법 제7조 제1항 제4호·제5호에 따른 퇴직 근로자에 대한 대지급금에 한하여 적용됨.

임금채권보장법 및 하위규정의 태도에 따르면, 대지급금의 재원은, 간이대지급금의 경우 상호간의 연계성이 약하게 있기는 하나, 전체적으로는 이와 같이 임금등의 항목별로 구분하여 사용될 것이 예정되어 있다고 볼 수 있다.

나. 경감비율 조정 여부

그렇다면 퇴직금, 퇴직급여의 경우에는 사외적립과 같은 방식에 의해 근로자에 대한 지급을 담보할 수 있는 장치가 제도화되어 있고, 이러한 제도를 이용한 사업주에 대해서는 일정한 요건이 충족되는 경우에는 임금 항목에 대응하는 재원에 대해서도 인센티브를 주는 방안을 고려할 필요가 있다. 그러한 인센티브의 근거로는 사업주의 재무건전성이나, 신용도 등 경영의 안정성을 공적으로 확인할 수 있는 지표가 개발되어 있으므로 이를 활용하는 방법을 고려해 볼 수 있다. 그렇다면 퇴직급여를 제외한 나머지 임금 항목 재원에 대해서도 신용도 등을 바탕으로 경감을 인정한다고 할 때 경감의 비율을 얼마로 할 것인지가 문제된다.

현행 임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준에 따르면 퇴직급여의 지급이 보장되는 등 부담금 경감기준에 해당하는 경우 부담금의 100분의 50까지 경감이 가능하다. 이는 임금채권보장기금이 지급을 보장하는 큰 항목이 임금과 퇴직급여인데, 이를 50:50의 관계로 이해했기 때문으로 추측된다. 즉, 퇴직급여와 관련해서 사외적립 등 충분한 보장조치를 취한 사업주는 퇴직급여 미지급시 사용되는 임금채권보장기금의 50%에 대해서는 이를 사용하지 않을 개연성이 높기 때문에 위와 같은 수준의 경감기준을 적용하였다고 볼 수 있다. 실제로도 과거에는 대지급금이 임금과 퇴직금에 대응하여 지급되는 비율이 50:50수준을 유지하기도 하였다.

그런데 최근의 통계 자료에 따르면 이 50:50의 비율이 깨져 2017년 이래 이 비율은 계속 임금비율이 높아지는 추세에 있으며, 2020년 이후로는 퇴직금이 대지급금에서 차지하는 비

율이 40%를 하회하기에 이르렀다.

〈표 3-3〉 항목별 대지급금 지급 현황

(단위: 억원, %)

구분	합계 (a+b+c)	임금(a)		퇴직급여(b)		휴업수당 등(c)	
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
2019	4,599	2,681	58.3	1,907	41.5	11	0.2
2020	5,797	3,468	59.8	2,302	39.7	27	0.5
2021	5,466	3,272	59.9	2,127	38.9	66	1.2
2022	5,369	3,301	61.5	2,058	38.3	10	0.2
2023. 8.	4,415	2,839	64.3	1,571	35.6	5	0.1

자료: 근로복지공단

이는 과거보다 이직이 잦아 계속 고용의 기간이 줄고 있는 고용관계 패턴에 기인한 것으로 추측되나 이러한 현상이 최근 몇 년간의 추세로 확인되고 있다는 점에 비추어 볼 때, 이를 반영하여 경감비율을 조정할 필요가 있어 보인다. 즉, 기초가 되는 사실에 변화가 있다면 이를 제도에 반영하는 것이 합리적인 것이다. 현재의 추세는 임금채권보장기금의 지출에 있어 내부적으로 존재하는 임금항목에 따른 벽이 해체되고 있는 방향성을 보여준다고 볼 수 있다.

경감기준은 현재 고용노동부고시를 통해 정해진다는 점에서 개정이 비교적 용이하기는 하나 장기적인 추세를 반영하여 경감 범위를 조정할 수 있는 메커니즘을 명시하는 방법도 고려할 필요가 있다.

4. 부담금 부과와 차등화 여부

현 규정상 임금채권보장기금의 사업주 부담 비율은 보수총액의 0.06%로 전 업종에 공통이며, 사업주가 채용한 직원의 규모나 사업주의 매출액, 영업이익율 등과도 무관하게 일률적인 비율이 적용되고 있다.

그런데, 최근 3년간 대지급금제도를 이용한 사업장을 기준으로 낸 통계에 의하면 체불발생액이 대형화되면서 상위 5%에 해당하는 3,500개의 사업장이 전체 대지급금액의 47%인 약 1조 원을 사용하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 3-4〉 사업장 규모별 대지급금 지급 현황

(단위: 백만원, 개소, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 8월
4인 이하	119,721	178,542	189,285	201,670	168,248
5인 이상 ~ 9인 이하	81,908	106,026	98,025	96,319	81,184
10인 이상 ~ 49인 이하	167,291	203,387	176,500	155,481	136,390
50인 이상 ~ 99인 이하	52,135	50,473	43,891	37,840	26,310
100인 이상 ~ 499인 이하	31,544	35,266	25,621	41,545	27,234
500인 이상	7,280	5,996	13,249	4,009	2,163
합계	459,880	579,690	546,571	536,864	441,529

주: 1) 연도별, 규모별 지원금액은 백만원 단위에서 반올림한 수치로, 연도별 합계액과 일부 상이할 수 있음

2) 사업장 규모는 대지급금 최초 지급 시 근로복지공단에서 입력하는 “(도산/간이) 사업장” 화면의 상시근로자수 기준
자료: 근로복지공단

2021년 임금채권보장제도의 개편 이후 대지급금 지급이 용이해지면서 최근들어 임금채권 보장기금의 지출이 과거보다 상당히 큰 폭으로 증가하고 있는데, 이러한 상황을 고려할 때, 이제는 결국 기금의 재정악화로 연결되고 만약 재정이 고갈된다면 부담금 증액 등 특단의 조치가 취해져야 할 상황도 염두에 둘 시점이 된 것이다. 아울러 이러한 상황이 실제로 도래한다면 성실하게 부담금을 납부하면서 임금체불을 일으키지 않는 건전한 사업주의 입장에서는 자신이 납부한 부담금을 특정 사업주가 독식하여 사용하고 그 부담은 자신에게 돌아오는 것은 아닌지라는 의문을 가질 수도 있다. 이는 장차 제도 운영에 대한 신뢰를 저해하여 제도의 존속에도 악영향을 미칠 소지가 있다.

이러한 상황은 건전기업과 부실기업 사이의 부담금 분담비율의 문제와 관련있는데, 대체로 대기업, 우량기업의 경우에는 실질적으로 임금체불을 발생하는 경우가 없음에도 즉 수혜자가 없음에도 상당한 부담금을 납부하고 있는 반면, 소규모기업이나 신생기업 등은 임금체불이 발생하는 경우가 많아 제도의 수혜를 상대적으로 많이 누리면서도 납부한 부담금이 적어 제도 이용의 빈도가 비대칭적으로 많다는 비판으로 연결된다.

이러한 비판은 두 가지 관점에서의 검토를 요하는데, 먼저, 임금체불을 유발하지 않는 대기업 등이 상대적으로 더 많은 부담금을 납부한다는 점을 근거로 부담금을 감액할 필요가 있는지의 관점과, 임금체불을 유발하는 사업주에 대해서는 오히려 부담금을 증액해야 하는지의 관점이 그것이다. 정리하자면 차등적 부담금 부과가 가능한지의 문제라고도 볼 수 있고, 수혜 빈도나 규모를 고려하여 부담금 감액이나 증액과 같은 조정이 가능한지의 문제라 볼 수 있다.

동일한 맥락에서 부담금의 증액이 어렵다면 부실기업에 대해서는 대지급금제도의 이용한도를 설정하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 그러나 임금채권보장제도는 근로자 보호에 목적이 있는 제도이지 사업주에게 불이익을 주기위한 제도가 아닌 점, 근로자가 어느 사업주에게 고용되었는지를 기준으로 대지급금제도를 이용하는데 차별이 발생하는 문제가 있는데, 이러한 차별은 합리적 이유가 있다고 인정받을 가능성이 낮은 점, 같은 사업장에 다니는 여러 체불근로자들의 총 체불액이 이 사업장의 한도를 초과하는 경우, 대지급금 지급신청의 선후에 따라 선착순으로 대지급금을 지급할지, 체불발생일을 기준으로 우선순위를 정할지, 근로자 수나 아니면 체불액수를 기준으로 안분할지 등 여러 가지 실무적으로 해결하기 어려운 문제가 발생할 소지가 있는 점에서도 바람직한 방안이라고 보기는 어렵다. 임금체불은 통상 기업의 한계 상황에서 발생하는데, 영세기업일수록 이러한 위험에 처할 가능성이 많다는 점, 임금채권보장제도가 보호하려는 근로자는 이러한 상황에 처한 근로자인 점을 고려할 때, 부실기업의 문제를 제도적으로 어떻게 흡수하고 조화할 것인지에 대해서는 좀 더 신중한 접근이 필요해 보인다.

5. 부담금 경감 조정시 고려할 사항

임금채권보장법 제9조의 부담금은 임금채권보장기금의 재원으로 이에 대해서는 「부담금관리 기본법」이 적용된다. 부담금관리 기본법 제3조는 동법 별표에 규정된 법률에 따르지 아니하고는 설치할 수 없다고 규정하고 있는데, 임금채권보장법 제9조에 따른 사업주의 부담금은 이 별표 제60호에 명시되어 있기 때문이다. 이 법에서 정의하고 있는 “부담금”이란 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 행정권한을 위탁받은 공공단체 또는 법인의 장 등 법률에 따라 금전적 부담의 부과권한을 부여받은 자(이하 “부과권자”라 한다)가 분담금, 부과금, 기여금, 그 밖의 명칭에도 불구하고 재화 또는 용역의 제공과 관계없이 특정 공익사업과 관련하여 법률에서 정하는 바에 따라 부과하는 조세 외의 금전지급의무(특정한 의무이행을 담보하기 위한 예치금 또는 보증금의 성격을 가진 것은 제외한다)를 말한다(동법 제2조). 이러한 부담금의 개념에는, 부담금이 일반 재정수요보다는 특정사업을 위한 경비에 충당되고, 특정한 사업과 이해관계를 가지는 자에 대한 특별한 재정책임이라는 특징을 가지고 있다. 여기서 특별한 재정책임이라는 것은, 부담금은 부담금 부과대상자의 범위와 부담금 징수목적 사이에 밀접한 관계가 있어서 부담금을 납부할 의무를 지는 집단이 다른 집단 또는 일반적 납세의무자보다 징수목적에 대해 명백한 상관관계가 있어야 함을 뜻한다.²⁷⁶⁾

이를 고려할 때 임금채권보장법상 사업주 부담금의 부과대상은 그 징수목적과 밀접한 관련

276) 기획재정부, 「2022년도 부담금운용종합보고서」, 2023. 5, 4면.

이 있어야 하는바, 임금의 지급보장이라는 제도의 목적에 비추어 볼 때 근로자를 사용하는 모든 사업주는 임금지급의무를 부담한다는 점에서 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있어 특정 사업주에 대한 부담금의 경감은 그러한 의무를 부분적으로 면제시켜 주는 효과가 있으므로 이러한 점을 염두에 두고 허용여부가 판단되어야 한다.

한편, 일반적으로 부담금은 국가가 정책적 또는 유도적·조정적 기능의 공익사업의 재원으로 사용되는데, 임금채권보장제도에 따른 사업주 부담금도 이러한 기능을 고려하여 부담금의 액수를 산정하여야 한다. 다만, 이러한 관점에서 임금채권보장제도를 이해한다면 국가의 정책재량으로서의 성격이 강하므로 부담금은 임금채권보장법을 통해 사용자에게 부과되고 있을 뿐, 그 자체에 대한 헌법적 제한은 별도로 존재하지 않는다는 점에서 부담금의 경감의 허용여부, 경감사유의 설정, 경감비율의 선택 등은 원칙적으로 광범위한 입법재량에 달려 있다고 볼 수 있다.

그러나 부담금은 임금채권보장제도의 주요재원으로서 임금채권보장제도의 유지·존속의 필수조건이라는 점에서 임금채권보장제도의 법적 성격 여하에 따라 헌법적 차원 내지 제도 내재적 한계가 존재할 수는 있다. 예컨대, 제도의 유지·존속이 불가능할 정도로 부담금을 경감하는 것은 제도를 무력화시킨다는 점에서 그러한 경감으로 인한 재정적 손실을 만회하기 위한 대상조치가 이루어지지 않는다면 인정될 수 없을 것이다. 특히 그러한 무력화가 헌법적 차원에서의 문제를 유발한다면 이에 대해서는 보다 강력한 제한이 적용될 수 있다.

임금채권보장제도는 국가의 직접적인 사회보장의무의 본격적 개시에 앞서 근로자를 일정 범위에서 생활고라는 빈곤상태로부터 보호해 주는 역할을 수행하므로 사회보장제도로서의 성격을 지니고 있다.²⁷⁷⁾ 임금채권보장제도는 도산이라는 사업에 내재된 공통의 위험을 사업주들 사이에서 분배하여 대비한다는 점에서 사회적 위험을 보험의 방식으로 대처하는 제도인 사회보험(사회보장기본법 제3조 제2호 참조)에 가장 가깝다. 그렇다면 임금채권보장법상 사업주 부담금은 사회보험료로서의 성격도 지니고 있다고 보아야 할 것이다. 이에 임금채권보장법 제16조는 사업주 부담금의 징수에 관해서는 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률을 상당부분 준용하고 있기도 하다.

임금채권보장제도가 사회보장제도의 일환인 사회보험으로서의 성격을 지니고 있다면 사업주 부담금의 부담대상, 액수 결정, 경감 등의 한계 역시 사회보험료의 성격을 고려하여 정해져야 할 것이다. 부담금과 사회보험료는 아래 표와 같은 개념상의 차이가 있다.²⁷⁸⁾

277) 김린, “산림조합에 대한 임금채권부담금 납부 면제 여부 - 연대성의 관점에서”, 월간노동리뷰, 2016년 12월호, 한국노동연구원, 102~103면 및 기획재정부, 「2022년도 부담금운용종합보고서」, 2023. 5, 631면 참조.

278) 기획재정부, 「2022년도 부담금운용종합보고서」, 2023. 5, 6면.

〈표 3-5〉 사회보험료의 정의와 부담금과의 차이

개념	정의	부담금과의 차이
사회보험료	피보험자의 질병·노령·실업·사망 등의 사회적 사고에 의한 소득상실에 대하여 보험원리에 의거하여 그 소득을 보장 하기 위하여 국민건강보험법·국민연금법·고용보험법·산업재해보상보험법 등에 의하여 피보험자와 사용자 등이 부담하는 보험료	부담금이 특정의 공공사업과 특별한 관계가 있는 자에 대해 부과되는 반면, 사회보험료는 피보험자들간의 연대적 배분 및 차등적 조절을 감안해서 부과됨

요컨대, 부담금의 부과대상 선정이나, 액수 결정, 경감 등은 사업주들간의 연대적 배분 및 차등적 조절이라는 한계를 준수하여야 한다.

이러한 점에서, 현재 가능한 부담금 조정은 앞에서 본 바와 같이 제도 내재적으로 차별이 발생하고 있는 퇴직급여 보장 부분에서의 경감 적용 여부 및 경감을 산정이라 할 수 있다. ,

다만, 우량기업과 부실기업 즉, 사업주별 부담금 개별화의 문제는, 부담금 변경의 한계 설정에 관한 근본적 질문인 사업주들간의 연대적 배분 및 차등적 조절과 연결되어 있는 문제라는 점에서, 우량기업의 현재 부담금 부과가 과도한 것은 아닌지, 부실기업의 부담금 부과가 과소한 것은 아닌지, 우량기업에 대해 부담금을 인하하고 부실기업에 대해 부담금을 인상하였을 때 제도를 국민의 눈높이에 맞춰 유지·존속할 수 있는지 등을 종합적이고 체계적으로 연구한 이후에야 답을 내릴 수 있을 것으로 생각된다.

제2절 사업주 부담금 경감 기준 개선 방안

1. 부담금 및 경감에 관한 규정 형식

임금채권보장법 제9조 제1항은 대지급금을 지급하는 데 드는 비용에 충당하기 위해 사업주로부터 부담금을 징수하도록 규정하고 있고, 제2항은 “제1항에 따라 사업주가 부담하여야 하는 부담금은 그 사업에 종사하는 근로자의 보수총액에 1천분의 2 범위에서 위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 부담 비율을 곱하여 산정한 금액으로 한다.”고 규정하고 있다.

위 규정의 위임을 받아 고용노동부장관은 고용노동부고시를 통해 사업주 부담 비율을 정하고 있는데, 그동안 부담 비율은 아래 표와 같은 변화가 있었다.

〈표 3-6〉 연도별 사업주 부담금 부담 비율

기간	1998년	1999년	2000년	2001년~ 2002년	2003년~ 2004년	2005년~ 2009년	2010년~ 2015년	2016년~ 현재
부담 비율	0.02%	0.03%	0.09%	0.05%	0.03%	0.04%	0.08%	0.06%

현재 고용노동부고시 제2022-94호 「임금채권보장기금 사업주 부담금비율」은 임금채권보장기금의 사업주 부담 비율을 보수총액의 1000분의 0.6으로 규정하면서 전 업종에 공통된 비율을 적용하도록 하고 있다.

한편 임금채권보장법 제10조는 사업주 부담금 경감의 근거를 다음과 같이 규정하고 있다.

제10조(부담금의 경감) 고용노동부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업주에 대하여는 제 9조에 따른 부담금을 경감할 수 있다. 이 경우 그 경감기준은 고용노동부장관이 위원회의 심의를 거쳐 정한다.

1. 삭제
2. 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주
3. 법률 제7379호 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항에 따른 퇴직보험등에 가입한 사업주, 「근로자퇴직급여 보장법」 제3장에 따른 확정급여형퇴직연금제도, 같은 법 제4장에 따른 확정기여형퇴직연금제도 또는 같은 법 제25조에 따른 개인형퇴직연금제도를 설정한 사업주
4. 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제13조에 따라 외국인근로자 출국만기보험·신탁에 가입한 사업주

위 규정의 위임을 받은 고용노동부고시 제2018-50호 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준」은, 부담금의 100분의 50에 해당하는 금액에 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금 중 미리 정산하여 지급한 비율 또는 퇴직연금제도의 설정 등으로 지급이 보장되는 비율을 곱하여 산정한다고 하면서, 퇴직급여 정산·지급보장 비율의 산정 방법을 다음과 같이 구체적으로 규정하고 있다.

- 가. 퇴직금을 중간 정산한 경우: 개산부담금 또는 월별부담금 산정년도의 직전년도 말을 기준으로 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금에 대하여 미리 정산하여 지급한 비율
- 나. 퇴직연금제도를 설정한 경우
 - 1) 확정기여형 퇴직연금제도를 설정한 경우: 직전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정기여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여의 지급이 보장되는 비율

- 2) 확정급여형 퇴직연금제도를 설정한 경우: 직전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정급여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여부담금을 적립한 비율. 다만, 전체 가입 근로자의 평균가입기간이 3년을 초과하고 소급 적용하지 아니한 경우에는 다음 산식에 따른다.

$$\frac{3\text{년} - [\text{가입근로자 평균가입년수} \times (1 - \text{가입기간중 퇴직급여 적립비율})]}{3\text{년}}$$

- 다. 퇴직보험·퇴직일시금 신탁 또는 외국인근로자 출국만기보험·출국만기 일시금 신탁에 가입한 경우: 직전년도 말을 기준으로 가입 근로자의 평균근속연수가 3년 이하인 경우에는 퇴직금 적립비율(근로자의 퇴직금 지급보장을 위해 퇴직보험 등에 적립된 금액을 전체 근로자의 퇴직금 추계액의 합계액으로 나눈 비율을 말한다). 다만, 가입 근로자의 평균근속연수가 3년을 초과하는 경우에는 다음 산식에 따른다.

$$\frac{3\text{년} - [\text{평균근속연수} \times (1 - \text{퇴직금 적립비율})]}{3\text{년}}$$

- 주: 1) 평균근속연수는 전체근로자 근속연수의 합계를 전체근로자수로 나눈 것을 말함
2) 근속연수는 실근로연수가 아니라 퇴직금 산정 시 기준이 되는 근속연수를 말함(예: 10년 근무 시 15년치 퇴직금을 지급하는 누진제 사업장의 경우 근속연수는 15년)

- 라. 1개 사업체에서 가목부터 다목까지의 경감사유 중 2개 이상의 사유가 있는 경우: 전체 퇴직급여 지급대상 근로자 중 각 경감사유 해당 근로자의 비율을 구한 후 각 경감사유별 정산·지급보장 비율을 곱하여 산정한 값을 더하여 최종 정산·지급보장 비율을 산정함

2. 부담금 부과 및 경감의 고려 요소

가. 부담금 부과비율

1) 부담금 비율 차등 규정의 가능성

산재보험료율을 사업의 종류별로 구분하여 정하도록 규정하고 있는 고용산재보험료징수법과 달리 임금채권보장법은 사업주 부담 비율의 상한을 규정하고 있을 뿐이고, 구체적인 부담금 비율은 고용노동부고시에 위임하고 있다. 임금채권보장기금 사업주 부담금 비율에 관한

고시에 따른 부담금 비율은 보수총액의 1000분의 0.2에서 1000분의 0.9까지 변화가 있어왔으나 그와 같은 부담금 비율은 전 업종에 공통적으로 적용되는 것으로 규정하였다. 현재 사업주 부담금 역시 전 업종 공통으로 보수총액의 1000분의 0.6으로 일률적으로 규정하고 있다.

그러나 임금채권보장법이 구체적인 부담금 비율의 규정 방식에 대해서는 특별한 규정을 두지 않은 것은 부담금 비율을 규정하는데 있어 상당한 재량을 부여한 것으로 볼 수 있으므로, 일정한 기준에 따라 부담금 비율에 차등을 두더라도 가장 높은 부담금 비율이 1000분의 2를 넘지 않는다면 위법한 부담 비율 설정이라고 보기는 어려워 보인다.

2) 업종에 따른 부담금 비율 차등 여부

구체적인 상관관계에 대해서는 확인이 필요하겠지만, 업종에 따라 임금체불의 발생률과 이에 따른 대지급금 지급 비율에 현저한 차이가 발생한다면, 사업주 부담금 비율도 업종별 임금체불 위험성에 따라 다르게 규정하는 것을 고려할 필요가 있다. 임금채권보장법의 본질을 사회보장제도로 이해하고, 임금채권보장기금의 사업주 부담금이 사회보험료의 성격을 가진다고 이해한다면 그에 따라 부담금을 차등 부과하는 것이 보험의 원리에 부합하는 측면이 있다.

업종별 대지급금 지급 금액에 차이가 있을 수는 있으나 업무상 재해와 달리 임금체불 발생의 위험성은 사업의 종류와 본질적인 연관관계가 있는지는 의문이다. 대지급금 지급에는 기업의 규모나 형태 등 다양한 요소가 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 산재보험료와 같이 사업의 종류별로 부담금 비율을 다르게 정할 것인지에 대한 논의에 앞서 사업의 종류별 대지급금 지급 현황에 대한 조사 뿐 아니라, 사업의 종류에 따라 대지급금 지급에 차이가 발생한다면 그 원인이 무엇인지, 이를테면 사업의 종류에 따라 종사자의 수 또는 기업의 규모에 차이가 있기 때문에 그와 같은 차이가 발생하는 것은 아닌지 등에 대하여 면밀한 분석을 통해 사업의 종류에 따른 임금체불 위험성의 차이가 확인되는 것이 전제되어야 할 것이다.

3) 기업의 규모에 따른 차등 여부

기업의 규모가 영세할수록 임금체불의 발생 및 대지급금 지급 가능성이 높아진다는 점에서 기업의 규모에 따라 부담금 비율을 다르게 정할 것인지에 대해서는 검토가 필요하다. 앞서 본 <표 3-4> 사업장 규모별 대지급금 지급 현황에 따르면 임금체불은 기업 규모에 따라 발생 비율에 차이가 있음을 알 수 있다. 특히 대지급금 지급액에서 50인 이하 사업장이 차지하는 비율은 약 85%에 이르는데, 이는 영세한 규모로 인해 경영악화 및 도산 등의 위험이 상대적으로 크다는 점이 원인이 된 것으로 보인다.

소규모 기업에 대하여 상대적으로 많은 금액의 대지급금이 지급된 점을 고려하면, 기업의

규모에 따라 사업주 부담 비율을 달리 규정하는 것은 임금체불의 위험도를 고려한 부담금 부과 방안이 될 수 있다. 이 점에서 50인 이하 기업에 대하여 상대적으로 높은 사업주 부담 비율을 규정하는 것이 보험의 원리에 부합하는 측면이 있을 수 있고, 형평성에도 부합하는 것처럼 보인다. 다만 대기업의 사업주 부담 비율을 감액하는 것을 인정하더라도 그 근거는 단순히 대기업의 부실가능성이 상대적으로 낮다는 것에서 찾아서는 안 되고, 대기업 스스로 임금체불의 발생을 예방하기 위해 충분한 노력을 기울이고 있다는 점에 대한 고도의 예측과 보장에 터잡은 것이어야 한다. 즉, 과거의 이력이 아닌 미래 위험에 대한 대비 수준에 기초한 것이어야 한다. 퇴직금에 대한 담보를 통해 부담금 감액을 인정하고 있는 이유 역시 이와 같은 원리라고 볼 수 있다.

임금체불의 위험도를 단순히 현재의 대지급금 지급 금액만으로 판단하는 것은 적절하지 않은 측면이 있다. 보험이란 미래의 불확실성에 대비하는 제도라는 점에서 대기업이라 하더라도 언제든지 부실의 위험에 노출될 위험을 배제하기는 어렵고, 따라서 이들 역시 근로자를 위한 보험을 통해 임금체불에 대비하도록 할 필요성이 있다. 특히 대기업의 경우 대지급금 지급 대상이 되는 근로자 수도 많고, 상대적으로 임금 수준이 높은 경우가 많은 점을 고려하면 근로자 1인당 대지급금 금액도 상대적으로 많을 수 있다. 즉 대기업이 비록 부실의 위험이 경험칙상 상대적으로 낮고 이로 인해 임금체불의 발생 가능성이 적다고 하더라도, 일단 대지급금 지급 사유가 발생하면 대지급금 지급 규모가 커질 수 있다는 점에서, 사업에 내재하는 위험이 적다고 단정할 수 있을지 의문이다.

부실기업에 대하여 더 높은 사업주 부담금을 부과하는 것과 관련하여 근로자보호를 위해 시행중인 산재보험의 예를 참고할 수 있다. 산재보험의 경우 재해율이 높은 사업장에 대해서는 더 많은 부담을 요구하고 있다는 점에서 임금채권보장기금도 그러한 방식을 취할 수 있다는 주장이 있을 수 있다. 그러나 산재보험에서 재해율을 반영하여 산재보험요율을 인상하는 것은 그것이 사업주로 하여금 산재예방에 관한 동기를 부여하고, 산재예방에 유효한 수단이기 때문에 그러하다고 이해하는 것이 타당하다. 임금채권보장제도는 부담금요율을 인상한다고 하여 그것이 체불예방의 효과로 이어질 것인지는 확답하기 어렵다. 이는 추후 체계적인 조사를 통한 면밀한 분석을 요하는 문제라 할 것이다. 다만 단견으로는 사업자금이 부족하여 임금체불이 발생하였는데, 거기에 다시 더 많은 부담금을 납부하라고 한다 하여 임금체불이 근절될 것인지에 대해서는 긍정적인 답변을 하기 어려워 보인다.

임금채권보장제도는 사회보험의 성격을 가지므로 사회연대의 원리가 적용된다. 사회보험은 사회연대의 원리에 기초하여 가입자의 개별적인 보험 위험에 따라 보험료를 책정되지 않고 원칙적으로 가입자의 경제적인 능력에 따라 보험료를 납부하도록 하고, 소득에 따른 부담을 통해 사회보험 확대에 필요한 재정적 수요에 대응한다.²⁷⁹⁾ 이 점에서 사회보험에는 보험의

원리가 엄격하게 적용되지 않는다. 국민건강보험에서 소득에 기초하여 보험료를 부담하면서도 보험급여에 있어서는 차이가 없는 것은 능력에 따른 기여 측면에서 형평성이 인정될 수 있는 것이다. 임금채권보장기금의 사업주 부담금을 능력에 따른 기여 측면에서 접근한다면, 상대적으로 경제적 능력이 큰 대기업에 대하여 더 높은 비율의 부담금을 부과하는 것까지도 정당성을 인정할 여지가 있다. 기업 규모가 적은 경우에는 사업주의 경제적인 능력도 대기업에 비해 떨어지는 경우가 많으므로, 50인 이하 기업에 대지급금 지급이 많이 이루어진다고 하여 50인 이하 기업에 더 높은 사업주 부담 비율을 규정하는 것은 사회연대의 원리 측면에서 문제가 있으며, 임금채권보장기금의 재정건전성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 임금채권보장법에서 사업주의 부담금 경감 규정을 도입하면서 개정 이유로 “5인 미만의 근로자를 사용하는 사업주는 그 사업규모가 영세하고, 근로기준법상 퇴직금 지급의무도 없으므로 사업주가 임금채권보장기금에 납부하여야 할 의무가 있는 부담금을 경감할 수 있도록 함”이라고 한 것²⁸⁰⁾ 역시 임금채권보장제도의 사회적 성격을 고려한 것으로 이해할 수 있다.

4) 외국의 사례

가) 프랑스

프랑스의 경우 임금채권의 보장은 근로자임금채권보장제도관리협회(Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés: AGS)에서 담당하고 있는데, AGS는 임금보장국민기금(Fonds national de garantie des salaires: FNGS)을 운영하면서 보호절차, 회생절차, 청산절차가 진행되는 경우 기업을 대신하여 경영자금 부족으로 인한 체불임금 중 일정한 금액을 지급하고 있으며, 그 재원은 실업보험료 중 사용자가 부담하는 기여금(cotisation sociale)을 통해 조성하고 있다.²⁸¹⁾

AGS의 기여율은 회의를 통해 결정하는데, 2023. 6. 20. 기여율을 기존의 0.15%로 유지하기로 결정하였고,²⁸²⁾ 기업 규모에 따른 차등은 두고 있지 않은 것으로 보인다.

나) 일 본

일본의 경우 임금채권보장제도는 「임금의지불확보등에관한법률」에서 규정하고 있는데, 「노동자재해보상보험법(이하 ‘노재보험법’이라 함)」 제29조 제1항 제3호에서 ‘임금의 지급 확보

279) 장승혁, “사회보험법과 사회연대 원리”, 「사회보장법학」 제6권 제1호, 한국사회보장법학회, 2017. 6, 20-21면.

280) 임금채권보장법(2000. 12. 30. 법률 제6334호로 일부개정된 것) 제정·개정이유

281) 김근주 외, 「체불임금 해결시스템의 국제비교 연구 -임금채권보장제도를 중심으로-」, 한국노동연구원, 2016. 12, 43면, 48면.

282) <https://www.ags-garantie-salaires.org/key-figures.html>

를 도모하기 위하여 필요한 사업'을 노재보험법상 사회복지촉진 등의 사업으로 규정하고 있다. 해당금 지급을 위한 예산은 노동보험특별회계노재계정의 사회복지 등 촉진사업비 중 '미지급 임금의 해당금 사업비 보조금'으로 계상되어 있다.²⁸³⁾

「노동보험의보험료징수등에관한법률(이하 '노동보험징수법'이라 함)」 제12조 제1항은 일반 보험료와 관련된 보험료율을 노재보험율과 고용보험율을 더한 비율(둘 중 하나의 보험관계만이 성립하고 있는 사업의 경우에는 그 보험율만을 적용)을 보험료율로 하도록 규정하고 있다. 노동보험징수법 제12조 제2항에서 노재보험율을 과거 3년간 업무재해 및 통근재해와 관련된 재해율, 노동복지사업으로 행하는 사업의 종류 및 내용, 기타의 사정을 고려하여 노동대신이 정하도록 규정하고 있는데, 노동보험징수법 시행규칙 별표 1은 업종별로 노재보험율을 정하고 있으며, 제12조 제4항에서 고용보험율은 원칙적으로 1000분의 14.5로 규정하고 있다.

노재보험율은 해당금 지급을 위한 예산을 고려하여 정하도록 되어 있는데, 일률적인 비율을 규정하고 있다는 점을 고려하면, 일본은 해당금 사업비 보조금에 대한 사업주의 부담금에 관하여 사업 규모에 따른 차등을 두고 있지는 않다.

5) 소 결

부담금 부과 비율의 차등 적용 문제와 관련하여 단순히 사업 규모에 따른 대지급금 지급 금액의 차이만 고려할 것이 아니라, 임금체불의 구체적인 위험성, 임금채권보장제도의 사회 보장제도로서의 성격과 정책적인 목적 등에 대한 종합적인 고려가 필요하다. 외국의 임금채권보장제도 역시 임금채권보장법과 유사하게 그 재원을 사업주의 납부를 통해 마련하고 있으며, 부담 비율은 사업의 규모나 업종 등을 고려하지 않고 일률적으로 규정하고 있는데, 업종이나 사업 규모에 따라 사업주 부담금 부과 비율을 달리 해야 할 당위성은 없다는 것을 보여주는 것이라 할 수 있다.

따라서 임금채권보장기금의 사업주 부담금 부담 비율을 업종이나 사업 규모에 따라 차등 적용하는 방안은 신중한 검토가 필요할 것으로 보인다.

나. 부담금 경감의 고려요소

1) 부담금 경감의 근거

임금채권보장법에서 사업주의 부담금 경감 규정을 처음 둔 것은 2000. 12. 30. 개정에서였는데, 경감 규정을 둔 이유를 “5인 미만의 근로자를 사용하는 사업주는 그 사업규모가 영

283) 김근주 외, 앞의 책, 103면.

세하고, 근로기준법상 퇴직금 지급의무도 없으므로 사업주가 임금채권보장기금에 납부하여야 할 의무가 있는 부담금을 경감할 수 있도록 함”이라고 하였을 뿐,²⁸⁴⁾ 퇴직보험 등에 가입한 사업주에 대한 경감 이유는 명확히 밝히지는 않았다. 그러나 5인 미만 근로자를 사용하는 사업주의 부담금 경감 이유로 퇴직금 지급의무가 없다는 점을 들고 있는 것을 고려하면, 퇴직보험 등에 가입한 사업주는 퇴직금 체불 가능성이 적다는 점을 고려한 것으로 이해할 수 있다.

경감기준은 사업주가 부담하는 퇴직금 중 이미 지급하였거나 퇴직보험 등에 의해 지급이 보장되는 금액의 비율에 따른 경감을 규정하고 있는데, 이 역시 퇴직금의 체불 가능성을 고려하여 경감을 하고 있는 것으로 볼 수 있다.

임금채권보장제도를 임금체불로 인해 발생하는 근로자의 생활상 불이익을 방지하는 사회보험의 성격을 가진다는 점을 고려하면, 보험사고라고 할 수 있는 임금체불의 발생 가능성을 고려하여 사업주 부담금을 경감하는 것은 일응 보험의 원리에 부합하는 것으로 볼 수 있다.

또한 퇴직연금제도를 설정하여 퇴직급여의 지급을 보장하고 있는 사업주와 그렇지 않음으로 인해 퇴직금의 체불 위험을 발생시키고 있는 사업주에 대하여 동일한 부담금을 부과하는 것은 평등원칙 위반의 문제가 제기될 수도 있다. 퇴직연금제도를 설정함으로써 적어도 일정 범위 내에서는 퇴직금에 대한 체불 가능성이 없는 사업주와 그렇지 않은 사업주는 임금체불의 발생 위험 측면에서 차이가 있다. 임금채권보장제도의 사회보험으로서의 성격을 고려한다면, 임금체불이라는 보험사고 발생 위험의 차이를 고려하여 부담금을 납부하도록 하는 것이 보험의 원리에도 부합한다.

부담금 경감은 부수적으로 사업주로 하여금 퇴직연금제도를 설정하도록 유도하는 기능을 할 수 있다. 사업주가 부담금을 경감받기 위해 퇴직연금제도를 설정한다면 그만큼 해당 사업장의 근로자에 대해서는 퇴직금의 체불 위험이 감소하게 될 것이다. 이를 통해 근로자의 생활 안정에 기여할 뿐 아니라 퇴직금에 대한 대지급금 지급을 감소시킴으로 인해 임금채권보장기금의 재정 안정성에도 기여할 수 있다는 것이 부담금 경감의 근거가 될 수 있다.

따라서 임금채권보장법이 사업주 부담금 경감의 원인으로 퇴직급여 등의 지급이 보장되는 사정을 규정하고 있는 것은 퇴직금의 지급 보장을 통한 임금체불의 예방과 재정 안정성 확보, 보험의 원리 등을 근거로 한 것으로서 타당성을 인정할 수 있다.

2) 부담금 경감 사유의 추가 가능성

부담금 경감 요건의 추가와 관련하여 우선 퇴직급여제도 설정에 준하는 사정을 경감 사유로 추가하는 방안을 생각해볼 수 있다. 그런데 퇴직급여제도를 설정하면 그만큼 퇴직금에 대한 대지급금 지급 가능성이 감소하므로 부담금 부과의 형평성 관점에서 부담금을 경감하고

284) 임금채권보장법(2000. 12. 30. 법률 제6334호로 일부개정된 것) 제정·개정이유

있는 것인데, 임금의 경우 사회적립 등의 방법으로 임금 지급을 담보할 수 있는 제도적 장치가 없는 상황에서 퇴직급여제도의 설정에 준하는 부담금 경감 사유를 인정하는 것은 무리라고 보인다. 재무건전성이나 신용도 등을 통해 경영의 안정성을 확인할 수 있다 하더라도 이는 해당 기업의 과거 이력을 바탕으로 하는 것이지, 미래의 임금체불을 방지하기 위한 대비 수준을 보여주는 직접적인 지표라고 보기도 어렵다. 무엇보다도 근로기준법 제43조에 따른 임금 지급은 사용자의 의무인데, 이러한 의무를 이행했다는 이유로 부담금 경감까지 인정할 수 있을 것인지 의문이고, 경감사유를 확대함에 따른 재정 문제를 고려하면 사업주 부담 비율도 함께 조정해야 할 것인데 이 경우 부담금 경감이 실질적인 의미를 가질 수 있을 것인지도 의문이다.

한편 부담금 경감 사유의 추가와 관련하여 과징금의 산정 기준을 정하고 있는 공정거래위원회의 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」를 참고할 수 있는데, 위 고시는 사업자들간에 공동행위 등의 합의를 하고 실행하지 않은 경우, 조사·심의에 협조한 경우, 약식심의 결과를 수락한 경우, 위반행위를 자진 시정한 경우, 위반행위가 통상의 업무 수행 중 발생할 수 있는 가벼운 과실에 의한 것임이 명백한 경우를 과징금 경감 사유로 규정하고, 각 사유별로 구체적인 감경 범위를 규정하고 있다. 이를 참고하면 임금채권보장법상 사업주 부담금에 있어서도 임금체불 발생 억제를 위한 노력 여부, 임금체불 발생 이력, 임금체불에 대한 고의·과실 여부 등을 고려할 수 있을 것이다. 그러나 임금채권보장법 제10조에서 규정하고 있지 않은 사유를 근거로 하여 사업주 부담금을 경감하는 것은 법률의 규정에 반한다는 점, 경감 사유를 확대하면 재정 건전성에 문제가 될 수 있는 점, 과징금은 부과 사유가 발생한 후 사후에 부과하기 때문에 여러 사정을 고려하여 가중 및 경감을 하는 것이 용이하지만 임금채권보장법상 사업주 부담금은 사전에 부과 기준을 정해야 하기 때문에 임금체불을 방지하기 위한 사업주의 노력이나 고의·과실 여부 등을 경감요소로 삼기는 어려운 점 등을 고려하면 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시와 같은 형태로 경감사유를 규정하는 것은 적절하지 않다. 또한 사업의 규모와 같은 요소는 부담금의 경감 단계가 아니라 부담금 부담 비율의 결정 단계에서 고려하는 것이 타당하다.

결국 퇴직급여제도 설정 등 현재 규정되어있는 사유 이외에 부담금 경감 사유를 추가하는 것은 적절해 보이지 않는다.

3. 부담금 경감 비율의 적정성

현재 경감기준은 퇴직급여 정산·지급보장 비율에 50%를 곱하여 산정된 비율을 기준으로 사업주 부담금을 경감하도록 하고 있다. 1998년 7월부터 2001년 10월까지 지급된 해당금 중 퇴직금은 전체의 49.6%였는데, 사업주 부담금 경감 규정을 제정할 당시 대지급금 지급 비

율이 임금과 퇴직금이 약 50:50인 점을 고려하여 부담금 경감 비율을 50%로 정한 것으로 보인다.²⁸⁵⁾ 그런데 <표 3-3> 항목별 대지급금 지급 현황에서 본 것처럼 최근 대지급금에서 퇴직금이 차지하는 비율이 지속적으로 감소하는 추세이다.

대지급금에서 퇴직금의 비율이 감소한 원인으로 퇴직연금 가입률이 증가함에 따라 퇴직금에 대한 체불 자체가 감소하였을 가능성을 고려할 수 있다. 그런데 2021년 기준 퇴직연금 가입률은 300인 이상 사업장의 경우 91%에 달하지만, 30인 미만 사업장의 경우 25%에 불과하였고, 소득이 상위 20%인 근로자와 하위 20%인 근로자의 퇴직연금 가입률은 15배의 차이가 있었다.

<표 3-7> 종사자 규모별 퇴직연금 도입 현황

	2020년				2021년			
	전체 도입 사업장	도입 대상 사업장(A)	도입 사업장(B)	도입률 (B/A×100)	전체 도입 사업장	도입 대상 사업장(A)	도입 사업장(B)	도입률 (B/A×100)
합계 (구성비)	408,462 (100.0)	1,464,143 (100.0)	398,587 (100.0)	27.2	424,950 (100.0)	1,530,363 (100.0)	414,565 (100.0)	27.1
5인 미만	88,002 (21.5)	777,024 (53.1)	82,642 (20.7)	10.6	93,038 (21.9)	826,941 (54.0)	87,340 (21.1)	10.6
5~9인	127,026 (31.1)	380,503 (26.0)	124,255 (31.2)	32.7	131,688 (31.0)	389,235 (25.4)	128,871 (31.1)	33.1
10~29인	126,029 (30.9)	221,442 (15.1)	124,669 (31.3)	56.3	130,904 (30.8)	226,809 (14.8)	129,436 (31.2)	57.1
30~49인	27,704 (6.8)	37,711 (2.6)	27,544 (6.9)	73.0	28,698 (6.8)	39,097 (2.6)	28,542 (6.9)	73.0
50~99인	22,337 (5.5)	27,595 (1.9)	22,211 (5.6)	80.5	22,880 (5.4)	28,275 (1.8)	22,740 (5.5)	80.4
100~299인	12,694 (3.1)	14,738 (1.0)	12,608 (3.2)	85.5	12,856 (3.0)	14,686 (1.0)	12,772 (3.1)	87.0
300인 이상	4,670 (1.1)	5,130 (0.4)	4,658 (1.2)	90.8	4,886 (1.1)	5,320 (0.3)	4,864 (1.2)	91.4

상대적으로 영세한 중소기업에서 임금체불이 발생할 위험이 높다는 점을 고려하면, 퇴직연금 가입률의 증가가 그대로 대지급금 중 퇴직금 비율 감소라는 결과로 이어지지는 않는다고 볼 수 있다.

대지급금에서 퇴직금의 비율이 감소한 원인으로 대지급금 제도의 확대를 고려할 수 있다. 대지급금은 사업주의 파산 등의 경우 최종 3개월분의 임금과 최종 3년간의 퇴직금을 보장하

285) 김호경, “퇴직보험 활성화와 임금채권보장기금 부담금체계 개선방안: 합리적인 부담금 경감체계 및 제도개선을 위한 보험수리적 고찰”, 『노동정책연구』 2001년 창간호, 한국노동연구원, 2001, 60면.

는 제도로 출발하여, 최종 3개월분의 휴업수당과 출산전후휴가급여가 보장 범위에 추가되었고, 2021. 4. 13. 개정으로 재직 근로자에 대한 간이대지급금 지급 제도가 신설되었다. 사업주의 파산 등으로 인해 대지급금 지급 사유가 발생하는 경우 통상 임금과 퇴직금은 동일한 금액이 되고, 특별한 사정이 없다면 체불된 임금과 퇴직금 금액도 동일하게 될 것이다. 그런데 대지급금 지급 대상 확대에 따라 퇴직금에 대한 대지급금 지급이 감소하지 않더라도 대지급금에서 임금 등과 퇴직금의 지급 비율이 달라질 수 있다. 더욱이 퇴직과는 무관한 간이대지급금이 활성화된다면 대지급금에서 퇴직금의 비율은 더욱 낮아질 수도 있다. 이러한 추세는 재직자와 퇴직자에 대한 대지급금 지급 비율을 통해서도 어느 정도 확인할 수 있다.

〈표 3-8〉 재직자 및 퇴직자에 대한 대지급금 지급 비율

(단위: 백만원, %)

구분	합계 (a+b)	재직자(a)		퇴직자(b)	
		금액	비율	금액	비율
2019	459,880	0	0.0	459,880	100.0
2020	579,690	0	0.0	579,690	100.0
2021	546,571	954	0.2	545,617	99.8
2022	536,864	4,807	0.9	532,057	99.1
2023.8.	441,529	3,598	0.8	437,931	99.2

자료: 근로복지공단

대지급금에서 퇴직금이 차지하는 비율이 감소하고 있는 것에 퇴직연금제도의 확대 외에 임금채권보장제도 자체의 변화와 그 밖에 외부적인 요인이 영향을 미쳤다면, 사업주 부담금 경감 기준도 대지급금 지급 비율을 고려하여 조정할 필요가 있다. 그렇지 않는다면 퇴직연금제도 설정으로 인해 감소하는 임금체불의 위험성 이상으로 부담금 경감이 이루어지는 것으로 볼 수 있고, 이는 임금채권보장기금의 재정 건전성 측면에서도 문제가 된다.

따라서 사업주 부담금의 경감률은 대지급금에서 퇴직금이 차지하는 비중을 고려하여 현재의 50%보다 낮게 설정할 필요가 있다. 또한 대지급금이 퇴직금에서 차지하는 비중이 지속적으로 감소하는 추세인 점을 고려하면, 대지급금 지급 현황을 고려하여 부담금 경감률을 몇%로 할 것인지에 대해 지속적으로 재검토할 필요도 있다.

4. 부담금 경감의 개선 방식

가. 현재 부담금 경감 기준의 적절성 여부

부담금 경감 기준은 퇴직금 중간정산 또는 퇴직연금제도 등의 설정에 따라 일정 범위의 퇴직금에 대해서는 체불이 발생하지 않는 점을 고려하여, 이에 해당하는 비율에 따라 부담금을 경감하도록 규정하고 있다.

1) 퇴직금 중간지급 등의 경우

현재 부담금 경감 기준은 크게 퇴직금을 중간정산한 경우와 퇴직연금제도등을 설정한 경우로 구분할 수 있다. 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주는 미리 정산한 부분에 대해 퇴직금 지급 의무가 소멸한다는 점에서 퇴직금 체불이라는 문제가 더 이상 발생할 여지가 없게 된다. 대지급금의 지급 대상이 되는 최종 3년간의 퇴직금에 대하여 중간정산이 이루어진 근로자의 경우에는 중간정산한 금액만큼 대지급금 지급 가능성이 소멸하게 되므로 그에 비례하여 사업주의 부담금을 경감하는 것은 타당성을 인정할 수 있다.

다만 현재의 임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준은 직전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 퇴직금에 대하여 미리 정산하여 지급한 비율을 기초로 부담금을 경감하도록 하고 있는데, 대지급금 지급사유가 발생한 시기에 따라서는 대지급금 지급 경감률을 정확히 반영하지 못하는 문제가 있을 수 있다.²⁸⁶⁾ 예를 들어 직전 년도 말을 기준으로 최종 3년간 퇴직금 전액을 중간정산한 경우 미리 정산하여 지급한 비율은 100%로 인정될 것이지만, 대지급금 지급사유가 해당년도 연말에 발생하면 거의 1년간의 퇴직금에 대한 체불이 발생할 수 있다. 반대로 직전년도 말까지 퇴직금 중간정산이 이루어지지 않았으나 해당년도에 대지급금 지급사유가 발생하기 직전에 3년간 퇴직금에 대한 중간정산이 이루어졌다면 중간정산으로 인해 퇴직금에 대한 체불은 발생하지 않지만 중간정산을 이유로 한 부담금 경감은 이루어지지 않을 수도 있다. 그러나 일정한 시점을 기준으로 하여 사전에 부담금 경감률을 산정할 수밖에 없는 이상, 실제 대지급금의 지급 경감률과 부담금 경감률에 다소의 차이가 발생할 수 있다는 점을 불가피한 것으로 보인다.

2) 퇴직연금제도 등을 설정한 경우

부담금 경감을 위해 고려할 요소 중 가장 중요한 것은 대지급금 지급 범위 내에서 퇴직연

286) 퇴직연금제도를 설정한 경우에도 동일한 문제가 발생할 수 있다.

금제도 등을 통해 퇴직금 지급이 보장되는 금액이다. 현행 부담금 경감 기준은 이를 고려하여 퇴직연금 가입연수 또는 근속기간과 적립률 등을 경감 요소로 규정하고 있다. 또한 대지급금의 연령별 상한액이 있다는 점을 고려하면 근로자의 연령도 부담금 경감에 있어 고려요인이 될 수 있다.

임금채권보장법 제7조 제2항 제1호는 임금채권보장법이 보장하는 퇴직금의 범위를 최종 3년간의 퇴직급여 등으로 규정하고 있다. 위와 같은 퇴직금의 범위는 임금채권의 우선변제권을 고려한 것이다. 퇴직급여법 제12조 제2항은 최종 3년간의 퇴직금에 대하여 최우선변제권을 규정하고 있는데, 대지급금을 지급한 경우 임금채권보장법 제8조에 따라 고용노동부장관이 우선변제권 및 최우선변제권을 포함하여 근로자의 권리를 대위하게 된다. 이러한 점을 고려하면 퇴직연금가입기간 등이 3년 이하인 경우와 3년을 초과하는 경우를 구분하여 볼 필요가 있다.

근로자의 퇴직연금가입기간이나 근속연수가 3년 이하인 경우에는 퇴직연금의 적립비율에 해당하는 금액 만큼 대지급금 지급 금액이 경감된다고 할 수 있다. 한편 근속연수가 3년을 초과하는 경우 퇴직금의 체불액이 대지급금의 지급 범위를 넘을 수 있으므로 이 경우 부담금 경감은 퇴직연금 등의 적립률에 따라 실제로 지급이 확보되는 퇴직금의 액수를 고려하여 산정할 필요가 있으며, 구체적인 계산식은 다음과 같이 유도할 수 있다.²⁸⁷⁾²⁸⁸⁾

$$\text{대지급금 지급액}(A) = \text{근속연수}(N) * \text{연간퇴직금}(S) * (1 - \text{적립비율})$$

대지급금 지급 한도는 최종 3년간의 퇴직급여이므로,

$$\begin{aligned} \text{대지급금 지급 경감액}(X) &= 3S - A \\ &= S \left(3 - \frac{A}{S} \right) \\ &= S \{ 3 - N (1 - \text{적립비율}) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{대지급금 지급 경감률} &= \frac{X}{3S} \\ &= 1 - \frac{N}{3} (1 - \text{적립비율}) \\ &= \frac{3 - N(1 - \text{적립비율})}{3} \end{aligned}$$

현재의 부담금 경감 기준은 위와 같이 계산한 대지급금 경감률을 기초로 하여 규정된 것으

287) 김호경, 앞의 글, 59면

288) 계산식의 유도 과정에 대해서는 김호경, 앞의 글, 59-61면을 참고

로 이해할 수 있다. 다만 부담금 경감 기준은 퇴직연금제도 등을 설정한 경우 이에 해당하는 근로자의 평균 가입기간과 적립비율을 기준으로 경감률을 산정하도록 하고 있으며, 연령별 대지급금 상한액도 고려하지 않고 있다는 점에서, 실제 임금체불이 발생하였을 때 구체적인 개별 근로자에 대하여 대지급금의 지급이 경감된 액수를 정확히 반영한 것이라 보기는 어렵다. 위와 같이 대지급금 지급 경감률을 계산함에 있어 근로자의 연령을 고려하지 않은 것은 상대적으로 그 영향이 미미하거나 대지급금에 영향을 미치는 구조적인 요인이라고 보기 어렵기 때문이다.²⁸⁹⁾

이로 인해 대지급금 지급 경감률이 퇴직급여제도 등으로 인한 대지급금 지급 경감을 정확하게 반영하지는 못하는 측면이 있다. 그러나 부담금의 경감은 임금체불 발생 후 구체적인 체불 금액과 대지급금 지급 금액을 고려하여 사후에 계산하는 것이 아니라 사전에 퇴직연금제도 설정 등을 통해 임금체불의 방지에 기여한 사정을 고려하여 추상적으로 위험도를 평가하여 이루어질 필요가 있다는 점을 고려하면, 실제 체불이 발생하였을 때 퇴직연금제도의 설정 등으로 대지급금 지급이 감소되는 금액을 정확히 계산하여 경감기준을 두어야 하는 것은 아니다. 사전에 일일이 구체적인 금액을 계산하여 부담금 경감률을 계산하도록 하는 것은 현실적으로도 무리한 측면이 있다. 따라서 현재의 부담금 경감 기준은 퇴직연금제도 설정 등을 통한 대지급금 지급 경감률을 적절히 반영한 것으로 볼 수 있다.

나. 새로운 부담금 경감 기준에 대한 검토

1) 퇴직금 중간정산의 경우

퇴직금을 중간정산한 경우에는 중간정산으로 인해 퇴직금의 체불이 발생하지 않는다는 점을 고려하면, 최종 3년간의 퇴직금에서 중간정산이 이루어진 비율을 기준으로 부담금을 경감할 수밖에 없을 것이다. 따라서 퇴직금 중간정산은 현재와 같은 기준을 유지하는 것이 적절할 것으로 보인다.

2) 퇴직연금제도를 설정한 경우

현재 부담금 경감규정은 확정기여형 퇴직연금과 확정급여형 퇴직연금을 구분하여 경감 기준을 설정하고 있다. 이는 확정급여형 퇴직연금의 경우 근로자의 근속연수가 3년을 초과하면 체불 퇴직급여가 임금채권보장법에서 보장하고 있는 수준을 초과할 수 있으므로, 체불 퇴직금에서 적립률에 따라 지급비 보장되는 퇴직금을 공제한 금액을 대지급금 지급액으로 보고,

²⁸⁹⁾ 김호경, 앞의 글, 66면 미주 4)

최종 3년분의 퇴직금에서 위와 같이 계산한 대지급금 지급액을 공제한 금액을 대지급금 경감액으로 보고, 3년분의 퇴직금액에 대한 대지급금 경감액의 비율을 구하는 방식으로 부담금 경감을 하는 것이다.

부담금 경감기준을 간소화하는 방안으로, 퇴직연금제도를 설정함으로써 장래 발생할 수 있는 임금체불의 위험을 감소시켰다고 평가할 수 있다는 점을 고려하여 퇴직연금제도 등을 설정한 사업주에 대하여 일률적인 비율에 따라 부담금을 경감하는 방안을 생각할 수 있다. 실제 퇴직금의 체불이 발생한 경우, 퇴직연금제도 가입 기간에 따라 퇴직연금제도에 따라 임금채권보장법에서 규정하는 퇴직급여가 전부 보장되지 않을 수 있다. 이에 따른 재정적 문제를 최소화하기 위해, 일률적인 기준을 설정하는 경우에는 사업주 부담금 경감률을 40%보다 더 하향할 필요가 있다. 그러나 이와 같이 부담금 경감 기준을 설정하는 경우 보험에 가입한 기간과 적립률 등에 따라 임금체불의 위험 정도가 다름에도 동일한 부담금을 납부하게 된다는 점에서 형평성의 문제가 제기될 수 있고, 부담금 경감률이 낮아짐으로 인해 사업주가 납부해야 할 부담금 액수가 커지게 되는 사업주의 반발도 고려할 필요가 있다. 따라서 퇴직연금제도를 설정하였다는 이유만으로 일률적인 부담금 경감을 적용하기보다는 퇴직연금제도 등을 통해 감소되는 임금체불의 위험성 정도를 반영하여 부담금 경감 기준을 설정하는 것이 적절할 것으로 보인다.

구체적인 임금체불의 위험성 정도를 고려하는 경우 부담금 경감과 관련하여 퇴직급여의 적립비율이 문제된다. 현재 확정급여형 퇴직연금의 최소적립금 수준이 지속적으로 상향되어 현재 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 제4조의2는 2019년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 기간에 대해서는 90%, 2022년 1월 1일 이후의 기간에 대해서는 100%의 최소적립금 수준을 규정하고 있다. 그러나 확정급여형 퇴직연금제도를 설정한 사업주가 실제로 100% 이상의 적립금 수준을 유지한다는 것은 또다른 문제이다. 확정급여형 퇴직연금제도를 설정하면서 소급적용하는 경우에는 개정된 기준에 따르더라도 상당기간동안 적립률이 100%에 미치지 못할 수도 있다. 따라서 부담금 경감 기준을 설정함에 있어 퇴직연금제도를 설정함으로써 일반적으로 감소되는 퇴직금 체불의 위험성과 함께, 구체적인 퇴직급여 적립비율 등을 함께 고려할 필요가 있다.

확정급여형 퇴직연금제도의 경우 사용자는 매 사업연도 말에 대통령령으로 정하는 비율에 따른 최소적립금액 이상의 적립금을 지급하여야 하는데,²⁹⁰⁾ 퇴직급여법 제16조 제1과 퇴직급여법 시행령 제5조 제1항의 위임에 따라 제정된 퇴직급여법 시행규칙 제4조의 2는 최소적립금 비율을 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지의 기간은 90%, 2022. 1. 1. 이후의 기간은 100%로 규정하고 있다. 적립비율이 100%인 경우에는 확정급여형 퇴직연금제도와 마찬가지로

290) 퇴직급여법 제16조 제1항.

지로 가입기간이 1년 이상인 경우에는 적어도 최종 1년간 퇴직급여가, 가입기간이 2년 이상인 경우 최종 2년간 퇴직급여가, 가입기간이 3년 이상인 경우 최종 3년간의 퇴직급여가 보장된다고 할 수 있다. 퇴직급여법 시행규칙 제4조의 2가 2022. 1. 1. 이후의 최소적립금 비율을 100%로 규정하고 있으므로, 장기적으로는 확정기여형 퇴직급여제도를 설정한 경우와 동일한 기준에 따라 부담금을 경감하는 것도 가능할 것이다.

위와 같은 기준은 사용자가 퇴직급여 부담금을 전액 납부하거나 퇴직급여 적립금 비율이 100%인 경우를 전제로 한 것이다. 그러나 사용자가 확정기여형 퇴직연금제도를 설정하고도 부담금의 일부 또는 전부를 납입하지 않는 경우도 있을 수 있고, 확정급여형 퇴직연금제도를 설정한 사용자가 퇴직급여법령에 따른 적립금 비율을 충족하지 않는 경우도 있다. 이러한 경우에도 동일한 기준에 따라 임금채권보장기금의 부담금을 경감하는 것은 형평의 문제가 있고, 임금채권보장기금의 재정건전성 측면에서도 문제가 된다. 따라서 앞서 본 기준에 직전년도 말의 실제 적립비율 등을 곱하여 최종 부담금 경감액을 산정하도록 할 필요가 있다.

이에 따라 퇴직급여 정산·지급보장 비율 산식을 규정한다면 다음과 같다.²⁹¹⁾

- 1) 직전년도 말을 기준으로 평균 가입 기간이 1년 이상 2년 미만인 경우
: $1/3 \times (\text{가입기간 중 퇴직급여 적립비율})$
- 2) 직전년도 말을 기준으로 평균 가입 기간이 2년 이상 3년 미만인 경우
: $2/3 \times (\text{가입기간 중 퇴직급여 적립비율})$
- 3) 직전년도 말을 기준으로 평균 가입 기간이 3년 이상인 경우
: $1 \times (\text{가입기간 중 퇴직급여 적립비율})$

위와 같이 부담금 경감 기준을 규정하는 경우 퇴직연금제도 등의 설정으로 인해 감소하는 임금체불의 위험성을 반영하면서도 산식이 간단하다는 장점이 있으나, 현재의 부담금 경감 기준과 비교하였을 때, 퇴직급여 등에 대한 임금체불의 위험성을 정확히 반영하지 못한다는 점에서 한계가 있다. 위와 같은 경감 기준을 도입하는 경우 이에 따라 재정건전성에 어떠한 영향이 발생할 수 있는지에 대해서도 면밀한 검토가 선행될 필요가 있다. 퇴직급여 등에 대한 체불 위험성을 최대한 정확히 반영하여 부담금 경감 기준을 규정한다면 일단은 기존 부담금 경감 기준에 따른 수밖에 없을 것으로 보인다.

291) 외국인근로자 출국만기보험·출국만기 일시금 선택의 경우 아래 산식의 가입기간을 근속연수로, 퇴직급여 적립비율을 퇴직금 적립비율로 하여 적용할 수 있을 것이다.

다. 기존 부담금 경감 기준에 대한 개선 방안

퇴직급여 등에 대한 체불 위험성과 실제 대지급금 지급 경감률을 최대한 정확하게 반영한 퇴직급여 정산·지급보장 비율을 기준으로 부담금 경감을 한다면 현재의 부담금 경감 산식을 적용할 수밖에 없을 것으로 보인다. 다만 이에 따르더라도 부담금 경감 산식을 이해하기 쉽게 정리하고 부담금 경감 사유도 현재의 상황에 맞게 수정할 필요가 있다.

1) 부담금 경감 산식의 개선 방안

현재의 부담금 경감 산식은 앞서 본 것처럼 퇴직연금제도의 설정을 통한 대지급금 지급 경감률을 계산하여 도출한 것이나, 여러 단계의 계산 과정을 거쳐 도출된 산식이다보니 이해하기 어려운 측면이 있다. 이러한 점을 고려하여 부담금 경감 산식의 내용을 조금이나마 직관적으로 이해하기 쉽도록 수정한다면 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다.

$$1 - \left\{ \frac{\text{가입근로자평균가입년수}}{3\text{년}} \times (1 - \text{가입기간중 퇴직급여 적립비율}) \right\}$$

위와 같이 산식은 {1 - (최종 3년간 퇴직급여 중 퇴직연금제도에 따라 보장되지 않는 비율)}로 이해할 수 있고, 이를 다시 말하면 최종 3년간 퇴직급여 중 퇴직연금제도에 따라 보장되는 비율에 비례하여 부담금을 경감하는 것이므로, 현재의 부담금 경감 산식에 비해 부담금 경감의 취지와 내용을 조금 더 쉽게 설명가능할 것으로 보인다.

2) 부담금 경감 사유의 정리

2007. 4. 11. 법률 제8372호로 개정된 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항은 퇴직보험 또는 퇴직일시금신탁에 가입한 경우 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다고 규정하면서, 그 효력기간은 2010년 12월 31일까지로 한다고 규정하고 있다. 퇴직보험과 퇴직일시금신탁을 퇴직금제도로 볼 수 있는 효력기간이 경과한 상황에서 더 이상 퇴직보험과 퇴직일시금신탁에 가입한 것을 이유로 사업주 부담금을 경감하는 규정을 유지할 이유가 있을지 의문이다. 따라서 위 사유는 사업주 부담금 경감에서 제외할 필요가 있는 것으로 보인다.

5. 소 결

현재 사업주 부담금 경감은 퇴직급여 정산·지급보장 비율에 50%를 곱하도록 하고 있는데, 이는 경감기준 제정 당시 체당금에서 퇴직금이 차지하는 비중이 약 50%인 점을 고려한 것으로 보인다. 그런데 전체 대지급금에서 퇴직급여 등이 차지하는 비율 변화를 고려하면, 부담금 경감률은 현재의 100분의 50보다 하향하여 조정할 필요가 있고, 추후 대지급금 지급 현황에 따라 지속적으로 경감 비율의 적정성을 재검토하여야 할 것이다.

기존의 사업주 부담금 경감을 위한 산식은 퇴직연금제도 등을 통해 감소하는 임금체불 위험성을 최대한 정확히 반영하고자 한 것으로 볼 수 있다. 따라서 새로운 부담금 경감 기준을 검토한다면 현재의 부담금 경감 기준보다 추상적인 기준에 따를 수밖에 없을 것으로 보인다. 앞에서는 퇴직연금 등에 가입한 기간과 적립비율 등을 기준으로 하는 경감 기준을 사업주 부담금 경감 산식을 제시하였으나, 임금체불의 위험성 정도를 정확히 반영하기 어렵다는 점과 이로 인해 발생하는 임금채권보장기금의 재정건전성 문제 등을 고려하였을 때, 기본적으로는 기존의 부담금 경감 산식을 유지하는 것이 현실적으로 타당한 방안으로 보인다.

기존의 부담금 경감기준을 유지하더라도, 현재 시점에서는 의미가 없는 것으로 보이는 퇴직보험과 퇴직일시금신탁은 제외하고, 퇴직급여 정산·지급보장 비율의 산식도 그 의미를 이해하기 쉽도록 다음과 같이 정리하는 방안을 고려할 수 있다.

$$1 - \left\{ \frac{\text{가입근로자평균가입년수}}{3\text{년}} \times (1 - \text{가입기간중 퇴직급여 적립비율}) \right\}$$

제4장 기타 임금채권보장을 위한 제도 방안

제1절 도산대지급금의 연령별 차등 지급 적정성

임금채권보장법 제7조 제2항 단서는 시행령이 정하는 바에 따라 도산대지급금과 간이대지급금의 상한액은 근로자의 퇴직 당시의 연령 등을 고려하여 따로 정할 수 있다고 규정하고 있고, 위임에 따라 시행령 제6조 제2항은 근로자의 임금이나 소득 수준, 물가상승률, 기금의 재정상황 및 근로자의 퇴직 당시 연령 등을 고려하여 상한액을 정하도록 규정하고 있다. 각 대지급금의 상한액을 설정함에 있어 법률은 연령을 임의적 고려요소로 제시하였는데, 시행령은 연령 이외의 다른 사유들도 고려요소로 추가하였다. 이에 따라 현재 적용되고 있는 도산대지급금의 지급의 상한액은 아래 표와 같다(「채불임금등 대지급금 상한액 고시」 참조).

〈표 4-1〉 채불임금 등 대지급금 상한액 고시

(단위: 만원)

항목 \ 퇴직당시 연령	30세 미만	30세 이상 40세 미만	40세 이상 50세 미만	50세 이상 60세 미만	60세 이상
임금	220	310	350	330	230
퇴직급여 등	220	310	350	330	230
휴업수당	154	217	245	231	161
출산전후휴가기간 중 급여	310				

주: 임금, 출산전후휴가기간 중 급여, 휴업수당은 1월분, 퇴직급여 등은 1년분 기준임.

다만, 특이한 점은 간이대지급금의 경우에는 이와 같은 연령 차별 없이 일괄 임금과 퇴직급여 등 각각 700만 원(총 1,000만 원)으로 한도가 설정되어 있다.

이와 관련하여 대지급금의 지급사유에 따라 연령 고려의 차이를 두는 것이 타당한지에 대한 의문이 제기될 수 있다.

대지급금제도의 변천과정에서 도산대지급금은 1998년 임금채권보장법 제정 당시부터 존재 하던 제도로 제정 임금채권보장법 제6조 제2항은 퇴직 당시의 연령등을 고려하여 상한액을 제한할 수 있도록 규정하고 있었고, 이러한 입법태도가 오늘날까지 이어져 오고 있다.

2013년 11월 체당금 상한액 인상 고시 일부 개정(안) 행정예고(고용노동부 공고 제2013 - 261호)에 따르면 당시 체당금 상한액을 인상하면서, 퇴직연령별 상한액은 ‘연령별 월평균임

금' 인상액을 기준으로 하고, 나이대의 구분에 있어서도 처음에는 최고령층을 '50세 이상'으로 설정하였다가 2013년 고령화 추세를 감안하여 이를 '50세 이상 60세 미만'과 '60세 이상'의 구간으로 세분화하였음을 확인할 수 있다.

도산대지급금제도는 국제적으로 널리 도입된 제도로 도산상황에서 근로자의 생활안정을 도모하는데 중요한 역할을 수행한다. 이에 반해 간이대지급금제도는 세계적으로 유례를 찾아보기 어려운 우리나라만의 특색이 반영된 제도이다. 도산시 임금채권보장제도와 관련하여 프랑스는 근로기간에 따라 상한액에 차등을 두는데 반해, 일본은 연령별 상한액의 차이를 두고 있어 양자 모두 차등을 인정한다는 점에서 우리 제도와 유사성이 있다.

생각건대, 도산대지급금에 연령차등을 둔 연혁적 이유는 명확히 확인하기 어렵지만, 위와 같은 해외사례를 고려하고, 아울러 기업이 도산한 상황에서 발생하는 특수성을 고려한 것으로 추측된다.

기업이 도산하는 경우 채권자 평등원칙에 따라 담보가 없는 채권자들은 각자가 보유한 기업에 대한 채권액에 안분비례하여 채권을 회수한다. 사업주가 도산하는 상황에서는 해당 사업장에 종사하던 근로자 전반에 대하여 대규모 체불이 발생하게 되는데, 근로자들도 임금채권자로서 기업의 여타 채권자와 동일한 지위에 놓이게 되는 것이 원칙이다. 따라서 체불근로자가 여럿인 경우 그들끼리의 사이에서도 각자의 체불임금액에 비례하여 해당 기업의 잔여재산으로부터 체불임금액을 지급받을 수 있다. 예를 들어 A, B, C 세명의 체불근로자가 받아야 할 임금액을 각각 100만원, 200만원, 300만원이고 해당 사업주의 책임재산이 300만원밖에 남지 않았다고 가정하다. 이 경우 A, B, C는 채권자평등원칙에 따라 각자의 채권액에 비례하여 자신의 임금채권을 충족할 수 있는바, 총 책임재산에서 A는 $1/6$, B는 $2/6$, C는 $3/6$ 을 각 수령하여, A는 50만원, B는 100만원, C는 150만원을 받는 것을 끝으로 기업의 청산절차는 종료하게 될 것이다. 그런데, 이와 달리 당사자가 가진 체불임금액에 상관없이 인원수에 비례하여 즉, 최대한도를 동일하게 설정하여 체불임금을 청산된다면 A, B, C는 각자 100만원씩 체불임금을 받을 수 있게되어 각자의 체불임금청산비율은 A는 100%이나, B는 50%, C는 33.4%가 되어 차등이 발생하게 되는 이는 도산상황에서의 채권변제의 대원칙인 안분배분에 반하는 결과가 된다. 이러한 차별적 상황은 체불임금액이 많은 사람일수록 더 큰 불이익을 입게 된다는 점에서 부당하다. 따라서 체당금을 지급받음에 있어 이러한 부당한 차이가 발생하지 않도록 하기 위해서는 각자의 채권액의 다과에 대한 배려가 필요하다. 근로자별 급여의 차이는 사업장마다 다르지만 기업에서 오랜기간 사용해 온 급여체계의 전통이 대체로 연공서열을 중시하는 점, 근로자의 실질적인 퇴직이 40대에 많이 이루어지는 경향이 있어 연공서열에 따른 급여의 정점은 통상 40대에 맞는 경우가 많다는 점 등을 고려할 때 대체로 연령별 평균임금을 기준으로 대지급금을 지급한다면 어느정도 합리적인 범위에서 안분이 가능하다고

볼 수 있다. 연령별 월임금총액의 변화양상은 아래 표에서 보는 바와 같이 40대까지 증가하다 50대부터 다시 감소세로 돌아선다는 점에서 앞의 설명을 뒷받침해 준다.

〈표 4-2〉 2022년 전체 근로자 연령별 월 임금총액

(단위: 천원)

연령	월 임금총액
전체	3,526
29세 이하	2,471
30~39세	3,710
40~49세	4,195
50~59세	3,909
60세 이상	2,645

자료: 고용노동부, 고용형태별근로실태조사²⁹²⁾

한편, 이와 같이 각 연령대별 상한액의 차이를 두면 대지급금을 지급한 후 도산 사업주의 총재산에 대해 대위하여 변제금을 회수하는 과정에서도 근로복지공단이 보다 높은 비율로 회수를 할 수 있게 된다. 상한액을 연령별 차등없이 간이대지급금과 동일하게 설정한다면, 앞선 사례에서 A, B, C에 대하여 동일한 한도를 적용하였을 때 각자의 채권 회수율에 차이가 발생한 것처럼 이를 대위한 근로복지공단 역시 이러한 들쭉날쭉한 채권회수율을 보일 수밖에 없을 것이다. 좀 더 쉽게 설명하자면, 채권회수율은 비율, 즉 상대적인 수치이다. 전체적으로 체불임금을 얼마나 회수하였는가가 아니라 떼인 금액 중 얼마만큼을 거두어들였는지의 비율이다. 많이 떼인 사람과 적게 떼인 사람이 모두 동등한 금액을 받는다면 많이 떼인 사람의 채권 회수율은 각각 큰 차이가 난다. 그러나 많이 떼인 사람이 많이 받고 적게 떼인 사람이 적게 받는다면 각자의 채권회수율은 큰 차이가 나지 않음을 위의 설명에서 본 바와 같다. 근로복지공단이 체불임금 근로자를 대위하여 사업주에게서 임금채권을 회수하는 만큼 연령별 차등 없이 모두에게 동등한 대지급금을 지급하고 사업주로부터 회수한다면 들쭉날쭉한 채권회수율이 나오는 것이다.

도산대지급금은 기업의 도산이라는 상황을 염두에 둔 것으로 대규모 체불발생이 예견되고 사업주의 책임재산 역시 충분하지 않을 것이라는 점에서 이러한 안분배분원칙의 관철은 중요한 의미를 지닌다. 이와 달리 간이대지급금은 특정 사업장에서의 대규모 체불을 염두에 둔 것이 아니어서 연령별 차등을 둔다면 오히려 불합리한 경우가 많이 생길 것이므로 이러한 방식의 상한액 설정을 하지 않은 것으로 추측할 수 있다.

292) http://stathtml.moel.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_118N_LCE0004&conn_path=12

최근 우리의 기업문화에서 연공제보다는 직무급제, 성과급제 등 다양한 임금체계의 보급이 확산되고 있으므로 기존의 도산대지급금의 연령별 차등이 어색해 보일 수는 있다. 그러나 그렇다고 하더라도 여전히 연공제 방식의 임금체계는 상당수의 기업에서 채택하고 있다는 점에서 현시점에서 단순히 연령에 따른 차별을 두고 있다는 이유만으로 부당한 차별이라 단정하는 것은 타당해 보이지 않는다. 도산 상황의 특수성을 고려한다면 장차 해당 사업장의 급여체계를 적절히 반영할 수 있는 체계를 연구하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 다만, 그러한 급여체계도 연령대별 지출패턴과 관련성을 가지고 형성될 것이라는 점에서 연공제가 아닌 다른 임금체계라 하여 소득분포를 본질적으로 바꿀 수 있을지는 의문이다. 이런 점에서 현행 도산대지급금제도의 차등적 상한 설정은 나름의 합리성이 있다고 볼 것이다.

제2절 사업주용자제도 확대 필요성

1. 한도의 확대

임금채권보장법 제7조의3 제1항에 따르면 고용노동부장관은 사업주가 일시적인 경영상 어려움 등 고용노동부령으로 정하는 사유로 근로자에게 임금등을 지급하지 못한 경우에 사업주의 신청에 따라 체불임금등을 지급하는 데 필요한 비용을 융자할 수 있다. 다만, 그 한도는 사업주당 총 1억 5천만원의 범위에서 횟수의 제한 없이 할 수 있고, 이 경우 체불임금등 융자금지급대상근로자 1명에 대한 융자 신청 금액의 상한은 1천5백만원으로 한다(시행규칙 제8조의9 제2항).

이러한 사용자용자의 한도가 적어 사용자용자제도를 활성화하는데 애로가 있다는 의견이 있다. 간이대지급금 제도 개편과 재직자 대지급금제도의 신설로 사업주와 근로자의 담합 등으로 인한 부정수급에 대한 우려가 커지고 있다. 이를 예방하기 위해서는 사업주가 자기 책임하에 체불임금을 해결하도록 유도할 필요가 있는데, 사업주용자는 이를 도모하는데 유익한 수단이 될 수 있다. 특히, 한도 1억 5천을 넘는 대규모 체불이 발생하는 경우(최근의 사례로는 이스타항공 사건이 있다. 체불액은 대략 500억원 상당)에는 자발적 체불 해결 수단 자체를 사용할 수 없는 경우도 발생할 수 있다. 사업주용자 한도확대는 대기업에게도 임금채권보장기금 차원의 회생 기회를 부여하고 자발적으로 책임감있는 체불청산을 유도하는 실익이 있다. 이러한 점에서 이 방안을 정책적으로 고려할 필요성이 인정된다. 다만, 사업주용자의 한도가 커지면 임금채권보장기금을 회복하지 못할 위험이 특정 사업주에게 집중될 위험이 있

고, 자칫 임금채권보장기금이 대기업의 금고로 전락할 위험도 배제하기는 어렵다. 따라서 사업주용자를 확대하더라도 이러한 문제에 대응하기 위한 수단, 예컨대, 사업주의 재무상태에 대한 면밀한 검토와 용자실시 후의 감시 체계를 마련하는 등의 보완책 수립이 필요하다.

2. 사전 용자제도의 도입

사업주용자제도의 한도 확대는 체불이 발생한 이후에 체불사업주에게 용자를 하는 것으로, 사후적 대응이라는 한계가 있다. 근로자의 입장에서는 자신이 생활 수요에 맞춰 적시에 임금을 지급받는 것이 가장 바람직하며 하루라도 체불이 발생하면 여러 가지 생활 곤란에 처할 위험이 있다. 이에 사업주용자제도를 사전에 이용할 수 있도록 한다면 근로자의 이와 같은 불편을 사전에 차단할 수 있고, 대지급금제도를 운영하는 국가의 입장에서도, 앞에서 본 바와 같이 간이대지급금 제도 개편과 재직자 대지급금제도의 신설로 사업주와 근로자의 담합 등으로 인한 부정수급에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 그러한 상황 자체의 발생을 예방하고, 사업주 스스로 자기 책임하에 체불임금을 해결하도록 유도하여 대지급금제도 운영에 소요되는 부담을 완화할 실익이 있다.

다만, 현행 임금채권보장법은 사업주용자 요건으로 “근로자에게 임금등을 지급하지 못한 경우”만을 정하고 있어 근로자에게 임금등을 지급하지 못할 우려 내지, 근로자에게 임금등을 지급하지 못할 고도의 위험이 있는 경우와 같은 사전적 상황에는 활용하지 못한다는 법적 한계가 있다. 따라서 사전 용자제도를 도입하기 위해서는 법개정이 선행되어야 한다. 법개정의 과정에서는 다음과 같은 점을 가장 중요하게 고려할 필요가 있다. 바로 임금채권보장기금이 기업의 사적 금융 융통수단으로 전락할 위험을 방지하는 수단을 강구하는 것이다. 이를 위해서는 긴급한 상황임을 확인하기 위한 지표를 개발함은 물론이고, 제도 초기에는 이용횟수나 한도를 제한하는 등의 조치를 취하여 관련 자료를 수집할 필요가 있으며, 이를 바탕으로 장래에 제도를 보다 확장해 나가는 방법을 택할 필요가 있다.

제3절 간이대지급금 제도 보완 필요성

1. 제도의 현황

통계에 따르면, 2021년 간이대지급금제도 간소화 및 지급대상 확대 등으로 2022년 기준 간이대지급금이 전체 대지급금의 94%를 차지하고 있고, 그중 2021년 신설된 요건인 체불확인서를 통한 대지급금 지급액이 전체 대지급금 지급액의 85% 차지하고 있다. 사실 이점은 2021년 제도 개선을 통해 어느 정도 예상할 수 있었던 부분이다. 기존의 소액채당금제도에 서 요구한 확정판결 등 이에 준하는 집행권원을 획득하기 위해서는 수개월의 민사소송을 거쳐야 한다는 요건은 현재의 요건과 비교할 수 없을 정도로 불편한 것이었기 때문이다. 나아가 도산대지급금제도와 비교할 때도 도산대지급금은 비록 그 상한액이 높으나 도산 등 사실인정을 받기까지 시일이 소요된다는 점에서 근로자 입장에서는 간이대지급금의 상한액을 초과하지 않을 정도의 임금채불이라면 구태여 도산대지급금을 이용할 유인이 없다. 이에 현행 체불 사실확인서만으로 지급되는 간이대지급금은 이러한 종래 대지급금의 유형이 내재한 불편을 모두 흡수하면서 많은 근로자들이 이용하고 있는 것으로 추측된다.

종래 임금채불죄에 대한 합의는 사업주가 체불임금액의 전부 내지 일부를 근로자에게 지급하는 것을 조건으로 이루어지는 경우가 일반적이었다. 즉, 사업주의 자신의 재산으로 구체적인 변제-그것이 비록 전액은 아닐지라도-를 제공하는 것을 전제로 ‘합의’가 이루어졌다. 따라서 임금채불을 형사처벌함으로써 사업주를 압박하고 그가 스스로 자신의 비용으로 변제를 하도록 유도하는 제도적 메카니즘을 가지고 있는 것이다.

한편, 간이대지급금제도는 근로감독관의 체불사실 확인이 있으면 근로자가 간이대지급금을 지급받을 수 있는데, 이때 근로감독관이 체불사실을 함에 있어서, 원칙적으로 자신의 재량으로 사실을 판단하고 그러한 판단에 터잡아 체불사실을 확인하면 충분하나, 실무적으로는 근로감독관이 사업주의 체불사실 시인을 하는 경우에 주로 발급되고 있는 것으로 추정된다. 이때 사업주가 형사처벌에 관한 합의를 조건으로 근로감독관에게 체불사실을 시인하는 것이 가능하다. 근로자 입장에서는 자금사정이 어려운 사업주가 충분한 변제재력을 확보할 때까지 기다리는 것보다는 체불확인서를 발급받으면 신속하게 간이대지급금을 받을 수 있으므로 구태여 사업주를 처벌하느라고 변제해 줄 때까지 기다릴 이유가 없다. 사업주가 체불한 사실이 많지만 그래도 신속한 변제가 근로자에게는 우선이다. 사업주의 경우에도 형사처벌에 대한 합의만 받아낼 수 있다면 근로감독관의 체불사실 확인에 대해 부인하면서 버틸 이유가 없다.

어차피 자신은 근로복지공단의 변제금 회수에 대해 민사소송으로 응소하며 시간을 벌 수 있고 자력이 없으면 없는대로 변제금 회수를 피할 수 있다. 근로자로부터 지속적인 변제독촉을 받는 고통도 면할 수 있다. 한편, 근로감독관의 경우에도 신속하고 용이하게 사건을 처리할 수 있다는 점에서 양자 사이의 이러한 거래를 막을 이유는 없는 것이다. 감시자가 작동할 수 없는 상태에서는 이러한 제도적 남용을 막기가 쉽지 않다. 이에 대해서는 장차 심층적인 근로감독관의 체불사실확인 과정에 대한 조사와 분석이 필요할 것으로 보인다.

또 하나 알아봐야 할 것이 사업주변제금의 회수 현황이다. 근로복지공단이 2020년부터 2022년까지 사업주변제금을 회수한 비율을 보면 2020년 21.1%(1천225억원), 2021년 27.1%(1천482억원), 2022년 28.5%(1천532억원)를 기록하고 있어 해마다 높아지고는 있지만 여전히 30% 미만이다.²⁹³⁾ 이러한 회수율은 장기적으로 임금채권보장기금의 재정을 악화시킬 우려가 있기 때문에 회수율을 높일 필요성이 크다.

2. 제도적 보완의 내용

사업주변제금의 회수율을 높이기 위한 방안으로 ‘국세체납처분절차’를 도입하는 것을 고려할 수 있다. 2021년 임금채권보장법 개정 과정에서 당초 국회에 제출된 정부안에는 포함되어 있었으나 국회 검토과정에서 삭제된 국세체납처분 절차를 도입하는 것이다. 이 방법은 강제집행의 신속성을 도모하는 방법으로 행정청의 고권적 지위에 기하여 이루어지는 강제집행 절차로서 강제집행에 전문화된 행정기관이 체납처분 대상자의 의무를 확정해 바로 강제 실현한다는 점에 특색이 있다. 즉, 변제금 회수의 경우 현재는 법원의 판결을 받아 집행권원을 획득한 후 법원을 통해 강제집행이 이루어지나, 국세체납처분 절차에 의하는 경우에는 법원의 신청·판단·결정을 거치지 않고 행정기관이 직접 강제징수함으로써 사업주가 재산을 도피하기 전에 신속·효과적으로 징수할 수 있어 현재보다 변제금의 변제를 촉구하는 위하력이 강하다고 볼 수 있다. 이러한 장점으로 인해 오늘날은 조세뿐 아니라 각종 부담금, 공보험의 보험료 등과 같이 공적 성격의 금전채권의 강제집행에 널리 활용되고 있다.²⁹⁴⁾

현재는 국세징수법 제3장에 관련 규정을 두고 있으므로 이를 준용하는 방식으로 시행이 가능하다. 이 방식은 이미 2021년 정부안으로 국회에 제출된 바 있는데, 당시의 입법 과정과 관련하여 국회 환경노동위원회 회의록에 따르면 변제금은 국세가 아니므로 국세체납처분 절

293) 고용노동부 보도설명자료, “변제금 미납 사업주의 지속적인 관리·감독을 통해 임금에 대한 사업주의 책임을 강화해 나겠습니다”, 2023. 10. 19; 매일노동뉴스, “정부가 사용자에게 3조3천억원 떼인 이유는”, 2023. 10. 10. 자 기사.

294) 김린·구본권·조재호·김종우·조제희, 「체불행정 혁신을 위한 법제 정비 방안」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2018, 63-64면.

차를 준용할 수 없다거나, 변제금은 임금채권의 변형물로서 그 본질은 민사채권이라는 점에 착목하여 변제금 회수에 국가가 특별한 절차를 사용하는 것은 공·사법 이분론에 비추어 타당하지 않다는 취지의 주장이 반대의 주된 논거로 작용하였다.²⁹⁵⁾ 그러나 근로복지공단이 대지급금을 지급한 후 사용자에게 대위행사하는 변제금채권은 공적 자금에 기초한 대위변제라는 과정을 거친 것이라는 점에서 온전히 민사채권이라 보기어려운 점, 나아가 만약 이를 민사채권이라 이해한다면 임금채권에 대한 국가가 임금채권보장제도를 통해 민사관계인 노사간에 개입하는 것 자체도 부인하는 것이 논리적이라는 점에서 이러한 주장은 임금채권보장제도의 실질을 간과한 것이라는 비판을 면하기 어려운 점 등에서 타당하지 않다. 특히, 민사채권인 응급의료비 채권에 대해 체납처분을 통한 회수를 인정하고 있고(응급의료에 관한 법률 제22조 제6항 참조. 2017.10.24. 개정에 의해 도입), 역시 민사채권인 양육비에 대해서도 긴급지원을 한 경우 소정의 절차를 거쳐 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있는(양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률 제14조 제5항 참조. 2020. 6. 9. 개정에 의해 도입) 등 민사채권에 대한 국세체납처분 적용에 관한 다수의 입법례가 존재하고 있다. 아울러 대법원 역시 이러한 취지의 판결을 한 바 있다(대법원 2005. 5. 13. 선고 2004다8630 판결 참조)²⁹⁶⁾

나아가 공·사법 이분론은 국가의 사적 영역에 국가의 개입을 억제하기 위한 법리로 고안된 것으로 근대에 유행한 야경국가 모델을 전제로 한다는 점에서 국가의 역할이 부각되고 사인간의 관계에 적극적인 개입을 요구하는 현대적 국가 모델에는 부합하지 않는 이론으로서 이를 근거로 변제금에 대한 국세체납처분 적용을 배제하자는 주장은 타당하지 않다. 현대에서는 해당 채권의 발생근거가 민사관계냐 공법관계냐가 중요한 것이 아니라 그 채권에 대한 공적 보호가 필요한지 여부에 의해 국가의 개입을 판단해야 하며, 응급의료에 관한 법률에 따른 치료비, 양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률에 따른 양육비는 모두 민사관계에서 발생한 채권이나 공적 보호의 필요성이 강하기 때문에 국세체납처분의 예에 의한 회수를 인정하는 것이다. 임금채권보장제도 역시 제도의 운영과 지속가능성은 공적 관심사로서 그러한 관심에 상응하는 수준의 보호장치가 강구되어야만 한다.

이러한 법리적 관점의 문제를 차치하더라도 무엇보다 당시의 논의과정에서 현재와 같은 문제점을 미처 예상하지 못한 채 검토가 이루어졌다는 점도 고려할 필요가 있다. 즉, 2021년 이후 현재에 이르는 사이에 상당한 수준의 사정변경이 발생한 것이다.

따라서 현재와 같은 문제점을 염두에 두고 국세체납처분 절차 도입을 재검토할 필요가 있다.

295) 당시 입법 과정에 대한 상세한 소개와 평가는 김린, 임금채권보장에 대한 기본권적 접근과 과제- 2021년 임금채권보장법 개정에 부쳐 -, 「노동법논총」 제56집, 한국비교노동법학회, 2022, 242면 이하 참조.

296) 변제금회수에 대해 체납처분절차를 준용하는 것에 대한 자세한 논증은, 김린·구본권·양승엽·김수련, 「효율적인 체불임금 청산을 위한 임금체불근로자 권리구제 확대방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2017, 128~138면 참조.

제5장 결 론

제1절 사업주 책임을 강화하기 위한 비교법 연구의 시사점

1. 임금체불 시 형사처벌 제도의 의의

임금체불을 막기 위한 사업주의 책임을 강화하기 위해서는 기존의 제도를 보완하고 새로운 제도의 도입을 모색해 보아야 한다. 이를 위해 미국, 캐나다, 일본, 3개국의 임금체불에 있어 사업주가 어떤 공·사법적 책임을 지는지를 살펴보았다.

먼저 기존 제도의 보완으로 각국의 형사처벌 제도를 보면 미국의 경우 임금체불을 임금절도(wage theft)라 하여 30개의 주에서 형사처벌을 하고 있는데, 실제 공소제기는 잘 이루어지지 않고 있다. 그 이유로 뉴저지주의 경우를 보면 사업주의 대부분이 공소제기를 피하고자 그 전에 임금체불근로자와 합의하기 때문이라고 한다. 즉, 형사처벌이 사업주의 체불임금 지급에 영향을 크게 미치고 있음을 알 수 있다.

캐나다 역시 임금체불을 임금절도로 형사처벌을 하고 있다. 그러나 실제 적용은 잘되지 않는다고 한다. 그 이유로는 임금절도의 위법성 때문에 사업주를 형사처벌 하려 하기보다는 이러한 규정을 연방노동법에 규정함으로써 사업주에게 노동 기준을 지키도록 하는 수단적 성격이 강하기 때문이라 한다. 즉, 형사처벌의 위하(威嚇)적 효과를 유지하고 있다 할 수 있다.

일본은 임금체불에 관한 제도가 우리와 유사하다. 임금체불에 관해서는 형사처벌을 규정하고 있는데, 벌칙의 대상은 사업주에 한정되지 않고 ‘사업주를 위하여 행위하는 자’, 예를 들어 관리직 역시 위반행위가 있다면 벌금형이 부과되는 것이 특징이다. 다만, 사업주가 위반의 방지에 필요한 조치를 취한 경우에는 적용되지 않는다고 한다. 일본 역시 형사처벌 제도를 유지하고 있다.

위 국가들은 모두 임금체불죄를 유지하고 있지만 미국과 캐나다의 경우 기소 전 임금체불을 해결하기 위한 목적으로 사용되어 처벌 중심의 제도는 아니라고 할 수 있다. 실제 기소 건수가 적음에도 불구하고 임금체불죄를 유지하는 것은 근로자의 임금채권 회복에 아직 형사제도가 유의미한 효과가 있다는 것을 의미한다.

국내에서는 임금체불에 대해 형사처벌 제도를 유지할 것인가에 대한 회의적인 입장이 있

다. 민사채무 관계인 임금체불인 형사별로 처벌하는 것이 타당한지부터,²⁹⁷⁾ 현재 반의사불벌죄를 유지함으로써 실제 처벌받는 사업주가 드문 점 등을 근거로 하고 있다. 그러나 임금체불죄와 반의사불벌의 표시를 한 묶음으로 보았을 때 그 의의는 여전하다고 생각한다.

임금체불을 임금절도라 생각하는 측에서는 임금체불의 위법성을 생각해 보았을 때 처벌불원의 표시와 관계없이 임금체불 사업주를 처벌하여야 하며, 체불임금을 미끼로 근로자들에게 처벌불원의 표시를 하도록 종용한다고 한다. 일견 타당한 말이지만, 형사처벌을 포함한 전체 임금채권보장제도의 목적을 생각해 보아야 한다. 국가가 형벌로 임금체불을 처벌하는 것은 위하(威嚇)로 사전에 사업주가 임금을 체불하는 것을 막기 위함이다. 근로자 처지에서도 당장 사업주의 처벌보다는 체불임금을 받아 생계를 유지하는 것이 더 이익이 되기 때문에 반의사불벌제도가 오히려 체불임금을 받아내는 유용한 무기가 될 수 있다. 그러나 일부 상습적이고 고의적인 악덕 임금체불 사업주가 최대한 임금을 지급하지 않다가 기소 위기에 몰렸을 때 근로자에게 처벌불원의 표시를 요구하며 밀린 임금을 지급하는 경우도 있다. 이런 경우를 대비하여 상습적·고의적인 임금체불의 요건을 설정하여 이 경우에는 반의사불벌죄를 적용하지 않는 것도 입법적으로 고려할 수 있다.

2. 새로운 경제 제재(과징금·법정배상배액제도)의 도입 여부

현재의 경제 제재는 과징금과 법정배상배액제도(또는 징벌적 손해배상제도)²⁹⁸⁾ 같이 직접적으로 국가 및 근로자가 사업주로부터 금원을 취득하는 것이 아니라, 간접적으로 상습적으로 고액의 임금을 체불한 사업주의 명단 공개와 신용제재를 하는 방식이다. 이런 제재에도 불구하고 서론에서 살펴본 바와 같이 임금체불의 인원수는 줄어들고 있으나 체불금액은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 따라서 상습적이고 고의적인 임금체불 사업주에 대한 경제 제재를 높이는 방안을 생각해 볼 수 있다.

미국의 경우 민사별로 과징금을 부가하며²⁹⁹⁾ 그 성격상 당연히 과징금은 국고로 귀속된다. 그러나 미국의 연방노동부에 따르면 상습적인 사업주의 43%만 민사벌이 검토되었고 그중 61%만 부과되었다는 본문의 통계는 민사벌이 실제로는 활발히 작동하지 않다는 것을 알 수 있다.

297) 노동공탁제에 대한 자세한 설명은 하지환, “임금체불의 형사처벌에 대한 비판적 검토”, 「법학논총」 제33권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2016. 6, 191면 참조.

298) 법정배상배액제도와 징벌적 손해배상제도가 그 목적과 성격이 다를 것 같아 알아보았지만 우리나라는 두 제도를 혼용하여 부르고 있다. 또한 양자가 서로 중첩되고 있는 과정이므로 두 제도 중 어느 명칭을 따라도 큰 무리가 없다.

299) 미국의 민사벌이 우리의 과징금제도에 해당한다는 설명은 권재열, “미국의 민사금전벌 제도에 관한 비교법적 소고”, 「법과 기업 연구」 제6권 제3호, 서강대학교 법학연구소, 2016, 99면.

생각전대 우리에게 임금체불 과징금제도를 도입하는 것은 좀 더 신중히 생각해 볼 필요가 있다. 임금체불을 임금절도라 하여 형사처벌을 가하는 것은 임금체불의 위법성과 위하 효과를 생각하면 충분히 그러할 수 있다. 그러나 여기에 보충적으로 과징금을 부과하는 것은 비록 형벌과 민사벌(또는 행정벌)은 다른 체계이지만 이중처벌이라는 비판이 있을 수 있다. 과징금 제도를 실행하고 있는 미국의 경우 그 효과에 대한 문헌을 찾아볼 수 없는 것도 그 실효성이 크지 않음을 방증(傍證)하는 것으로 생각된다.³⁰⁰⁾ 또한 과징금제도는 피해자인 근로자에게 손해 회복의 이익을 주지도 못한다. 왜냐하면 그 목적이 “범위반행위를 억제하거나, 범위반행위로 획득한 이익을 환수하여 공정성을 확보하거나, 그러한 범위반행위에 대한 신속한 구제”이기 때문이다.³⁰¹⁾

임금체불에 대한 법정배상배액제도는 현재 국회 입법안으로 논의되고 있다.³⁰²⁾ 예를 들어 최종윤의원안의 경우 상습적인 임금체불의 경우 체불액의 3배까지 손해배상으로 청구할 수 있도록 제안한다. 이러한 법정배상배액제도의 효과에 대해 미국의 경우를 보면 최저임금을 위반하는 사례가 줄어드는 결과가 있다고 한다.³⁰³⁾ 우리의 경우에도 상습적이고 고의적인 임금체불 사업주에게 법정배상배액제도를 도입하는 것을 생각해볼 수 있지만 이는 최후의 수단이고 먼저 보완적인 방법으로 정부 지원 등 제한, 공공입찰 시 불이익 부여, 신용제재 확대·강화를 시도한 후 그래도 상습·고의적인 임금체불이 지속된다면 법정배상배액제도의 실행을 고려해보아야 한다. 이것이 최후의 수단이 되어야 하는 이유는 법정배상배액제도가 손해의 공평한 ‘전보(填補)’라는 손해배상제도의 대원칙에서 예외적인 경우이기 때문이다. 우리의 전반적인 성문법 체계에 맞지 않으며, 우리가 집단소송 등 법원을 통한 배액배상청구가 활발하지 않다는 것을 생각하면 그 활용도가 낮을 것으로 예상되기 때문이다. 비교하여 미국은 관련하여 집단소송이 활발하고, 캐나다, 독일, 프랑스 등에서는 법정배상배액제도를 도입하지 않고 관련하여 큰 논의가 없다는 점 역시 그것이 임금 체불을 억제하는 효과가 크지 않기 때문에 추정된다.

300) 다만, 임금체불에 대한 형사처벌을 폐지한다면 이에 대한 대안으로 과징금을 생각할 수 있다. 형사처벌에 비해 민사벌제도가 가지는 장점에 대해서는 권재열, 위의 논문, 103면 참조.

301) 이는 민사벌의 특징에 대한 내용이지만 그대로 과징금에도 해당되기에 인용하다. 권재열, 위의 논문, 102면.

302) 대표적으로 최종윤의원안(2020. 8. 7. 제안 의안번호 2102801)과 류호정 의원안(2021. 5. 4. 제안 의안번호 2109905)이 있다.

303) 본문은 다만, 제재를 강화하는 것과 강화된 법을 제대로 집행하는 것은 별개의 문제라고 하며, 미국 실무상 관련 행정청이 사용자가 체불임금을 즉시 지급할 경우 임금 이자 또는 법정 손해액을 면제해 주는 관행이 있다는 점을 지적한다.

제2절 현행 사업주 부담금 경감제도의 실효성

1. 현행 사업주 부담금 제도의 검토와 보완점

먼저 임금채권보장기금의 부담금에서 퇴직급여 항목의 경감을 인정해 주는 것은 타당한 이유가 있다. 퇴직급여 항목은 퇴직금 중간정산 또는 퇴직연금제도 확립 등 퇴직급여의 수령을 보장할 경우 그 항목에 대해서는 체불 가능성이 없기 때문에 사업주의 부담을 경감할 수 있다. 그러나 임금, 휴업수당, 또는 출산전후휴가기간 중 급여의 경우 사전에 이를 담보할 제도적 장치가 아직 마련되지 않았기 때문에 쉽게 사업주의 부담을 경감할 수 없다. 다만, 퇴직급여에 관한 사업주 부담금의 100분의 50까지 경감이 가능하도록 한 것은 개선의 여지가 있다. 과거 대지급금에서 임금과 퇴직금이 대응하여 지급되는 비율이 50:50의 수준이었는데, 이러한 비율은 깨져 2017년부터는 임금비율이 높아지고 퇴직금 비율이 낮아서 2020년 이후에는 퇴직급여가 차지하는 대지급금의 비율이 40% 아래로 떨어졌다. 그러므로 이러한 수치에 맞춰 경감 비율의 상한을 개선할 필요가 있다.

현재 임금채권보장기금에서 사업주의 부담 비율은 전 업종에 있어 공통(보수총액의 0.06%)인 것도 현행 유지하여야 한다. 마치 산재보험과 같이 산재 발생률이 높은 사업장의 경우 사업주의 보험 부담금이 많고, 산재 발생률이 낮은 경우 보험 부담금을 적게 내는 것이 보험원리의 형평성에는 맞을 수 있다. 그러나 임금채권보장기금의 민간보험이 아니라 사회보험적 성격까지도 아울러 가지고 있다는 점을 감안하면, 건강보험의 연대성과 같이 우량기업의 부담금이 부실기업에 대한 대지급금 지급을 보완하는 수평적 이동이 타당하다. 만일 우량기업의 부담금을 깎아주고 부실기업의 부담금은 높인다면 대규모 기업의 부담금 납부가 적어지기 때문에 임금채권보장기금의 재정에도 악영향을 미칠 수 있다.

이러한 우량기업-부실기업 간의 부담금 형평성을 조정하고자 부실기업에 대해서는 대지급금의 이용 한도를 설정하는 방안도 생각해 볼 수 있다. 그러나 대지급금의 지급 대상은 사업주가 아니라 근로자이다. 즉, 대지급금 이용 한도를 설정하면 피해를 보는 것은 사업주가 아니라 임금채불을 당하고 있는 근로자이기 때문에 이 방안은 신중히 고려하여야 한다. 또한 한도가 없는 사업장 근로자와 한도가 설정된 사업장 근로자의 대지급금에 차이가 생기는데 이것을 합리성 있는 불리한 처우, 즉 차별이 아니라고 하기도 어렵다. 이외 대지급금의 한도가 생기면 그 한도 내에서 임금채권을 어떻게 배분할 것인가에 관한 복잡한 문제가 발생한다.

2. 현행 사업주 부담금 경감 산식의 개선 여부

임금채권보장기금의 사업주 부담금을 경감하는 데 있어 퇴직금 중간정산이나 확정기여형퇴직연금제도의 경우 사업주가 납부한 금액이 측정되기 때문에 정산 또는 지급이 보장되는 비율이 나와 계산이 쉽다. 그러나 확정급여형인 경우에서 전체 가입 근로자의 평균 가입 기간이 3년을 초과하고 소급 적용하지 아니할 경우에는 다음 산식을 따른다.

$$\frac{3\text{년} - [\text{평균근속연수} \times (1 - \text{퇴직금 적립비율})]}{3\text{년}}$$

그리고 퇴직보험·퇴직일시금 신탁 또는 외국인근로자 출국만기보험·출국만기 일시금 신탁에 가입한 경우, 가입 근로자의 평균 근속연수가 3년을 초과하는 경우에는 다음 산식을 따른다.

$$\frac{3\text{년} - [\text{평균근속연수} \times (1 - \text{퇴직금 적립비율})]}{3\text{년}}$$

위의 산식이 복잡하고 직관적이지 않아 실제 현장에서는 적용하기 힘들다는 견해가 있어 산식의 개선 여부를 살펴보았다. 그런데 먼저 살펴볼 것은 2007. 4. 11. 개정된 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항은 퇴직보험 또는 퇴직일시금신탁에 가입한 경우 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다고 규정하면서, 그 효력 기간은 2010년 12월 31일까지로 한다고 규정하고 있다. 그러므로 효력 기간이 경과한 퇴직보험과 퇴직일시금신탁에 가입한 것을 이유로 사업주의 부담금을 경감하는 것은 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다.

첫 번째 산식을 중심으로 보면 이러한 산식이 나온 배경에는 복잡한 보험수리적 계산이 바탕에 있다.³⁰⁴⁾ 그리고 본문에서 살펴본 바와 같이 현재의 부담금 경감 기준은 대지급금의 경감률을 기초로 하여 규정된 것이다. 만일 다른 부담금 경감 기준을 정확히 측정하려면 더욱 복잡한 산식을 도출하여야 하고, 반대로 산식을 단순화하면 사업주의 대지급금 경감 비율을 적절히 반영할 수 없다는 한계에 부딪치게 된다. 따라서 현재의 산식 내용은 고정하되 더 이해가 빠르도록 분모와 분자를 정리하여 다음과 같이 표현할 것을 제안한다.

$$1 - \left\{ \frac{\text{가입근로자평균가입연수}}{3\text{년}} \times (1 - \text{가입기간중 퇴직급여 적립비율}) \right\}$$

304) 김호경, 앞의 글, 59~61면 참조.

제3절 기타 현행 임금채권보장제도의 쟁점과 보완

1. 도산대지급금의 연령별 차등 지급 여부

현행 임금채권보장제도는 고시로 도산대지급금의 상한액을 규정하고 있다. 그런데 이를 30세 미만에서 60세 이상 내에 5구역으로 나누어 상한액을 차등하고 있다. 나이가 어릴수록 상한액이 낮고 나이가 많을수록 상한액이 높다. 이러한 연령 차이에 대해 일각에서는 연령차별 또는 차등의 합리성에 의문을 표시하고 있다.

그러나 아직까지 도산대지급금의 연령별 차등은 우리 사회 현실에 부합하는 면이 많다. 현재 직무급·성과급 임금체계가 널리 확산되고 있으나 그 직무급·성과급도 강한 연공서열식을 가미한 것이기 때문이다. 즉, 우리 사회는 나이가 어리면 임금이 낮고 나이가 많으면 임금이 높아지는 구조에 머물고 있다. 이런 상황에서 만일 연령별로 도산대지급금의 상한을 똑같이 한다면 채권자평등의 원칙에 어긋날 수 있다. 만일 20대의 체불임금이 300만 원, 30대가 400만 원, 그리고 40대가 500만 원이라고 할 때, 각자에게 상한액을 차등해서 주면 각자가 가지는 채권 회수율은 약간의 차이가 있지만 비슷하게 된다. 가령, 20대에게 200만 원, 30대에게 300만 원, 40대에게 400만 원의 상한액을 지급하면 각각 $2/3(0.66)$, $3/4(0.75)$, $4/5(0.8)$ 의 채권 회수율이 나온다. 그리고 그 격차는 $0.66 \sim 0.8$ 정도이다. 그러나 20대에서 40대까지 모두 300만 원이라는 동일한 상한액을 지급한다면 1, $3/4(0.75)$, $3/5(0.6)$ 으로 그 격차가 $0.6 \sim 1.0$ 으로 더욱 벌어지게 된다. 한정된 재원을 비율별로 안분해야 할 경우 상한액을 일괄적으로 고정시키는 것보다 차등을 두는 것이 더 적합함을 알 수 있다. 그리고 부차적으로 우리 사회의 연령별 지출액이 40~50대가 가장 많음도 염두에 두어야 한다.

2. 사업주응자제도의 개선 방안

사업주응자제도는 임금체불근로자에게 대지급금이라는 공적 자원을 투입하지 않고 사업주가 자발적으로 임금체불을 해결할 수 있도록 하고, 파산 위기까지 가지 않고 기업에 회생 기회를 줄 수 있다는 것이 점, 그리고 간이대지급금 제도의 개편과 재직자 대지급금제도의 신설로 사업주와 근로자 간 담합이 일어나 부정수급의 우려가 있는데, 사업주가 용자를 받아 체불을 해결하면 이런 부정수급이 일어나지 않게 된다는 점이 장점으로 꼽힌다.

그러나 그 한도액이 사업주당 총 1억 5천만 원, 체불임금 근로자 1인당 1천 5백만 원으로

낮아 제도를 활성화하는데 애로 있다는 의견이 있다. 다만, 그렇다고 한도액을 증액할 경우 임금채권보장기금이 임금체불액이 큰 특정 사업주에게 몰릴 가능성이 높고, 그럴 경우 대기업의 금고로 전락할 위험이 있다. 따라서 한도액을 늘리더라도 용자 시 사업주의 재무 상태를 검사하는 사전 조치와 용자 후의 이행 정도를 점검하는 사후 조치가 동시에 보완되어야 한다.

한편 임금체불이 일어난 이후에 지급하는 사후적 사업주용자제도가 아니라 체불 이전에 임금체불을 막기 위한 사전 사업주용자제도를 입법으로 도입하는 것을 생각해 볼 수 있다. 그럼으로써 임금체불 이후 발생할 근로자의 생계 위험을 사전에 막을 수 있는 장점이 있다. 그러나 역시 위험한 부실 대기업의 금고 역할을 할 위험이 있기 때문에 임금이 체불될 상황이라는 것을 알 수 있는 지표 개발과 이용 횟수와 한도액 제한 등 부가적인 장치 역시 고민해야 할 것이다.

3. 간이대지급금 제도 확대에 대한 보완 방안

간이대지급금 제도 간소화 및 지급 대상 확대로 간이대지급금이 전체 대지급금의 대부분(94%)을 차지하고 있다. 이 점은 제도 개선 시부터 예상된 바이나 그 간단한 과정에서 임금체불 사업주와 근로자 간의 ‘합의’(반의사불벌의 표시)로 임금체불죄가 유명무실해지고 있다는 비판도 제기된다.

그러나 임금체불 사업주와 근로자 간의 합의를 꼭 나쁘게 볼 점은 아니다. 상습적·고의적 임금체불 사업주의 처벌도 필요하지만 그만큼 근로자들의 신속한 생계 구조도 절실하기 때문이다. 다만, 앞서 지적한 바와 같이 악덕 임금체불 사업주의 경우 최대한 임금을 체불하다가 형사 기소에 몰렸을 때 처벌불원의 표시를 조건으로 임금을 체불하는 사례가 있어 문제가 된다. 그러나 이러한 경우 임금체불의 횟수와 금액 등 한도를 정하여 상습적이고 고의적인 임금체불의 경우 반의사불벌죄의 예외로 하는 것도 제안할 수 있다. 하지만 주의해야 할 점은 간이대지급금 제도에서 사용자의 체불사실 확인을 조건으로 처벌불원의 표시를 하는 것인데 이것이 행정적인 편의를 위해 종용하여서는 안 된다는 것이다. 어디까지나 근로자의 자유의사에 맡기도록 행정적인 안내가 필요하다.

또한 과거 국회 입법안으로 논의되었으나 불발된 국세체납처분의 절차를 도입하는 것도 생각해볼 수 있다. 이 방법은 강제집행의 신속성을 도모하는 방법으로 조세뿐만 아니라 각종 부담금과 사회보험의 보험료 체납에도 널리 이용되고 있어 다시 한번 장단점을 재고하여 입법을 모색할 필요가 있다.

참고문헌

〈제2장〉

구미영, “캐나다의 임금차별 판단 법리에 관한 비교법적 검토”, 노동법학 제40호, 한국노동법학회, 2011.

박지원, 민사소송에서 법정배액배상 조항의 심리에 관한 소고, 민사소송 제26권 제2호, 2022.

이준범, 장애인차별금지법 사건의 활성화와 편면적 소송비용 부담제도, 비교사법 제27권 제2호, 2020.

——, 정보공개청구거부처분취소 사건 결과와 원고 소송대리인 선임의 관계, 저스티스 통권 177호, 2020.

——, 증권관련 집단소송에서 디스커버리의 인적 적용 범위에 관한 연구, 저스티스 통권 제 197호, 2023.

——, 증권관련집단소송 사건 중 집단소송허가절차에 관한 한국과 미국 법리 비교연구 - 사건연구를 중심으로 -, 민사소송 제26권 2호, 2022.

Nita Chhinzer, “캐나다 온타리오주의 연결되지 않을 권리 제정과 영향”, 국제노동브리프 2023년 1월호, 한국노동연구원, 2023.

Alexander J.S. Colvin, The Growing use of Mandatory Arbitration 1(Economic Policy Institute Apr. 6, 2018)

Alisha Jarwala, Collective Action Notice Requirements: The Next Hurdle in the Arbitration Fight, Onlabor,(2020. 4. 30.), <https://onlabor.org/collective-action-notice-requirements-the-next-hurdle-in-the-arbitration-fight/>(2023. 9. 9 최종방문)

Amy K. Jensen, Effective Counseling and Defending Employers in Increasing Wage and Hour Class Action, in Strategies for Employment Class and Collective Actions (2012)

Anthony Damelio, Making Wage Theft Costly: District Attorneys and Attorneys General Enforcing Wage and Hour Law, 49 Fordham Urb. L.J. 113(2021)

- Benjamin Levin, Wage Theft Criminalization, 54 U.C. Davis L. Rev. 1429(2021)
- CBS News Sacramento, National Wage Theft Investigation Reveals California Victims Wait Twice As Long For Resolution,(Jan. 26, 2023), <https://www.cbsnews.com/sacramento/video/national-wage-theft-investigation-reveals-california-victims-wait-twice-as-long-for-resolution/>(2023. 9. 28. 최종방문)
- César F. Rosado Marzán, Wage Theft as Crime: An Institutional View, 20 J. Law in Society 300(2020)
- Cheryl Fiandaca, I-Team: Wage Theft in Massachusetts is Widespread in Some Industries, CBS News Boston,(Jan. 24, 2023, 11:28 PM), <https://www.cbsnews.com/boston/news/i-team-wage-theft-massachusetts-investigation/>(2023. 9. 28. 최종방문)
- Chris Hacker, Ash-har Quraishi, Amy Corral, & Ryan Beard, Wage theft often goes unpunished despite state systems meant to combat it, CBS News,(June 30, 2023 8:00AM), <https://www.cbsnews.com/news/owed-employers-face-little-accountability-for-wage-theft/>(2023. 9. 4. 최종방문)
- Daniel J. Galvin, Deterring Wage Theft: Alt-Labor, State Politics, and the Policy Determinants of Minimum Wage Compliance, 14 Perspective on Politics 324 (2016)
- David Weil, Improving Workplace Conditions Through Strategic Enforcement: A Report to the Wage and Hour Division(2010)
- Elizabeth Ford, Wage Recovery Funds, 110 Cal. L. Rev. 1503(2022)
- Employment and Social Development Canada, “Recovering Unpaid Wages - Know that Facts”, 2019.
- Eric Tucker, “Shareholder and Director Liability for Unpaid Workers' Wages in Canada: From Condition of Granting Limited Liability to Exceptional Remedy”, OSGOODE HALL LAW JOURNAL(26), YORK UNIVERSITY, 2008.
- , “When Wage Theft Was a Crime in Canada, 1935-1955: The Challenge of Using the Master’s Tools Against the Master”, OSGOODE HALL LAW JOURNAL (54), YORK UNIVERSITY, 2017.
- Ihna Mangundayao, Celine McNicholas, Margaret Poydock & Ali Sait, More than \$ 3 billion in stolen wages recovered for workers between 2017 and 2020 (Economic Policy Institute Dec. 22, 2022)

James M. Nicholas, Defending Wage and Hour Class Action Cases: Winning Strategies, in *Strategies for Employment Class and Collective Actions*(2012)

Jay Tidmarsh & Roger H. Trangsrud, *Complex Litigation and Its Alternatives*(2018)

Jeanne Kuang & Alejandro Lazo, Wage Theft Whack-a-mole: California Workers Win Judgments Against Bosses but Still Don't Get Paid,(Sept. 15, 2022, updated May 2, 2023), <https://calmatters.org/california-divide/2022/09/california-wage-theft-cases/?series=unpaid-wages-california-workers>(2023. 9. 28. 최종방문)

Jennifer J. Lee & Annie Smith, Regulating Wage Theft, 94 Wash. L. Rev. 759, 794 (2019)

Jill S. Kirila, Defense Strategies in Hybrid Wage and Hour Class Action Litigation, in *Strategies for Employment Class and Collective Actions*,(2012)

Joan Murray, Are you getting paid? Wage theft not uncommon in South Florida, CBS News Miami,(2023. 1. 24. 11:18 PM), <https://www.cbsnews.com/miami/news/are-you-getting-paid-wage-theft-not-uncommon-in-south-florida/>(2023. 9. 4. 최종방문)

John C. Coffee, Jr., Rescuing the Private Attorney General: Why the Model of the Lawyer as Bounty Hunter is not Working, 42 Md. L. Rev. 215(1983)

Jonah Kaplan, "I was scared." How wage theft drains millions of dollars from Minnesota a families ? and what's being done to stop it., CBS News Minnesota,(Jan. 24, 2023 6:00pm), <https://www.cbsnews.com/minnesota/news/i-was-scared-how-wage-theft-drains-millions-of-dollars-from-minnesota-families-and-whats-being-done-to-stop-it/>(2023. 9. 4. 최종방문)

Kim Bobo, Wage Theft in America: Why Millions of Working Americans are not Getting Paid - And What we can do About it(2014)

Lauren K. Dasse, Wage Theft in New York: The Wage Theft Prevention Act as a Counter to an Endemic Problem, 16 CUNY L. Rev. 97(2012)

Llezie L. Green, Wage Theft in Lawless Courts, 107 Cal. L. Rev. 1303(2019)

Marc Doussard & Ahmad Gamal, The Rise of Wage Theft Laws: Can Community-Labor Coalitions win Victories in State Houses?, 52 Urb. Aff. Rev. 780(2015)

Mass.gov, Office of the Attorney General, The Attorney General's Fair Labor Division, Enforcement Authority, The Attorney General's Office Enforces Workplace

- Laws Both Civilly and Criminally, <https://www.mass.gov/info-details/enforcement-authority#:~:text=A%20civil%20citation%20orders%20an%20employer%20to%20pay,a%20violation%20and%20whether%20the%20offense%20is%20intentional>.(2023. 9. 28. 최종방문)
- Matthew Fritz-Mauer, The Ragged Edge of Rugged Individualism: Wage Theft and the Personalization of Social Harm, 54 U. Mich. J. L. Reform 735(2021)
- Max Siegelbaum, 127,000 New York Workers Have Been Victims of Wage Theft, Documented,(Aug 22, 2023), <https://documentedny.com/2023/08/22/wage-theft-restaurants-new-york-nyc/>(2023. 9. 4. 최종방문)
- National Employment Law Project, Winning Wage Justice: An Advocate's Guide to State and City Policies to Fight Wage Theft(2011)
- Nicole Hallett, The Problem of Wage Theft, 37 Yale L. & Pol'y Rev. 93(2018)
- Pamel S. Karlan, Diarming the Private Attorney General, 2003 U. Illinois L. Rev. 183(2003)
- Samuel Issacharoff, Civil Procedure(2022)
- Sean Farhang, The Litigation State(2010)
- Seyfarth Shaw, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2021 Edition
———, Annual Workplace Class Action Litigation Report: 2022 Edition
- Stephen B. Burbank & Sean Farhang, A New(Republican) Litigation State?, 11 UC Irvine L. Rev. 657(2021)
- Stephen B. Burbank, Sean Farhang & Herbert M. Kritzer, Private Enforcement, 17 Lewis & Clark L. Rev. 637(2013)
- Terri Gersten, How district attorneys and state attorneys general are fighting work place abuses: An introduction to criminal prosecutions of wage theft and other employer crimes against workers(Ecomonic Policy Institute May 17, 2021)
- U.S. Department of Labor, Data Enforcement, Data Catalog, Wage and Hour Compliance Action Data, https://enforcedata.dol.gov/views/data_summary.php (2023. 9. 4. 최종방문)
- William C. Martucci, Katherine R. Sinatra, & Gregory K. Wu, Understanding and Preparing for Today's Employment Class Action Environment, in Strategies for Employment Class and Collective Actions(2012)

William F. Allen, Defending Employers in Complex Wage and Hour Litigation, in Strategies for Employment Class and Collective Actions,(2012)

石寄信憲編,『賃金規制・決定の法律実務』,中央経済社,2022.

嶋田哲郎・君和田伸仁・棗一郎,『労働審判制度その仕組みと活用の実際(第3訂版)』,日本法令,2023.

旬法法律事務所編,『未払い残業代請求』,学陽書房,2022.

野村剛司,『未払賃金立替払制度[第2版]』,金融財政事業研究会,2021.

厚生労働省,“賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します”: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.html

厚生労働省,“賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します(別紙)”
<https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001126169.pdf>

厚生労働省,“未払賃金の立替払の推移:”<https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001129229.pdf>

最高裁判所事務総局,“令和4年 司法統計年報 1. 民事・行政編”: <https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/657/012657.pdf>

未払賃金の立替払事業: <https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx>

労働者健康安全機構,“未払賃金の立替払事業”: <https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/1021/Default.aspx>

〈제3·4장〉

고용노동부, 고용형태별근로실태조사: http://stathtml.moel.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_118N_LCE0004&conn_path=I2

김근주 외,「체불임금 해결시스템의 국제비교 연구 -임금채권보장제도를 중심으로-」, 한국노동연구원, 2016. 12.

김린,“산림조합에 대한 임금채권부담금 납부 면제 여부 - 연대성의 관점에서”, 월간노동리뷰, 2016년 12.월호, 한국노동연구원. 2016. 12.

——, 임금채권보장에 대한 기본권적 접근과 과제- 2021년 임금채권보장법 개정에 부쳐 -, 「노동법논총」 제56집, 한국비교노동법학회, 2022.

김린·구본권·조재호·김종우·조제희,「체불행정 혁신을 위한 법제 정비 방안」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2018.

김호경, “퇴직보험 활성화와 임금채권보장기금 부담금체계 개선방안: 합리적인 부담금 경감체계 및 제도개선을 위한 보험수리적 고찰”, 「노동정책연구」 2001년 창간호, 한국노동연구원, 2001.

장승혁, “사회보험법과 사회연대 원리”, 「사회보장법학」 제6권 제1호, 한국사회보장법학회, 2017. 6.

프랑스 AGS Wage guarantee scheme: <https://www.ags-garantie-salaires.org/key-figures.html>

기획재정부, 「2022년도 부담금운용종합보고서」, 2023. 5.

〈제5장〉

하지환, “임금체불의 형사처벌에 대한 비판적 검토”, 「법학논총」 제33권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2016. 6.